Giáo Trình

LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

(Tập 1)

Chủ biên

Ts. ***Nguyễn Ngọc Điện***

Trưởng khoa Luật

MỤC LỤC

BÀI 1 - GIỚI THIỆU LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM 11

MỤC 1 - ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ 11

1. Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự 11

1.1. Cá nhân 12
1.2. Pháp nhân 12
1.3. Hộ gia đình 12
1.4. - Tổ hợp tác 13

2. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự 13

2.1. Quyền có tính chất tài sản 13
2.1.1. Quyền đối vật 13
2.1.1.1. Phân loại vật 13
2.1.1.1.1. Động sản và bất động sản 13
2.1.1.1.2. Vật hữu hình và vật vô hình 13
2.1.1.1.3. Vật chuyển giao được và vật không chuyển giao được trong giao lưu dân sự 13
2.1.1.2. Phân loại quyền đối vật 13
2.1.1.2.1. Quyền mà việc thực hiện tác động trực tiếp lên đối tượng 13
2.1.1.2.2. Quyền có đối tượng là giá trị tiền tệ của một hoặc nhiều tài sản cụ thể 13
2.1.2. Quyền đối nhân 14
2.2. Quyền nhân thân 14

3. Xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự 14

3.1. Tạo ra hoặc chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự 14
3.1.1. Tạo ra quyền và nghĩa vụ dân sự 14
3.1.2. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự 14
3.2. Giao dịch hoặc sự kiện pháp lý 15
3.2.1. Giao dịch 15
3.2.2. Sự kiện pháp lý 16

4. Bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự 16

4.1.1. Khái niệm quyền khởi kiện 17
4.1.2. Các loại quyền khởi kiện 17

MỤC 2 - NGUỒN CỦA LUẬT DÂN SỰ 17

1. Luật viết 18
2. Tục lệ 19

2.1. Tục lệ phổ quát 19
2.2. Tục lệ chung 19
2.3. Tập quán địa phương 19
2.4. Tập quán nghề nghiệp 19
2.5. Quy ước 19

3. Quan hệ giữa luật viết và tục lệ 20

MỤC 3 - SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM 20
1. Giai đoạn của luật cổ 20
2. Giai đoạn của luật cận đại 21
3. Giai đoạn của luật hiện đại 21
3.1. Từ 1945 đến những năm 1980 21
3.2. Từ những năm 1980 đến nay 21
BÀI 2 - CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT TRONG LUẬT DÂN SỰ 23
CHƯƠNG 1 - CÁ NHÂN 23
MỤC 1 - Lý lịch dân sự của cá nhân 23
1. Họ và tên 23
1.1. Tổng quan 23
1.2. Đặt họ và tên 24
1.2.1. Quyền và nghĩa vụ được đặt họ và tên 24
1.2.2. Đặt họ 27
1.2.3. Đặt tên 28
1.2.3.1. Chọn tên 28
1.2.3.2. Chọn chữ đệm 29
1.3. Thay đổi họ và tên 30
1.3.1. Thay đổi họ. 30
1.3.2. Thay đổi tên 31
1.3.3. Hệ quả của việc thay đổi họ tên. 31
2. Hộ tịch 32
2.1. Tổ chức hệ thống hộ tịch 32
2.2. Lập chứng thư hộ tịch 32
2.2.1. Những người tham gia vào việc lập chứng thư hộ tịch 32
2.2.2. Các quy định riêng về việc lập giấy khai sinh Khai việc sinh. 33
2.2.3. Các quy định riêng về việc lập giấy chứng tử 34
2.2.4. Các quy định riêng về việc lập giấy chứng nhận kết hôn 34
2.3. Thay đổi, cải chính nội dung chứng thư hộ tịch 36
2.4. Giá trị chứng minh của chứng thư hộ tịch 37
3. Nơi cư trú 38
3.1. Chức năng của nơi cư trú 38
3.2. Xác định nơi cư trú 38
3.2.1. Xác định nơi cư trú dựa vào quan hệ quản lý hành chính về trật tự xã hội 38
3.2.2. Xác định nơi cư trú dựa vào quan hệ gia đình 39
3.2.3. Xác định nơi cư trú dựa vào các quan hệ nghề nghiệp 39
MỤC 2 - Tư cách chủ thể quan hệ pháp luật của cá nhân 40
1. Khái niệm 40
2. Xác lập nhân thân 40
2.1. Thời gian tồn tại của nhân thân 40
2.2. Nhân thân và năng lực 41

3. Các trường hợp đặc thù 42
3.1. Vắng mặt 42
3.1.1. Điều kiện 42
3.1.2. Hiệu lực 43
3.1.2.1. Chế độ bảo vệ: Quản lý tài sản của người vắng mặt 43
3.1.2.2. Tường hợp người vắng mặt xuất hiện trở lại 46
3.2. Mất tích 46
3.2.1. Điều kiện 46
3.2.2. Hiệu lực 47
3.2.2.1. Trường hợp người mất tích trở về 48
3.3. Tuyên bố là đã chết 49
3.3.1. Điều kiện và hiệu lực 49
3.3.2. Trường hợp người bị tuyên bố đã chết trở về 50
MỤC 3 - Tình trạng không có năng lực hành vi 51
1. Tổng quan 51
1.1. Khái niệm 51
1.2. Tính chất ngoại lệ của tình trạng không có năng lực hành vi 53
1.3. Lý lẽ của nguyên tắc và ngoại lệ 54
1.3.1. Lý lẽ của nguyên tắc 54
1.3.2. Lý lẽ của ngoại lệ 54
MỤC 4 - Bảo vệ người không có năng lực hành vi 54
1. Đại diện cho người chưa thành niên 55
1.1. Giám hộ đối với người chưa thành niên 55
1.1.1. Tổ chức việc giám hộ 56
1.1.1.1. Người giám hộ 56
1.1.1.2. Giám sát việc giám hộ 58
1.1.2. Cơ chế hoạt động giám hộ 59
1.1.2.1. Thân phận của người được giám hộ 59
1.1.2.2. Nghĩa vụ và quyền của người giám hộ 59
1.1.2.2.1. Nghĩa vụ của người giám hộ 59
1.1.2.2.1.1 Thực hiện các nghĩa vụ của người được giám hộ 60
1.1.2.2.2. Quyền của người giám hộ 61
1.1.2.2.3. Các trường hợp đặc thù 62
1.1.2.3. Thay đổi người giám hộ 62
1.1.2.4. Chấm dứt việc giám hộ. 63
1.2. Đại diện theo pháp luật cho con chưa thành niên 63
1.2.1. Tổ chức việc đại diện 63
1.2.2. Thực hiện quyền đại diện 64
1.2.2.1. Nguyên tắc 64
1.2.2.2. Các trường hợp đặc biệt 64
1.2.3. Chấm dứt việc đại diện 64

2. Đại diện cho người đã thành niên....64
2.1. Đại diện cho người đã thành niên mất năng lực hành vi....65
2.1.1. Điều kiện giám hộ....65
2.1.1.1. Đối với người được giám hộ....65
2.1.1.2. Đối với người giám hộ....65
2.1.1.3. Điều kiện thủ tục....65
2.1.2. Cơ chế giám hộ....66
2.2. Đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự....66
2.2.1. Điều kiện....66
2.2.2. Cơ chế đại diện....67
MỤC 5 - Quyền nhân thân....68
1. Tổng quan....68
2. Tính chất của quyền nhân thân....69
3. Các quyền nhân thân cơ bản....69
3.1. Quyền đối với thân thể....69
3.1.1. Các quyền được bảo vệ....70
3.1.2. Thực hiện các tác nghiệp y học trên thân thể....71
3.1.3. Bảo vệ chống việc định đoạt trái pháp luật....71
3.1.3.1. Định đoạt pháp lý.....71
3.1.3.2. Định đoạt vật chất....71
3.2. Quyền đối với sự toàn vẹn phẩm giá....72
3.3. Quyền đối với bí mật của cuộc sống riêng tư....72
3.3.1. Thư tín....72
3.3.2. Hình ảnh....73
3.3.3. Tín ngưỡng, tôn giáo....74
CHƯƠNG 2 - PHÁP NHÂN....74
MỤC 1 - Lịch sử của chế định pháp nhân....75
MỤC 2 - Tính chất pháp lý của pháp nhân....76
MỤC 3 - Phân loại pháp nhân....78
MỤC 4 - Chế độ pháp lý của pháp nhân....80
1. Sự thành lập pháp nhân....80
2. Hoạt động của pháp nhân....80
2.1. Các cơ quan của pháp nhân....80
2.1.1. Pháp nhân công pháp....81
2.1.2. Pháp nhân tư pháp và pháp nhân hỗn hợp....82
2.2. Năng lực của pháp nhân....82
2.2.1. Năng lực pháp luật của pháp nhân....82
2.2.2. Năng lực hành vi của pháp nhân.....83
2.3. Tài sản của pháp nhân....83
2.4. Nhân thân của pháp nhân....84
2.5. Quyền kiện cáo....85
3. Chấm dứt pháp nhân....85

CHƯƠNG 3 - Hộ Gia đình. Tổ hợp tác 86
MỤC 1 - Hộ gia đình 86
MỤC 2 - Tổ hợp tác 87
BÀI 3 - TÀI SẢN 88
Nhập đề - GIỚI THIỆU CHUNG PHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN 88
1. Lý thuyết về sản nghiệp trong luật học phương Tây 89
1.1. Quan niệm chủ thể 89
1.2. Quan niệm khách thể 89
2. Sự phát triển của pháp luật về tài sản trong luật Việt Nam 89
2.1. Trong luật cổ và tục lệ 89
2.2. Luật cận đại 90
2.3. Luật hiện đại 90
CHƯƠNG 1 - TÀI SẢN 91
MỤC 1 - Động sản và Bất động sản 92
1. Tiêu chí phân biệt 92
1.1. Vật 92
1.2. Quyền 92
1.3. Trường hợp đặc biệt 93
1.3.1. Bất động sản trở thành động sản do đặc điểm công dụng tương lai. 93
1.3.2. Bất động sản trở thành động sản do công dụng 94
1.3.3. Tài sản thay thế 94
2. Ý nghĩa của sự phân biệt 94
2.1. Là căn cứ để xác định thời hiệu xác lập quyền sở hữu 94
2.2. Là căn cứ để xác lập thẩm quyền của TAND trong việc giải quyết các tranh chấp về tài sản. 94
MỤC 2 - Phân loại thứ cấp 95
1. Tài sản gốc và hoa lợi, lợi tức 95
2. Vật chính và vật phụ 95
3. Vật tiêu hao và vật không tiêu hao 96
4. Vật đặc định và vật cùng loại 97
5. Vật sở hữu được và vật không sở hữu được. 98
MỤC 3 - Các tài sản vô hình 98
1. Các đặc điểm của tài sản vô hình 98
1.1. Là kết quả của lao động sáng tạo 98
1.2. Không phải là quyền chủ nợ cũng không gắn liền với vật thể. 99
1.3. Nội dung quyền sở hữu đối với tài sản vô hình với quyền sở hữu theo luật chung 100
2. Các hình thức tồn tại của tài sản vô hình 100
2.1. Quyền sở hữu tác phẩm văn chương, nghệ thuật, khoa học 100
2.1.1. Tác phẩm 100
2.1.2. Tác phẩm của nhiều tác giả, tác phẩm của tập thể, tác phẩm vô danh 101
2.1.3. Quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm 101
2.1.3.1. Quyền nhân thân 101

2.1.3.2. Quyền tài sản 102
2.2. Quyền sở hữu công nghiệp 102
2.2.1. Sáng chế 102
2.2.2. Kiểu dáng công nghiệp 102
2.2.3. Nhãn hiệu 103
2.2.4. Chỉ dẫn địa lý 103
2.3. Các yếu tố vô hình của sản nghiệp thương mại 103
2.3.1. Mạng lưới tiêu thụ hàng hóa và cung ứng dịch vụ 103
2.3.2. Tên thương mại 104
2.3.3. Biển hiệu 104
MỤC 4 - Quyền sử dụng đất 104
1. Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất 104
2. Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 105
3. Quyền sử dụng đất thuê 106
3.1. Hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm 106
3.2. Hợp đồng thuê đất trả tiền nhiều năm 108
CHƯƠNG 2 - QUYỀN SỞ HỮU 109
MỤC 1 - Nội dung pháp lý của quyền sở hữu 109
1. Quyền sử dụng 109
2. Quyền định đoạt. 110
3. Quyền chiếm hữu 110
3.1. Chiếm hữu của chủ sở hữu 111
3.1.1. Các yếu tố của quyền chiếm hữu của chủ sở hữu 111
3.1.2. Xác lập quyền chiếm hữu của chủ sở hữu 112
3.1.3. Mất quyền chiếm hữu của chủ sở hữu 112
3.1.4. Chiếm hữu không hoàn hảo 113
3.1.5. Hiệu lực của quyền chiếm hữu của chủ sở hữu 113
3.2. Chiếm hữu tài sản của người khác 114
MỤC 2 - Căn cứ xác lập quyền sở hữu 114
1. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu 115
2. Xác lập quyền sở hữu theo các phương thức trực tiếp khác 118
2.1. Sáp nhập, trộn lẫn, chế biến 118
2.1.1. Chế biến 118
2.1.2. Sáp nhập và trộn lẫn 118
2.1.2.1. Sáp nhập bất động sản 119
2.1.2.2. Sáp nhập và trộn lẫn động sản 119
2.2. Chiếm hữu theo khoản 6 Điều 170 BLDS 119
2.2.1. Vật bị đánh rơi, bị bỏ quên 120
2.2.2. Gia súc, gia cầm bị thất lạc 120
2.2.3. Vật bị chôn giấu 121
2.3. Chiếm hữu theo khoản 7 Điều 170 BLDS 122

2.3.1. Chiếm hữu với tư cách chủ sở hữu 122
2.3.2. Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình 122
3. Trường hợp người chuyển nhượng không có quyền sở hữu tài sản do giao dịch chuyển nhượng vô hiệu: 123
MỤC 3 - Bằng chứng về quyền sở hữu 124
1. Trách nhiệm của các bên tranh chấp về quyền sở hữu trong việc cung cấp chứng cứ 125
1.1. Đối tượng chứng minh 125
1.2. Phương tiện chứng minh 125
MỤC 4 - Các hình thức sở hữu 126
1. CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU CÓ MỘT CHỦ THỂ 127
1.1. Sở hữu nhà nước 127
1.1.1. Chủ thể của sở hữu nhà nước 127
1.1.2. Tài sản thuộc sỏ hữu nhà nước 127
1.1.3. Sử dụng tài sản thuộc sở hữu nhà nước 127
1.1.4. Quản lý Nhà nước đối với tài sản thuộc sở hữu nhà nước 128
1.1.5. Bảo vệ sở hữu nhà nước 128
1.2. Sở hữu tập thể. 128
1.3. Sở hữu của các pháp nhân không hoạt động sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận 128
1.3.1. Tài sản 128
1.3.2. Thực hiện quyền sở hữu 129
2. SỞ HỮU CHUNG 129
2.1. Sở hữu chung hỗn hợp 129
2.2. Sở hữu của hộ gia đình, tổ hợp tác 129
2.2.1. Chủ thể 129
2.2.1.1. Thành viên của hộ gia đình 129
2.2.1.2. Thành viên của tổ hợp tác 130
2.2.2. Tài sản 130
2.2.2.1. Tài sản có của hộ gia đình, tổ hợp tác 130
2.2.2.2. Tài sản nợ của hộ gia đình, tổ hợp tác 130
2.3. Sở hữu chung của cộng đồng 131
2.4. Sở hữu chung của vợ chồng 132
2.5. Sở hữu nhà chung cư 132
2.5.1. Cấu tạo của căn hộ chung cư 132
2.5.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu chung 133
2.5.2.1. Quyền của chủ sở hữu chung 133
2.5.2.1.1. Quyền chiếm hữu và sử dụng 133
2.5.2.1.2. Quyền định đoạt 133
2.5.2.2. Nghĩa vụ của các chủ sở hữu chung 133
2.6. Sở hữu chung theo phần 134
2.6.1. Thành phần cấu tạo của khối tài sản thuộc sở hữu chung theo phần 134
2.6.1.1. Tài sản có 134

2.6.1.1.1. Chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu chung 134
2.6.1.1.2. Hoa lợi, lợi tức của tài sản chung – 136
2.6.1.2. Tài sản nợ 137
2.6.2. Quản lý tài sản thuộc sở hữu chung theo phần 137
2.6.2.1. Các nguyên tắc do luật định 137
2.6.2.2. Quản lý tài sản chung theo thỏa thuận 138
2.6.2.3. Quyền của chủ sở hữu chung đối với phần tài sản của mình 138
MỤC 5 - Các hạn chế đối với việc thực hiện quyền sở hữu 139
1. RANH GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 140
1.1. Cọc mốc 140
1.2. Hàng rào, hào, rãnh, kênh, mương, bờ bao 140
1.3. Vách tường ngăn cách các bất động sản 141
1.3.1. Xác lập quyền sở hữu chung 141
1.3.2. Tính chất pháp lý của quyền sở hữu chung 141
1.3.3. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu chung 142
1.4. Xây dựng, trồng cây, mở lỗ thông khí, khe sáng và tầm nhìn 142
1.4.1. Xây dựng 142
1.4.2. Trồng cây 142
1.4.3. Lỗ thông khí, khe sáng 142
1.4.4. Tầm nhìn 142
2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LÁNG GIỀNG 143
2.1. Các quyền và nghĩa vụ láng giềng phát sinh do địa thế tự nhiên của bất động sản hoặc do quy định của luật 143
2.1.1. Quyền, nghĩa vụ của láng giềng trong việc thoát nước mưa và nước thải 143
2.1.2. Sử dụng hạn chế bất động sản liền kề 143
2.1.2.1. Điều kiện xác lập quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề do luật định 144
2.1.2.2. Thực hiện quyền quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề do luật định 144
2.1.2.2.1. Lựa chọn bất động sản để xây dựng lối thông thương theo thoả thuận hoặc bằng con đường tư pháp 144
2.1.2.2.2. Trường hợp bất động sản bị vây bọc do hệ quả của sự phân chia 144
2.1.3. Chấm dứt quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề do luật định 144
2.2. Quyền và nghĩa vụ láng giềng phát sinh do sự tác động của con người 145
2.2.1. Các điều kiện và căn cứ xác lập quyền và nghĩa vụ láng giềng phát sinh do sự tác động của con người. 145
2.2.1.1. Điều kiện liên quan đến bất động sản 145
2.2.1.2. Căn cứ xác lập 145
2.2.1.2.1. Do thỏa thuận 146
2.2.1.2.2. Di chúc 146
2.2.1.2.3. Tách rời các bất động sản thuộc về cùng một chủ sở hữu 146

2.2.1.2.4. Thời hiệu 146
2.2.2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ láng giềng phát sinh do sự tác động của con người 146
2.2.2.1. Điều kiện thực hiện 146
2.2.3. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ láng giềng phát sinh do sự tác động của con người 147
2.2.3.1. Trường hợp bất động sản phục vụ và bất động sản được phục vụ hoà nhập thành một 147
2.2.3.2. Trường hợp chủ sở hữu bất động sản được phục vụ từ chối quyền sử dụng hệ thống phục vụ 147
2.2.3.3. Trường hợp chủ sở hữu bất động sản được phục vụ không còn sử dụng hệ thống phục vụ 147
2.2.3.4. Trường hợp bất động sản phục vụ được Nhà nước mua lại và trở thành tài sản công – 147
2.2.4. Trách nhiệm dân sự do vi phạm quyền và nghĩa vụ láng giềng 147
MỤC 6 - Quyền sở hữu bề mặt 148
1. Xác lập quyền sở hữu bề mặt 148
1.1. Xác lập quyền sở hữu bề mặt theo pháp luật đất đai trong các trường hợp cụ thể như: 149
1.1.1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê hàng năm- 149
1.1.2. Trường hợp thuê đất trả tiền nhiều năm của tổ chức ngoại giao nước ngoài 149
1.1.3. Trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước 150
1.2. Xác lập quyền sở hữu bề mặt theo pháp luật dân sự trong một số trường hợp sau: 150
1.2.1. Tách quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất thành hai bất động sản độc lập 150
1.2.2. Cho thuê quyền sử dụng đất ở, đất chuyên dùng 150
1.3. Xác lập quyền sở hữu bề mặt bằng các phương thức được thừa nhận trong luật chung 151
2. Chế độ pháp lý của quyền sở hữu bề mặt 151
2.1. Tài sản thuộc sở hữu bề mặt 151
2.2. Quyền sở hữu theo luật chung 151
2.3. Quyền sử dụng hạn chế đối với đất 152
2.4. Đăng ký quyền sở hữu 152

BÀI 1 - GIỚI THIỆU LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

Luật và luật dân sự - Luật là tập hợp những quy tắc xử sự chung mà sự tôn trọng (đối với những quy tắc ấy) được bảo đảm bằng các biện pháp cưỡng chế của bộ máy Nhà nước.
Luật dân sự, trong quan niệm La-tinh, là tập hợp các quy tắc xử sự chung chi phối các mối quan hệ giữa người và người. Theo nghĩa đó, thì thoạt trông hầu như không có gì khác biệt giữa luật dân sự và tư pháp: tư pháp cũng bao gồm các quy tắc xử sự chi phối các mối quan hệ giữa người và người; trong khi công pháp là tập hợp các quy tắc xử sự chung chi phối các mối quan hệ trong đó có sự tham gia của Nhà nước, cơ quan Nhà nước, hoặc nhân viên Nhà nước thi hành công vụ (Luật hiến pháp, Luật hành chính, Luật hình sự,...).
Ở La Mã, luật dân sự (*jus civile*) là luật áp dụng đối với các công dân La Mã, phân biệt với luật chung (*jus gentium*) áp dụng cho tất cả những ai không có tư cách công dân La Mã.

Vào thời Trung cổ, người ta gọi luật dân sự là Luật La Mã, phân biệt với luật giáo hội. Với cách phân biệt đó, thì luật dân sự được hiểu như tất cả những quy tắc chi phối cuộc sống thế tục của con người, kể cả các quy tắc mà trong quan niệm hiện đại, được xếp vào nhóm công pháp..

Đến thế kỷ XV và XVI, người ta bắt đầu không chú ý đến các quy tắc của Luật La Mã liên quan đến tổ chức bộ máy Nhà nước, và Luật La Mã (luật dân sự) dần dần chỉ còn được nhớ đến như là tập hợp các quy tắc chi phối các quan hệ giữa người và người,... là tất cả các quy tắc không thuộc công pháp.

Thế rồi theo thời gian, các quy tắc riêng chi phối thái độ xử sự của con người trong những quan hệ đặc thù giữa người và người càng lúc càng phong phú và trở thành những mảng đặc biệt của Tư pháp, tách ra khỏi luật dân sự để trở thành những ngành luật độc lập. Ta có: luật thương mại áp dụng cho các hoạt động thương mại (hành vi thương mại), cho những người thực hiện các hoạt động đó (thương nhân); luật nông thôn chi phối việc xây dựng và thực hiện các quy hoạch nông nghiệp và các hợp đồng thuê đất; luật lao động điều chỉnh các quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động;...

Luật dân sự, trong quan niệm của luật Việt Nam hiện đại, là tập hợp các quy tắc quy định địa vị pháp lý của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác (hộ gia đình, tổ hợp tác), quy định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự (BLDS năm 1995 - BLDS - Điều 1 đoạn 2)
Ta lần lượt tìm hiểu đối tượng điều chỉnh của luật dân sự, nguồn của luật dân sự và sự tiến triển của pháp luật dân sự trong luật Việt Nam.

MỤC 1 - ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ

Dựa vào định nghĩa của luật viết hiện hành, có thể xác định rằng luật dân sự Việt Nam giải quyết bốn vấn đề lớn:

1 - Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự gồm những ai ?

2 - Các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự có những quyền và nghĩa vụ gì ?

3 - Các quyền và nghĩa vụ này được xác lập như thế nào ?

4 - Luật dự liệu những biện pháp gì để bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó ?

1. Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự

Các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự trong luật thực định bao gồm: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình và tổ hợp tác.

1.1. Cá nhân

Là con người cụ thể và đang sống. Cá nhân phải có hộ tịch rõ ràng, cho phép phân biệt được với cá nhân khác. Mọi cá nhân không nhất thiết đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau, dù tất cả các cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật. Việc xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân lệ thuộc vào kết quả đánh giá năng lực pháp luật và năng lực hành vi của cá nhân đó.

Năng lực pháp luật - *Là khả năng của cá nhân được hưởng quyền hoặc đảm nhận tư cách người có nghĩa vụ (BLDS Điều 14 khoản 1). Năng lực pháp luật của cá nhân có từ khi cá nhân được sinh ra và mất đi khi cá nhân chết (Điều 14 khoản 3)*. Luật nói rằng *mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau* (Điều 14 khoản 2); song, có khi cá nhân không thể có một quyền nào đó mà tất cả những cá nhân khác đều có thể có, như trong trường hợp người không có quyền hưởng di sản do đã có một trong những hành vi được ghi nhận tại BLDS Điều 643 khoản 1. Ta nói rằng cá nhân có thể mất năng lực pháp luật ngay khi còn sống trong những trường hợp đặc biệt. Trong luật thực định Việt Nam, tình trạng mất năng lực pháp luật chỉ tồn tại trong những trường hợp đặc biệt do luật quy định và chỉ có hiệu lực đối với các quan hệ phát sinh trong những trường hợp đó. Nói cách khác, không có tình trạng mất năng lực pháp luật tổng quát: người không có quyền hưởng di sản, trên nguyên tắc, chỉ không có quyền hưởng đối với một di sản xác định, và bảo tồn khả năng có quyền hưởng đối với các di sản khác.

Năng lực hành vi - *Là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự* (BLDS Điều 17). Khác với năng lực pháp luật, năng lực hành vi chỉ được thừa nhận cho những cá nhân có đủ các điều kiện do pháp luật quy định: người chưa đủ sáu tuổi không có năng lực hành vi dân sự (Điều 21); người bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình có thể bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của toà án (Điều 22 khoản 1). Tất cả những giao dịch của người không có hoặc mất năng lực hành vi dân sự đều chỉ có thể được xác lập thông qua người đại diện. Ta nói rằng luật có ghi nhận tình trạng không có hoặc mất năng lực hành vi tổng quát. Tình trạng không có năng lực hành vi tổng quát luôn có tính chất tạm thời và sẽ chấm dứt sau một thời gian; trong khi tình trạng mất năng lực hành vi tổng quát có thể kéo dài không thời hạn.

1.2. Pháp nhân

Là một tổ chức tồn tại vì một mục đích nào đó. Pháp nhân phải có những yếu tố lý lịch cơ bản rõ ràng cho phép phân biệt với cá nhân các thành viên của nó và với các pháp nhân khác. Pháp nhân có năng lực pháp luật và năng lực hành vi phù hợp với mục đích tồn tại của mình: có những pháp nhân (như quỹ xã hội, quỹ từ thiện) không thể có những quyền và nghĩa vụ của thương nhân; không pháp nhân nào có thể có quyền và nghĩa vụ của người thừa kế theo pháp luật.

1.3. Hộ gia đình

Là tập hợp những người gắn bó với nhau do quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân, có tài sản chung và thực hiện các hoạt động kinh tế chung. Cũng như pháp nhân, hộ gia đình có năng lực pháp luật và năng lực hành vi phù hợp với mục đích tồn tại của mình. Song nội dung năng lực pháp luật của hộ gia đình được xác định theo những nguyên tắc gần giống với những nguyên tắc xác định năng lực pháp luật của cá nhân; bởi vậy, hộ gia đình, trên nguyên tắc, có khả năng có quyền và nghĩa vụ như cá nhân, trừ những quyền và nghĩa vụ mà chỉ cá nhân mới có thể có được, như quyền thừa kế theo pháp luật, quyền kết hôn, quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ đối với con cái,...

1.4. - Tổ hợp tác

Là tập hợp những người có cùng một nghề nghiệp trong các lĩnh vực dịch vụ và thủ công nghiệp và quan hệ bè bạn, thầy trò, cùng góp tài sản để thực hiện chung các hoạt động nghề nghiệp. Tổ hợp tác cũng phải có các yếu tố lý lịch rõ ràng và có năng lực pháp luật, năng lực hành vi phù hợp với mục đích tồn tại của mình, như pháp nhân.

2. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự

Pháp luật dân sự Việt Nam thừa nhận cho các chủ thể hai loại quyền dân sự: quyền có tính chất tài sản và quyền không có tính chất tài sản (còn gọi là quyền nhân thân).

2.1. Quyền có tính chất tài sản

Là những quyền định giá được bằng tiền, là quan hệ giữa các chủ thể mà có đối tượng là một giá trị tài sản. Có những quyền được thực hiện trực tiếp trên một vật cụ thể (gọi là quyền đối vật); có những quyền tương ứng với những nghĩa vụ mà người khác phải thực hiện (gọi là quyền đối nhân).

2.1.1. Quyền đối vật

Các vật mà trên đó quyền đối vật được thực hiện rất đa dạng; bản thân các quyền đối vật cũng có thể được phân thành nhiều loại.

2.1.1.1. Phân loại vật

Ta chỉ ghi nhận một vài cách phân loại tiêu biểu.

2.1.1.1.1. Động sản và bất động sản

- Bất kỳ tài sản nào cũng chỉ có thể hoặc là bất động sản hoặc là động sản. Luật phân biệt động sản và bất động sản chủ yếu dựa vào tiêu chí vật lý: bất động sản là tài sản không di dời được (đất, nhà ở, công trình xây dựng và nói chung, các tài sản gắn liền với đất); động sản là tài sản di, dời được (bàn, ghế, xe máy,...). Mặt khác, có những động sản được coi là bất động sản do có công dụng như bất động sản; có những bất động sản được coi như động sản do chỉ có thể được chuyển giao trong giao lưu dân sự như động sản.

2.1.1.1.2. Vật hữu hình và vật vô hình

- Vật hữu hình là vật có thể nhận biết được bằng giác quan tiếp xúc: nhà, đồng hồ, xe máy,... Vật vô hình là ý niệm của luật về những giá trị tài sản phi vật thể (quyền tác giả, các yếu tố vô hình thuộc sản nghiệp thương mại,...).

2.1.1.1.3. Vật chuyển giao được và vật không chuyển giao được trong giao lưu dân sự

- Trên nguyên tắc, các quyền có tính chất tài sản chuyển giao được trong giao lưu dân sự. Song, cũng có những quyền có giá trị tài sản không thể được chuyển giao, do được gắn liền với nhân thân của người có quyền như quyền được cấp dưỡng, quyền hưởng trợ cấp mất sức,...

2.1.1.2. Phân loại quyền đối vật

2.1.1.2.1. Quyền mà việc thực hiện tác động trực tiếp lên đối tượng

- Thuộc nhóm này có thể kể ra: quyền sở hữu, quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề, quyền sở hữu bề mặt, quyền thuê quyền sử dụng đất ở, đất chuyên dùng,...

2.1.1.2.2. Quyền có đối tượng là giá trị tiền tệ của một hoặc nhiều tài sản cụ thể

- Quyền này được xác lập nhằm bảo đảm cho việc thực hiện một nghĩa vụ tài sản. Nó có đối tượng là tài sản của người khác và cho phép người có quyền được yêu cầu xử lý tài sản theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận để thanh toán nghĩa vụ được bảo đảm. Ta có quyền nhận thế chấp, nhận cầm cố tài sản là những ví dụ tiêu biểu của loại quyền này.

2.1.2. Quyền đối nhân

Là quyền của một người, được phép yêu cầu một người khác thực hiện một nghĩa vụ tài sản đối với mình. Đó có thể là nghĩa vụ làm hoặc không làm một việc hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản.

2.2. Quyền nhân thân

Quyền chính trị - Trên nguyên tắc các quyền chính trị của các chủ thể của quan hệ pháp luật thuộc phạm vi điều chỉnh của công pháp. Song, một số quyền có ý nghĩa chính trị được liệt kê trong nhóm các quyền nhân thân theo nghĩa của pháp luật dân sự: quyền xác định dân tộc, quyền đối với quốc tịch, quyền được bảo đảm an toàn về chỗ ở, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền tự do đi lại, cư trú.

Quyền gia đình - Gồm các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các quan hệ giữa những thành viên trong gia đình: quyền bình đẳng giữa vợ và chồng, quyền được hưởng sự chăm sóc giữa các thành viên trong gia đình,... Các quyền gia đình, trên nguyên tắc, không có tính chất tài sản; nhưng cũng có những quyền gia đình có tính chất tài sản, như quyền của vợ, chồng đối với tài sản chung, quyền thừa kế theo pháp luật.

Quyền nhân thân đúng nghĩa - Các quyền này rất đa dạng trong luật dân sự: các quyền đối với thân thể (quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể); các quyền trong đời sống dân sự (quyền đối với họ, tên, hộ tịch, quyền kết hôn, quyền ly hôn,...); các quyền trong quan hệ công (quyền tự do đi lại, cư trú); các quyền được tôn trọng đối với đời tư (quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quyền đối với bí mật đời tư); các quyền nhân thân của người sáng tạo ra tác phẩm văn chương, nghệ thuật, khoa học; các quyền trong đời sống kinh tế (quyền tự do kinh doanh);...

3. Xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự

Quyền và nghĩa vụ dân sự được xác lập theo các căn cứ quy định tại Điều 13 BLDS. Nói chung một quyền có thể được xác lập do được tạo ra hoặc được chuyển giao, do hiệu lực của một giao dịch hoặc do hệ quả của một sự kiện pháp lý.

3.1. Tạo ra hoặc chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự

3.1.1. Tạo ra quyền và nghĩa vụ dân sự

- Nói "quyền và nghĩa vụ dân sự được tạo ra", ta hiểu rằng quyền và nghĩa vụ này xuất hiện ở chủ thể thứ nhất.

Các quyền nhân thân, nói chung, chỉ có thể được xác lập do được tạo ra. Có những quyền phát sinh cùng một lúc với người có quyền: được sinh ra, con người có quyền đối với họ, tên, hộ tịch, có quyền nhận cha, mẹ. Có những quyền phát sinh sau một sự kiện: quyền bình đẳng giữa vợ và chồng được xác lập do hôn nhân; quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ được xác lập do việc sinh con.

Nhưng các quyền nhân thân của tác giả được để lại cho người thừa kế. Vậy, cũng có thể có trường hợp quyền nhân thân được xác lập bằng con đường chuyển giao.

Các quyền có tính chất tài sản cũng có thể được tạo ra: quyền đối nhân được tạo ra từ hợp đồng hoặc từ một sự kiện pháp lý nào đó (tai nạn, ly hôn); quyền sở hữu được tạo ra bằng cách chiếm hữu vật vô chủ, bằng việc chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong nhiều năm; quyền sở hữu trí tuệ được tạo ra bằng hoạt động sáng tạo.

3.1.2. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự

- Gọi là được chuyển giao, các quyền và nghĩa vụ trước đây thuộc về một người, nay được giao lại cho một người khác. Hầu hết các quyền được xác lập bằng con đường chuyển giao đều là các quyền có tính chất tài sản: quyền đối nhân được chuyển giao bằng cách chuyển quyền yêu cầu, chuyển nghĩa vụ; quyền sở hữu được chuyển giao bằng hợp đồng, thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật;...

3.2. Giao dịch hoặc sự kiện pháp lý

3.2.1. Giao dịch

Khái niệm - Giao dịch là việc bày tỏ ý chí của một hoặc nhiều người nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một quyền. Người bày tỏ ý chí gọi là bên giao dịch.

Trong trường hợp chỉ có một người bày tỏ ý chí, ta có giao dịch một bên. Có khi giao dịch một bên cũng được ghi nhận trong luật Việt Nam, dù có đến hai người bày tỏ ý chí, như khi vợ chồng cùng lập một di chúc để định đoạt tài sản chung. Song, thông thường, với sự bày tỏ ý chí của nhiều người, ta có giao dịch nhiều bên. Giao dịch nhiều bên được xác lập, một khi có sự gặp gỡ (sự thống nhất) ý chí của nhiều người. Bởi vậy, ta còn gọi giao dịch nhiều bên là sự thoả thuận.

Theo động cơ kinh tế của người bày tỏ ý chí, ta có giao dịch có đền bù (mua bán, trao đổi) hoặc không có đền bù (tặng cho, di chúc).

Theo tầm quan trọng của giao dịch, ta có giao dịch định đoạt và giao dịch quản trị. Bằng giao dịch định đoạt, một quyền có tính chất tài sản đi ra khỏi khối tài sản của người định đoạt: quyền này có thể biến mất (tài sản được tiêu dùng) hoặc được chuyển cho người khác (tài sản được bán, được tặng cho). Bằng giao dịch quản trị, người giao dịch bảo quản và khai thác lợi ích từ các quyền có tính chất tài sản của mình (giao kết hợp đồng sửa chữa, bán hoa lợi từ tài sản gốc).

Các điều kiện để giao dịch có giá trị - Giao dịch chỉ có giá trị khi có đủ các

điều kiện quy định tại Điều 122 BLDS.

a - ***Điều kiện phát sinh từ yêu cầu bảo vệ trật tự xã hội và các giá trị của cộng đồng*** - Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội (BLDS Điều 122 khoản 1 điểm b). Mục đích của giao dịch là lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch; còn nội dung của giao dịch có thể được hiểu như đối tượng của giao dịch đó.

Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định (BLDS Điều 128).

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng (BLDS Điều 128).

b - ***Điều kiện về hình thức*** - Để có giá trị giao dịch phải được xác lập dưới một hình thức nào đó phù hợp với quy định của pháp luật; tuy nhiên, hình thức giao dịch chỉ là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định (BLDS Điều 122 khoản 2). Trong luật thực định Việt Nam phần lớn các giao dịch quan trọng đều phải được lập thành văn bản (mua bán, tặng cho, cho vay, cho thuê, thế chấp, cầm cố,...). Cá biệt, có những giao dịch không những phải được ghi nhận bằng văn bản mà còn phải bằng một văn bản có hình thức phù hợp với các quy định cụ thể của luật viết (như di chúc): ta gọi đó là những giao dịch trọng thức. Một khi việc lập văn bản là điều kiện để giao dịch có giá trị, thì giao dịch được xác lập mà không có văn bản là giao dịch vô hiệu.

Mặt khác, một số giao dịch còn phải đăng ký theo quy định của pháp luật. Ý nghĩa của việc đăng ký giao dịch được người làm luật xác định tùy theo tính chất, tầm quan trọng của giao dịch đối với các bên giao dịch cũng như đối với người thứ ba. Có trường hợp giao dịch có giá trị một khi được xác lập phù hợp với các quy định của luật, nhưng chỉ phát sinh hiệu lực đối với người thứ ba kể từ ngày được đăng ký (BLDS Điều 323 khoản 3) như trường hợp thế chấp một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ; có trường hợp việc đăng ký giao dịch có tác dụng xác nhận việc chuyển quyền sở hữu tài sản giao dịch, như trường hợp mua bán, trao đổi các tài sản thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu (BLDS Điều 439 khoản 2; Điều 463 khoản 4); có trường hợp hiệu lực của giao dịch chỉ phát sinh, cả đối với hai bên giao dịch và đối với người thứ ba, kể từ thời điểm đăng ký, như trường hợp tặng cho các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu (BLDS Điều 466 và Điều 467 khoản 2) và trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng

trồng, tàu bay, tàu biển (Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/06 Điều 10 Khoản 1 Điểm c) .
c - ***Điều kiện về nội dung*** - Có thể coi quy định theo đó, giao dịch không được có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội là một trong những điều kiện về nội dung (hiểu theo nghĩa rộng nhất) để giao dịch có giá trị. Phần lớn các điều kiện về nội dung được pháp luật dự liệu nhằm bảo vệ quyền tự do ý chí của bên giao dịch. Nói rõ hơn, ý chí của người giao dịch phải được tôn trọng, nhưng với điều kiện đó phải là ý chí được bày tỏ bởi một người có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
c1. **Năng lực của bên giao dịch** - Giao dịch chỉ có giá trị một khi được thực hiện bởi một người có năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Tình trạng mất năng lực pháp luật, ta đã biết, luôn có tính chất đặc biệt và chỉ được ghi nhận ở một vài quan hệ được xác định (thường là các quan hệ trong lĩnh vực gia đình). Người không có năng lực pháp luật không được phép xác lập giao dịch làm phát sinh những quyền và nghĩa vụ mà người đó không thể có.

Ngay những người có năng lực pháp luật không nhất thiết đều có năng lực hành vi, nghĩa là không nhất thiết có khả năng tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà mình có. Trẻ dưới 6 tuổi có năng lực pháp luật ngang với người đủ 18 tuổi, nhưng mọi giao dịch của trẻ dưới 6 tuổi đều chỉ có thể được xác lập và thực hiện thông qua vai trò của người đại diện (BLDS Điều 21).
c2. **Sự tự nguyện của bên giao dịch** - Người bị bệnh tâm thần không thể xác lập giao dịch một cách tự nguyện, bởi ở người này không hề có ý chí và do đó, không thể có sự bày tỏ ý chí.
Có nhiều trường hợp ý chí tồn tại và được bày tỏ một cách tự nguyện, nhưng sự tự nguyện không hoàn hảo: người bày tỏ ý chí có thể chấp nhận xác lập giao dịch do nhầm lẫn, do bị lừa dối hoặc bị đe dọa. Một khi sự tự nguyện trong việc bày tỏ ý chí không hoàn hảo, thì giao dịch có thể bị tuyên bố vô hiệu, cũng như trong trường hợp giao dịch được xác lập bởi một người không có năng lực hành vi.

3.2.2. Sự kiện pháp lý

Khái niệm - Sự kiện pháp lý là sự việc có tác dụng tạo ra, chuyển giao hoặc làm chấm dứt các quyền và nghĩa vụ. Thông thường, sự kiện pháp lý có nguồn gốc từ hành vi của con người, cố ý hoặc vô ý: hủy hoại tài sản của người khác; lái xe không làm chủ được tốc độ, gây tai nạn dẫn đến thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác;... Nhưng sự kiện pháp lý cũng có thể có nguồn gốc vật chất, tự nhiên hoặc xã hội: sau một thời gian do luật quy định, người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai đối với một tài sản sẽ trở thành chủ sở hữu tài sản đó; do việc một người chết, những tài sản của người này được chuyển giao cho người thừa kế, người được di tặng; do một người con bị tai nạn và trở thành tật nguyền, cha, mẹ có nghĩa vụ nuôi dưỡng người con đó;...
Các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch luôn luôn là các quyền và nghĩa vụ mà các bên giao dịch quan tâm, muốn có, tìm kiếm, trông đợi và đeo đuổi. Trong khi đó, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ sự kiện pháp lý luôn do luật áp đặt, độc lập với ý chí của con người. Ngay cả khi sự kiện pháp lý có nguồn gốc từ hành vi cố ý của con người, thì các quyền và nghĩa vụ từ sự kiện đó sinh ra không phải là mục tiêu hành động của người đó: một người cố tình gây thiệt hại cho người khác không phải với mong muốn trở thành người có nghĩa vụ bồi thường cho người bị thiệt hại. Bởi vậy, có thể gọi các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ một giao dịch là nội dung hiệu lực của giao dịch đó; còn các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ một sự kiện pháp lý là nội dung hệ quả của sự kiện pháp lý đó.

4. Bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự

Nhìn chung, các quy tắc của luật được các chủ thể của quan hệ pháp luật chấp hành một cách tự giác.
Cá biệt, trong một số trường hợp, chủ thể này hoặc chủ thể khác đi quá giới hạn mà luật xác định, đối với các quyền của mình và thế là có sự phản ứng của người bị thiệt hại. Trong một xã hội có tổ chức, không ai có thể tự thiết lập công lý cho chính mình. Trong trường hợp một người bị thiệt hại do lỗi của một người khác, luật cho phép người bị thiệt hại yêu cầu

sự can thiệp của quyền lực công cộng để khôi phục các quyền của mình. Đại diện cho quyền lực công cộng trong việc giải quyết những bất đồng giữa các chủ thể của quan hệ pháp luật là các toà án; quyền của chủ thể của quan hệ pháp luật được yêu cầu toà án bảo vệ quyền lợi của mình gọi là quyền khởi kiện. Tổ chức toà án là đề tài của một nghiên cứu khác. Ở đây ta xem xét một vài vấn đề chung nhất liên quan đến quyền khởi kiện.

4.1.1. Khái niệm quyền khởi kiện

Quyền và quyền khởi kiện - Quyền khởi kiện, hiểu theo nghĩa rộng nhất là phương tiện sử dụng bởi một người tự cho rằng mình có một quyền để yêu cầu công lý thừa nhận quyền đó cho mình cũng như bảo đảm việc người khác tôn trọng quyền đó của mình. Thông thường, bất kỳ quyền nào cũng được bảo đảm thực hiện bằng quyền khởi kiện. Tuy nhiên, một cách ngoại lệ:

- Có những quyền mà việc kiện đòi tôn trọng quyền đó không được thừa nhận. Hầu hết các quyền loại này được bảo đảm thực hiện bằng đạo đức, bằng ý thức tự giác, bằng lương tâm, chứ không phải bằng sự cưỡng chế của Nhà nước. Ví dụ: quyền của con đã thành niên mà không có khả năng lao động, được cha, mẹ nuôi dưỡng.
- Có những việc kiện không nhằm yêu cầu tôn trọng một quyền (hoặc ít nhất không trực tiếp nhằm mục đích đó) mà chỉ nhằm bảo tồn các lợi ích. Ví dụ: quyền yêu cầu toà án áp dụng các biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt.
- Có trường hợp quyền vẫn còn, nhưng quyền khởi kiện lại không còn.Ví dụ: một người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai đối với một động sản; sau mười năm, nếu chủ sở hữu không kiện đòi lại tài sản, thì quyền kiện đòi lại tài sản biến mất; nhưng nếu người chiếm hữu tự nguyện trả lại tài sản cho chủ sở hữu vào năm thứ mười một, thì người sau này vẫn có thể tiếp nhận tài sản như là người luôn có quyền sở hữu đối với tài sản đó, chứ không phải như là người được người khác chuyển quyền sở hữu tài sản.

4.1.2. Các loại quyền khởi kiện

Quyền khởi kiện không có tính chất tài sản - Bao gồm các quyền khởi kiện liên quan đến những quyền và lợi ích không định giá được bằng tiền. Tiêu biểu cho nhóm này là những quyền khởi kiện về hộ tịch: quyền yêu cầu nhận cha, mẹ cho con; quyền yêu cầu nhận con cho cha, mẹ; quyền kiện xin ly hôn;...

Quyền khởi kiện có tính chất tài sản - Bao gồm các quyền khởi kiện nhằm xác lập, khôi phục hoặc bảo đảm việc thực hiện một quyền đối với một tài sản hay một quyền tương ứng với một nghĩa vụ tài sản của một người khác. Có thể kể ra: quyền kiện đòi lại tài sản, quyền kiện đòi bồi thường thiệt hại;...

Quyền khởi kiện có tính chất hỗn hợp - Bao gồm những quyền khởi kiện liên quan cả đến quyền không có tính chất tài sản và quyền có tính chất tài sản, cả đến quyền đối với một tài sản cụ thể và quyền tương ứng với nghĩa vụ tài sản của một người khác.

Ví dụ: khi kiện xin nhận con cho cha, mẹ đã chết, người khởi kiện có thể không chỉ quan tâm đến quyền xác lập quan hệ cha mẹ-con cái mà còn đến quyền hưởng di sản.

Ví dụ khác: quyền quyền khởi kiện yêu cầu tuyên bố vô hiệu một hợp đồng mua bán là một quyền khởi kiện có tính chất hỗn hợp, bởi sự vô hiệu có tác dụng một mặt, làm biến mất các nghĩa vụ tài sản của hai bên giao kết (nghĩa vụ trả tiền của người mua, nghĩa vụ bảo hành của người bán,...), mặt khác, khôi phục quyền sở hữu của người bán đối với tài sản bán.

MỤC 2 - NGUỒN CỦA LUẬT DÂN SỰ

Luật và tục lệ - Nguồn của luật là nơi mà các quy phạm pháp luật được tìm thấy.

Ta phân biệt hai loại nguồn.

- *Nguồn trực tiếp*: là nơi mà các quy phạm pháp luật được tạo ra. Luật dân sự Việt

Nam thừa nhận hai loại nguồn trực tiếp: luật viết và tục lệ.

- *Nguồn diễn dịch và giải thích*: là nơi mà các quy phạm pháp luật được phát hiện từ các kết quả phân tích luật viết. Việc phân tích có thể được thực hiện trong khuôn khổ các nghiên cứu khoa học: ta có các quy phạm pháp luật là kết quả phân tích của học thuyết pháp lý. Phân tích cũng có thể được thực hiện trong quá trình vận dụng các quy tắc của luật viết để tiến hành xét xử: ta có các quy phạm pháp luật là kết quả của hoạt động xét xử (còn gọi là án lệ). Cuối cùng, phân tích còn có thể được thực hiện trong quá trình vận dụng luật viết để giải quyết các vấn đề cụ thể của hoạt động thực hành luật: ta có các quy phạm pháp luật được rút ra từ thực tiễn áp dụng pháp luật.

Ở đây, ta chỉ xem xét các nguồn trực tiếp: luật viết và tục lệ.

1. Luật viết

Khái niệm - Theo nghĩa chính thức, luật viết được hiểu như là một quyết định của cơ quan lập pháp (Quốc hội) có chứa đựng các quy phạm pháp luật.

Theo nghĩa rộng nhất, luật viết là văn bản có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Vậy luật viết, với tư cách là nguồn của luật, có thể là các văn bản của cơ quan quyền lực Nhà nước, cơ quan chấp hành và hành chính, thậm chí, cơ quan xét xử và cơ quan kiểm sát.

Luật viết luôn có hiệu lực bắt buộc thi hành. Song có luật luôn phải được bắt buộc thi hành; có luật chỉ phải được bắt buộc thi hành, nếu các chủ thể của quan hệ pháp luật không bày tỏ ý chí khác đi. Ta tạm gọi loại luật thứ nhất là luật mệnh lệnh, loại luật thứ hai là luật bổ khuyết.

Luật mệnh lệnh - Bao gồm các quy phạm do người làm luật chủ động thiết lập nhằm chi phối các quan hệ pháp luật nhất định theo các tiêu chí chung. Các chủ thể của quan hệ pháp luật liên quan có trách nhiệm xử sự phù hợp với các quy định của luật mệnh lệnh mà không có sự lựa chọn nào khác. Ví dụ: việc thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản (BLDS Điều 343); vậy, nếu các bên xác lập giao dịch thế chấp bằng miệng, thì việc thế chấp không có giá trị.

Luật bổ khuyết - Bao gồm các quy phạm do người làm luật thiết lập và được áp dụng bắt buộc và đương nhiên, trong trường hợp chủ thể của quan hệ pháp luật liên quan không chủ động bày tỏ ý chí về việc xác định thái độ xử sự của mình theo cách khác. Luật bổ khuyết rất cần thiết trong chừng mực nó được coi như sự suy đoán của người làm luật về nội dung của ý chí không được bày tỏ hoặc được bày tỏ không rõ ràng của các chủ thể của quan hệ pháp luật. Nó có tác dụng tạo ra các chuẩn mực xử sự chung mà dựa vào đó, cơ quan giải quyết tranh chấp đánh giá mức độ nghiêm chỉnh của bên này hay bên kia trong việc thực hiện giao dịch. Ví dụ: trong trường hợp bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác (BLDS Điều 358 khoản 2).

Hiệu lực của luật trong thời gian - Khác với nhiều hệ thống luật phương Tây, luật viết ở Việt Nam không chỉ được áp dụng đối với các tình huống pháp lý xảy ra sau ngày luật có hiệu lực. Trong trường hợp cần thiết, người làm luật có thể quyết định việc áp dụng luật cho các tình huống xảy ra trước đó. Nói riêng trong lĩnh vực dân sự, các nguyên tắc cơ bản trong luật hiện hành về áp dụng luật viết trong thời gian được ghi nhận tại Nghị quyết của Quốc hội ngày 14/06/2005 về việc thi hành BLDS (Nghị quyết chỉ nói về việc áp dụng luật đối với các giao dịch; song ta có thể mở rộng phạm vi áp dụng của Nghị quyết ra đến tất cả các tình huống trong đó tồn tại quan hệ pháp luật dân sự, dù quan hệ có nguồn gốc từ một giao dịch hay một sự kiện pháp lý).

Nguyên tắc mở rộng phạm vi áp dụng BLDS trong chừng mực có thể được - Tất nhiên, các tình huống pháp lý xảy ra sau khi BLDS có hiệu lực sẽ chịu sự chi phối của BLDS. Đối với các tình huống xảy ra trước ngày BLDS có hiệu lực thì việc áp dụng pháp luật được quy định như sau:

a. Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của BLDS thì áp dụng các quy định của BLDS.

b. Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức khác với quy định của BLDS hoặc giao dịch được thực hiện xong trước ngày BLDS có hiệu lực mà có tranh chấp xảy ra thì áp dụng quy định của BLDS 1995 và các văn bản pháp luật hướng dẫn áp dụng BLDS 1995 để giải quyết.

c. Thời hiệu hưởng quyền dân sự và thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự được áp dụng theo quy định của BLDS.

d. Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu đối với những giao dịch được xác lập sau ngày BLDS được công bố được áp dụng theo quy định của BLDS.

2. Tục lệ

Khái niệm - Tục lệ, cách diễn đạt rút gọn cụm từ "phong tục, tập quán" dùng trong BLDS, có thể được định nghĩa như là các quy tắc xử sự chung hình thành từ cách cư xử được lặp đi lặp lại trong thực tiễn giao dịch và trở thành thói quen được dân cư chấp nhận và tôn trọng như các quy phạm pháp luật.

Sự đa dạng của tục lệ - Tục lệ được hình thành một cách tự phát từ cuộc sống; nó mang đậm dấu ấn của môi trường nơi mà nó được sinh ra và tương ứng với tính cách của con người sống trong môi trường đó. Môi trường, con người khác nhau có đặc điểm, tính cách không giống nhau. Bởi vậy, tục lệ rất đa dạng, ngay trong lĩnh vực dân sự.

2.1. Tục lệ phổ quát

Là những quy tắc xử sự được chấp nhận đối với tất cả mọi người, không phân biệt dân tộc, quốc tịch. Tục lệ được thừa nhận có giá trị phổ quát, một khi tính hợp lý, hợp tình của nó không thể bị tranh cãi. Ví dụ: không ai tiến hành thủ tục cưỡng chế việc trả nợ trong lúc đang diễn ra tang lễ của người mắc nợ.

2.2. Tục lệ chung

Là những quy tắc xử sự được chấp nhận ở một nước. Ví dụ điển hình nhất về loại tục lệ này ở Việt Nam là các tục lệ liên quan đến tên họ: trong trường hợp con sinh ra có đủ cha, mẹ và khi khai sinh, người khai không có yêu cầu gì đặc biệt, thì viên chức hộ tịch sẽ tự động ghi cho đứa trẻ mang họ cha.

2.3. Tập quán địa phương

Là những quy tắc xử sự được chấp nhận ở một địa phương, một vùng thuộc một nước, thể hiện tính đặc thù trong nếp sinh hoạt của cộng đồng người ở vùng, địa phương đó, nếp sinh hoạt phù hợp với vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên và hoàn cảnh kinh tế của vùng, địa phương. Ví dụ: ở rất nhiều vùng, cô dâu được gia đình chú rể tặng một đôi hoa tai nhân lễ đính hôn hoặc lễ cưới; hoa tai được coi là tài sản riêng của người vợ, nghĩa là không được tính vào khối tài sản chung của vợ, chồng để chia, một khi chế độ tài sản của vợ, chồng được thanh toán (do ly hôn, do vợ hoặc chồng chết,..).

2.4. Tập quán nghề nghiệp

Là những quy tắc xử sự được chấp nhận trong một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp. Điển hình nhất là các quy tắc liên quan đến bí mật nghề nghiệp.

2.5. Quy ước

Là những tập quán, được chấp nhận trong phạm vi một địa phương hoặc một lĩnh vực nghề nghiệp nào đó, chi phối các quan hệ kết ước được xác lập ở địa phương đó hoặc giữa những người có cùng nghề nghiệp đó. Quy ước thường có tác dụng xác định những nghĩa vụ phụ tiềm ẩn hoặc những thỏa thuận mặc nhiên không được ghi nhận trong hợp đồng. Tham gia kết ước, bên này coi như bên kia đã biết và mặc nhiên thừa nhận sự ràng buộc của những quy ước đó đối với quan hệ kết ước giữa hai bên mà không cần phải bày tỏ ý chí một cách rành mạch. Ví dụ: ở một vài địa phương tại Nam bộ, khi giao kết việc mua bán một chục xoài hoặc một chục cam, các bên đều ngầm hiểu rằng hợp đồng mua bán có đối tượng là mười

bốn trái xoài hoặc mười sáu trái cam chứ không phải chỉ mười trái xoài hoặc cam.

3. Quan hệ giữa luật viết và tục lệ

Ta biết rằng trong lĩnh vực dân sự, tục lệ được thừa nhận là một trong những nguồn của luật. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp luật viết phải được ưu tiên áp dụng; chỉ khi nào luật viết không đầy đủ hoặc không rõ nghĩa, thì tục lệ mới được sử dụng như một công cụ điều chỉnh bổ sung hoặc như một cách giải thích luật viết. Nguyên tắc này dẫn đến các hệ quả sau đây:

1 - ***Hệ quả thứ nhất*: trong trường hợp tục lệ trái với luật viết, thì tục lệ phải bị loại bỏ** - Luật viết ở đây phải là luật mệnh lệnh: luật bổ khuyết có thể bị tục lệ lấn át, một khi người giao dịch thường xuyên bày tỏ ý chí phù hợp với tục lệ. Về mặt lý thuyết, một khi người làm luật tuyên bố rằng một quy phạm nào đó phải được bắt buộc áp dụng và chủ thể quan hệ pháp luật không thể bày tỏ ý chí ngược lại, thì các tục lệ trái với quy phạm đó phải bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, cũng có trường hợp tục lệ trái với luật mệnh lệnh vẫn được duy trì và, sau một thời gian, lại đẩy luật mệnh lệnh vào tình trạng không hữu hiệu, cuối cùng, bị loại bỏ. *Ví dụ: Luật đất đai năm 1987 nghiêm cấm việc mua bán, sang nhượng đất (Điều 5); nhưng người dân, theo thói quen, vẫn mua bán, sang nhượng đất mà Nhà nước không kiểm soát được; đến năm 1993, Luật đất đai mới thừa nhận rằng người sử dụng đất quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khuôn khổ pháp luật.*

2 - ***Hệ quả thứ hai*: tục lệ có giá trị như luật viết, trong trường hợp được thừa nhận như một công cụ điều chỉnh bổ sung hoặc như một cách giải thích luật viết** - "Có giá trị như luật viết" nghĩa là sự tôn trọng đối với tục lệ, nếu cần, cũng được bảo đảm bằng các biện pháp cưỡng chế của bộ máy Nhà nước.

MỤC 3 - SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM

Quá trình phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam có thể được chia thành ba giai đoạn.

1. Giai đoạn của luật cổ

Khái niệm pháp luật dân sự, được xây dựng trong luật cận đại và luật hiện đại Việt Nam, không tồn tại trong luật cổ. Các quy tắc viết có tác dụng điều chỉnh các quan hệ giữa cá nhân và cá nhân trong xã hội cổ thường nằm lẫn lộn trong các chương về hình sự, hành chính liên quan đến hôn nhân, gia đình và ruộng đất.

Pháp luật trước thời Lê chỉ còn có thể được hình dung thông qua sách sử, các tài liệu chuyên môn về luật đều đã thất lạc hoặc bị tiêu hủy. Một số dữ kiện trong sách sử cho phép suy đoán về sự tồn tại của các quy tắc xử sự chung chi phối các quan hệ gia đình, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng. Mọi suy đoán đều không chắc chắn.

Dưới thời Lê, pháp luật dân sự được xây dựng và hoàn thiện với sự quan tâm đặc biệt. Bộ Quốc triều hình luật đã dành hẳn hai chương - Hộ hôn và Điền sản - để nói không chỉ về hôn nhân, gia đình và ruộng đất, mà còn cả về chế độ tài sản của vợ, chồng, thừa kế, tặng cho và di chúc, hương hỏa, nghĩa vụ, hợp đồng,... không kể các quy định có liên quan đến quan hệ pháp luật dân sự nằm rải rác ở các chương khác hoặc trong các văn bản luật riêng lẻ mà không được đưa vào Bộ luật. Nói chung, mặc dù chịu ảnh hưởng của văn hóa pháp lý Trung Quốc, người làm luật thời Lê vẫn nhận ra những đặc điểm riêng của đời sống dân sự Việt Nam và đã xây dựng được nhiều quy tắc pháp lý thể hiện tính độc đáo của pháp luật dân sự Việt Nam, nhất là những quy tắc liên quan đến hôn nhân, chế độ tài sản của vợ, chồng và thừa kế.

Đến thời Nguyễn, luật viết lại trở về với thân phận chư hầu của Trung Quốc. Nói riêng về luật dân sự, Bộ luật Gia Long hầu như chỉ lấy lại câu chữ của các quy định liên quan trong Bộ luật nhà Thanh. Thực ra, người làm luật nhà Thanh, cũng như người làm luật thời trước đó ở Trung Quốc, không có ý niệm gì về luật dân sự: đối với luật, ngoài các quan hệ trong nội bộ gia đình, con người chỉ có các quan hệ với quyền lực công cộng. Sao chép luật nhà Thanh, Bộ luật Gia Long giải quyết các vấn đề dân sự như là một phần của những vấn đề lớn hơn về gia đình, hành chính và hình sự. Trong thời gian áp dụng Bộ luật Gia Long, người làm luật thời Nguyễn có bổ sung một số quy định về dân sự trong các lĩnh vực thừa kế, nghĩa vụ

và hợp đồng, hôn nhân và gia đình; nhưng đó chỉ là những bổ sung rất vụn vặt, không ảnh hưởng đến những nguyên tắc cơ bản của Bộ luật này.

2. Giai đoạn của luật cận đại

Luật dân sự Việt Nam xây dựng theo kiểu Pháp

Cùng với việc xây dựng và củng cố chế độ thực dân ở Việt Nam, người Pháp đã nỗ lực La tinh hóa hệ thống pháp luật Việt Nam. Nói riêng trong lĩnh vực dân sự, luật Việt Nam thời kỳ thuộc địa được xây dựng theo khuôn mẫu luật của Pháp, có cải biên cho phù hợp với bối cảnh kinh tế và xã hội của Việt Nam thời kỳ đó. Về luật viết, có một số văn bản đáng chú ý: dân luật giản yếu (1883) áp dụng tại Nam kỳ; Sắc lệnh ngày 21/7/1925 về chế độ điền thổ cũng áp dụng tại Nam Kỳ; BLDS Bắc (1931); BLDS Trung (1936, 1938, 1939); Sắc lệnh ngày 21/2/1921 về thương mại, áp dụng tại Bắc và Nam Kỳ; Bộ thương luật Trung (1942);... Theo kiểu Pháp, luật viết thường chỉ ghi nhận những quy phạm mang tính nguyên tắc và được bổ khuyết bằng các giải pháp được xây dựng trong học thuyết pháp lý và án lệ. Bên cạnh đó, tục lệ đóng vai trò của một nguồn quan trọng của luật, nhất là tại Nam Kỳ, nơi mà cho đến khi chấm dứt chế độ thuộc địa vẫn chưa có một BLDS hoàn chỉnh (dân luật giản yếu năm 1883 chỉ đề cập đến các vấn đề về nhân thân, tương ứng với quyển 1 BLDS Pháp, không đả động gì đến các quan hệ tài sản).

3. Giai đoạn của luật hiện đại

Người làm luật xã hội chủ nghĩa luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc xây dựng pháp luật dân sự. Tuy nhiên, do phải tập trung thì giờ và công sức, trí tuệ cho chiến tranh cũng như cho việc giải quyết các hậu quả của chiến tranh, người làm luật chỉ có thể đầu tư đúng mức cho luật học dân sự khoảng mươi năm trở lại đây.

3.1. Từ 1945 đến những năm 1980

Trong những năm đầu kể từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, người làm luật chấp nhận duy trì hiệu lực của hệ thống luật cũ trừ các quy định "trái với nền độc lập của nước Việt Nam và chính thể dân chủ cộng hòa" (Sắc lệnh số 47 ngày 10/10/1945, Điều 12). Với chủ trương đó, gần như toàn bộ hệ thống pháp luật dân sự (lúc đó gọi là luật hộ) được xây dựng trong thời kỳ thuộc địa vẫn giữ nguyên giá trị.

Đến năm 1950, trước yêu cầu cấp bách của việc xoá bỏ các tàn tích của chế độ phong kiến trong lĩnh vực dân sự, người làm luật, trong hoàn cảnh rất khắc nghiệt của cuộc kháng chiến chống Pháp, đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để bắt tay vào việc xây dựng hệ thống pháp luật dân sự xã hội chủ nghĩa. Một trong những thành tựu đáng chú ý nhất của thời kỳ này là việc ban hành Sắc lệnh số 97 ngày 22/5/1950 sửa đổi một số quy lệ và chế định trong dân luật. Sắc lệnh ghi nhận một số nguyên tắc lớn liên quan đến nhân thân và tài sản: quyền nhận cha, mẹ, quyền tự do kết hôn, quyền bình đẳng của người phụ nữ so với nam giới, nguyên tắc bảo vệ kẻ yếu trong quan hệ hợp đồng, quyền thừa kế,...

Pháp luật cũ không còn được dùng làm căn cứ cho việc xét xử của các toà án kể từ năm 1957 theo Chỉ thị số 772/TATC ngày 10/7/1957 của Toà án nhân dân tối cao. Tuy nhiên, do chiến tranh và những khó khăn của thời kỳ đầu sau chiến tranh, giao lưu dân sự không phát triển; bởi vậy, từ đó cho đến những năm đầu thập niên 80, hầu như không có văn bản nào chứa đựng có hệ thống các quy định về dân sự được ban hành. Riêng toà án nhân dân tối cao, trong điều kiện quá thiếu công cụ để xử lý các tranh chấp liên quan đến việc thanh toán di sản (một loại giao dịch mà gần như bất kỳ người nào cũng có lúc phải xác lập), đã đúc kết các kinh nghiệm từ thực tiễn xét xử và tham khảo các giải pháp trong luật so sánh, để xây dựng một văn bản mang tính quy phạm về thừa kế áp dụng tạm (chủ yếu trong các toà án) trong lúc chờ đợi có luật viết.

3.2. Từ những năm 1980 đến nay

Với chính sách kinh tế thị trường, bắt đầu từ năm 1987, việc tích lũy của cải trong khu vực tư nhân được khuyến khích và, như là một hệ quả tất yếu, lưu thông dân sự phát triển nhanh. Nhằm kịp thời điều chỉnh các quan hệ tài sản càng lúc càng trở nên rất phong phú và đa

dạng trong dân cư, Nhà nước đã xây dựng trong thời gian ngắn hàng loạt quy phạm pháp luật dân sự, được ghi nhận trong nhiều văn bản lập pháp và lập quy: Luật hôn nhân và gia đình năm 1986; Luật đất đai năm 1987; Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987; Luật quốc tịch năm 1988; các Nghị định số 27, 28, 29 ngày 9/3/1998 và số 170 ngày 14/11/1988 về kinh tế ngoài quốc doanh; các Nghị định số 85 ngày 13/5/1988, số 200 và 201 ngày 28/12/1988 về sở hữu công nghiệp; Pháp lệnh về chuyển giao công nghệ năm 1988; Pháp lệnh sở hữu công nghiệp năm 1989; Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989; Pháp lệnh thừa kế năm 1990; Pháp lệnh nhà ở và Pháp lệnh hợp đồng dân sự năm 1991; Luật đất đai năm 1993; Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả năm 1994;...

Những kinh nghiệm từ việc áp dụng các văn bản nói trên đã được đúc kết; những nghiên cứu mang tính học thuật về di sản pháp luật dân sự Việt Nam, về tục lệ truyền thống, về luật so sánh,... cũng được thực hiện một cách nghiêm túc và khẩn trương, song song với việc áp dụng các văn bản này. Toàn bộ kết quả của những việc đó, cùng với các dự báo về khả năng phát triển của các quan hệ dân sự trong xã hội Việt Nam, đã đặt cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện dự án BLDS Việt Nam, được Quốc hội thông qua ngày 28/10/1995 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/1996. Có thể nói rằng BLDS 1995 là thành tựu lớn nhất của năm mươi năm xây dựng hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam hiện đại.

Sau mười năm áp dụng BLDS 1995; đến ngày 14 tháng 6 năm 2005 Quốc hội đã thông qua Bộ luật dân sự 2005 (có hiệu lực từ ngày 01/01/06) trên cơ sở kế thừa những nguyên tắc và nội dung cơ bản của BLDS 1995. Tuy còn nhiều bất cập nhưng BLDS 2005 đã thể hiện rõ hơn nguyên tắc tôn trọng sự tự thoả thuận và tự chịu trách nhiệm giữa các chủ thể trong quan hệ dân sự, giảm bớt sự can thiệp hành chính của Nhà nước vào các quan hệ dân sự.

BÀI 2 - CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT TRONG LUẬT DÂN SỰ

Luật dân sự Việt Nam hiện hành thừa nhận sự tồn tại của bốn loại chủ thể của quan hệ pháp luật: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình và tổ hợp tác.

CHƯƠNG 1 - CÁ NHÂN

Cá nhân luôn có lý lịch dân sự cho phép phân biệt với cá nhân khác. Sự tồn tại của tư cách chủ thể quan hệ pháp luật của cá nhân lệ thuộc vào một số điều kiện. Mặt khác, ta biết rằng trên nguyên tắc, mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật ngang nhau và, một cách ngoại lệ, một cá nhân nào đó có thể mất năng lực pháp luật trong một hoặc nhiều quan hệ đặc thù; trái lại, không phải mọi cá nhân đều có năng lực hành vi ngang nhau và có những cá nhân ở trong tình trạng mất năng lực hành vi tổng quát hoặc có năng lực hành vi không đầy đủ (gọi chung là không có năng lực hành vi): luật xác định rằng người không có năng lực hành vi cần được bảo vệ. Cuối cùng, có những cá nhân, dù đã thành niên, ở trong tình trạng suy đồi về nhân cách: luật nói rằng những cá nhân này có thể ở bị đặt trong tình trạng bị hạn chế năng lực hành vi để các giao dịch của họ được giám sát nhằm tránh gây thiệt hại cho người khác, cũng như để bảo vệ quyền lợi của chính họ trong điều kiện những quyền lợi ấy có nguy cơ bị hy sinh trong những giao dịch được xác lập một cách thiếu cân nhắc.

MỤC 1 - Lý lịch dân sự của cá nhân

Lý lịch dân sự của cá nhân hình thành từ ba yếu tố: họ và tên, hộ tịch, và nơi cư trú.

1. Họ và tên

1.1. Tổng quan

Khái niệm. Họ và tên là những từ ngữ dùng để chỉ định một người. Đó là danh xưng bắt buộc mà một cá nhân phải có để phân biệt với những cá nhân khác, nhất là khi được xướng lên ở nơi công cộng, để xưng hô trong hoạt động giao tiếp xã hội. Họ và tên bao gồm hai phần: *họ*, để chỉ định nguồn gốc gia đình; *tên* (đúng ra là tên và chữ lót hoặc chữ đệm), để chỉ định một người không phải là một người khác. Tất nhiên, chỉ họ và tên thôi chưa đủ để phân biệt các cá nhân trong tất cả mọi trường hợp; nhưng rõ ràng, trong hầu hết các quá trình giao tiếp phổ thông thực hiện trong khuôn khổ cuộc sống hàng ngày, họ và tên là công cụ phân biệt hữu hiệu nhất.

Họ và tên. Bí danh. Bút danh. Nghệ danh. Biệt Danh. BLDS có nhắc đến bí danh, bút danh của cá nhân, nhưng không định nghĩa các cụm từ này. Các định nghĩa liên quan trong các từ điển thông dụng lại khá ngắn gọn[1].

- Bí danh: là tên dùng thay tên thật để giữ bí mật. Bí mật, hiểu theo nghĩa rộng nhất, là tình trạng một người được che giấu tung tích không chỉ đối với nhà chức trách hoặc với đối phương, kẻ thù địch trong quan hệ chính trị, quân sự, ngoại giao, mà cả đối với những đối tác bình thường trong giao tiếp xã hội.
- Bút danh: là tên ghi vào tác phẩm, bài viết, dùng làm tên tác giả. Nói chung, gọi là bút danh, tên mà một người sử dụng trong quá trình hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật, dùng để xác định tác giả của tác phẩm văn học, nghệ thuật được tạo ra.
- Biệt danh: là tên riêng khác với tên vốn có. Nguồn gốc của biệt danh khá đa dạng. Có những người mang một đặc điểm về ngoại hình (Hoa Béo, Hùng Còi) hoặc liên quan đến một chức năng nào đó của một bộ phận cơ thể (Dũng Ngọng, Hoàng Lé); có một biệt tài nào đó (Xuân thiện xạ) , làm một nghề nào đó (Tâm Hớt Tóc); xuất xứ từ một nơi chốn nào đó (Trung

[1] Xem, ví dụ, Trung tâm ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam-Bộ giáo dục và đào tạo, Đại từ điển tiếng Việt, nxb Văn hoá thông tin, 1998. Các định nghĩa bí danh, bút danh, biệt danh ghi nhận trong tập sách này được lấy ra từ quyển Từ điển đó.

Huế), một vùng miền nào đó (Cường Bắc); … Trong trường hợp sử dụng biệt danh trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tên được sử dụng được gọi là nghệ danh[2], ví dụ, nghệ danh của ca sĩ, diễn viên,…

Bất kỳ người nào cũng phải có họ và tên, trong khi không phải ai cũng có bí danh, bút danh, biệt danh. Hơn nữa việc đặt họ và tên chịu sự chi phối của các quy tắc được ghi nhận cả trong luật và trong tục lệ, và được đăng ký bắt buộc trong các chứng thư hộ tịch; trong khi việc đặt bí danh, bút danh, biệt danh thường chỉ cần tuân theo các tập quán vùng hoặc nghề nghiệp, không được ghi trong chứng thư khai sinh, và không bắt buộc ghi trong các chứng thư hộ tịch khác[3]. Bí danh, bút danh, biệt danh trong luật Việt Nam cũng có thể được bảo vệ, nhưng chế độ bảo vệ không được rõ ràng lắm
trong khung cảnh luật thực định. Tất nhiên, để được hưởng sự bảo vệ của luật, bí danh, bút danh, biệt danh phải thoả mãn một số điều kiện, đặc biệt là các điều kiện về đạo đức, thẩm mỹ: không không có quy định rõ ràng của luật, có thể thừa nhận rằng luật không bảo vệ những bí danh, bút danh, biệt danh không phù hợp với đạo đức hoặc thuần phong mỹ tục.

Luật về họ và tên. Luật về họ và tên là tập hợp các quy tắc chi phối việc đặt, thay đổi, sử dụng và bảo vệ họ và tên. Ở hầu như tất cả các nước, luật về họ và tên chủ yếu mang tính chất luật tục lệ. Tuy nhiên, người làm luật ở các nước tiền tiến có xu hướng can thiệp ngày càng sâu vào việc hoàn thiện pháp luật về họ và tên, đặc biệt về phần liên quan đến việc đặt, thay đổi và bảo vệ họ và tên. Lý do của sự can thiệp này khá đa dạng: họ và tên càng lúc càng trở nên cần thiết với tư cách là một công cụ xác định lý lịch cá nhân trong thời đại bùng nổ thông tin; họ và tên không chỉ là các giá trị đạo đức mà còn có xu hướng trở thành một giá trị tài sản;…

Ở Việt Nam, luật về họ và tên cũng mang nặng dấu ấn của tục lệ. Luật viết, về phần mình, hình như lại có xu hướng phát triển ngược lại so với các nước tiền tiến. Các quy định về họ và tên xuất hiện khá nhiều trong BLDS năm 1995, nhưng BLDS năm 2005 đã cắt bỏ một số quy tắc quan trọng liên quan đến họ và tên và chỉ giữ lại một vài quy tắc mang tính nguyên tắc trong khuôn khổ xác định nội dung của hệ thống quyền nhân
thân[4]. Đặc biệt, vấn đề đặt họ và tên được thực hiện như thế nào bị bỏ ngỏ trong luật thực định.

1.2. Đặt họ và tên

Đặt họ và tên là một quyền đồng thời là một nghĩa vụ đối với mỗi cá nhân. Việc đặt tên chịu sự chi phối của những nguyên tắc riêng so với việc đặt họ.

1.2.1. Quyền và nghĩa vụ được đặt họ và tên

Mỗi người có quyền có họ và tên. Nguyên tắc này được chính thức thừa nhận trong luật viết (BLDS Điều 26 khoản 1). Quyền có họ và tên được hiểu như quyền được gọi, được xưng hô, quyền tự xưng bằng họ và tên, trong quan hệ với người khác, quyền được phân biệt của một cá nhân với các cá nhân khác. Để thực thi quyền đó, cá nhân tự xưng bằng họ tên của mình trong các hoạt động giao tiếp xã hội; viết và ký tên của mình trong các chứng thư pháp lý. Việc sử dụng họ và tên còn được thực hiện trong cuộc sống dân sự phổ thông, không mang tính pháp lý, như trong quan hệ gia đình, quan hệ bè bạn, quan hệ xã giao

Quyền có họ và tên không mất đi do thời hiệu, cũng không được xác lập vĩnh viễn do thời hiệu. Một người không sử dụng họ và tên của mình một cách liên tục trong thời gian dài vẫn bảo tồn đầy đủ quyền có họ và tên không được sử dụng đó[4]. Việc một người sử dụng

---

[2] Nghệ danh được dùng không chỉ trong hoạt động nghệ thuật mà cả trong các hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi kỹ năng, kỹ xảo. Ví dụ, nghệ nhân tạo hình hoa kiểng, nghệ nhân nuôi cá kiểng,…

[3] Trong các mẫu lý lịch thường có mục khai bí danh, bút danh, biệt danh. Tuy nhiên, nếu người có bí danh, bút danh, biệt danh không khai, thì không nhất thiết bị coi là khai không trung thực các chi tiết về lý lịch của mình.

Về việc sử dụng bút danh, bí danh của người nổi tiếng: xem

[4] Việc không sử dụng họ tên thật một cách liên tục trong thời gian dài có thể xảy ra trong trường hợp một người được phép sử dụng bí danh hoặc bút danh của mình trong tất cả các lĩnh vực của đời sống pháp lý

họ và tên không phải là thật của mình liên tục trong một thời gian dài không thể làm cho họ và tên đó trở thành họ và tên thật.

Không chỉ có quyền có họ và tên, mỗi người còn có quyền đối với họ và tên của mình. Trong chừng mực nào đó, quyền đối với họ và tên có những đặc điểm của quyền sở hữu[5]: người có một họ và tên có thể yêu cầu được bảo vệ, trong trường hợp họ và tên của mình bị một người khác sử dụng. Họ và tên còn được bảo vệ như những giá trị tinh thần: người có một họ và tên có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trong trường hợp họ và tên của mình bị bôi nhọ. Tất cả những vấn đề này sẽ được xem xét chi tiết trong khuôn khổ các phân tích liên quan đến quyền nhân thân.

Mỗi người có nghĩa vụ có họ tên. Tương ứng với quyền có họ và tên, mỗi người có nghĩa vụ có họ và tên. Nghĩa vụ có họ và tên được xác lập chủ yếu trong mối quan hệ giữa cá nhân và Nhà nước: cá nhân phải có họ và tên, vì điều đó cần thiết cho việc quản lý dân cư, cho việc quản lý hộ tịch và lý lịch tư pháp của cá nhân.

Như đã nói, họ tên của một người là công cụ phân biệt người đó với những người người khác. Việc phân biệt con người, về phần mình, là một trong những điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và vận hành của xã hội có tổ chức[6]. Sự phân biệt chỉ có thể được thực hiện một khi mỗi người có họ và tên xác định. Bởi vậy, mỗi người có trách nhiệm mang họ và tên.

Họ tên mà một người có nghĩa vụ phải mang, hiểu theo nghĩa rộng nhất bao gồm họ tên thật, bí danh, biệt danh, bút danh, thậm chí,… họ tên giả.

Họ tên thật và họ tên giả. Những khái niệm có vẻ rất thông thường, lại trở nên đặc biệt phức tạp khi được xây dựng ở góc độ pháp lý. Họ tên thật là gì ? Theo BLDS Điều 26 khoản 1, họ tên của một người được xác định theo họ tên khai sinh của người đó. Vậy có nghĩa rằng họ tên thật của một người là họ tên được ghi nhận trên giấy khai sinh của người này. Điều 26 khoản 2 quy định rằng cá nhân xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự theo họ tên của mình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Điều này cho phép nghĩ rằng việc ghi nhận họ và tên của một người trên giấy khai sinh mang ý nghĩa của việc Nhà nước (tức là pháp luật) công nhận việc đương sự mang họ và tên ấy.

Tóm lại, họ và tên thật của một người là họ và tên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và được ghi nhận trên giấy khai sinh của người đó. Áp dụng phương pháp suy lý ngược đối với định nghĩa đó, ta xây dựng định nghĩa về họ và tên giả: đó là họ và tên không được ghi nhận trên giấy khai sinh hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Cần nhấn mạnh rằng họ và tên giả trước hết phải là họ và tên, nghĩa là một cụm từ dùng để xưng hô có cấu trúc của họ và tên. Nếu một người có giấy khai sinh, thì có thể biết trong trường hợp người đó không sử dụng họ tên thật. Còn nếu một người không có giấy khai sinh, việc xác định họ tên thật, họ tên giả của người đó sẽ rất khó khăn trong khung cảnh cũa luật thực định, do khái niệm "họ và tên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận" trở nên mập mờ trong trường hợp này[7].

Sử dụng họ và tên thật. Nhắc lại rằng theo BLDS Điều 26 khoản 2, cá nhân xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận. Thực ra, cá nhân có nghĩa vụ sử dụng họ và tên thật của mình không chỉ trong việc xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự. Cá nhân chỉ được phép sử dụng họ và tên khác, không phải là họ và tên được ghi trong chứng thư khai sinh, trong những trường hợp mà luật không cấm. Đặc biệt, họ và tên thật phải được sử dụng trong các giấy tờ giao dịch với cơ quan Nhà nước.

Song, nguyên tắc sử dụng họ và tên thật, được thiết lập như trên, không cứng nhắc. Tục lệ Việt Nam thừa nhận rằng người phụ nữ có chồng sẽ mang họ và tên chồng trong quan hệ với người ngoài gia đình. Tục lệ này có nguồn gốc trong chế độ phụ quyền áp dụng đối

---

[5] Nhưng khác với quyền sở hữu, quyền đối với họ và tên không thể chuyển nhượng

[6] Các khái niệm chủ thể của quyền, chủ thể của nghĩa vụ sẽ trở nên vô nghĩa nếu tất cả mọi người đều là những cá thể cùng loại, có thể thay thế cho nhau.

[7] Dẫu sao, vấn đề càng ngày càng mất đi ý nghĩa thực tiễn, do số "người không có giấy khai sinh" càng ngày càng giảm.

với gia đình Việt Nam cổ xưa: người cha trong gia đình là người duy nhất có quyền đại diện cho gia đình trước người thứ ba[8]. Tục lệ hiện đại không còn coi việc người vợ mang tên chồng như là một nghĩa vụ, nhưng tiếp tục thừa nhận quyền của người vợ sử dụng tên chồng trong các giao dịch xác lập với người ngoài gia đình. Có trường hợp người vợ mang tên chồng cả khi tham gia vào các hoạt động chính trị hoặc các hoạt động của bộ máy Nhà nước, chứ không chỉ khi xác lập các giao dịch dân sự hoặc thương mại. Một khi người phụ nữ được xã hội biết đến dưới họ tên chồng nhiều hơn dưới họ tên thật, thì tục lệ chấp nhận rằng họ tên chồng cũng là họ tên thật của người phụ nữ đó trong quan hệ xã hội. Trong một số trường hợp đặc biệt, người phụ nữ nổi tiếng dưới tên chồng có quyền xác lập các giao dịch pháp lý dưới tên đó.

Sử dụng họ tên giả. Cá nhân có nghĩa vụ có họ tên và phải sử dụng họ tên thật của mình trong các trường hợp do pháp luật quy định. Vậy có nghĩa rằng cá nhân có quyền sử dụng họ tên giả trong tất cả các trường hợp mà pháp luật không buộc sử dụng họ tên thật. Nói cách khác, cá nhân có quyền tự do sử dụng họ tên giả, trừ các trường hợp pháp luật buộc sử dụng tên thật.

Các trường hợp sử dụng tên giả mang tính chất vi phạm pháp luật được ghi nhận chủ yếu trong luật hình sự. Một trong những ví dụ điển hình là trường hợp sử dụng giấy tờ tuỳ thân không phải của mình trong các giao dịch có tính pháp lý[9]. Cũng gọi là sử dụng tên giả mang tính chất vi phạm pháp luật, việc một người khai một tên khác không phải là tên khai sinh của mình, như là tên thật, trong các giấy tờ giao dịch mà việc khai họ và tên thật là cần thiết để xác định lai lịch của chủ thể quyền hoặc chủ thể nghĩa vụ trong một quan hệ pháp luật.

Các trường hợp sử dụng tên giả không có tính chất vi phạm pháp luật không thể được liệt kê trong một danh sách, do hiệu lực của quyền tự do sử dụng họ tên giả. Chắc chắn, cá nhân có quyền sử dụng họ và tên giả trong tất cả các giao dịch không mang tính pháp lý: quan hệ bè bạn, quan hệ yêu đương, giao tiếp mang tính chất qua đường giữa những người không quen biết;…Thậm chí, trong các giao dịch mang tính pháp lý, việc sử dụng tên giả cũng có thể được thực một cách hợp pháp một khi người giao dịch có nghĩa vụ khai họ tên, nhưng người cùng giao dịch lại không có quyền kiểm tra tính xác thực của lời khai đó[10].

Sử dụng bí danh, bút danh của người nổi tiếng. Trong chừng mực nào đó, ta nói rằng sử dụng bí danh, bút danh,… cũng chỉ là những trường hợp đặc thù của việc sử dụng họ tên giả. Có những nhân vật được xã hội nhận biết bằng bí danh, bút danh nhiều hơn bằng họ và tên thật. Trong trường hợp này, luật (đúng ra là thực tiễn áp dụng pháp luật) cho phép cá nhân sử dụng bí danh, bút danh khi thực hiện các hoạt động trong những lĩnh vực mà do những hoạt động trong lĩnh vực đó, đương sự trở nên nổi tiếng dưới bí danh, bút danh của mình, bao gồm cả các hoạt động mang tính giao dịch pháp lý. Ví dụ: nhà hoạt động chính trị, nhà hoạt động xã hội, khi giữ một chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước hoặc trong các thiết chế chính trị, xã hội, có thể ký bí danh, bút danh của mình trong văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản giao dịch chính thức của tổ chức.

Không sử dụng họ tên. Việc sử dụng họ tên được coi là một nghĩa vụ trong các trường hợp mà danh tính của cá nhân cần được làm rõ. Điều đó cũng có nghĩa rằng trong các trường hợp không bị ràng buộc vào một nghĩa vụ pháp lý nào, cá nhân có quyền giao dịch mà không cần làm rõ danh tính của mình. Ví dụ điển hình là trường hợp tặng cho quỹ từ thiện của người không muốn nêu họ tên.

---

[8] Ở Pháp, việc phụ nữ có chồng mang họ của chồng thực sự là một quan hệ pháp luật và được chi phối bằng các quy tắc rành mạch trong luật viết.: xem BLDS Pháp

[9] Nếu giấy tờ là thật (nghĩa là được cơ quan có thẩm quyền cấp cho một người nào đó đang tồn tại và đủ điều kiện để nhận và sử dụng giấy tờ đó) nhưng người sử dụng giấy tờ không phải là người được cấp giấy tờ đó, thì ta có trường hợp mạo danh; nếu giấy tờ không được cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc cơ quan cấp có thẩm quyền nhưng người được cấp lại không đủ điều kiện để nhận và sử dụng giấy tờ đó, thì ta có trường hợp sử dụng giấy tờ giả.

[10] Ví dụ, khi nộp tiền vào một tài khoản tại Ngân hàng, người nộp thường có thể ghi một họ tên nào đó bất kỳ ở cột họ tên người nộp; ngân hàng không kiểm tra lai lịch người nộp, do không có quyền đó.

Suy cho cùng, chính việc giao dịch mà không sử dụng họ tên lại được cá nhân thực hiện trong cuộc sống hàng ngày nhiều hơn các giao dịch cần sử dụng họ tên. Có thể hình dung: khi vào siêu thị mua hàng, gọi taxi để di chuyển, vào hàng quán để ăn uống,…, cá nhân có thể hoàn toàn vô danh đối với người bán hàng, người lái taxi, dù các giao dịch được xác lập vẫn có đầy đủ tính pháp lý và vẫn phát sinh hiệu lực: người mua, người yêu cầu dịch vụ trả tiền và người bán, người cung ứng dịch vụ giao hàng hoặc thực hiện dịch vụ. Nếu giao dịch diễn ra suôn sẻ, các bên có thể không bao giờ (và cũng không cần) biết rõ lai lịch của nhau. Nói chung, cá nhân có quyền tự do không để lộ danh tính của mình không các mối quan hệ mang tính kết ước hoặc trong việc công bố một tác phẩm, miễn là việc đó không gây phương hại đến lợi ích chung và lợi ích chính đáng của người khác.

1.2.2. Đặt họ

Cơ sở của việc đặt họ: quan hệ cha mẹ-con. Theo quy ước truyền thống ở tất cả các nềnm văn hoá pháp lý, họ, trên nguyên tắc, là dấu hiệu của gia đình. Bởi vậy, việc đặt họ cho một người dựa vào việc trả lời câu hỏi: người này là con của ai ? Do cơ sở của việc đặt họ là quan hệ cha mẹ-con mà lai lịch của cha và mẹ là một phần nội dung giấy khai sinh của cá nhân.

Tục lệ: nguyên tắc lấy họ cha. Cá nhân, khi sinh ra, được mang họ cha. Quy tắc này được thiết lập ở Việt Nam không phải trong luật viết mà trong tục lệ. Không thể xác định thời điểm chính xác thời điểm mà việc con mang họ cha trở thành quy tắc. Tuy nhiên, có thể coi đây là một trong những hệ quả cơ bản của sự thống trị của mô hình gia đình tộc họ-phụ hệ trong xã hội Việt Nam cổ xưa[11]: gia đình tộc họ-phụ hệ có cha chung và việc mỗi thành viên gia đình mang họ cha là biểu hiện của nguồn gốc chung
của các thành viên đó. Tục lệ lấy họ cha được thừa nhận ở tất cả các xã hội áp dụng chế độ gia đình phụ hệ.

Trong một số cộng đồng dân tộc ít người ở Việt Nam có thể tồn tại tục lệ cho con lấy họ mẹ, tương ứng với sự thống trị của chế độ mẫu hệ. Dẫu sao, tục lệ lấy họ mẹ không phổ biến; điều đó có nghĩa rằng tục lệ lấy họ cha mang tính nguyên tắc.

Do nguyên tắc lấy họ cha mà: 1 - Tất cả các con cùng cha đều có cùng một họ; 2- Họ được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác bởi những người có giới tính nam. Con gái cũng mang họ cha, nhưng không thể chuyển giao họ đó cho con trai của mình, nếu không có thỏa thuận khác giữa cha và mẹ của đứa con trai đó.

Luật. Trong BLDS năm 1995, nguyên tắc lấy họ cha không được xếp vào nhóm các quy phạm của luật mệnh lệnh. Họ của trẻ sơ sinh là họ của người cha hoặc họ của người mẹ theo tập quán hoặc theo thoả thuận của cha và mẹ (Điều 55 khoản 1)[13]. Trong trường hợp không xác định được người cha, thì họ của trẻ sơ sinh là họ của người mẹ (cùng điều luật). Quy tắc sau này cho phép nghĩ rằng trong trường hợp xác định được người cha, thì trẻ sơ sinh sẽ ưu tiên mang họ cha. Ta nói rằng luật có xu hướng tôn trọng sự thống trị của tục lệ trong việc đặt họ của cá nhân.

BLDS năm 2005 loại bỏ các quy định về hộ tịch, do đó, không giải quyết vấn đề đặt tên[12]. Điều đáng tiếc là khi xây dựng và ban hành hệ thống quy định mới về hộ tịch vào cuối năm 2005 (nghĩa là sau khi BLDS mới được thông qua), Chính phủ cũng không đề cập đến đến chuyện đặt họ cho một người, đặc biệt là khi tiến hành thủ tục khai sinh. Hậu quả là, trong khung cảnh của luật viết, vấn đề đặt họ bị bỏ ngỏ.

Dẫu sao, hầu như không thể hình dung trường hợp con có cha, mẹ lại được khai sinh theo họ của một người thứ ba[13]. Mặt khác, tục lệ hiện đại vẫn đủ mạnh để áp đặt việc lấy họ cha cho hầu như tất cả các trường hợp con sinh ra trong giá thú. Thậm chí, trong các trường hợp cha và mẹ chỉ chung sống như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn, một khi các dấu hiệu của gia đình có đủ, thì con sinh ra cũng được khai sinh theo họ cha.

Đặt họ cho trẻ bị bỏ rơi. Không có quy định về cách đặt họ trong các trường hợp bình thường, luật hiện hành lại chú ý đến việc đặt họ trong trường hợp rất đặc biệt khi mà người cần được

---

[11] Xem, Bình luận khoa học Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, Tập I-Gia đình, nxb Trẻ TPHCM, 2002, số 13.

[12] Điều 55 khoản 1 của BLDS năm 1995 là điều luật được xây dựng trong khuôn khổ chế định hộ tịch.

[13] Người làm luật, khi quy định việc thay đổi họ và tên, có nêu trường hợp con mang họ cha muốn đổi sang họ mẹ và ngược lại. Điều đó cho thấy rằng họ của một người có cha và mẹ chỉ có thể là họ của cha hoặc họ của mẹ.

đặt họ là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 Điều 16 khoản 3, thì họ của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được ghi nhận trên giấy khai sinh theo đề nghị của người đi khai sinh[14]. Luật không có quy định gì đặc biệt về cách đề nghị của người đi khai sinh. Điều đó có nghĩa rằng việc đề nghị này chịu sự chi phối của tục lệ phổ biến tại vùng nơi việc khai sinh được thực hiện[15]: trẻ có thể mang họ của người đi khai sinh hoặc họ của đa số cư dân trong vùng hoặc thậm chí bất kỳ một họ nào đó do người khai sinh nghĩ ra, với điều kiện không gây phương hại đến lợi ích, danh dự, nhân phẩm của người khác. Tất nhiên, họ trong trường hợp này không phải là dấu hiệu của gia đình nơi xuất xứ của đương sự mà chỉ là thành phần bắt buộc phải có trong cơ cấu họ và tên của cá nhân theo quy định của pháp luật.

Đúng là nguyên tắc lấy họ cha không phải là quy phạm mệnh lệnh theo BLDS năm 1995; nhưng Điều 55 khoản 1 có vẻ muốn thiết lập một quy phạm mệnh lệnh khác, theo đó, con có cha và mẹ chỉ có thể mang họ cha hoặc họ mẹ chứ không thể mang họ của một người thứ ba.

1.2.3. Đặt tên

Tên ở Việt Nam đi sau họ và được sử dụng để xưng hô, cả trong quan hệ xã giao hoặc gia đình, bè bạn, và cả theo nghĩa nghiêm túc, trang trọng lẫn theo nghĩa thân mật[16].

Cấu tạo của tên. Tên của một người Việt Nam thường có hai bộ phận: tên và chữ đệm. Tên là bộ phận bắt buộc, cần có để làm cho họ và tên trở nên hoàn chỉnh; còn chữ đệm là bộ phận không bắt buộc. Thông thường, tên được cấu tạo bằng một từ; chữ đệm cũng vậy. Song, cũng có trường hợp tên có cấu tạo với hai thậm chí nhiều hơn hai từ, ví dụ, Thiên Thanh, Xuân Hương, Tài Em,...

1.2.3.1. Chọn tên

Nguyên tắc tự do đặt tên. Khác với họ (được đặt theo họ cha, họ mẹ hoặc theo quyết định của cơ quan hộ tịch, trong trường hợp khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi và không có người nhận nuôi), tên của cá nhân do người khai sinh cho cá nhân lựa chọn theo ý mình. Tục lệ có can thiệp vào việc đặt tên, còn luật viết chưa có quy định cụ thể ở điểm này. Thông thường, cá nhân được đặt tên lựa chọn giữa các tên thông dụng (Hùng, Dũng, Minh, Hồng, Tuyết,...). Một số tên chỉ phù hợp với một giới tính nhất định. Ví dụ, tên "Dũng", "Hùng" dành cho nam; "Đoan Trang", "Mỹ Dung" dành cho nữ[17]. Những tên lạ cũng có thể được chấp nhận. Có những tên rất buồn cười cũng được ghi nhận[18]. Nhưng, dù luật không

---

[14] Quy định này cũng được áp dụng trong trường hợp trẻ bị bỏ rơi và được khai sinh không phải là trẻ sơ sinh: Nghị định đã dẫn Điều 16 khoản 4. Người đi khai sinh, theo Nghị định, là cá nhân hoặc tổ chức đang tạm nuôi đứa trẻ.

Trước đây, Nghị định số 83-CP ngày 10/10/1998 về đăng ký và quản lý hộ tích quy định rằng trong trường hợp có người nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi, thì họ và tên của người nhận nuôi được ghi vào các ô dành cho cha, mẹ trong giấy khai sinh (Điều 21). Điều đó cho phép nghĩ rằng đứa trẻ mang họ của người nhận nuôi. Quy định này cũng được lấy lại trong Nghị định số 158 đã dẫn; tuy nhiên, trong điều kiện đã có quy định về trách nhiệm đặt họ cho trẻ của người đi khai sinh, quy định này không còn cho phép nghĩ rằng trẻ bị bỏ rơi và được nhận nuôi mang họ của người nuôi như trước. Tất nhiên, người nuôi có quyền yêu cầu cho trẻ được đổi sang họ của mình, nếu trẻ đã được khai sinh trước đó và đã mang một họ nào đó; nhưng đây là một thủ tục khác.

[15] Trong thực tiễn áp dụng pháp luật ở Pháp, họ trong trường hợp này sẽ được lựa chọn giữa các từ được dùng để đặt tên.

[16] Ở phương Tây, tên dùng để xưng hô thân mật; còn họ dùng để xưng hô theo nghi thức, theo phép lịch sự hoặc trong các quan hệ xã giao. Trong quan niệm Pháp, tên, nếu đứng cô lập không mang một nội hàm pháp lý nào: Cornu, sđd,

[17] Các tên thuộc "độc quyền" của nữ thường có ít nhất hai từ. Có những tên một từ rất nữ tính, nhưng sử dụng được cho nam, ví dụ, Phượng, Hạnh, Dung,…

[18] Một thanh niên ở Quảng Nam có họ tên đầy đủ là Mai Phạt Sáu Nghìn Rưỡi: Tuổi Trẻ, số ngày 07/7/2006.

Nguồn gốc của tên này khá đặc biệt: người cha, do sinh ra cậu thanh niên ấy, bị phạt hành chính về hành vi sinh nhiều con. Bức xúc, ông lấy luôn mức phạt đặt tên cho con. Câu chuyện đi vào ký ức, nhưng tên người lại cứ gắn

chính thức cấm, không thể đặt tên cho cá nhân bằng những từ dùng để chưởi rủa hoặc bằng những từ thuộc nhóm ngôn ngữ hạ cấp: khi nhận được những yêu cầu đặt tên như thế, viên chức hộ tịch có nhiều cách để từ chối đáp ứng thuận lợi.

Ngôn ngữ của tên. Tên được chấp nhận, trong khung cảnh của thực tiễn và tập quán hộ tịch, phải là tên bằng tiếng Việt, đối với người được khai sinh mang quốc tịch Việt Nam. Riêng người thuộc dân tộc thiểu số có thể mang tên phù hợp với ngôn ngữ của dân tộc mình; nhưng khi khai sinh, tên đó phải được phiên âm và viết bằng các chữ cái latinh.

Dẫu sao, không thể coi là trái pháp luật hoặc trái đạo đức một nguyện vọng đặt tên bằng tiếng nước ngoài, nhất là trong điều kiện người được khai sinh có mang dòng máu của dân tộc sử dụng ngôn ngữ có tên đó. Mặt khác, các tên có nguồn gốc nước ngoài nhưng đã được phiên âm hoàn chỉnh ra tiếng Việt cũng được coi là các tên Việt. Ví dụ, Giác (Jacques), Linh Côn (Lincohn),…

Người có quyền đặt tên. Luật hiện hành chỉ xác định người có quyền đặt tên trong trường hợp khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi (Nghị định số 158 ngày 27/12/2005 Điều 16 khoản 3). Tuy nhiên, quyền của cha mẹ đặt tên cho con được thừa nhận rộng rãi trong tục lệ và được người thực hành luật tôn trọng. Trên thực tế, quyền của cha mẹ đặt tên cho con được thực hiện thông qua vai trò của người khai sinh; tuy nhiên, nếu người đi khai sinh không phải là cha mẹ, thì việc đặt tên nói chung được đặt dưới sự kiểm soát của cha mẹ; người đi khai sinh thường chỉ khai tên của người được khai sinh theo yêu cầu của cha hoặc/và mẹ của người được khai sinh.

1.2.3.2. Chọn chữ đệm

Tục lệ về chữ đệm. Khác với việc đặt tên, việc đặt chữ đệm ở Việt Nam chịu sự chi phối khá rõ nét của tục lệ và các tục lệ này được người làm luật thừa nhận mặc nhiên.

Chữ đệm không đa dạng như tên. Có thể dẫn ra: văn, thị, xuân, ngọc, đình,… Cũng như tên, có chữ đệm chỉ được đặt cho người có giới tính phù hợp. Ví dụ, chữ "thị" được dùng để đặt cho nữ; chữ "văn" dùng để đặt cho nam. Có chữ đệm trung tính: xuân, ngọc, duy, thuỵ,…

Song, nói chữ đệm không đa dạng không có nghĩa rằng luật chỉ cho phép sử dụng các chữ đệm ghi nhận trên một danh sách do luật hoặc tục lệ thiết lập. Về mặt lý thuyết, chữ đệm có thể được đặt một cách tự do như tên; nhưng, con người tự nguyện giới hạn quyền tự do của mình bằng cách lựa chọn trong số các chữ đệm thông dụng, để tránh điều tiếng không hay có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của người được đặt tên. Trên thực tế, cũng có người sử dụng quyền tự do đặt chữ đệm một cách đầy cảm hứng. Có khá nhiều trường hợp người ta dùng tên làm chữ đệm, ví dụ, Nguyễn Dũng Nhân. Có trường hợp chữ đệm được lấy từ họ của mẹ trong điều kiện con mang họ cha, ví dụ, Trần Nguyễn, Lê Trần,… Có thể coi đó là những phá cách được chấp nhận đối với tục

lệ về chữ đệm. Tuy nhiên, sự phá cách có giới hạn của nó: không thể hình dung trường hợp nam mang chữ đệm "Thị"; nữ mang chữ đệm "Văn"[19]. Không loại trừ khả năng viên chức hộ tịch nhận được những yêu cầu kỳ dị của người khai sinh, liên quan đến việc đặt chữ đệm cho người được khai sinh; nhưng, cũng như đối với yêu cầu đặt tên, viên chức hộ tịch có cách để không phải đáp ứng các yêu cầu mà tính kỳ quái vượt quá giới hạn.

Ngôn ngữ của chữ đệm. Chữ đệm, trên nguyên tắc, cũng phải có nguồn gốc tiếng Việt hoặc tiếng của dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam. Một cách ngoại lệ, có những chữ đệm có nguồn gốc tiếng nước ngoài được Việt hoá cũng được thừa nhận. Chữ đệm cũng có thể không thanh lịch, nhưng phải ở mức độ thô thiển chấp nhận được.

Người đặt chữ đệm. Người đặt chữ đệm tất nhiên cũng là người đặt họ và tên cho người được khai sinh.

Chữ đệm của gia đình. Có những gia đình sử dụng thống nhất chữ đệm cho tất cả các thành viên của mình, ví dụ, Nguyễn Long, Phạm Gia, Trần Trọng. Khi đó, chữ đệm gắn với họ

---

chặt với người mang nó trong cuộc sống hàng ngày, như một cái gì đó rất khôi hài.

[19] Thế nhưng, "Thị" có thể là một tên nam và "Văn" là một tên nữ.

và trở thành dấu hiệu phân biệt thành viên của gia đình với những người khác cùng họ.

1.3. Thay đổi họ và tên

1.3.1. Thay đổi họ.

Các trường hợp. Theo khoản 1 Điều 29 BLDS 1995, việc thay đổi họ được cho phép trong những trường hợp sau đây:

1 - Theo yêu cầu của đương sự, mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

2 - Theo yêu cầu của cha, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ tên mà cha, mẹ đẻ đã đặt;

3 - Theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con; 4 - Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

5 - Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc từ nhỏ mà tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

6 - Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

BLDS năm 2005 giữ nguyên các trường hợp này, đồng thời ghi nhận thêm trường hợp đổi họ, tên do đã xác định lại giới tính (Điều 27 khoản 1 điểm e).

Nhận xét. Điều nhận xét đầu tiên là, dù luật không khẳng định rành mạch bằng một quy tắc viết, có thể thừa nhận nguyên tắc theo đó họ của cá nhân không thể thay đổi. Việc thay đổi họ chỉ được ghi nhận như các ngoại lệ trong các trường hợp do pháp luật quy định. Giải pháp này phù hợp với bản chất của họ - dấu hiệu của nguồn gốc gia đình. Cũng chính vì họ không thể thay đổi, trừ trường hợp được pháp luật cho phép, mà việc tự tiện thay đổi họ đồng nghĩa với việc sử dụng họ tên giả.

Mặt khác, việc thay đổi họ, trong những trường hợp được pháp luật dự kiến, chỉ được thực hiện trên cơ sở có yêu cầu của những người có liên quan chứ không bao giờ là hệ quả đương nhiên của một giao dịch hoặc một sự kiện pháp lý (ví dụ, nhận con nuôi)[20]. Điều chắc chắn là người có họ được thay đổi, trong điều kiện có đủ năng lực hành vi dân sự, phải đồng ý về việc thay đổi đó: không thể có sự thay đổi họ mang tính áp đặt[21]. Thậm chí, trong trường hợp người có họ cần được thay đổi chưa thành niên, thì sự đồng ý của người này là điều kiện bắt buộc, nếu người này đã đủ 9 tuổi trở lên (BLDS năm 2005 Điều 27 khoản 2).

- Trường hợp thứ nhất ghi trên, theo tập quán, chỉ được áp dụng đối với việc thay đổi tên: "họ" trước hết là một giá trị tinh thần, giá trị đạo đức; nói rằng mang một họ nào đó, thì sẽ bị mất danh dự... là một hành vi có tác dụng phủ nhận nguồn gốc và bị coi như phi đạo đức[22].
- Trường hợp xác định lại giới tính, hẳn đương sự cũng chỉ có quyền đổi tên chứ không có quyền đổi cả họ. Nói rõ hơn, thay đổi giới tính tự nó không thể là lý do để xin thay đổi họ.

Thủ tục. Khác với luật của nhiều nước, luật Việt Nam quy định thủ tục thay đổi họ trong khuôn khổ thay đổi nội dung chứng thư hộ tịch, chính xác hơn nữa là thay đổi nội dung giấy khai sinh[23]. Thủ tục thay đổi nội dung giấy khai sinh, về phần mình, là thủ tục thống nhất, được áp dụng chung cho tất cả các trường hợp xin thay đổi nội dung giấy khai sinh:

---

[20] Trong luật của Pháp, một khi được nuôi trọn (adoption plénière) người con nuôi đương nhiên mang họ của người nuôi.

[21] Luật không có quy định gì đặc biệt về trường hợp đổi họ cho người không có năng lực hành vi. Tuy nhiên, trong logic của sự việc, có thể thừa nhận rằng một khi các yếu tố của những trường hợp được dự kiến trong luật có đủ, thì người giám hộ của người không có năng lực hành vi có quyền yêu cầu đổi họ cho người được giám hộ. Người bị hạn chế năng lực hành vi, về phần mình, có vẻ có quyền tự mình xin thay đổi họ mà không cần sự đồng ý của người đại diện, bởi chế độ hạn chế năng lực hành vi trong luật Việt Nam chỉ chi phối các giao dịch liên quan đến tài sản của người bị hạn chế năng lực hành vi: xem số và kế tiếp.

[22] Về mặt lý thuyết có thể hình dung trường hợp con không mang họ của cha, mẹ ruột mà mang họ của một người khác, dù không phải do lưu lạc. Khi đó, việc thay đổi nhằm mục đích để cho con mang họ cha hoặc họ mẹ có thể được thực hiện với lý do được nêu trong trường hợp này.

[23] Trong luật của Pháp, việc thay đổi họ được tiến hành theo các thủ tục riêng, kết thúc bằng một bản án hoặc một quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi họ. Chính bản án hoặc quyết định ấy là cơ sở để tiến hành thủ tục cải chính chứng thư hộ tịch

không có thủ tục riêng đối với việc thay đổi họ và thủ tục riêng áp
dụng đối với một yêu cầu thay đổi nào đó khác. Thủ tục này được ghi nhận tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, sẽ được nghiên cứu sau.

1.3.2. Thay đổi tên

Các trường hợp. Như đã biết, BLDS năm 2005 (và cả BLDS năm 1995) không phân biệt các trường hợp thay đổi họ và các trường hợp thay đổi tên: Điều 27 khoản được áp dụng chung cho cả việc thay đổi họ và tên. Thực ra, việc thay đổi tên thường được yêu cầu trong trường hợp a của khoản 1 Điều 27 và có thể trong trường hợp thay đổi giới tính, dự kiến tại điểm e khoản 1 của Điều luật.

Việc xác định thế nào là tên gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người đó không phải là việc đơn giản. Chắc chắn, một tên đặt bằng một từ ngữ thô tục có thể khiến người mang tên đó cảm thấy tủi hổ và muốn rũ bỏ. Có trường hợp một người xuất thân từ một gia đình nghèo và mang một tên quê mùa hay buồn cười, nay thành đạt và giàu có, mong muốn thay đổi một tên khác phù hợp với thành phần xã hội của mình. Cũng có trường hợp một tên vốn bình thường, nhưng sau một sự kiện nào đó, lại trở thành biểu tượng của điều ác, điều xấu, khiến người có tên đó không muốn mang nó nữa[24]. Có tên chỉ thích hợp với một thời kỳ lịch sử nào đó; khi thời kỳ đó qua đi, thì tên trở nên cổ lỗ, không còn phù hợp với cuộc sống mới.

Trong trường hợp giới tính của một người thay đổi, việc đổi tên tỏ ra cần thiết,một khi tên được mang trước lúc thay đổi giới tính chỉ phù hợp với giới tính cũ. Việc đánh giá tính phù hợp hay không phù hợp của tên với giới tính hẳn phải dựa vào tục lệ đặt tên của vùng, địa phương nơi cư trú của người có tên đó. Ví dụ, ở miền Nam Việt Nam hầu như không có người nào thuộc giới tính nam mang tên Phượng; bởi vậy, một cô gái miền Nam tên Phượng, sau khi chuyển đổi giới tính, có lý do chính đáng để xin đổi một tên khác.

Trong các trường hợp còn lại, các yêu cầu thường chỉ dừng lại ở việc thay đổi họ. Tuy nhiên, có những người .

Người yêu cầu và thủ tục. Người yêu cầu thay đổi tên là chính đương sự hoặc cha mẹ hay người đại diện, trong trường hợp đương sự không có năng lực hành vi. Thủ tục thay đổi tên, trong khung cảnh của luật thực định, cũng được thực hiện giống như thủ tục thay đổi họ, nghĩa là trong khuôn khổ thủ tục thay đổi nội dung giấy khai sinh, sẽ được phân tích sau.

1.3.3. Hệ quả của việc thay đổi họ tên.

Không ảnh hưởng đến nhân thân. Tất nhiên, sau khi thay đổi họ tên, đương sự được quyền yêu cầu cải chính nội dung của các giấy tờ tuỳ thân của mình cho phù hợp với tên mới[25]. Việc thay đổi họ tên không có tác dụng làm thay đổi lai lịch, nhân thân của đương sự. Đơn giản, trước khi họ tên thay đổi, đương sự mang họ tên cũ; sau khi họ tên thay đổi, đương sự mang họ tên mới. Về mặt pháp lý, hai người, được chỉ định bằng hai họ tên khác nhau, chỉ là một.

Tất nhiên, sau ngày họ tên thay đổi, họ tên mới của đương sự trở thành họ tên thật[26] và đương sự có nghĩa vụ sử dụng họ và tên đó trong tất cả các trường hợp giao dịch mà theo quy định của pháp luật, đương sự phải sử dụng họ tên thật. Thế nhưng, "việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi. chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ tên cũ (BLDS năm 2005 Điều 27 khoản 3). Người có họ tên được thay đổi tiếp tục là chủ thể của các quan hệ xác lập dưới tên cũ và tiếp tục có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ ấy: người vay nợ của Ngân hàng, sau khi đổi họ, tên, tiếp tục là người có nghĩa vụ trả nợ vay đối với ngân hàng, dưới họ, tên mới. Ngay cả trong trường hợp các quan hệ pháp luật xác lập trước ngày thay đổi họ và tên đã chấm dứt, thì các quan hệ ấy vẫn tiếp tục gắn với người có

---

[24] Ví dụ, một người khác cùng tên thực hiện một tội ác ghê tởm đến mức cứ nhắc đến tên đó, thì mọi người lại nghĩ đến tội ác đó

[25] Chắc chắn, đương sự có quyền xin cải chính nội dung của các chứng thư hộ tịch và chứng minh thư, hộ chiếu của mình. Tuy nhiên, trong khung cảnh của luật thực định, không chắc đương sự có quyền yêu cầu thay đổi nội dung các giấy tờ khác gắn với nhân thân, ví dụ, bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận huân, huy chương,...

[26] Và, tương ứng, họ tên cũ của đương sự, nếu tiếp tục được sử dụng, bị coi là họ tên giả.

họ tên được thay đổi, như là một phần lịch sử của người đó[27].

2. Hộ tịch

Tình trạng nhân thân và chứng thư hộ tịch. Cá nhân được phân biệt với cá nhân khác bằng việc xác định những yếu tố tạo thành tình trạng nhân thân. Quan niệm cổ điển chỉ coi như chất liệu của tình trạng nhân thân những yếu tố gắn liền cá nhân với Nhà nước và gia đình: quốc tịch, quan hệ cha-con, mẹ-con và quan hệ vợ chồng. Trong quan niệm hiện đại, các yếu tố cấu thành tình trạng nhân thân rất đa dạng: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tôn giáo, tình trạng hôn nhân và gia đình, dân tộc, quốc tịch,...

Một số yếu tố cơ bản của tình trạng nhân thân được chính thức ghi nhận trong những giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập, gọi là chứng thư hộ tịch.

Khái niệm chứng thư hộ tịch. Đó là văn bản do cơ quan Nhà nước lập nhằm ghi nhận những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết. Ba loại chứng thư hộ tịch quan trọng nhất là giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và giấy chứng tử.

Ta lần lượt tìm hiểu tổ chức hệ thống hộ tịch, lập chứng thư hộ tịch, hiệu lực của chứng thư hộ tịch và cải chính hộ tịch.

2.1. Tổ chức hệ thống hộ tịch

Cơ quan hộ tịch. Theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/05 cơ quan hộ tịch trong luật Việt Nam hiện hành được phân thành ba nhóm: cơ quan quản lý, cơ quan quản lý và đăng ký và cơ quan giúp việc. Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao là các cơ quan quản lý hộ tịch. UBND cấp tỉnh là cơ quan quản lý hộ tịch trong phạm vi tỉnh và có trách nhiệm tiến hành việc đăng ký hộ tịch cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về hộ tịch. UBND cấp huyện là cơ quan quản lý và đăng ký hộ tịch trong phạm vi huyện. Sở Tư pháp và phòng Tư pháp
là cơ quan giúp việc cho UBND cấp mình trong công tác hộ tịch[28]. UBND cấp xã là cơ quan quản lý hộ tịch trong phạm vi xã và có trách nhiệm đăng ký hộ tịch cho người Việt Nam thường trú tại Việt nam theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Cơ quan lãnh sự là cơ quan quản lý hộ tịch trong phạm vi quản hạt lãnh sự và trách nhiệm đăng
ký hộ tịch cho cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ hộ tịch. Biểu mẫu, sổ đăng ký hộ tịch được lập theo mẫu thống nhất do Bộ Tư pháp quy định. Sổ hộ tịch phải được lưu trữ, bảo quản để sử dụng lâu dài; phục vụ cho hoạt động quản lý của Nhà nước. Mỗi loại việc hộ tịch phải được đăng ký vào 2 quyển sổ (đăng ký kép), 1 quyển lưu tại ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký hộ tịch; 1 quyển chuyển lưu tại ủy ban nhân dân cấp huyện. Những việc hộ tịch thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp và ủy ban nhân dân cấp huyện, thì chỉ đăng ký vào 1 quyển và lưu tại Sở Tư pháp và ủy ban nhân dân cấp huyện. Đối với sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thì chỉ cần lập 1 quyển và lưu tại ủy ban nhân dân cấp xã (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/05 Điều 70).

2.2. Lập chứng thư hộ tịch

2.2.1. Những người tham gia vào việc lập chứng thư hộ tịch

Người lập chứng thư hộ tịch. Người lập chứng thư hộ tịch là Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền đăng ký hộ tịch. Về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2007 quy định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ký giấy chứng nhận kết hôn, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, quyết định cho nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi; Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/05 quy định Giám đốc Sở tư pháp có thẩm quyền ký chứng thư hộ tịch như giấy khai

---

[27] Ví dụ, người đã từng đạt một thành tích thể thao dưới họ tên cũ tiếp tục được ghi nhận là người có thành tích đó, nhưng dướI một tên mới.

[28] Trên thực tế, ở cấp tỉnh, chính Sở tư pháp là cơ quan trực tiếp đăng ký hộ tịch; còn UBND là cơ quan quyết định (dưới danh nghĩa cơ quan đăng ký hộ tịch) việc cho hay không cho đăng ký.

sinh, giấy chứng tử,…
Cán bộ Tư pháp hộ tịch chịu trách nhiệm soạn thảo chứng thư hộ tịch do Chủ tịch UBND cấp xã ký; cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm soạn thảo chứng thư hộ tịch do Chủ tịch UBND cấp huyện ký; cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp chịu trách nhiệm soạn thảo chứng thư hộ tịch do Chủ tịch UBND cấp tỉnh và Giám đốc Sở tư pháp ký, đồng thời giúp ủy ban nhân dân cấp tương ứng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong đăng ký và quản lý hộ tịch.
Người khai. Người khai là người đến cơ quan đăng ký hộ tịch để xác nhận với người lập chứng thư hộ tịch về việc xảy ra sự kiện cần được ghi nhận bằng chứng thư hộ tịch. Trong việc đăng ký kết hôn, người khai là những người kết hôn. Trong việc khai sinh và khai tử, người khai là người thân thích của người có tên trong chứng thư hộ tịch hoặc một cơ quan, tổ chức có trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hộ tịch.
Người làm chứng. Vai trò của người làm chứng chỉ được ghi nhận trong thủ tục lập một vài loại chứng thư hộ tịch (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/05).
- *Làm chứng việc đăng ký khai sinh trong trường hợp trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế*.

- *Làm chứng việc khai tử cho người chết không rõ tung tích.* Đối với người chết trên phương tiện giao thông, thì người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông phải lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác nhận việc chết thay cho Giấy báo tử. Đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú, thì văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng thay cho Giấy báo tử.

Người làm chứng phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Nghị định đã dẫn, tức là phảphải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và biết rõ sự việc làm chứng. Người làm chứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của sự việc mà mình làm chứng.

2.2.2. Các quy định riêng về việc lập giấy khai sinh Khai việc sinh.
Người khai việc sinh, trên nguyên tắc, là cha, mẹ hoặc người thân thích của người được khai sinh (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP Điều 14). Trường hợp trẻ bị bỏ rơi, người hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP Điều 16 khoản 2)
Việc khai sinh phải được thực hiện trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh của trẻ (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP Điều 14). Trong trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, thì người hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh sau 30 ngày, kể từ ngày phát hiện mà không tìm được cha, mẹ (Nghị định đã dẫn Điều 16 khoản 2).
Trong trường hợp khai sinh quá hạn hoặc khai lại việc sinh, thì người phải khai vẫn là cha, mẹ, người thân thích, người đại diện theo pháp luật của người được khai sinh hoặc chính người được khai sinh, nếu người này có đủ năng lực hành vi.
Nơi đăng ký khai sinh (Nghị định đã dẫn Điều 13 và Điều 49). 1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp xã), nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.2. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.3. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó. 4. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha và mẹ là người nước ngoài, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ, nếu họ có yêu cầu. 5.Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người mẹ. 6.Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam, được thực hiện tại Sở Tư pháp, nơi cư trú của người mẹ hoặc người cha là

công dân Việt Nam.

Nội dung giấy khai sinh. Giấy khai sinh được lập theo mẫu do Bộ Tư pháp thống nhất quản lý việc phát hành. Ta chỉ lưu ý một vài điểm:

- Ngày sinh là ngày trẻ được sinh ra; trong trường hợp khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi và không rõ ngày sinh, thì ngày phát hiện trẻ được coi là ngày sinh (Nghị định đã dẫn Điều 21).
- Nơi sinh của trẻ bị bỏ rơi, trong trường hợp không thể được xác định, thì được quy ước là nơi lập biên bản về việc phát hiện trẻ bị bỏ rơi (Nghị định đã dẫn Điều 16 khoản 3).
- Phần khai về cha, mẹ của trẻ bị bỏ rơi được để trống (Điều 16). Trong trường hợp có người nhận trẻ làm con nuôi, thì tên của cha, mẹ nuôi được ghi vào phần khai về cha, mẹ; nhưng trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "cha, mẹ nuôi"; nội dung ghi chú này phải được giữ bí mật, chỉ những người có thẩm quyền mới được tìm hiểu[29] (cùng điều luật).

2.2.3. Các quy định riêng về việc lập giấy chứng tử

Khai việc tử. Người khai việc tử là người thân thích, chủ nhà hoặc cơ quan, tổ chức nơi có người chết (BLDS Điều 30). Thời hạn đi khai tử là 15 ngày, kể từ ngày chết (Nghị định đã dẫn Điều 20 khoản 1).Việc đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố là đã chết được thực hiện khi quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. Người yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là đã chết phải thực hiện việc đăng ký khai tử (Nghị định đã dẫn Điều 21 khoản 1). Người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử (Nghị định đã dẫn Điều 21 khoản 1)

Nội dung giấy chứng tử. Giấy báo tử phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người chết; giờ, ngày, tháng, năm chết; địa điểm chết và nguyên nhân chết (Nghị định đã dẫn Điều 22 khoản 1).

T**hẩm quyền cấp Giấy báo tử**. Đối với người chết tại bệnh viện hoặc tại cơ sở y tế, thì Giám đốc bệnh viện hoặc người phụ trách cơ sở y tế đó cấp Giấy báo tử; đối với người cư trú ở một nơi, nhưng chết ở một nơi khác, ngoài cơ sở y tế, thì ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó chết cấp Giấy báo tử; đối với người chết là quân nhân tại ngũ, công chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và những người được tập trung làm nhiệm vụ quân sự do các đơn vị quân đội trực tiếp quản lý, thì thủ trưởng đơn vị đó cấp Giấy báo tử; đối với người chết trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giam hoặc tại nơi tạm giữ, thì Thủ trưởng cơ quan nơi giam, giữ người đó cấp Giấy báo tử; đối với người chết tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục do ngành Công an quản lý, thì Thủ trưởng các cơ quan đó cấp Giấy báo tử; đối với người chết do thi hành án tử hình, thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp Giấy báo tử; trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết, thì quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật thay cho Giấy báo tử; trường hợp người chết có nghi vấn, thì văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên thay cho Giấy báo tử; đối với người chết trên phương tiện giao thông, thì người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông phải lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác nhận việc chết thay cho Giấy báo tử; đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú, thì văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng thay cho Giấy báo tử (Nghị định đã dẫn Điều 22 khoản 2).

Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử được cấp cho thân nhân người chết để đi khai tử. Trong trường hợp người chết không có thân nhân, thì Giấy báo tử được gửi cho ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai tử để ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký khai tử.

2.2.4. Các quy định riêng về việc lập giấy chứng nhận kết hôn

a. Khai đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam sống tại Việt Nam (Nghị định đã dẫn Điều 17, 18)

---

[29] Nếu hai người (tất nhiên là khác giới tính) cùng nhận một trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi, thì phải xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kết hôn khi lập khai sinh, bởi một người không thể là con nuôi của hai người trừ trường hợp là con nuôi của vợ chồng (Luật hôn nhân và gia đình Điều 68 khoản 3).

Thẩm quyền đăng ký kết hôn. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn. Trong trường hợp cả hai bên nam, nữ là công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, đã cắt hộ khẩu thường trú ở trong nước, thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú trước khi xuất cảnh của một trong hai bên nam, nữ.

Thủ tục đăng ký kết hôn. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó. Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, thì phải có xác nhận của Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó. Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì thủ trưởng đơn vị của người đó xác nhận tình trạng hôn nhân.Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc bằng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, thì ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

b. Khai đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Gọi là kết hôn có yếu tố nước ngoài, việc kết hôn giữa công dân Việt nam vối công dân nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà có một bên đang định cư ở nước ngoài, và giữa công dân nước ngoài đang sống tại Việt Nam với nhau (Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP)[30]. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp đối với hai bên nam, nữ để kiểm tra, làm rõ về sự tự nguyện kết hôn của họ, về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chung và mức độ hiểu biết về hoàn cảnh của nhau. Việc phỏng vấn phải được lập thành văn bản. Cán bộ phỏng vấn phải nêu rõ ý kiến đề xuất của mình và ký tên vào văn bản phỏng vấn;
- Niêm yết việc kết hôn trong 07 ngày liên tục tại trụ sở Sở Tư pháp, đồng thời có công văn đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn của bên đương sự là công dân Việt Nam, nơi thường trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thực hiện việc niêm yết. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết việc kết hôn trong 07 ngày liên tục tại trụ sở Uỷ ban, kể từ ngày nhận được công văn của Sở Tư pháp. Trong thời hạn này, nếu có khiếu nại, tố cáo hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về việc kết hôn thì Uỷ ban nhân dân cấp xã phải gửi văn bản báo cáo cho Sở Tư pháp;
- Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn. Trong trường hợp nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo đương sự kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp, kết hôn giả tạo, lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ, kết hôn vì mục đích trục lợi khác hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của đương sự hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, Sở Tư pháp tiến hành xác minh làm rõ. Trong trường hợp xét thấy vấn đề cần xác minh thuộc chức năng của cơ quan công an thì Sở tư pháp có công văn nêu rõ vấn đề cần xác minh, kèm theo một bộ hồ sơ đăng ký kết hôn gửi cơ quan Công an cùng cấp đề nghị xác minh.
- Báo cáo kết quả phỏng vấn các bên đương sự, thẩm tra hồ sơ kết hôn và đề xuất

[30] Các phân tích chi tiết về việc khai đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài sẽ được thực hiện trong khuôn khổ môn Luật gia đình I

ý kiến giải quyết việc đăng ký kết hôn, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, kèm theo 01 bộ hồ sơ đăng ký kết hôn.

Việc đăng ký kết hôn cũng bị từ chối, nếu kết quả phỏng vấn, thẩm tra, xác minh cho thấy việc kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp; kết hôn giả tạo không nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; kết hôn không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ hoặc vì mục đích trục lợi khác.

c. Nội dung giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn được lập theo mẫu do Bộ Tư pháp thống nhất quản lý việc phát hành. Ngày kết hôn là ngày tiến hành lễ đăng ký kết hôn tại UBND xã (ngày UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đối với việc kết hôn có yếu tố nước ngoài). Giấy chứng nhận kết hôn phải có chữ ký của các bên kết hôn.

2.3. Thay đổi, cải chính nội dung chứng thư hộ tịch

Khái niệm. Thay đội nội dung chứng thư hộ tịch là việc sửa đổi các ghi chép trong chứng thư đó, một khi có lý do chính đáng hoặc trong những trường hợp khác được pháp luật thừa nhận. Cải chính nội dung chứng thư hộ tịch là việc làm cho các chi tiết trong chứng thư phù hợp với sự thật hoặc hợp lý hơn.

Chứng thư hộ tịch được phép thay đổi, cải chính và nội dung thay đổi, cải chính được phép. Tương ứng với quyền thay đổi họ, tên (BLDS Điều 27), quyền xác định lại dân tộc (BLDS Điều 28), quyền xác định lại giới tính (BLDS Điều 36), Nghị định số 158/2005/NĐ-CP Điều 36 quy định phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch bao gồm:

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự.
- Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký.
- Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ luật Dân sự.
- Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính.
- Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.
- Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.

Người yêu cầu thay đổi, cải chính. Tất nhiên người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền tự mình yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch. Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP Điều 38 khoản 1).

Thẩm quyền thay đổi, cải chính. (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP Điều 37) Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi; ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.

Thủ tục thay đổi, cải chính. (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP Điều 37) Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính phải được ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

Việc bổ sung hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Nội dung bổ sung được ghi trực tiếp vào những cột, mục tương ứng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung. Cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh phải ghi rõ nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; họ, tên, chữ ký của người ghi bổ sung; ngày, tháng, năm bổ sung. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung.

Trong trường hợp nội dung Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh trước đây không có cột mục cần ghi bổ sung, thì nội dung bổ sung được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh.

Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại ủy ban nhân dân cấp huyện, thì ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc bổ sung.

Sau khi việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi, cải chính hoặc bổ sung.

Trong trường hợp nội dung bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ đã thay đổi do việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, thì ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con, căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ thực hiện việc điều chỉnh nội dung đó trong phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con cho phù hợp; nếu Sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu tại ủy ban nhân dân cấp huyện, thì ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.

2.4. Giá trị chứng minh của chứng thư hộ tịch

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP Điều 5 khoản 1 quy định: Giấy tờ hộ tịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật về hộ tịch là căn cứ pháp lý xác nhận sự kiện hộ tịch của cá nhân đó. Thực tiễn, về phần mình, cũng thừa nhận rằng chứng thư hộ tịch là bằng chứng về những việc đã được ghi nhận trong chứng thư đó: ngày sinh của một người được ghi trong giấy khai sinh là ngày sinh đích thực; việc một người được ghi tên trên giấy chứng tử cho phép tin rằng người có tên đó đã chết;… Tuy nhiên, các bằng chứng được thiết lập bằng chứng thư hộ tịch không phải là bằng chứng tuyệt đối, bởi, như ta đã biết, chứng thư hộ tịch có thể được cải chính hoặc thay đổi nội dung. Trong trường hợp có tranh cãi về tính xác thực của một ghi nhận nào đó trong giấy khai sinh, thì người bác

bỏ ghi nhận đó phải tìm cách chứng minh về tính không xác thực của nó[31].

3. Nơi cư trú

Sự cần thiết của việc xác định nơi cư trú. Hộ tịch giúp phân biệt một cá nhân với một cá nhân khác. Nhưng để xác lập và thực hiện các giao dịch với người khác, cá nhân phải ở trong tình trạng có thể được liên lạc. Cá nhân không liên lạc được không thể được coi là chủ thể hiện thực của quyền và nghĩa vụ pháp lý: người ta sẽ không biết làm thế nào gọi người đó đến để tiếp nhận việc thực hiện một nghĩa vụ hoặc để đáp ứng quyền yêu cầu của một người khác.

Trong quan niệm truyền thống, đời sống pháp lý của cá nhân nhất thiết phải gắn với một nơi chốn nào đó. Luật gọi nơi chốn đó là nơi cư trú. Chế định nơi cư trú là biện pháp định vị cá nhân trong không gian, về phương diện pháp lý. Nơi cư trú phải là một điểm cố định trên lãnh thổ chứ không thể là một điểm di động. Điều đó cũng có nghĩa rằng mỗi người chỉ có một nơi cư trú: một người có nơi cư trú tại nhiều hơn một điểm cố định coi như luôn di động giữa các điểm cố định đó.

Ta lần lượt nghiên cứu chức năng của nơi cư trú và cách xác định nơi cư trú.

3.1. Chức năng của nơi cư trú

Địa chỉ liên lạc của cá nhân và nơi lưu trữ các dữ kiện cơ bản về hộ tịch. Nơi cư trú theo nghĩa pháp lý không nhất thiết là nơi cư trú theo nghĩa vật chất. Con người có thể liên tục thay đổi nơi cư trú vật chất mà vẫn giữ cố định nơi cư trú pháp lý của mình.

Về phương diện công pháp, nơi cư trú giữ vai trò địa chỉ liên lạc giữa cá nhân với Nhà nước, cụ thể hơn, với các cơ quan Nhà nước: nhà chức trách thuế vụ gửi giấy báo thuế đến nơi cư trú của người chịu thuế; hội đồng bầu cử gửi thẻ cử tri đến nơi cư trú của cử tri; hội đồng nghĩa vụ quân sự gửi giấy triệu tập để khám sức khoẻ và lệnh gọi nhập ngũ đến nơi cư trú của người phải thi hành nghĩa vụ quân sự;...

Ở góc độ tư pháp, chức năng của nơi cư trú khá đa dạng:

- Thông thường, nơi cư trú đầu tiên của cá nhân, sau khi ra đời, cũng là nơi đăng ký khai sinh của cá nhân. Nơi đăng ký kết hôn là nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ; nới đăng ký khai tử là nơi cư trú cuối cùng của người chết; nơi cư trú của người xin thay đổi, cải chính hộ tịch là nơi đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch;... Một cách tổng quát, nơi cư trú của cá nhân là nơi mà người ta có thể thu thập các thông tin về hộ tịch của cá nhân.
- Trong trường hợp một nghĩa vụ tài sản có tính chất động sản được xác lập và các bên không có thoả thuận về nơi thực hiện nghĩa vụ, thì nơi này là nơi cư trú của người có quyền yêu cầu (BLDS Điều 284 khoản 2).
- Trong các tranh chấp dân sự, Toà án có thẩm quyền giải quyết là Toà án nơi cư trú của bị đơn, trừ trường hợp việc tranh chấp có liên quan đến bất động sản hoặc các bên tranh chấp có thoả thuận yêu cầu Toà án nơi cư trú của nguyên đơn giải quyết (Bộ luật tố tụng dân sự 2004 Điều 35 khoản 1).

3.2. Xác định nơi cư trú

Dựa vào các Điều từ 52 đến 57 BLDS và các Điều từ 12 đến 17 của Luật cư trú năm 2006 ta nói rằng có bốn cách xác định nơi cư trú: dựa vào quan hệ quản lý hành chính về trật tự xã hội, quan hệ gia đình, quan hệ nghề nghiệp và theo ý chí của đương sự.

3.2.1. Xác định nơi cư trú dựa vào quan hệ quản lý hành chính về trật tự xã hội

Theo BLDS Điều 52 khoản 1, nơi cư trú của một cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống. Điều 12 Luật cư trú cho rằng "Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà

---

[31] Trong luật của Pháp, các ghi nhận trong chứng thư hộ tịch mà được viên chức hộ tịch đích thân và trực tiếp kiểm chứng có tính xác thực và chỉ có thể bị bác bỏ thông qua thủ tục đăng cáo giả mạo (*inscription de faux*) rất phức tạp. Các ghi nhận khác trong chứng thư có giá trị chứng minh cho đến khi có bằng chứng ngược lại, nghĩa là trách nhiệm chứng minh, trong trường hợp có tranh cãi, thuộc về người nào không thừa nhận tính xác thực của các ghi nhân đó.

người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú. Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định trên thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống."

Quy tắc này có lẽ được áp dụng chủ yếu đối với người có đầy đủ năng lực hành vi hoặc từ đủ mười lăm tuổi trở lên và được phép có nơi cư trú riêng trong những trường hợp dự liệu tại các Điều 53 khoản 2 và 54 khoản 2 BLDS: người chưa thành niên dưới 15 tuổi có thể cư trú ở một nơi khác với nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ, nhưng luôn có nơi cư trú (theo luật) trùng với nơi cư trú của những người sau này.

3.2.2. Xác định nơi cư trú dựa vào quan hệ gia đình

Nơi cư trú của người chưa thành niên. Theo BLDS Điều 53 khoản 1, nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau, thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống. Trong trường hợp người chưa thành niên không có cha và mẹ, thì nơi cư trú của người này được xác định dựa theo các quy định về nơi cư trú của người được giám hộ. Nếu không có người giám hộ, thì hẳn phải xác định nơi cư trú của người chưa thành niên theo luật chung, nghĩa là dựa vào quan hệ quản lý hành chính về trật tự xã hội, đã được phân tích ở trên.

Người chưa thành niên từ đủ mười lăm tuổi trở lên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ, nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định (Điều 53 khoản 2). Nơi cư trú khác của người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên sẽ được xác định theo luật chung, dựa vào quan hệ quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi cư trú của người được giám hộ. Theo BLDS Điều 54 khoản 1, nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ. Và cũng như người chưa thành niên có cha hoặc mẹ, người được giám hộ từ đủ 15 tuổi trở lên có thể có nơi cư trú riêng so với người giám hộ, nếu được người sau này đồng ý hoặc pháp luật có quy định (Điều 50 khoản 2). Dù luật không nói rõ, người được giám hộ đủ 15 tuổi ở đây phải là người chưa thành niên: người thành niên được giám hộ là người mất năng lực hành vi và do đó, không có năng lực bày tỏ ý chí một cách hữu hiệu.

Nơi cư trú của vợ, chồng. Vợ, chồng có thể có nơi cư trú khác nhau, nếu có thoả thuận (BLDS Điều 55 đoạn 2). Điều đó có nghĩa rằng nếu không có thoả thuận, thì vợ, chồng coi như có cùng nơi cư trú. Điều 55 đoạn 1 nói rằng nơi cư trú của vợ, chồng là nơi vợ, chồng thường xuyên chung sống. Tổng hợp các quy tắc vừa nêu, ta có thêm một quy tắc nữa: nếu vợ, chồng không có nơi sống chung mà cũng không có sự thoả thuận rành mạch về việc sống riêng, thì giữa hai người coi như có sự thoả thuận mặc nhiên về việc xác lập nơi cư trú riêng và nơi cư trú của mỗi người trong trường hợp này cũng được xác định theo Điều 52 BLDS. Quy tắc sau cùng này cần thiết trong trường hợp vợ và chồng sống trong tình trạng ly thân thực tế mà không cắt đứt quan hệ hôn nhân.

3.2.3. Xác định nơi cư trú dựa vào các quan hệ nghề nghiệp

Nơi cư trú của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng. Ở góc độ nơi cư trú có hai loại quân nhân - quân nhân đang làm nghĩa vụ quân sự và sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp. Luật quy định rằng quân nhân đang làm nghĩa vụ quân sự có nơi cư trú tại nơi đóng quân (BLDS Điều 56 khoản 1); còn nơi cư trú của sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp là nơi người này thường xuyên sinh sống (Điều 56 khoản 2); chỉ khi nào không thể xác định nơi cư trú theo cách đó, thì sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp mới được coi là có nơi cư trú tại nơi đóng quân (cùng điều luật). Nơi cư trú của công nhân, viên chức quốc phòng được xác định tương tự như đối với quân nhân chuyên nghiệp (cùng điều luật).

Nơi cư trú của người làm nghề lưu động. Những người làm nghề lưu động, theo định nghĩa của luật, là những người hoạt động nghề nghiệp trên tàu, thuyền hoặc phương tiện hành nghề lưu động khác (xe vận tải đường dài, chẳng hạn). Nơi cư trú của những người này được xác định là nơi nơi thường xuyên sinh sống (Điều 57). Nếu không xác định được nơi cư trú theo cách đó, thì những người này coi như có nơi cư trú tại nơi đăng ký tàu, thuyền, phương tiện mà trên đó người này hành nghề lưu động (cùng điều luật).

MỤC 2 - Tư cách chủ thể quan hệ pháp luật của cá nhân

1. Khái niệm

Triết học. Nhân thân, như là một khái niệm của triết học luật, được hiểu là xu hướng của cá nhân trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật.. Xu hướng này hình thành một cách tự nhiên, không điều kiện và như nhau đối với tất cả mọi cá nhân, mọi thành viên trong xã hội có tổ chức.

Xã hội học. Nội dung xã hội học của nhân thân còn được gọi là thân phận của cá nhân. Thân phận được hiểu là các điều kiện chủ quan và khách quan mà trong những điều kiện ấy, cá nhân xác lập các quan hệ xã hội. Tham gia vào đời sống xã hội, mỗi cá nhân mang thân phận của mình. Thân phận ấy quyết định các khả năng hưởng quyền của cá nhân, thông qua việc lựa chọn loại hình giao dịch, đối tác giao dịch trong hoàn cảnh, điều kiện cho phép. Có thể hình dung: người nghèo chỉ mua xe đạp hoặc xe máy rẻ tiền và trở thành chủ sở hữu của xe đạp, xe máy rẻ tiền chứ không mua ô tô hoặc xe máy đắt tiền; người giàu có thể ra nước ngoài để học đại học, chứ không học trong nước; người có nhiều của cải có thể nghĩ đến việc định đoạt tài sản của mình sau khi chết bằng di chúc; người nghèo thường để lại gia tài khiêm tốn của mình cho những người thừa kế theo pháp luật; người mang thân phận con của một người khác là người thừa kế theo pháp luật của người sau này;..

Thân phận của mỗi người có thể thay đổi do tác động của các nỗ lực chủ quan (phấn đấu) hoặc của hoàn cảnh khách quan (may mắn hoặc xui xẻo); do giao dịch (được nhận làm con nuôi) hoặc do sự kiện pháp lý (khi người chồng chết, người vợ trở thành goá bụa).

Luật. Nhân thân, như là một khái niệm pháp lý, có thể được định nghĩa là tổng hợp các quan hệ pháp luật có tác dụng ghi nhận sự hiện hữu của một cá nhân trong cuộc sống pháp lý, với tư cách là chủ thể của quyền và nghĩa vụ pháp lý. Tư cách chủ thể của quyền và nghĩa vụ pháp lý, đến lượt mình, là điều kiện để cá nhân được hưởng và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể, đặc thù. Bởi vậy, ta nói rằng nhân thân của cá nhân là cơ sở của việc xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của cá nhân trong khuôn khổ pháp luật.

2. Xác lập nhân thân

Trong luật thực định Việt Nam, nhân thân được thừa nhận cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, tuổi tác, khả năng nhận thức, thành phần xã hội, địa vị xã hội, trình độ học vấn, tôn giáo,… Tất cả mọi người đều được pháp luật đối xử như nhau về phương diện xác lập nhân thân. Nội dung của nhân thân có thể khác nhau tùy theo chủ thể, do sự khác biệt về đặc điểm của hoàn cảnh, điều kiện tồn tại và phát triển của mỗi người, như đã biết; nhưng, điều chắc chắn là mỗi người đều có nhân thân của riêng mình.

2.1. Thời gian tồn tại của nhân thân

Nguyên tắc. Được thừa nhận như nhau cho tất cả mọi người, nhân thân của cá nhân gắn liền với cuộc sống của cá nhân đó. Bất kỳ người nào đến với thế giới này đều trở thành chủ thể của luật dân sự[32]. Bởi vậy, một người có nhân thân khi được sinh ra và chấm dứt nhân thân khi chết. Cuộc sống sinh học của con người đòi hỏi được nhìn nhận về mặt pháp lý và sự nhìn nhận đó biến cuộc sống sinh học thành cuộc sống pháp lý.

Trong một số trường hợp đặc thù, cuộc sống của cá nhân bắt đầu không phải từ lúc cá nhân được sinh ra mà ngay từ lúc cá nhân thành thai, tất nhiên với điều kiện sinh ra và còn sống[33].

---

[32] G.Cornu, Droit civil-Introduction. Les personnes, Les biens, Montchrestien, 1990, số 459.

[33] Ví dụ, theo pháp luật thừa kế, người chỉ mới thành thai ở thời điểm mở thừa kế cũng có thể là người thừa kế

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng nhân thân của cá nhân tồn tại một cách đầy đủ trước khi cá nhân sinh ra. Theo một câu ngạn ngữ trong luật học La Mã, *infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur* (trẻ con thành thai được coi như đã sinh ra, một khi điều đó có lợi cho trẻ đó), việc ghi nhận sự tồn tại của cá nhân ngay từ lúc thành thai chỉ được thực hiện trong những trường hợp được pháp luật dự kiến và chỉ có ý nghĩa phục vụ cho việc giải quyết một hoặc một số vấn đề pháp lý đặc thù phát sinh trong những trường hợp đó (thừa kế di sản của một người; suy đoán một người là con trong giá thú của một cặp vợ chồng;…). Nếu vấn đề pháp lý đặc thù không phát sinh thì vấn đề nhân thân của người mới thành thai cũng không được đặt ra.

2.2. Nhân thân và năng lực

Nhân thân và năng lực pháp luật. Theo BLDS Điều 14 khoản 1, năng lực pháp luật của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Điều 14 khoản 2 thừa nhận rằng mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật như nhau. Thực ra, năng lực pháp luật của các cá nhân không như nhau. Ví dụ, trong luật Việt Nam hiện hành, người thuộc giới tính nam mà chưa được 20 tuổi không thể có khả năng có quyền kết hôn trong bất kỳ trường hợp nào và do đó, không thể được coi là có năng
lực pháp luật kết hôn; trong khi tất cả những người trên 20 tuổi, trên nguyên tắc, đều có năng lực pháp luật kết hôn[34]. Đáng lý ra, luật phải quy định rằng tất cả các cá nhân đều có nhân thân pháp lý như nhau, chứ không phải năng lực pháp luật như nhau. sự tồn tại của nhân thân là cơ sở của việc xác lập năng lực pháp luật; còn năng lực pháp luật có được xác lập hay không, lại lệ thuộc vào việc cá nhân có hay không có đủ các điều kiện do pháp luật quy định để được hưởng một quyền nào đó.

Cần nhấn mạnh rằng cả trong trường hợp cá nhân không có năng lực pháp luật hoặc trong trường hợp năng lực pháp luật bị tước bỏ đối với một hoặc nhiều quyền nào đó, thì nhân thân vẫn tồn tại một cách trọn vẹn; bởi nhân thân chỉ là thiên hướng, là tiềm năng có quyền chứ chưa phải là khả năng có quyền. Nói cách khác, *nhân thân là điều kiện để có năng lực pháp luật và điều kiện này được thiết lập như nhau đối với tất cả các cá nhân*. Có lẽ, do muốn đồng hoá hai khái niệm nhân thân và năng lực pháp luật mà các tác giả BLDS năm 2005 đã thừa nhận rằng năng lực pháp luật của các cá nhân là như nhau. Dẫu sao, tình trạng có những người không có năng lực pháp luật đối
với một quyền nào đó, trong khi những người khác lại có năng lực pháp luật đối với quyền đó lại cũng được ghi nhận trong chính BLDS, như ta đã biết.

Mặt khác, tình trạng mất năng lực pháp luật luôn luôn có tính chất cá biệt và chỉ được ghi nhận trong các trường hợp cụ thể trong các quan hệ cụ thể. Ví dụ, con có hành vi xâm phạm tính mạng của cha sẽ không có quyền hưởng di sản do cha để lại, áp dụng BLDS Điều 643; nhưng con trong trường hợp này vẫn duy trì năng lực pháp luật thừa kế đối với tất cả những người khác, đặc biệt là đối với mẹ của mình.

---

theo pháp luật hoặc theo di chúc (BLDS Điều 635); theo pháp luật hôn nhân và gia đình, con do người vợ có thai trong thờI kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng (Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 63 khoản 1). Các tiêu chí pháp lý của tình trạng "sinh ra và còn sống" chưa được xây dựng rõ ràng trong luật thực định Việt Nam. Theo Nghị định số 83-CP ngày 10/10/1998 Điều 20, nếu trẻ em sinh ra sống được 24 giờ trở lên rồi mới chết, thì cũng phải đăng ký khai sinh theo quy định của Nghị định này; nếu chết trước khi sinh hoặc sinh ra mà sống chưa được 24 giờ, thì không phải đăng ký khai sinh. Có thể từ quy định đó thừa nhận rằng chỉ có thể gọi là sinh ra còn sống, nếu trẻ sống được ít nhất 24 giờ. Các dấu hiệu pháp lý của sự sống hẳn cũng chính là các dấu hiệu sinh học của sự sống: hoạt động của tim, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn,…

Mặt khác, trong điều kiện luật không có quy định riêng, ta nói rằng việc chứng minh tình trạng "sinh rà và còn sống" được thực theo các quy định trong luật chung về chứng cứ, nghĩa là có thể bằng mọi phương tiện được pháp luật thừa nhận.

[34] Nói "trên nguyên tắc", bởi theo Luật hôn nhân và gia đình hiện hành, người thành niên mà mất năng lực hành vi thì không có năng lực pháp luật kết hôn: xem Gia đình, nxb Trẻ TPHCM, 2002, số.

Nhân thân và năng lực hành vi. Theo BLDS Điều 17, năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Nếu nhân thân là điều kiện để có năng lực pháp luật, thì năng lực pháp luật là điều kiện để có năng lực hành vi.

Năng lực hành vi có thể chưa có, chưa có đủ, bị mất hoặc bị hạn chế[35], do tuổi tác, sức khoẻ, khả năng nhận thức hoặc do nhiễm thói hư, tật xấu dẫn đến sự suy đồi về nhân cách, phẩm hạnh.. Thế nhưng, trong bất kỳ trường hợp nào, nhân thân vẫn còn nguyên vẹn. Nói cách khác, nhân thân của cá nhân không bị ảnh hưởng bởi tính hoàn hảo hay không hoàn hảo của năng lực hành vi.

3. Các trường hợp đặc thù

Trong các trường hợp sau đây, cá nhân chưa hẳn đã chấm dứt cuộc sống sinh học của mình, nhưng cuộc sống pháp lý trở nên mong manh và điều đó khiến cho tính hiện thực của nhân thân bị suy yếu. Tuỳ theo mức độ suy yếu của nhân thân pháp lý, luật thực định Việt Nam ghi nhận các trường hợp vắng mặt, mất tích và tuyên bố một người là đã chết.

3.1. Vắng mặt

Khái niệm. Vắng mặt, theo nghĩa thông dụng, được hiểu là việc một cá nhân ngưng xuất hiện ở nơi cư trú mà cũng không để lại tin tức cho những người thân quen cũng như những người có quan tâm và tình trạng này kéo dài trong một thời gian.

Luật Việt Nam hiện hành không định nghĩa vắng mặt về phương diện pháp lý mà chỉ quy định các điều kiện để xác lập tình trạng này bằng con đường tư pháp.

3.1.1. Điều kiện

Điều luật. Theo BLDS Điều 74, khi một người biệt tích từ sáu tháng liền trở lên, thì những người có quyền và lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và có thể yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt theo quy định tại Điều 75 của Bộ luật này.

Có thể rút ra từ điều luật ấy các điều kiện cần và đủ của việc xác lập tình trạng vắng mặt như sau: có sự biệt tích của một người, sự biệt tích kéo dài trong một thời gian và có thông báo tìm kiếm của Toà án.

Biệt tích. Luật không định nghĩa cụm từ biệt tích. Thực tiễn, về phần mình, thừa nhận rằng chỉ coi là biệt tích một khi đương sự vắng mặt không chỉ tại nơi cư trú thường xuyên mà cả tại những nơi đương sự tạm trú, thậm chí tại những nơi đương sự thường lui tới trong quá trình sống và giao tiếp hàng ngày (cơ quan làm việc, nơi lui tới mua sắm, ăn uống, giải trí , thư giãn hàng ngày,…). Một cách tổng quát, sự biệt tích được ghi nhận một khi không còn sự xuất hiện của đương sự theo ghi nhận của tất cả những người có khả năng nhận biết đương sự, bao gồm người thân, bạn bè, người láng giềng, người quen và thậm chí cả những người không quen nhưng có những hiểu biết tối thiểu về đương sự để có thể phân biệt đương sự với những người khác trong cuộc sống hàng ngày.

Sự biệt tích có thể do cố ý hoặc không cố ý. Song, điều quan trọng là những người có quyền và lợi ích liên quan không thể tiếp cận và cũng không thể liên lạc với đương sự thông qua tất cả các kênh, các phương tiện giao tiếp thông thường: gặp gỡ trực tiếp, điện thoại, thư từ thông thường, email,….

Thời gian biệt tích. Để sự vắng mặt có thể được ghi nhận như một sự kiện pháp lý, thời gian biệt tích của đương sự phải kéo dài ít nhất là sáu tháng. Thời gian này bắt đầu tính từ ngày đương sự ngưng xuất hiện ở những nơi mà đương sự thường xuất hiện theo thói quen, theo sự ghi nhận của tất cả những người có thể nhận biết đương sự. Thời gian biệt tích phải liên tục: chỉ cần đương sự xuất hiện trở lại, thời gian biệt tích sẽ lập tức bị gián đoạn.

Thông báo tìm kiếm. Tình trạng vắng mặt không được xác lập một cách đương nhiên sau sáu tháng biệt tích liên tục. Cần có một người nào đó có quyền, lợi ích liên quan, ví dụ, vợ (chồng), con, cha mẹ hoặc một người thân thích, thậm chí bạn bè, chủ nợ lên tiếng yêu cầu

[35] Xem: Bình luận khoa học Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam

Toà án thông báo việc tìm kiếm người biệt tích.
Theo Bộ luật TTDS Điều 33 khoản 2 điểm a và Điều 35 khoản 2 điểm b, Toà án thụ lý yêu cầu là Toà án cấp quận (huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh) nơi cư trú cuối cùng của người được tìm kiếm. Tuy nhiên, theo Điêu 36 khoản 2 điểm a, người yêu cầu có thể yêu cầu Toà án quận (huyện) nơi cư trú làm việc hoặc nơi có trụ sở của mình (nếu là pháp nhân) giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm đối với một người khác đang vắng mặt mà mình quan tâm.
Toà án quyết định phát hay không phát thông báo tìm kiếm trên cơ sở đánh giá các thông tin được cung cấp (BLTTDS Điều 326 khoản 1)[36]; trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu, thì Toà án ra quyết định chấp nhận đơn yêu cầu và ra thông báo (Điều 326 khoản 2).
Thông báo tìm kiếm được thực hiện theo các quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Về nội dung, thông báo tìm kiếm phải có các thông tin sau đây (BLTTDS Điều 327).
- Ngày, tháng, năm ra thông báo;
- Tên Toà án ra thông báo;
- Số và ngày, tháng, năm của quyết định Toà án chấp nhẫn đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú;
- Tên, địa chỉ của người yêu cầu Toà án thông báo;
- Họ, tên và ngày, tháng, n8m sinh hoặc tuổi của người cần tìm kiếm và địa chỉ của người đó trước khi biệt tích;
- Địa chỉ liên hệ của cá nhân, cơ quan, tổ chức, nếu người cần được tìm kiếm biết được thông báo hoặc người khác có được tin tức về người cần tìm kiếm.

Về thể thức, thông báo tìm kiếm phải được đăng trên báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh và đài truyền hình của trung ương ba lần trong ba ngày liên tiếp.
Chi phí thông báo do người yêu cầu thông báo chịu (Điều 155 khoản 1; Điều 329 khoản 2).

3.1.2. Hiệu lực

Tính chất pháp lý: suy đoán còn sống. Việc ra thông báo tìm kiếm người vắng mặt cho phép thừa nhận rằng trong suy nghĩ của mọi người, kể cả của thẩm phán, người vắng mặt và được tìm kiếm vẫn còn sống. Ta nói rằng người vắng mặt được suy đoán còn sống. Bởi vậy, người này vẫn duy trì nhân thân của mình; và do nhân thân được duy trì mà người này vẫn có thể có năng lực pháp luật, đặc biệt là vẫn được gọi để nhận di sản theo di chúc và theo pháp luật.

3.1.2.1. Chế độ bảo vệ: Quản lý tài sản của người vắng mặt

Chỉ định người quản lý Theo BLDS Điều 75, Toà án giao tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú cho những người sau đây quản lý, theo yêu cầu của người có quyền và lợi ích liên quan
- Đối với tài sản đã được người vắng mặt uỷ quyền quản lý, thì người được uỷ quyền tiếp tục quản lý;
- Đối với tài sản chung, thì do chủ sở hữu chung còn lại quản lý;
- Tài sản do vợ hoặc chồng đang quản lý, thì vợ hoặc chồng tiếp tục quản lý; nếu vợ hoặc chồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì con đã thành niên hoặc cha mẹ của người vắng mặt quản lý.

Nhận xét về việc chỉ định người quản lý. Việc chỉ định người quản lý có vẻ như chỉ được thực hiện một khi có người yêu cầu. Người này đồng thời cũng là người yêu cầu thông báo tìm kiếm đối với người vắng mặt. Tuy nhiên, người này không nhất thiết là một trong những người đang nắm giữ tài sản của người vắng mặt. Quy định của Điều 75 BLDS cho phép rút ra các nhận xét sau đây:
1. Tài sản của người vắng mặt không được đặt dưới sự quản lý thống nhất của một người mà có thể được nhiều người khác nhau quản lý, tuỳ trường hợp.

[36] Quyết định không chấp nhận của Toà án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm: BLTTDS Điều 316.

2. Câu chữ của luật thực ra không rõ lắm, về phần quyền yêu cầu của người có quyền và lợi ích liên quan. Suy cho cùng người có quyền và lợi ích liên quan chỉ có quyền yêu cầu Toà án chỉ định người quản lý tài sản. Toà án, về phần mình, chỉ định người quản lý theo đúng quy định tại BLDS Điều 75 đối với các tài sản được ghi nhận tại điều luật đó; Toà án không có quyền chỉ định người khác quản lý tài sản và người có quyền và lợi ích liên quan cũng không có quyền yêu cầu chỉ định người khác quản lý tài sản của người vắng mặt.

Thế nhưng, vậy có nghĩa rằng đối với các tài sản không được quy định tại điều luật đó, thì người có quyền và lợi ích liên quan có quyền đề xuất các yêu cầu của mình về việc chỉ định người quản lý tài sản. Ví dụ điển hình là các tài sản riêng của một người độc thân, không được giao cho người khác quản lý theo uỷ quyền[37].

3. Tài sản do vợ hoặc chồng quản lý bao gồm các tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng và có thể cả các tài sản riêng của người vắng mặt được vợ (chồng) quản lý theo sự uỷ quyền rành mạch hoặc mặc nhiên từ trước khi xảy ra vụ biệt tích của đương sự.

Quyền và nghĩa vụ của người quản lý. Theo BLDS Điều 76, người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú có các nghĩa vụ sau đây:

1. Giữ gìn, bảo quản tài sản của người vắng mặt như tài sản của chính mình;
2. Bán ngay tài sản là hoa màu, sản phẩm khác có nguy cơ hư hỏng;
3. Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, thanh toán nợ đến hạn của người vắng mặt bằng tài sản của người đó theo quyết định của Toà án;
4. Giao lại tài sản cho người vắng mặt khi người này trở về và phải thông báo cho Toà án biết; nếu có lỗi trong việc quản lý tài sản mà gây thiết hại, thì phải bồi thường.

Theo BLDS Điều 77, người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú có các quyền sau đây:

1. Quản lý tài sản của người vắng mặt;
2. Trích một phần tài sản của người vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn của người vắng mặt;
3. Được thanh toán các chi phí cần thiết trong việc quản lý tài sản

Nhận xét về quyền và nghĩa vụ của người quản lý tài sản. Các quy định về quyền và nghĩa vụ của người quản lý tài sản được ghi nhận tại các Điều 76 và 77 BLDS chỉ được áp dụng trong trường hợp không có chế độ quản lý nào khác đang được áp dụng đối với tài sản của người vắng mặt. Bởi vậy,

- Đối với tài sản được đặt dưới chế độ quản lý theo uỷ quyền, thì các quyền và nghĩa vụ của người quản lý tiếp tục là các quyền và nghĩa vụ được xác định theo hợp đồng uỷ quyền chứ không phải theo các Điều 76 và 77 đã dẫn[38];

- Đối với các tài sản thuộc khối tài sản chung của vợ chồng và đang được vợ (chồng) của người vắng mặt quản lý, thì chế độ quản lý là chế được xây dựng trong khuôn khổ luật hôn nhân và gia đình và các quyền, nghĩa vụ của người quản lý được quy định theo chế độ đó[39].

- Đối với các tài sản thuộc sở hữu chung, thì việc quản lý được thực hiện theo đúng các quy định về quản lý tài sản chung, tại các Điều BLDS.

Trên thực tế, chỉ có những tài sản riêng của người vắng mặt độc thân mà không được uỷ quyền cho người khác quản lý mới chịu sự quản lý theo chế độ được quy định tại các Điều 76 và 77 đã dẫn.

---

[37] Trong trường hợp người yêu cầu tổ chức việc quản lý tài sản của người vắng mặt đề nghị chỉ định một người nào đó quản lý tài sản liên quan, thì Toà án có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị đó. Trong trường hợp không chấp nhận, Toà án có quyền chỉ định người khác quản lý tài sản của người vắng mặt.

[38] Hợp đồng uỷ quyền không chấm dứt trong trường hợp người uỷ quyền vắng mặt: BLDS

[39] Xem: Các quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, nxb Trẻ-TPHCM, 2002.

Tất cả những điều trên đây cho thấy rằng việc quản lý tài sản của người vắng mặt không theo một chế độ thống nhất; giữa những người quản lý tài sản của người vắng mặt cũng không có sự phối hợp trong việc thực hiện công tác quản lý.

Dẫu sao, giữa chế độ quản lý theo các Điều 76, 77 đã dẫn và các chế độ quản lý khác luôn có một điểm chung: người quản lý có nghĩa vụ và có quyền dùng tài sản của người vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng và các nghĩa vụ tài sản đến hạn khác của người vắng mặt theo quyết định của Toà án[40].

Nhắc lại rằng người vắng mặt vẫn có đầy đủ năng lực pháp luật thừa kế và do đó có thể được gọi để nhận di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Vấn đề không có gì đặc biệt trong trường hợp di sản có khả năng thanh toán, nhưng sẽ trở nên cực kỳ rắc rối trong trường hợp di sản mất khả năng thanh toán mà không có người quản lý chính thức[41]. Trong khung cảnh của luật thực định, không ai trong số những người quản lý được quyền thay mặt người vắng mặt từ chối nhận di sản mà người vắng mặt được
hưởng. Nếu di sản không có khả năng thanh toán và không có người quản lý chính thức, thì người vắng mặt có nguy cơ phải chịu trách nhiệm đối với nợ di sản bằng tài sản riêng của mình[42].

Tuy nhiên, như đã nói, sự vắng mặt khiến nhân thân của người vắng mặt bị suy yếu và điều đó có ảnh hưởng nhất định không thể tránh khỏi đối với số phận của các quyền mà người này là chủ thể, nhất là những quyền gắn với nhân thân của người này. Giả sử người vắng mặt đang là nguyên đơn trong một vụ án đòi bồi thường thiệt hại do tính mạng, danh dự, nhân phẩm bị xâm hại, thì sự vắng mặt của người này có thể khiến vụ án bị đình chỉ, bởi người quản lý tài sản của người vắng mặt không thể thay thế người này ở vị trí nguyên đơn trước Toà án.

Điều gần như chắc chắn, đó là người được cấp dưỡng sẽ không có quyền yêu cầu tiếp tục cấp dưỡng cho mình, sau khi vắng mặt. Vấn đề có thể không có gì đặc biệt trong trường hợp người vắng mặt là người duy nhất thụ hưởng việc cấp dưỡng. Trái lại, trong trường hợp cả gia đình của người vắng mặt thụ hưởng việc cấp dưỡng[43], thì sự vắng mặt của người có quyền yêu cầu cấp dưỡng có thể đẩy gia đình của người này đến chỗ cùng cực, bởi, trong khung cảnh của luật thực định, quan hệ cấp dưỡng không
được xác lập trực tiếp giữa người có nghĩa vụ cấp dưỡng và các thành viên khác trong gia đình của người có quyền yêu cầu cấp dưỡng.

Vai trò của người yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt . Sau khi yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt và yêu cầu quản lý tài sản của người này được Toà án đáp ứng thuận lợi, người yêu cầu chấm dứt vai trò của mình. Trong việc quản lý tài sản của người vắng mặt, chỉ những người quản lý tài sản được Toà án chỉ định là những người có quyền và có trách nhiệm pháp lý. Có trường hợp người yêu cầu quản lý tài sản của người vắng mặt là một chủ nợ của người này và họ đưa ra yêu cầu với Toà án chỉ nhằm mục đích tạo điều kiện để thu hồi số nợ cần đòi; sau khi đạt được mục đích của mình, họ chẳng quan tâm đến người vắng mặt hay người quản lý nữa.

---

[40] Cần nhấn mạnh rằng việc thực hiện các nghĩa vụ của người vắng mặt bằng tài sản của người này phải theo quyết định của Toà án, người quản lý, dù theo uỷ quyền, theo chế độ quản lý tài sản của vợ chồng hoặc theo chế độ được quy định tại Điều 76 và 77, không được tự ý trích tài sản của người vắng mặt để thực hiện các nghĩa vụ ấy. Có thể hình dung cơ chế thực hiện nghĩa vụ như sau: người có quyền yêu cầu yêu cầu người quản lý tài sản của người vắng mặt thực hiện nghĩa vụ của người vắng mặt đối với mình; người quản lý thông báo cho Toà án; Toà án xem xét cơ sở của yêu cầu và chấp thuận cho người quản lý thực hiện nghĩa vụ, người quản lý trích tài sản của người vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ. Cũng có thể hình dung trường hợp người có quyền yêu cầu không yêu cầu trực tiếp đối với người quản lý mà gửi yêu cầu cho Toà án. Sau khi xem xét, Toà án chấp thuận yêu cầu và thông báo cho người quản lý để người này trích tài sản của người vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ. Trong trường hợp này, nếu tài sản của người vắng mặt được phân thành nhiều khối do nhiều người quản lý một cách độc lập, thì Toà án có quyền chỉ định bất kỳ người nào trong những người quản lý thực hiện nghĩa vụ

[41] Về người quản lý chính thức di sản, xem Thừa kế, nxb Trẻ TPHCM, 1999, tr. và kế tiếp.

[42] Xem Thừa kế, đd, tr. và kế tiếp

[43] Trong trường hợp người được cấp dưỡng có gia đình riêng của mình, thì việc xác định mức cấp dưỡng phải được thực hiện như thế nào để không chỉ người được cấp dưỡng mà cả các thành viên gia đình của người này cũng được cứu giúp: xem Gia đình, nxb Trẻ, 2002, số 387

3.1.2.2. Tường hợp người vắng mặt xuất hiện trở lại

Dấu hiệu của việc xuất hiện trở lại. Người vắng mặt có thể xuất hiện trở lại tại nơi cư trú hoặc ở bất kỳ nơi nào. Cũng được coi là xuất hiện trở lại, việc người vắng mặt, dù không xuất hiện, cho thấy mình vẫn còn sống, thông qua việc tiến hành các hoạt động thông tin liên lạc với người khác (điện thoại, thư từ, email, chat,…).

Hiệu lực. Theo BLTTDS Điều 329, nếu người vắng mặt xuất hiện trở lại, thì quyết định thông báo tìm kiếm đương nhiên hết hiệu lực. Tất nhiên, thông báo tìm kiếm cũng hết hiệu lực. Người quản lý tài sản theo chế độ được quy định tại các Điều 76 và 77 BLDS phải giao trả tài sản cho người vắng mặt trở về, như đã nói ở trên. Cần lưu ý rằng theo quy định của pháp luật, người quản lý tài sản của người vắng mặt theo quy

định của các Điều 76 và 77 phải báo cho Toà án về việc giao trả tài sản[44]. Thoạt trông, luật có vẻ hơi khắt khe đối với người quản lý tài sản và có vẻ dễ dãi đối vơi người vắng mặt: người quản lý phải đặt mình dưới sự giám sát của Toà án trong quá trình

quản lý và phải chính thức hoá việc chấm dứt nhiệm vụ của mình bằng cách thông báo cho Toà án; trong khi người vắng mình thậm chí chẳng cần phải báo cho Toà án về việc mình đã trở về, như người này đã chẳng cần báo cho Toà án về việc mình vắng mặt. Tuy nhiên, các giải pháp, suy cho cùng, đều nằm trong logique của sự việc: người quản lý tài sản là nhân vật do Toà án tạo ra; trong khi người vắng mặt không hề có một quan hệ nào với Toà án và cũng không bị buộc phải thiết lập một quan hệ nào với Toà án liên quan đến tình trạng vắng mặt của mình.

Rắc rối có thể phát sinh trong trường hợp người vắng mặt xuất hiện trở lại, nhưng không lên tiếng gì về việc quản lý tài sản của mình. Tất nhiên, sẽ không có vấn đề gì trong trường hợp tài sản đã được đặt dưới các chế độ quản lý đặc thù (uỷ quyền, tài sản chung,…) bởi các chế độ này cứ tiếp tục được duy trì theo luật chung. Nhưng, đối với tài sản riêng của người vắng mặt được đặt dưới sự quản lý theo các Điều 76, 77, thì liệu chế độ quản lý này có chấm dứt ngay sau khi người vắng mặt xuất hiện trở lại, hay chỉ chấm dứt sau khi người vắng mặt yêu cầu giao trả tài sản ? Trong khung cảnh của luật thực định, giải pháp thứ nhất có vẻ không phù hợp; nhưng giải pháp thứ hai

cũng tỏ ra không hợp lý trong trường hợp người vắng mặt hoàn toàn thụ động[45]. Hẳn cần thừa nhận cho người quản lý quyền yêu cầu Toà án tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ của mình và Toà án phải đáp ứng thuận lợi đối với yêu cầu ấy, một khi có đủ bằng chứng về sự xuất hiện trở lại của người vắng mặt, ngay cả trong trường hợp người này không đòi lại tài sản.

Sự xuất hiện trở lại của người vắng mặt còn có tác dụng khôi phục trọn vẹn nhân thân của người này. Chẳng hạn, nếu người trở về đã từng được cấp dưỡng và nay tiếp tục ở trong hoàn cảnh khó khăn, thì có thể tiếp tục được cấp dưỡng; tuy nhiên, có vẻ như đây là một quan hệ cấp dưỡng mới chứ không phải là sự khôi phục quan hệ cấp dưỡng đã tồn tại trước khi người này vắng mặt: quan hệ cấp dưỡng mới chỉ được xác lập nếu một trong các bên lên tiếng yêu cầu.

3.2. Mất tích

Khái niệm. Có thể định nghĩa mất tích là tình trạng pháp lý của một cá nhân vắng mặt liên tục trong một thời gian dài mà không rõ còn sống hay đã chết do không còn tin tức liên quan đến cá nhân đó.

3.2.1. Điều kiện

Điều kiện cần. Theo BLDS Điều việc tuyên bố mất tích có thể được thực hiện trong trường hợp một người đã biệt tích từ hai năm trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, nhưng vẫn không có tin tức

---

[44] Những người quản lý tài sản của người vắng mặt theo các chế độ riêng, như uỷ quyền, quản lý tài sản chung,… vẫn tiếp tục quản lý các tài sản của người vắng mặt theo các quy định thuộc`chế độ riêng đó.

[45] Người quản lý được thanh toán chi phí cần thiết chừng nào còn tiếp tục quản lý; song, vấn đề là người này có thể không còn màng đến công việc nữa và chỉ muốn được tự do.

xác nhận người đó là còn sống. Có thể nhận thấy ngay một trong những điều kiện cần cơ bản là: người được yêu cầu tuyên bố mất tích phải là người vắng mặt đã từng được Toà án thông báo tìm kiếm mà không có kết quả. Nói cách khác, người bị tuyên bố mất tích phải là người vắng mặt trong thời gian ít nhất hai năm liên tục.

Theo BLTTDS Điều 330 khoản 3, người yêu cầu phải gửi kèm theo đơn yêu cầu các chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích hai năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm. Trong trường hợp trước đó đã có quyết định của Toà án thông báo tìm kiếm người vắng mặt, thì phải có bản sao quyết định đó.

Từ câu chữ của điều luật vừa dẫn, có vẻ như việc tuyên bố mất tích có thể được yêu cầu cả trong trường hợp người bị yêu cầu tuyên bố mất tích chưa từng được chính thức tìm kiếm theo một thông báo của Toà án. Tuy nhiên, có thể tin rằng thủ tục thông báo tìm kiếm chỉ được bỏ qua đối với các trường hợp vắng mặt xảy ra trước khi BLDS 1995: không thể đòi hỏi việc bảo đảm các thủ tục nào đó trong điều kiện các thủ tục ấy chưa có.

Điều kiện đủ. Cũng như tình trạng vắng mặt, tình trạng mất tích không được xác lập một cách đương nhiên. Một khi có đủ các yếu tố của trường hợp được dự kiến tại BLDS Điều , người có quyền và lợi ích liên quan có thể nộp đơn yêu cầu Toà án tuyên bố mất tích đối với nhân vật chính trong trường hợp đó (cùng điều luật). Theo BLTTDS các Điều 33 khoản và 35 khoản 2 điểm b, Toà án có thẩm quyền thụ lý yêu cầu là Toà án nơi cư trú cuối cùng của nhân vật chính đã nói. Và cũng theo BLTTDS Điều 36 khoản 2 điểm a, người yêu cầu có thể yêu cầu Toà án nơi mình cư trú, làm viêc hoặc có trụ sở (nếu là pháp nhân).

Cũng như trong trường hợp vắng mặt, việc quyết định tuyên bố hay từ chối tuyên bố một người là mất tích là việc của thẩm phán dựa trên kết quả đánh giá các chứng cứ, thông tin do người yêu cầu cung cấp (BLTTDS Điều 332 khoản 2). Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu

3.2.2. Hiệu lực

Về quan hệ nhân thân. Người bị tuyên bố mất tích vẫn được suy đoán là còn sống. Bởi vậy, người này vẫn có thể được gọi để nhận di sản được thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Tuy nhiên, sự suy đoán đã yếu đi rất nhiều so với tình trang vắng mặt, do thời gian biệt tích của đương sự kéo dài. Bởi vậy, người làm luật quy định rằng nếu vợ (chồng) của người bị tuyên bố vắng mặt yêu cầu được ly hôn, thì Toà án giải quyết cho ly hôn. Sự ly hôn trong trường hợp này là đương nhiên; thẩm phán phải tuyên bố cho ly hôn chỉ trên cơ sở đương sự xuất trình quyết định tuyên bố mất tích đối với chồng (vợ) của mình mà không xem xét các yếu tố khác như trong trường hợp ly hôn thông thường.

Mặt khác, trong trường hợp người bị tuyên bố mất tích là một bên trong hợp đồng uỷ quyền, thì việc tuyên bố mất tích có tác dụng đương nhiên làm chấm dứt hợp đồng uỷ quyền (BLDS Điều 589 khoản 4)[46].

Về quan hệ tài sản. Do người bị tuyên bố mất tích vẫn được suy đoán là còn sống, các tài sản của người này không được chuyển giao bằng con đường thừa kế mà vẫn tiếp tục thuộc về người này. Theo BLDS Điều 79, tài sản của người bị tuyên bố mất tích được quản lý giống như trong trường hợp vắng mặt. Vậy nghĩa là các tài sản được giao cho người được uỷ quyền quản lý tiếp tục được đặt dưới sự quản lý của người này; các tài sản chung được chủ sở hữu chung quản lý; tài sản chung của vợ chồng do vợ (chồng) của người mất tích quản lý;… Đặc biệt, nếu vợ (chồng) của người bị tuyên bố mất tích được phép ly hôn, thì tài sản của người mất tích (mà được đặt dưới sự quản lý của vợ (chồng) người này) sẽ được giao cho con đã thành niên hoặc cha mẹ của người mất tích quản lý (cùng điều luật); nếu không có những người này, thì người thân thích quản lý và nếu không có người thân thích, thì Toà án chỉ định người quản lý.

---

[46] BLDS 1995 không thừa nhận việc chấm dứt hợp đồng uỷ quyền trong trường hợp một bên trong hợp đồng bị tuyên bố mất tích.

Có hai điều đáng chú ý:

1. Trong trường hợp tài sản của người mất tích được quản lý theo hợp đồng uỷ quyền, thì do việc uỷ quyền chấm dứt, việc tiếp tục quản lý tài sản sau khi có quyết định tuyên bố mất tích sẽ được thực hiện theo đúng các quy định tại các Điều 76 và 77 BLDS; người quản lý, về phần mình, sẽ mang tư cách người quản lý tài sản của người mất tích chứ không còn giữ tư cách người được uỷ quyền quản lý tài sản như trước;
2. Trong trường hợp vợ (chồng) của người mất tích được phép ly hôn, thì chế độ tài sản của vợ chồng cũng chấm dứt và khối tài sản chung của vợ chồng được chuyển thành sở hữu chung theo phần[47]. Thông thường, người ly hôn sẽ không muốn duy trì chế độ tài sản chung mà sẽ yêu cầu phân chia. Bởi vậy, các tài sản được chuyển giao cho những người quản lý được ghi nhận tại Điều 79 BLDS là tài sản riêng của người mất tích và phần tài sản chung của vợ chồng được chia cho người này.

Ngoài ra, cũng như người vắng mặt, người mất tích có thể được gọi để nhận một di sản không có khả năng thanh toán và cũng sẽ không được bảo vệ trong trường hợp di sản không có người quản lý chính thức và các tài sản thuộc di sản bị lẫn lộn với các tài sản của người mất tích.

3.2.2.1. Trường hợp người mất tích trở về

Huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích. Theo BLDS Điều 80 khoản 1, khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, thì thep yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền và lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích. Toá án có thẩm quyền là Toà án nơi cư trú cuối cùng của người bị tuyên bố mất tích (và cũng là Toà án đã ra thông báo tìm kiếm đối với người này), áp dụng BLTTDS Điều 35 khoản 2 điểm c.

Tuy nhiên, theo BLTTDS Điều 36 khoản 2 điểm a, đối với các yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 26 của Bộ luật này, thì người yêu cầu có thể yêu cầu Toà án nơi mình cư trú, làm việc hoặc có trụ sở (nếu là pháp nhân) giải quyết. Khoản 3 Điều 26 ghi nhận yêu cầu huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích. Vậy có nghĩa rằng người yêu cầu có quyền yêu cầu Toà án nới cứ trú của mình huỷ quyết dịnh tuyên bố mất tích đối với một người cư trú ở một nơi khác.

Dường như Điều 35 khoản 2 điểm c chỉ xác định một trong những giải pháp có thể được lựa chọn chứ không khẳng định giải pháp đó là duy nhất. Bởi vậy, nếu áp dụng kết hợp các Điều 35 khoản 2 điểm b và 36 khoản 2 điểm a, thì :

- Người yêu cầu trước đây đã yêu cầu Toà án nơi cư trú của người bi mất tích tuyên bố người sau này mất tích có quyền yêu cầu Toà án
- Một người có quyền và lợi ích liên quan có thể yêu cầu Toà án nơi cư trú của mình huỷ quyết định tuyên bố mất tích đối với một người khác sau khi người bị tuyên bố mất tích trở về, ngay cả trong trường hợp

Các dấu hiệu của sự trở về của người mất tích cũng được xác định theo các tiêu chí giống như các tiêu chí được áp dụng cho trường hợp xác định người vắng mặt trở về.

Hiệu lực về nhân thân. Người mất tích không bị coi là đã chết, do đó, không có vấn đề khôi phục nhân thân pháp lý của người này khi người này trở về. Tuy nhiên, có trường hợp sau khi có quyết định tuyên bố mất tích đối với một người, vợ (chồng) của người này đã xin ly hôn và được phép ly hôn. Theo BLDS Điều 80 khoản 3, việc ly hôn trong trường hợp này vẫn có hiệu lực pháp luật. Bởi vậy, nếu người bị tuyên bố mất tích mà trở về và vợ (chồng) trước đây của người này muốn nối lại cuộc sống vợ chồng thì họ phải tiến hành đăng ký lại việc kết hôn. Nếu sau khi ly hôn, vợ (chồng) của người bị tuyên bố mất tích đã kết hôn vối người khác, thì cuộc hôn nhân sau vẫn có giá trị sau khi người mất tích trở về.

Hiệu lực về tài sản. Theo BLDS Điều 80 khoản 2, người bị tuyên bố mất tích mà trở về được nhận lại tài sản do người quản lý chuyển giao sau khi đã thanh toán chi phí quản lý. Cần nhấn mạnh rằng, cũng như trong trường hợp người vắng mặt trở về, việc người mất tích

[47] Xem: Các quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, nxb Trẻ 2004

trở về chỉ có tác dụng chấm dứt chế độ quản lý thiết lập theo các điều 76 và 77 BLDS[48]: chủ sở hữu chung, vợ (chồng) quản lý tài sản chung và không ly hôn vẫn tiếp tục quản lý các tài sản liên quan theo chế độ áp dụng đối với các tài sản đó ngay cả trong trường hợp người mất tích trở về.

Có trường hợp người mất tích, dù vẫn còn sống, ở trong tình trạng không có khả năng giao dịch, ví dụ, do hôn mê hoặc rối loạn tâm thần và không cò khả năng nhận thức được hành vi của mình. Khi đó, chế độ quản lý tài sản của người mất tích vẫn phải chấm dứt, nhưng người có quyền và lợi ích liên quan có thể yêu cầu đặt người này trong tình trạng mất năng lực hành vi để người này có thể xác lập các giao dịch và thực hiện các nghĩa vụ của mình thông qua vai trò của người giám hộ.

3.3. Tuyên bố là đã chết

Khái niệm. Tuyên bố một người là đã chết là một quyết định tư pháp có tác dụng chấm dứt của sống pháp lý của một người thực ra không rõ là còn sống hay đã chết nhưng việc thừa nhận người này còn sống không đem lại lợi ích gì cho người này và những người có liên quan, nếu không muốn nói rằng còn gây trở ngại cho việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của những người có quyền và lợi ích liên quan.

3.3.1. Điều kiện và hiệu lực

Điều kiện. Theo BLDS Điều 81, việc tuyên bố một người là đã chết có thể được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Sau ba năm kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Toà án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;
- Biệt tích trong chiến tranh sau năm năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;
- Bị tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai mà sau một năm kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai chấm dứt mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- Biệt tích năm năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống; thời hạn này được tính từ ngày đương sự vắng mặt tại nơi cư trú mà không để lại tin tức[49].

Tuy nhiên, các trường hợp được ghi nhận trên đây cũng chỉ là điều kiện cần. Việc tuyên bố một người là đã chết chỉ được tiến hành một khi có một người nào đó có quyền và lợi ích liên quan yêu cầu Toà án làm việc đó. Toà án có thẩm quyền tuyên bố một người là đã chết là Toà án quận, huyện nơi cư trú cuối cùng của đương sự (BLTTDS Điều 33 khoản và Điều 35 khoản 2 điểm c). Tất nhiên, người yêu cầu phải xuất trình các bằng chứng cho thấy có đủ cơ sở để tuyên bố một người là đã chết. Toà án quyết định tuyên bố hay không tuyên bố một người là đã chết dựa trên kết quả đánh giá các chứng cứ được cung cấp; cũng như quyết định tuyên bố mất tích, quyết định liên quan đến việc tuyên bố một người là đã chết có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm.

Trong trường hợp Toà án quyết định tuyên bố một người là đã chết, thì việc xác định ngày chết được thực hiện tuỳ theo trường hợp. Trong luật của một số nước, nếu Toà án không thể xác định ngày chết dựa trên các thông tin được cung cấp, thì ngày này được xác định là ngày biệt tích hoặc ngày bản án liên quan được đăng ký vào sổ hộ tịch[50]. BLDS Việt Nam năm 1995, về phần mình, quy định rằng nếu không xác định được ngày chết của người bị tuyên bố là đã chết, thì ngày mà bản án tuyên bố người đó là đã chết có hiệu lực pháp luật được coi

---

[48] Xem lại số, ghi chú. Song, khác vớI trường hợp vắng mặt, trong trường hợp tuyên bố mất tích, ngườI quản lý tài sản theo uỷ quyền sẽ trở thành người quản lý tài sản theo các điều 76, 77, như ta đã biết: xem lại số

[49] Trong trường hợp này, việc tuyên bố đã chết có thể được yêu cầu, dù trước đó người bị yêu cầu tuyên bố đã chết không bị tuyên bố mất tích. Nói cách khác, trong khung cảnh của luật thực định Việt Nam, tuyên bố mất tích không phải là điều kiện cần thiết đối với tuyên bố đã chết. Tuy nhiên, có lẽ Toà án chỉ thụ lý yêu cầu tuyên bố đã chết đối với các trường hợp biệt tích mà Toà án đã ra thông báo tìm kiếm. Điều này hợp lý trong điều kiện theo quy định của pháp luật, việc tuyên bố mất tích cũng chỉ có thể được thực hiện đối vớI người vắng mặt đã được Toà án ra thông báo tìm kiếm.

[50] Xem, ví dụ, luật của Pháp: BLDS Điều 90 và 128

là ngày người đó chết (Điều 91). Tuy nhiên, quy định này đã không được lấy lại trong BLDS năm 2005.

Luật không ghi nhận thủ tục đăng ký quyết định tuyên bố một người là đã chết vào sổ khai tử; tuy nhiên, thủ tục này được ghi nhận trong Nghị định số 83-CP Điều 32 khoản 1: người yêu cầu tuyên bố một người là đã chết phải tiến hành đăng ký khai tử cho người chết. Quyết định tuyên bố một người là đã chết được coi như giấy báo tử (Điều 33 khoản 1, điểm g). Nghị định không xác định thời hạn đăng ký khai tử trong trường hợp này. Có lẽ thời hạn áp dụng đối với trường hợp chết thông thường cũng được áp dụng trong trường hợp này, nghĩa là việc khai tử phải thực hiện trong vòng 48 giờ kể từ ngày quyết định tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật (Điều 28).

Hiệu lực. Khi một người bị tuyên bố là đã chết, thì người này bị coi như đã chết. Có nhiều hệ quả phát sinh từ đó, được ghi nhận tại BLDS Điều 82, đáng chú ý nhất là:

- Nếu người bị tuyên bố là đã chết có vợ (chồng) thì cuộc hôn nhân của người này chấm dứt; người còn sống có thể tự do kết hôn với người khác;
- Các.tài sản của người bị tuyên bố là đã chết được di chuyển cho những người thừa kế theo di chúc và theo pháp luật.

3.3.2. Trường hợp người bị tuyên bố đã chết trở về

Huỷ bỏ quyết định tuyên bố đã chết. Theo BLDS Điều 83 khoản 1, khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền và lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết. Theo BLTTDS Điều 35 khoản 2 điểm c và Điều 36 khoản 2 điểm a, Toà án

Theo Nghị định số 83-CP đã dẫn, Điều 32 khoản 2, UBND nơi đã đăng ký khai tử phải gạch tên đương sự trong sổ khai tử. Điều luật không nói rõ việc gạch tên được thực hiện theo yêu cầu của ai. Tuy nhiên, trong logique của sự việc, có thể nói rằng UBND chỉ tiến hành gạch tên trên cơ sở có quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố là đã chết và quyết định này phải được đình kèm vào sổ hộ tịch, còn việc người nào yêu cầu xoá tên đương sự trong sổ khai tử có lẽ không quan trọng.

Hiệu lực về nhân thân. Theo BLDS Điều 83 khoản 2, quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục khi Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết, trừ các trường hợp sau đây:

- Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Toà án cho ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 78 của Bộ luật này, thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật;
- Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết kết hôn với người khác, thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật.

Riêng trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết không kết hôn với người khác, thì theo Luật hôn nhân và gia đình nằm 2000 Điều 26, thì quan hệ hôn nhân đương nhiên được khôi phục. Giải pháp của Luật hôn nhân và gia đình có thể được xem như một phần thưởng đối với vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết mà vẫn tỏ ra chung thuỷ với người chết. Tuy nhiên, trên thực tế có trường hợp vợ hoặc chồng không kết hôn mà chỉ chung sống như vợ chồng với người khác sau khi có quyết định tuyên bố là đã chết đối với chồng(vợ) mình. Thừa nhận rằng quan hệ vợ chồng đương nhiên được khôi phục đối với người không kết hôn, mà không xem xét

từng trường hợp cụ thể, có khi lại phản tác dụng[51]: trong trường hợp vừa nêu, thì người chung

---

[51] Cũng có trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết không kết hôn và cũng không chung sống như vợ chồng với người khác, nhưng đồng thời cũng chẳng thiết tha gì đối với việc khôi phục quan hệ vợ chồng trước đó. Khi ấy, việc thừa nhận rằng quan hệ vợ chồng đương nhiên khôi phục khiến vợ hoặc chồng, nếu không muốn duy trì quan hệ ấy, phải tiến hành thủ tục xin ly hôn. Giải pháp sẽ tỏ ra bất hợp lý, bởi người này đã tin tưởng một cách chính đáng và có căn cứ rằng mình đã được tự do (đúng hơn là được giải thoát) để sống cuộc sống độc thân sau khi đã xin được bản án tuyên bố đã chết đối với chồng (vợ) của mình.

Có vẻ như giải pháp của Luật hôn nhân gia đình năm 2000 Điều 26 là sự can thiệp trên mức cần thiết của luật

sống như vợ chồng với người khác sẽ ở trong tình trạng vi phạm chế độ một vợ một chồng sau khi người bị tuyên bố đã chết trở về.

Hiệu lực về phương diện tài sản. Theo BLDS Điều 83 khoản 3, người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản hoặc giá trị tài sản hiện còn. Điều này có nghĩa là:

- Người đã nhận tài sản thừa kế có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức gắn với tài sản đã nhận; họ không phải trả lại những thứ đó. Tuy nhiên, trong logique của sự việc, những người này chỉ có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức thu được cho đến ngày biết được rằng người bị tuyên bố là đã chết còn sống.
- Trong trường hợp người nhận tài sản thừa kế đã chuyển nhượng có đền bù tài sản nhận được cho người khác, thì vụ chuyển nhượng có giá trị. Người nhận tài sản thừa kế chỉ phải trả lại cho người trở về những gì mình nhận được từ vụ chuyển nhượng đó và còn lại ở thời điểm biết được người bị tuyên bố đã chết còn sống[52].
- Trong trường hợp người nhận tài sản thừa kế đã chuyển dịch không có đền bù bằng cách tặng cho cho người khác tài sản nhận được, thì vụ tặng cho có giá trị: người nhận tài sản thừa kế không phải hoàn trả gì cả cho người trở về. Tuy nhiên, có vẻ như trong trường hợp người nhận tài sản thừa kế, đến lượt mình, để lại các tài sản nhận được cho người thừa kế của mình, thì người thừa kế của người này phải hoàn trả những tài sản bằng hiện vật nhận được, nếu còn, cho người trở về.

Trong trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế, thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức (Điều 83 khoản 3); nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường (cùng điều luật). Trong giả thiết của điều luật, người thừa kế biết người bị tuyên bố là đã chết còn sống, nhưng không yêu cầu Toà án huỷ bỏ quyết định tuyên bố đã chết trước đây. Các giải pháp được ghi nhận trong điều luật có ý nghĩa như các biện pháp chế tài đối với người chiếm hữu không ngay tình tài sản của người khác[53]. Thế

nhưng, hẳn trách nhiệm chứng minh thuộc về người nào cho rằng người chiếm hữu tài sản đã không ngay tình.

MỤC 3 - Tình trạng không có năng lực hành vi

1. Tổng quan

1.1. Khái niệm

Tình trạng không có năng lực hành vi. Gọi là không có năng lực hành vi người ở trong tình trạng không thể tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà mình là chủ thể. Tình trạng không có năng lực hành vị, trong luật thực định Việt Nam, có hai cấp độ:

- Hoàn toàn không có năng lực hành vi. Những người hoàn toàn không có năng lực hành vi bao gồm người chưa đủ sáu tuổi và người mắc bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể làm chủ được hành vi của mình và bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi (Điều 21 và 22).
- Có năng lực hành vi không đầy đủ. Người có năng lực hành vi không đầy đủ là người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi[54]: người này chỉ có thể xác lập các giao dịch phục vụ cho

---

vào cuộc sống riêng tư của cá nhân: xem, Gia đình, nxb Trẻ, 2002, số 305 ghi chú 252

[52] Cụm từ "hiện còn" không rõ nghĩa lắm. Nếu người nhận tài sản thừa kế dùng tài sản thu được từ vụ chuyển nhượng để mua hoặc đổi lấy một tài sản khác, thì liệu người này phải trả tài sản mới đó hoặc chỉ trả giá trị của tài sản dùng để mua hoặc đổi ?

[53] Thế nhưng, người giấu giếm sẽ không ở trong tình trạng không có quyền hưởng di sản của người bị tuyên bố là đã chết sau khi người sau này chết thật; bởi trong các trường hợp ghi nhận tại BLDS Điều về tình trạng không có quyền hưởng di sàn, không có trường hợp nêu tạI Điều 83 khoản 3 đã dẫn. Vậy, ngườI bị buộc phải hoàn trả tài sản sẽ có cơ hội thu lại những tài sản đó sau khi người bị tuyên bố là đã chết chết thật, nếu người sau này không chủ động truất quyền hưởng di sản của người đó bằng di chúc..

[54] Có ý kiến cho rằng người phụ nữ chưa đủ 18 tuổi cũng được coi là có năng lực hành vi đầy đủ, nếu kết hôn. Ý kiến này xuất phát từ nhận xét theo đó, Luật hôn nhân và gia đình, khi quy định tuổi kết hôn tối thiểu, đã

như cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.
Tình trạng có năng lực hành vi không đầy đủ lại được chia thành hai cấp độ: người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi chỉ có quyền xác lập các giao dịch gọi nôm na là "lặt vặt"; người chưa thành niên từ đủ mười lăm tuổi trở lên được phép xác lập các giao dịch quan trọng, nếu có tài sản riêng đủ để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và nếu pháp luật không có quy định khác (Điều 20)[55].

Không có năng lực hành vi và không có năng lực pháp luật. Không có năng lực pháp luật được hiểu là tình trạng không có khả năng hưởng quyền, không có khả năng trở thành chủ thể của quyền (suy lý ngược BLDS Điều 14). Năng lực pháp luật có thể được hình dung theo nghĩa tích cực - khả năng hưởng quyền, hoặc theo nghĩa tiêu cực- khả năng đảm nhận nghĩa vụ. Bởi vậy, tình trạng không có năng lực pháp luật cũng có thể được ghi nhận theo hai khía cạnh đó.
Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi. Vấn đề có hay không có năng lực hành vi chỉ được đặt ra trong trường hợp đương sự có năng lực pháp luật: nếu đương sự không có khả năng hưởng quyền, đảm nhận nghĩa vụ, thì không cần thiết đặt vấn đề thực hiện quyền, nghĩa vụ.
Vả lại, tình trạng mất năng lực hành vi có thể được khắc phục; còn tình trạng mất năng lực pháp luật thì không. Người không có năng lực hành vi vẫn có thể xác lập một số giao dịch thông qua vai trò của người đại diện, trừ những giao dịch mà theo quy định của pháp luật phải do chính chủ thể xác lập và thực hiện[56], như sẽ thấy sau đây; trong khi đó, tình trạng mất năng lực pháp luật là không thể cứu chữa: người không có năng lực pháp luật không thể xác lập giao dịch bị cấm, dù dưới hình thức nào và bằng cách nào[57].
Không có năng lực đặc biệt và không có năng lực tổng quát. Trong học thuyết pháp lý latinh, còn có sự phân biệt giữa không có năng lực trong một số trường hợp (gọi là không có năng lực đặc biệt) và không có năng lực trong mọi trường hợp (gọi là không có năng lực tổng quát).

- Không có năng lực đặc biệt là tình trạng không có năng lực đối với một số giao dịch được xác định cụ thể.

- Không có năng lực hành vi đặc biệt là tình trạng không được tự mình trực tiếp thực hiện một hoặc nhiều quyền hoặc nghĩa vụ mà mình là chủ thể. Người không có năng lực hành vi đặc biệt vẫn có thể tự mình thực hiện tất cả những quyền và nghĩa vụ không bị cấm thực hiện. Ví dụ, người từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không có quyền tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch mang tính chất định đoạt đối với các tài sản có giá trị lớn, nhưng vẫn có quyền tự mình quản lý tài sản của mình và thậm chí tự mình định đoạt những tài sản có giá trị không lớn. Người thuộc giới tính nam đã thành niên mà chưa đủ 20 tuổi không thể kết hôn, nhưng có thể giao kết tất cả các loại hợp đồng dân sự, lập di chúc,…

- Không có năng lực pháp luật đặc biệt là tình trạng không có khả năng hưởng một hoặc nhiều quyền cụ thể. Người không có năng lực pháp luật đặc biệt vẫn có khả năng hưởng các quyền không bị cấm hưởng. Ví dụ, người chưa được 18 tuổi không có năng lực pháp luật kết hôn; người chưa đủ 14 tuổi không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhưng vẫn có

---

không đòi hỏi người phụ nữ phải đủ 18 tuổi. Thực ra, câu chữ của điều luật liên quan đến tuổi kết hôn tối thiểu trong Luật hôn nhân và gia đình không phản ánh trung thực ý chí của người làm luật. Trong khung cảnh của chính sách dân số, người làm luật không bao giờ khuyến khích việc kết hôn của người chưa thành niên. Chẳng qua, khi soạn thảo điều luật về tuổi kết hôn, người làm luật, dường như hơi "mất tập trung", đã lấy lại câu chữ của các Luật hôn nhân và gia đình trước đây.

[55] Theo Luật hôn nhân và gia đình Điều 46 khoản 2, người chưa thành niên đủ 15 tuổi muốn định đoạt tài sản có giá trị lớn hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Điều này có nghĩa rằng càng có nhiều tài sản, người chưa thành niên đủ 15 tuổi càng gần với tình trạng có đủ năng lực hành vi và sự giám sát của người đại diện càng được thu hẹp lại

[56] Xin ly hôn, chẳng hạn

[57] Bởi vậy, trong nhiều trường hợp, đặt một người vào tình trạng mất năng lực pháp luật được hình dung như một biện pháp chế tài. Ví dụ điển hình là việc cấm hành nghề, cấm đảm nhiệm một số chức vụ…. như là hình phạt bổ sung đối với người bị kết án về một số tội trong lĩnh vực kinh tế.

năng lực pháp luật thừa kế.

- Không có năng lực tổng quát là tình trạng không có năng lực đối với tất cả các loại giao dịch. Tình trạng không có năng lực hành vi có thể mang tính chất tổng quát: có những người (không có năng lực hành vi) không được phép tự mình thực hiện bất kỳ một giao dịch nào, dù quan trọng hay không quan trọng. Ví dụ điển hình là trường hợp người chưa đủ 6 tuổi.

Trái lại, tình trạng không có năng lực pháp luật chỉ được ghi nhận theo trường hợp. Nói rõ hơn, không thể có tình trạng mất năng lực pháp luật tổng quát, đặc trưng bằng việc một người không có khả năng hưởng bất kỳ một quyền nào và cũng không thể đảm nhận bất ký nghĩa vụ nào. Không có năng lực pháp luật tổng quát, đương sự không phải là chủ thể của quan hệ pháp luật và đó là điều không thể chấp nhận được trong một xã hội tôn trọng quyền con người[58].

Trong trường hợp một quyền nào đó tồn tại trong thời gian không xác định, thì tình trạng không có năng lực pháp luật phải được giới hạn trong thời gian, để, đến một lúc nào đó, chủ thể có thể khôi phục năng lực hưởng quyền đó. Chẳng hạn, quyền tự do kinh doanh tồn tại chừng nào chủ thể còn tồn tại; một chủ thể có thể mất năng lực pháp luật kinh doanh

1.2. Tính chất ngoại lệ của tình trạng không có năng lực hành vi

Trên nguyên tắc, mỗi người sinh ra đều có năng lực hành vi để giao tiếp, xác lập, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc sống dân sự. Thế nhưng, nguyên tắc này chỉ được áp dụng trong chừng mực chủ thể có khả năng chịu trách nhiệm về những hệ quả của hành vi do mình thực hiện. Khả năng chịu trách nhiệm, về phần mình, được lý giải bởi khả năng nhận thức của chủ thể về tính chất của giao dịch do mình xác lập, về tầm quan trọng của những hệ quả phát sinh từ giao dịch đó. Do những nguyên nhân khác nhau, không phải ai cũng có được khả năng nhận thức đó; bởi vậy, trong một số trường hợp đặc thù, nguyên tắc này phải bị gạt bỏ và thay vào đó, các ngoại lệ của nguyên tắc được thừa nhận.

Ngoại lệ do điều kiện tự nhiên. Các ngoại lệ do điều kiện tự nhiên bao gồm tình trạng hoàn toàn không có năng lực hành vi do chưa đủ 6 tuổi và tình trạng có năng lực hành vi không đầy đủ do chưa đủ 18 tuổi. Những người chưa đủ 18 tuổi được cho là chưa đủ chín mùi về thể chất để có thể nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tác động xã hội, pháp lý của hành vi do mình thực hiện. Sự suy đoán là không thể đảo ngược, nghĩa là không ai có thể nói khác đi.

Ngoại lệ do điều kiện tự nhiên được áp dụng mà không cần một thủ tục pháp lý nào: chừng nào đương sự chưa đạt đủ 18 tuổi, tình trạng chưa đủ năng lực hành vi được thiết lập một cách đương nhiên.

Ngoại lệ do quy định của pháp luật. Các ngoại lệ do quy định của pháp luật bao gồm tình trạng mất năng lực hành vi do không nhận thức được hành vi của mình và tình trạng hạn chế năng lực.

Khác với ngoại lệ do điều kiện tự nhiên, ngoại lệ do pháp luật quy định đòi hỏi sự can thiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong điều kiện đương sự đang được thừa nhận hoàn toàn có đủ năng lực hành vi, nhưng không xứnbg đáng với sự thừa nhận đó nữa, do những khiếm khuyết nghiêm trọng về thể chất hoặc về nhân cách. Bởi vậy:

- Người mắc bệnh gì đó mà không nhận thức được hành vi của mình vẫn là người có năng lực hành vi đầy đủ cho đến khi nào bị đặt trong tình trạng mất năng lực hành vi bằng một bản án của Toà án[59]. Tương tự, người thường xuyên có hành vi phá tán tài sản vẫn có năng lực hành vi đầy đủ và vẫn có quyền tự mình xác lập mọi giao dịch (bao gồm các giao dịch

---

[58] Trong xã hội chiếm hữu nô lệ, người nô lệ thực sự là người không có năng lực pháp luật tổng quát và không có tư cách chủ thể. Đó chỉ là một thứ tài sản của chủ nô.

Ở Pháp, có thời kỳ cá nhân có thể bị tuyên phạt "chết dân sự" (mort civile). Với hình phạt đó, cá nhân vẫn sống về phương diện vật chất, nhưng không còn được coi là tồn tại về mặt pháp lý. Đây thực sự là tình trạng mất năng lực pháp luật tổng quát. Hình phạt này đã bị huỷ bỏ từ năm 1954.

[59] Do người này vẫn có năng lực hành vi đầy đủ mà trong trường hợp người cùng giao kết hợp đồng muốn vô hiệu hoá hợp đồng với lý do người này không nhận thức được hành vi của mình, thì chính người cùng giao kết phải chứng minh điều đó.

có tính chất phá tán) chừng nào chưa bị tuyên bố hạn chế năng lực hành vi bằng một bản án của Toà án.

- Người đã bị đặt trong tình trạng mất năng lực hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi bằng một bản án của Toà án sẽ ở trong tình trạng này, chừng nào bản án chưa được dỡ bỏ, ngay cả trong trường hợp đã khôi phục hoàn toàn khả năng nhận thức của mình hoặc đã chấm dứt hoàn toàn các hoạt động mang tính chất phá tán tài sản.

1.3. Lý lẽ của nguyên tắc và ngoại lệ

1.3.1. Lý lẽ của nguyên tắc

Hệ quả tất yếu của việc thừa nhận sự bình đẳng giữa các chủ thể. Việc thiết lập nguyên tắc theo đó, mỗi người đều được thừa nhận có đầy đủ năng lực hành vi xuất phát từ một quy tắc cơ bản của luật về quyền chủ thể: mỗi người đều được đối xử ngang nhau trong việc xác lập tư cách chủ thể của các quyền; mỗi người có quyền đều được đối xử ngang nhau trong việc thực hiện quyền của mình. Quy tắc đó có nguồn gốc từ sự tự do của con người và từ chân lý "con người sinh ra bình đẳng".

1.3.2. Lý lẽ của ngoại lệ

Sự khác biệt giữa các chủ thể. Sự đối xử ngang nhau dành cho các chủ thể chỉ tỏ ra hợp lý một khi các chủ thể có khả năng nhận thức, khả năng chịu trách nhiệm ngang nhau, cũng như đều xứng đáng như nhau trong việc hưởng quyền, đảm nhận nghĩa vụ. Trên thực tế, điều này không phải lúc nào cũng được bảo đảm. Một cách hợp lý, các chủ thể khác nhau về khả năng nhận thức, chịu trách nhiệm hoặc ở những mức độ xứng đáng khác nhau sẽ được đối xử không giống nhau.

Tình trạng không có năng lực hành vi. Tình trạng không có năng lực hành vi được thiết lập nhằm mục đích cao nhất là bảo vệ những người không có năng lực, chống lại việc người này tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản của mình trong điều kiện không có hoặc không đủ khả năng đánh giá tầm quan trọng của các hệ quả pháp lý mà giao dịch ấy có thể mang lại cho mình.

Tính chất bảo vệ đối với người không có năng lực hành thể hiện rõ nét ở việc tổ chức và vận hành cơ chế đại diện cho người không có năng lực hành vi, như ta sẽ thấy. Cơ chế đại diện cho phép cả sự giám sát và sự can thiệp của người đại diện vào các giao dịch xác lập nhân danh người không có năng lực hành vi.

Không có năng lực pháp luật. Trái lại, tình trạng không có năng lực pháp luật được thiết lập với các mục đích đa dạng, được xác định gần như tuỳ theo trường hợp

Có trường hợp không có năng lực pháp luật được hiểu như một biện pháp chế tài. Chẳng hạn, người bị kết án về tội tham ô không có năng lực pháp luật đảm nhận các công việc mang tính chất quản lý tài sản của người khác; người bị kết án về các tội xâm phạm tính mạng, danh dự, nhân phẩm của trẻ em không có năng lực pháp luật nuôi con nuôi.

Có trường hợp không có năng lực pháp luật được hiểu là biện pháp bảo vệ đương sự. Ví dụ điển hình là tình trạng không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự của người chưa đủ 14 tuổi, của người không nhận thức được hành vi của mình: người này, dù phạm tội, không thể chịu hình phạt mà được xử lý bằng những biện pháp đặc biệt có tác dụng

Có trường hợp không có năng lực pháp luật mang ý nghĩa kép: vừa bảo vệ đương sự, vừa bảo vệ người thứ ba chống lại những hành động thiếu suy nghĩ của đương sự có thể dẫn đến hậu quả bất lợi cho người thứ ba, thậm chí cho xã hội. Ví dụ điển hình là tình trạng không có năng lực pháp luật lập di chúc của người chưa đủ 15 tuổi: người này có thể định đoạt tài sản của mình một cách thiếu suy nghĩ, nhưng cũng có thể định đoạt tài sản của người khác mà không biết. Tình trạng không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự của người dưới 14 tuổi cũng có thể được hiểu theo nghĩa kép đó: một mặt, người phạm tội dưới 14 tuổi không chịu trách nhiệm hình sự; mặt khác, nạn nhân của người phạm tội dưới 14 tuổi có thể được bảo vệ trong trường hợp người phạm tội chịu sự xúi giục của người khác.

MỤC 4 - Bảo vệ người không có năng lực hành vi

Bảo vệ người không có năng lực hành vi trong đời sống dân sự. Người không có năng lực hành vi vẫn có khả năng hưởng các quyền và nghĩa vụ dân sự; tuy nhiên, trên nguyên tắc, luật không cho phép người này tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó, bởi trong hầu hết các trường hợp, người này không đủ khả năng nhận định, đánh giá ý nghĩa, tầm quan trọng của các quyền và nghĩa vụ mà mình là chủ thể. Luật nói rằng người không có khả năng tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự nhất thiết phải được đại diện trong quá trình xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó. Chế độ đại diện cho người không có năng lực hành vi mang ý nghĩa bảo vệ người được đại diện trong đời sống dân sự, nhằm ngăn ngừa và chống các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người này[60].
Chế độ đại diện cho người không có năng lực hành vi không giống nhau, tuỳ theo người được đại diện là người chưa thành niên hoặc đã thành niên.

1. Đại diện cho người chưa thành niên

Khái niệm người chưa thành niên. Theo BLDS Điều 18, người đủ 18 tuổi trở lên là người thành niên; người chưa đủ 18 tuổi là người chưa thành niên. Trên nguyên tắc, người thành niên có quyền tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự và tự mình thực hiện các nghĩa vụ của mình[61]. Còn người chưa thành niên phải được đại diện hoặc được hỗ trợ trong cuộc sống dân sự.
Người chưa thành niên có thể được đại diện hoặc được hỗ trợ bởi cha, mẹ hoặc người giám hộ.

1.1. Giám hộ đối với người chưa thành niên

Định nghĩa. Giám hộ đối với người chưa thành niên là việc cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên (BLDS Điều 58 khoản 1).
Trong những trường hợp nào người chưa thành niên cần có người giám hộ ?. Được giám hộ, người chưa thành niên nào không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên và có yêu cầu cử giám hộ (Điều 58 khoản 2 điểm a).
Việc cử người giám hộ là bắt buộc trong trường hợp người chưa thành niên chưa đủ 15 tuổi mà rơi vào các trường hợp nêu ở trên (Điều 58 khoản 3).
Luật bỏ quên trường hợp cả cha và mẹ của người chưa thành niên đều vắng mặt hoặc bị tuyên bố mất tích. Có thể dùng phương pháp áp dụng tương tự pháp luật đối với Điều 58 khoản 2 điểm a để thừa nhận rằng việc cử người giám hộ cho người chưa thành niên cũng cần thiết trong trường hợp này, đặc biệt là khi người chưa thành niên chưa đủ 15 tuổi.
Giám hộ gia đình và giám hộ công. Giám hộ gia đình về mặt hình thức là việc giám hộ được thực hiện bởi một hoặc nhiều người có quan hệ thân thích với người được giám hộ, do mối liên hệ thân thuộc hoặc liên hệ hôn nhân. Về nội dung, giám hộ gia đình là một cơ chế mô phỏng cơ chế quản lý kiểu gia đình. Các công việc giám hộ không chỉ liên quan đến tài sản mà còn mang ý nghĩa của việc tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ tình cảm gia đình giữa những người có liên quan.
Giám hộ công, về mặt hình thức, là việc giám hộ do một cơ quan nhà nước hoặc một tổ chức xã hội, gọi chung là một thiết chế công, đảm nhận. Giám hộ công mang tính chất của một

---

[60] Chế độ đại diện người không có năng lực hành vi còn mang ý nghĩa bảo vệ người thứ ba nhằm ngăn ngừa và chống các hành vi của người không có năng lực hành vi xâm hại đến lợi ích của người thứ ba. Trong điều kiện người không có năng lực hành vi không có khả năng tự mình chịu trách nhiệm về hậu quả của những hành vi do mình thực hiện, người thứ ba bị thiệt hại khó có cơ may được bồi thường một cách thoả đáng, nếu người không có năng lực hành vi không được đại diện.

[61] Trong luật thực định Việt Nam, không phải người nào đã thành niên cũng đều có quyền xác lập tất cả các giao dịch trong cuộc sống dân sự: nam, dù đã thành niên, không thể kết hôn. Ngược lại, không phải người nào chưa đủ 18 tuổi cũng đều bị cấm tự mình xác lập các giao dịch quan trọng: nữ, chỉ cần được 18 tuổi, đã có thể kết hôn. Nếu việc cấm nam kết hôn khi chưa được 20 tuổi là phù hợp với chính sách dân số hiện hành, thì việc cho phép nữ kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi chỉ là một lỗi lập pháp rất đáng tiếc… và đáng trách. Càng đáng tiếc hơn nữa, vì không có một lời xin lỗi từ phía những người soạn thảo điều luật này

hoạt động xã hội, từ thiện. Mục đích cao nhất của giám hộ công là bảo vệ tài sản của người được giám hộ và bảo vệ chính người được giám hộ về mặt nhân thân chống lại những rủi ro có thể đến từ người thứ ba do việc lợi dụng khả năng nhận thức non kém của người được giám hộ.

Giám hộ: công việc không thù lao và không được chuyển giao. Giám hộ không phải là một nghề, cũng không được coi là một hoạt động tạo thu nhập. Người giám hộ bỏ sức lao động vì lợi ích của người khác, theo cung cách của một người làm việc tình nguyện, không vụ lợi. Tất nhiên, người giám hộ không bị buộc phải lấy tài sản của mình phục vụ cho người khác; bởi vậy, nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám hộ mà người giám hộ phải dùng đến các tài sản của mình, thì người này có quyền yêu cầu hoàn trả theo đúng giá trị. Trái lại, người giám hộ không có quyền yêu cầu trả thù lao[62], cũng không có quyền yêu cầu bồi hoàn công sức lao động của mình trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, nhiệm vụ của người giám hộ là nhiệm vụ gắn với nhân thân của người này. Trong trường hợp người giám hộ chết, việc giám hộ chấm dứt một cách đương nhiên: những người thừa kế của người giám hộ chỉ có trách nhiệm thanh toán công việc giám hộ của người chết chứ không có trách nhiệm (và cũng không có quyền) tiếp tục các công việc của người này.

Tính chất của việc giám hộ đối với người chưa thành niên. Trẻ em, trong điều kiện, hoàn cảnh bình thường, phải là thành viên của một gia đình và sự chăm sóc, giáo dục của gia đình là điều cần thiết cho sự phát triển lành mạnh của trẻ, trong quá trình chuẩn bị bước vào cuộc sống xã hội trong tư thế một chủ thể đầy đủ.

Việc giám hộ đối với người chưa thành niên, tức là đối với trẻ em, không ngoài mục đích thay thế sự chăm sóc, giáo dục mang tính chất gia đình mà người được giám hộ đã không có, cũng nhằm mục đích bảo đảm các điều kiện phát triển bình thường cho người đó. Bởi vậy, người giám hộ được chỉ định theo thứ tự ưu tiên được thiết lập dựa vào mức độ thân thuộc giữa người giám hộ và người được giám hộ.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng giám hộ không thể thay thế một cách hoàn hảo vai trò của cha mẹ. Người giám hộ không phải là người trực tiếp tạo ra người được giám hộ; bởi vậy, không thể trông đợi ở người giám hộ sự chăm sóc, giáo dục như là kết quả sự thôi thúc của một thiên hướng tự nhiên, như trong trường hợp của người giám hộ tự nhiên, là cha mẹ. Đặc biệt sự giám hộ công mang tính chất bảo trợ xã hội đối với sự phát triển của chủ thể hơn là sự thay thế gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục người được giám hộ.

1.1.1. Tổ chức việc giám hộ

Có hai loại người tham gia vào việc giám hộ: người giám hộ và người giám sát việc giám hộ.

1.1.1.1. Người giám hộ

Điều kiện về nhân thân. Theo BLDS Điều 60, cá nhân có đủ các điều kiện sau đây thì có thể làm người giám hộ: đủ 18 tuổi trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; có tư cách đạo đức tốt, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc là người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm, tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác[63]; có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ (Điều 69)[64].

Luật không có quy định gì về điều kiện đặt ra đối với tổ chức làm giám hộ; tuy nhiên, đó nhất

---

[62] Giữa người giám hộ và người cử giám hộ cũng không thể có một thoả thuận về việc trả thù lao cho công tác giám hộ; bởi, suy cho cùng, người cử giám hộ không có quyền định đoạt tài sản của người được giám hộ dưới hình thức dùng tài sản ấy trả thù lao cho người giám hộ.

[63] Đáng lý ra, nên cấm làm người giám hộ, một cách tổng quát, đối với người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị phạt tù mà chưa được xoá án, bất kể về tội gì. Suy cho cùng, người giám hộ phải trong sạch về mặt tư pháp thì mới xứng đáng đảm nhận tư cách đó: về mặt đạo lý, liệu một người phạm tội buôn lậu có thể được cử làm giám hộ ?

[64] Điều kiện cần thiết, dù luật không nói rõ, có lẽ là điều kiện về tài sản. Thực khó hình dung một người không có khả năng thanh toán nợ nần của bản thân lại đi quản lý tài sản của người khác.

thiết phải là một tổ chức có thiên hướng hoạt động xã hội, chẳng hạn, Hội liên hiệp phụ nữ, Uỷ ban bảo vệ-chăm sóc trẻ em,…;
Một người có thể làm giám hộ cho nhiều người chưa thành niên. Trái lại, một người chưa thành niên chỉ có thể được một người giám hộ trừ trường hợp giám hộ là ông, bà (Điều 58 khoản 4)[65].
Giám hộ đương nhiên và giám hộ được cử. Luật phân biệt người giám hộ đương nhiên và người giám hộ được cử. Việc cử giám hộ chỉ được tiến hành trong trường hợp không có giám hộ đương nhiên

Giám hộ đương nhiên được pháp luật chỉ định theo thứ tự ghi nhận tại BLDS Điều 61. Cụ thể, nếu người chưa thành niên có anh, chị đã thành niên, thì anh, chị cả là giám hộ đương nhiên; nếu anh, chị cả không đủ điều kiện để làm người giám hộ, thì anh, chị tiếp theo là giám hộ đương nhiên; nếu không có anh, chị hoặc anh, chị không đủ điều kiện làm người giám hộ, thì ông, bà nội, ông bà ngoại là giám hộ đương nhiên;
Nếu không có giám hộ đương nhiên, thì những người thân thích của đương sự cử một người trong số họ làm người giám hộ; nếu không có ai trong số những người thân thích đủ điều kiện làm người giám hộ, thì họ có thể cử một người khác làm người giám hộ; nếu những người thân thích không cử được người giám hộ, thì UBND xã, phường, thị trấn (nơi người được giám hộ cư trú) có trách nhiệm cử người giám hộ hoặc đề nghị một tổ chức đảm nhận việc giám hộ[66]. Luật không có quy định gì về thể thức cử người giám hộ: có thể chỉ cần một trong những người thân thích đề ra sáng kiến, người được cử theo sáng kiến đó đồng ý, là xong.
Cần nhấn mạnh rằng ngay cả trong trường hợp giám hộ đương nhiên, thì việc giám hộ chỉ có giá trị một khi người giám hộ đồng ý nhận nhiệm vụ giám hộ[67]. Song, có thể thừa nhận rằng sự đồng ý của người giám hộ đương nhiên có thể được ghi nhận bằng một hành vi cụ thể chứ không nhất thiết bằng sự bày tỏ ý chí rành mạch. Luật, về phần mình, chỉ quy định điều kiện thủ tục đối với giám hộ được cử.
Điều kiện thủ tục. Giám hộ đương nhiên, do bản chất, được thiết lập một khi các điều kiện nội dung có đủ; người giám hộ đương nhiên không cần có văn bản, cũng không phải đăng ký tư cách giám hộ của mình.
Trong các trường hợp không có giám hộ đương nhiên, việc cử người giám hộ phải được ghi nhận bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do cử người giám hộ, quyền và nghĩa vụ của người giám hộ, tình trạng tài sản của người này (Điều 64 khoản 1).
Luật không nói rõ ai là người phải lập văn bản và nội dung của văn bản phải như thế nào mới coi là hợp lệ. Tuy nhiên, trong logic của sự việc, chính người cử người giám hộ phải tỏ ra mẫn cán trong việc này. Vả lại, do luật đòi hỏi việc cử người giám hộ phải được sự đồng ý của người này, hẳn sự đồng ý đó cũng phải được ghi nhận trong văn bản cử người giám hộ.
Luật cũng không đòi hỏi văn bản cử người giám hộ phải được đăng ký. Thế nhưng, theo Nghị định số 158 ngày 27/12/2005 của Chính Phủ Điều 30, thì việc giám hộ phải được đăng ký tại UBND xã nơi cư trú của người giám hộ hoặc nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ. Điều khó hiểu là Nghị định chỉ đề cập trường hợp giám hộ được cử và không nói gì đến việc đăng ký giám hộ đương nhiên.
Cũng theo Điều 30 Nghị định, người được cử làm giám hộ phải nộp giấy cử giám hộ. Trên thực tế, UBND còn yêu cầu các giấy tờ khác như CMND, khai sinh, hộ khẩu,… Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc giám hộ đủ điều kiện theo quy

[65] Ở nhiều nước, luật cho phép chỉ định nhiều người giám hộ cho một người.

[66] Trước đây BLDS năm 1995 quy định rằng nếu không có người giám hộ đương nhiên thì UBND xã (phường, thị trấn) nơi người được giám hộ cư trú ïphối hợp với các tổ chức xã hội tại cơ sở cử người giám hộ hoặc đề nghị tổ chức từ thiện đảm nhận việc giám hộ; nếu vẫn không cử được người giám hộ theo cách đó, thì UBND xã, phường, thị trấn đề nghị cơ quan lao động, thương binh và xã hội nơi cư trú của người được giám hộ đảm nhận trách nhiệm giám hộ. Các quy định chi tiết này đã không được người làm luật năm 2005 lấy lại.
[67] Thực ra, luật chỉ đòi hỏi sự đồng ý của người giám hộ trong trường hợp giám hộ được cử (BLDS Điều 64 khoản 2). Tuy nhiên, trong điều kiện giám hộ là một công tác được thực hiện vì lợi ích của một người khác, sự đồng ý, tự nguyện của người giám hộ là cần thiết cho việc bảo đảm chất lượng của công tác đó

định của pháp luật, thì UBND đăng ký việc giám hộ. Trường hợp cần xác minh thời hạn này được kéo dài thêm không quá 5 ngày.
Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt. Cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký giám hộ và quyết định công nhận việc giám hộ. Chủ tịch UNBD ký và cấp cho người giám hộ và người cử giám hộ mỗi bên một bản chính quyết định công nhận việc giám hộ. Bản sao quyết định công nhận việc giám hộ được cấp theo yêu cầu của người giám hộ và người cử giám hộ.
Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, thì người cử giám hộ phải lập danh mục tài sản và ghi rõ tình trạng của tài sản đó, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ. Danh mục tài sản được lập thành 3 bản, giao cho người cử giám hộ, người được cử làm giám hộ, và để lưu tại UBND.
Thực ra, không ai hiểu tại sao giám hộ đương nhiên thì không phải đăng ký, còn giám hộ được cử thì phải đăng ký theo một thủ tục khá rườm rà. Đặc biệt, trong trường hợp giám hộ đương nhiên đối với người có tài sản thì vấn đề lập danh mục tài sản của người được giám hộ không được đặt ra.
Vả lại, cả giám hộ đương nhiên và và giám hộ được cử đều có người giám sát việc giám hộ. Thế mà việc giám sát việc giám hộ lại không phải đăng ký, cả trong trường hợp việc giám hộ phải đăng ký. Kỳ lạ hơn nữa, là trong trường hợp người thân thích không cử được người giám sát việc giám hộ, thì UBND có trách nhiệm cử người giám sát: UBND làm thế nào cử người giám sát đối với người giám hộ đương nhiên, trong điều kiện giám hộ đương nhiên không đăng ký ? Cuối cùng, trong trường hợp UBND cử người giám sát, thì thủ tục cử người ra sao, Nghị định số 152 không nói rõ.
Có vẻ như người làm luật gặp khá nhiều lúng túng khi tìm cách hoàn thiện chế định dù không phải là mới, nhưng ít được áp dụng trong thực tiễn, như chế định giám hộ này.

1.1.1.2. Giám sát việc giám hộ

Sự cần thiết của việc giám sát việc giám hộ. Việc giám hộ chỉ thực sự mang lại lợi ích cho người được giám hộ một khi người giám hộ thực hiện công tác của mình với sự tận tâm và thái độ trách nhiệm cần thiết. Tất nhiên, người giám hộ thường có ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ của mình một cách mẫn cán; song, nếu không có sự kiểm soát, giám sát khách quan đối với công việc của người này, thì những rủi ro đối với lợi ích của người được giám hộ có thể không được ngăn chặn kịp thời.
Cử người giám sát việc giám hộ. Trong thời gian áp dụng BLDS năm 1995, việc giám sát được giao cho UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ. Thế nhưng, cơ chế giám sát này có vẻ không phù hợp với khung cảnh chung, với các thói quen phổ biến và do đó, đã không bao giờ vận hành trên thực tế.
BLDS năm 2005 trao trả công việc giám sát việc giám hộ cho gia đình[68]. Theo Điều 59 khoản 1, người thân thích của người được giám hộ có trách nhiệm cử người đại diện làm người giám sát việc giám hộ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra người giám hộ trong việc thực hiện giám hộ. Chỉ trong trường hợp không có người thân thích, thì UBND mới can thiệp trong việc cử người giám sát.
Cũng theo điều luật đó, người thân thích của người được giám hộ là vợ, chồng, cha, mẹ, con của người được giám hộ; nếu không có ai trong số những người này, thì người thân thích là ông bà (nội, ngoại), anh, chị, em ruột của người được giám hộ; nếu cũng không có ai trong số những người này, thì người thân thích là bác, chú, cô, cậu, dì ruột của người được giám hộ. Nếu hoàn toàn không có ai trong số những người này hoặc vì lý do gì đó, mà những người này không cử được người giám sát việc giám hộ, thì UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ cử người giám sát việc giám hộ (Điều 59 khoản 2).
Về tiêu chuẩn để làm người giám sát việc giám hộ, luật chỉ yêu cầu người này có đủ năng lực hành vi (Điều 59 khoản 3), các điều kiện khác, đặc biệt là vấn đề trong sạch về mặt tư

[68] Gọi là "trao trả", bởi trên thực tế, việc chăm sóc, quản lý người chưa thành niên và những người có khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần thường được các thành viên gia đình của đương sự đảm nhận.

pháp, không được đặt ra.

Luật không quy định thể thức, thủ tục cử người giám sát việc giám hộ. Đặc biệt, trong trường hợp có nhiều người thân thích và giữa họ có sự bất đồng ý kiến trong việc cử người giám sát, thì luật không quy định cách thức giải quyết tranh cãi. Có vẻ người làm luật muốn để gia đình tự thu xếp, theo tập quán, tục lệ[69]. Riêng trong trường hợp không có người thân thích của người được giám hộ, thì hẳn UBND chỉ định người giám sát việc giám hộ bằng một văn bản.

Dẫu sao, trong logic của cơ chế, việc cử người giám sát việc giám hộ phải được thông báo cho người giám hộ, để người này biết mình phải liên hệ với ai trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Có lẽ, người nào cử người giám sát việc giám hộ, thì đồng thời cũng có trách nhiệm thực hiện việc thông báo đó.

Số lượng người giám sát việc giám hộ. Khác với trường hợp giám hộ, luật không quy định số lượng người giám sát việc giám hộ. Về mặt lý thuyết, có thể cử nhiều người giám sát, tuy nhiên, có lẽ thực tiễn sẽ có xu hướng tinh giản cấu trúc giám sát để giảm chi phí, cũng như giảm cả những rủi ro tranh cãi không cần thiết giữa những người giám sát trong quá trình thực hiện chức năng của mình, những tranh cãi không có lợi cho người được giám hộ.

1.1.2. Cơ chế hoạt động giám hộ

1.1.2.1. Thân phận của người được giám hộ

Giám hộ toàn phần và giám hộ một phần. Người được giám hộ, nếu chưa đủ sáu tuổi, chỉ có thể xác lập, thực hiện các giao dịch thông qua vai trò của người giám hộ (Điều 21). Ta nói rằng cho đến khi đủ sáu tuổi, người được giám hộ được đặt dưới chế độ giám hộ toàn phần.

Người được giám hộ từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể tự mình xác lập các giao dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi, các giao dịch khác chỉ có thể được xác lập và thực hiện với sự đồng ý của người giám hộ (Điều 20); cá biệt, người đủ 15 tuổi mà chưa đủ 18 tuổi, nếu có tài sản riêng đủ để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, thì có thể tự mình xác lập các giao dịch, trừ những giao dịch mà luật đòi hỏi có sự đồng ý của người giám hộ (cùng điều luật), ví dụ, lập di chúc để định đoạt tài sản sau khi chết (Điều 647 khoản 2) hoặc định đoạt tài sản có giá trị lớn, dùng tài sản để đầu tư kinh doanh (Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 46)[70]. Ta nói rằng người được giám hộ từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được đặt dưới chế độ giám hộ một phần. Chế độ này được chia thành hai cấp độ, tuỳ theo người được giám hộ chưa đủ hay đủ 15 tuổi.

1.1.2.2. Nghĩa vụ và quyền của người giám hộ

1.1.2.2.1. Nghĩa vụ của người giám hộ

Các nghĩa vụ của người giám hộ đối với người chưa thành niên được quy định tại các Điều 65 và 66 BLDS. Nội dung của nghĩa vụ được xác định tuỳ theo giám hộ mang tính chất toàn phần hay một phần.

Giám hộ toàn phần. Các nghĩa vụ của người giám hộ toàn phần có thể được chia thành hai nhóm: nghĩa vụ mang ý nghĩa thay thế chức năng của cha mẹ và nghĩa vụ của người quản trị tài sản.

Thay thế cha mẹ, người giám hộ dành cho người được giám hộ sự chăm sóc, giáo dục của gia đình. Mặc dù luật không nói rõ, có vẻ như tất cả các nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục của cha mẹ đối với con chưa thành niên đều ràng buộc người giám hộ. Tất nhiên người giám hộ không nuôi dưỡng người được giám hộ bằng chi phí của mình; nhưng cung cách nuôi dưỡng (bằng

---

[69] Vấn đề là chế định giám sát việc giám hộ và cả chế định giám hộ không phải là một phần của truyền thống pháp lý Việt Nam. Bởi vậy, khó có thể tìm trong tục lệ những quy tắc liên quan. Việc chăm sóc người thân, bao gồm trẻ em và người không nhận thức được hành vi của mình, thường không chịu sự chi phối của tình cảm, đạo đức hơn là các chuẩn mực khách quan.

[70] Thực ra, Điều 46 khoản 2 chỉ nhắc đến sự đồng ý của cha mẹ. Ta có được giải pháp nêu trên nhờ nguyên tắc áp dụng tương tự pháp luật

chi phí của người được giám hộ) cũng phải theo khuôn mẫu của việc nuôi dưỡng mà cha mẹ dành cho con. Việc giáo dục người được giám hộ cũng mang đầy đủ các đặc điểm của giáo dục gia đình: người giám hộ dành cho người được giám hộ sự giáo dục nhân cách, đạo đức, hỗ trợ trong việc học tập và định hướng nghề nghiệp cho người được giám hộ.

Quản trị tài sản của người được giám hộ, người giám hộ phải gìn giữ, khai thác tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình (Điều 69 khoản 1), nghĩa là phải tránh làm mất mát, hư hỏng tài sản và bảo đảm sức sinh lợi của tài sản. Người giám hộ không chỉ nói đồng ý hay không đồng ý để người được giám hộ xác lập giao dịch với người thứ ba mà còn phải đại diện cho người sau này trong việc xác lập và thực hiện các giao dịch đó.

Giám hộ một phần. Trong trường hợp giám hộ một phần, cần phân biệt tuỳ theo người được giám hộ chưa đủ hay đủ 15 tuổi.

1. Nếu người được giám hộ chưa đủ 15 tuổi, thì người giám hộ phải đảm nhận cả hai nhóm nghĩa vụ như đối với đối với người được giám hộ chưa đủ 6 tuổi. Các nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục có vẻ không có gì khác về nội dung so với trường hợp giám hộ người chưa đủ 6 tuổi. Trái lại, các nghĩa vụ quản trị tài sản trở nên nhẹ hơn, do người được giám hộ một phần có thể tự mình xác lập, thực hiện một số giao dịch.

Theo BLDS Điều 20 khoản 1, người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác. Điều 65 khoản 2 lại quy định rằng người giám hộ đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp pháp luật quy định người chưa đủ 15 tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Kết hợp hai điều luật, có thể ghi nhận ba nhóm giao dịch của người được giám hộ đủ 6 tuổi nhưng chưa đủ 15 tuổi.

- Nhóm các giao dịch mà người này được phép tự mình xác lập, thực hiện mà không cần sự đồng ý của người giám hộ;
- Nhóm các giao dịch người này có thể tự mình xác lập, thực hiện nhưng phải có sự đồng ý của người giám hộ;
- Nhóm các giao dịch người này chỉ có thể xác lập, thực hiện thông qua vai trò của người giám hộ.

Luật chỉ xác định đặc điểm của nhóm giao dịch thứ nhất: đó là các giao dịch đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi[71]. Đối với hai nhóm còn lại, các giao dịch được ghi nhận chủ yếu trong tập quán. Chẳng hạn, người chưa thành niên chưa đủ 15 tuổi có thể tự mình nộp học phí (cho bản thân), có thể tiếp nhận các đồ vật, do người khác mượn của gia đình và nay hoàn trả lại,...

2. Nếu người được giám hộ đủ 15 tuổi, người giám hộ không còn các nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục mà chỉ còn các nghĩa vụ quản trị tài sản. Thậm chi, các nghĩa vụ quản trị tài sản cũng trở nên rất nhẹ nhàng, bởi theo quy định của pháp luật, người được giám hộ đủ 15 tuổi, trên nguyên tắc, có quyền tự mình quản lý các tài sản của mình (Luật hôn nhân và gia đình Điều 45 khoản 1); riêng trong trường hợp cần định đoạt tài sản
có giá trị lớn hoặc dùng tài sản để kinh doanh, thì phải có sự đồng ý của người giám hộ (cùng điều luật)[72]. Người từ đủ 15 tuổi trở lên còn có quyền lập di chúc, nếu người giám hộ đồng ý (BLDS Điều 647 khoản 2), như đã biết. Nói chung, một khi người được giám hộ đủ 15 tuổi, thì người giám hộ chấm dứt vai trò đại diện và chỉ còn giữ vai trò người hỗ trợ, giám sát người được giám hộ trong giao dịch.

1.1.2.2.1.1 Thực hiện các nghĩa vụ của người được giám hộ

Luật chưa hoàn thiện. Không có năng lực hành vi nhưng có năng lực pháp luật, người chưa thành niên có thể là chủ thể của các quan hệ nghĩa vụ với tư cách là người có nghĩa vụ. Các ví dụ rất đa dạng: người chưa thành niên được gọi để nhận thừa kế; thực hiện một hành vi

[71] Ví dụ, mua thức ăn sáng, quà vặt,…

[72] Pháp luật lao động hiện hành cho phép người đủ 15 tuổi tự mình giao kết hợp đồng lao động với tư cách là người lao động (BLLĐ Điều)

trái pháp luật gây thiệt hại vật chất cho người khác;…
Các nghĩa vụ của người được giám hộ chưa thành niên trên nguyên tắc, do người giám hộ thực hiện bằng tài sản của người được giám hộ. Tuy nhiên, có vẻ như luật chủ trương rằng nếu nghĩa vụ do chính người chưa thành niên tự mình xác lập phù hợp với các quy định của pháp luật và theo đúng ý chí, thì cũng chính người này tự mình thực hiện nghĩa vụ ấy, trừ các nghĩa vụ có tác dụng dịch chuyển tài sản có giá trị lớn. Nói chung, thái độ của người làm luật đối với vấn đề này không rõ ràng và điều này có thể gây khó khăn cho người thực hành luật trong trường hợp có tranh chấp: khác với việc thực hiện quyền, việc thực hiện nghĩa vụ của người được giám hộ đặt người này vào thế bất lợi và do đó, cần có biện pháp bảo vệ đặc biệt đối với người này.

1.1.2.2.2. Quyền của người giám hộ

Các quyền của người giám hộ được quy định tại các Điều 68 và 69 BLDS. Điều đáng chú ý đầu tiên là người làm luật không có quy định nào liên quan đến các quyền phi tài sản tương ứng với các nghĩa vụ phi tài sản (chăm sóc, giáo dục). Các quyền đối với tài sản của người được giám hộ được xây dựng trên nguyên tắc, theo đó, người giám hộ quản lý tài sản của người được giám hộ nhằm phục vụ lợi ích của người này.
Các Điều 68 và 69 không phân biệt tuỳ theo người được giám hộ đủ hay chưa đủ 15 tuổi. Tuy nhiên, như đã nói, người đủ 15 tuổi được thừa nhận có những quyền rộng rãi đối với tài sản của mình; bởi vậy, các quyền của người giám hộ chủ yếu được ghi nhận trong điều kiện người được giám hộ dưới 15 tuổi. Người giám hộ của người chưa thành niên đủ 15 tuổi trở lên hầu như chỉ có quyền giám sát và phê duyệt các giao dịch quan trọng của người được giám hộ.
Sử dụng tài sản. Theo Điều 68 khoản 1, người giám hộ có quyền sử dụng các tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu cần thiết của người được giám hộ. Có thể, từ điều luật ngắn gọn này, thừa nhận rằng, trên nguyên tắc, người giám hộ có các quyền sử dụng, mà pháp luật thừa nhận cho chủ sở hữu, đối với tài sản của người được giám hộ, trừ những quyền bị cắt bằng các quy định rành mạch của luật.
Đối với doanh nghiệp thuộc sở hữu của người được giám hộ, người giám hộ điều hành theo cung cách của chủ sở hữu, nghĩa là được quyền quyết định các công việc kinh doanh hàng ngày phù hợp với mục đích hoạt động của doanh nghiệp.
Riêng việc cho thuê, cho mượn tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ được coi là giao dịch quan trọng và được điều chỉnh theo cùng một cách như các giao dịch mang tính chất định đoạt tài sản.
Quyền định đoạt. Theo BLDS Điều 69 khoản 1, việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặc cọc và các giao dịch khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.
Nhận xét đầu tiên rút ra từ quy định đó là: người giám hộ có quyền định đoạt tài sản của ngưởi được giám hộ. Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của giao dịch cũng như khả năng gây rủi ro của nó đối với lợi ích của người được giám hộ, luật đặt các giao dịch đó dưới sự giám sát khách quan (của người giám sát việc giám hộ) để bảo đảm lợi ích của người được giám hộ không bị xâm hại.
Tuy nhiên, luật chỉ dự kiến việc áp dụng cơ chế này trong trường hợp đối tượng của giao dịch là các tài sản có giá trị lớn. Điều đó có nghĩa rằng trong trường hợp tài sản có giá trị không lớn, thì cơ chế không được áp dụng: người giám hộ có quyền tự mình xác lập các giao dịch ấy, miễn là việc đó phù hợp với lợi ích của người được giám hộ.

Người giám hộ có quyền sử dụng và định đoạt các tài sản của người được giám hộ, với điều kiện việc sử dụng và định đoạt đó phải phù hợp với lợi ích của người được giám hộ. Người giám hộ không có quyền tặng cho người khác tài sản của người được giám hộ, cũng không có quyền thay mặt người được giám hộ chấp nhận một di sản không có khả năng thanh toán hay từ chối một di sản có khả năng thanh toán. Người giám hộ chỉ có thể bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ (và có lẽ cả việc bảo lãnh bằng tài sản của người được giám hộ) một khi có sự đồng ý của UBND xã, phường, thị trấn nơi người giám hộ cư trú.

1.1.2.2.3. Các trường hợp đặc thù

Giao dịch giữa người giám hộ và người được giám hộ. Các quyền lợi của người được giám hộ được đặt dưới sự quản lý của người giám hộ; bởi vậy, nếu người giám hộ xác lập một giao dịch liên quan đến tài sản của người được giám hộ, mà mình cũng là bên tham gia giao dịch với tư cách là người giao kết, thì rủi ro hy sinh lợi ích của người được giám hộ cho người giám hộ là rất lớn. Nhận thấy được điều này, người làm luật chủ động quy định rằng người giám hộ không được xác lập các giao dịch với người được giám hộ liên quan đến tài sản của người sau này (Điều 69 khoản 3).

Tuy nhiên, trong điều kiện quy tắc được xây dựng nhằm bảo vệ lợi ích của người được giám hộ, lý lẽ của quy tắc sẽ mất đi trong trường hợp lợi ích của người được giám hộ được bảo vệ thoả đáng. Do đó, luật thừa nhận rằng các giao dịch giữa người giám hộ và người được giám hộ mà được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ thì vẫn có giá trị. Tuy nhiên, việc giao dịch có phù hợp hay không với lợi ích của người được giám hộ cần phải được người giám sát việc giám hộ đánh giá. Sự đồng ý của người này đối với giao dịch là điều kiện cần thiết để giao dịch có giá trị.

Tặng cho. Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác (Điều 69 khoản 2). Được đồng hoá với tặng cho, việc miễn cho một người thực hiện nghĩa vụ tài sản. Cũng có thể đồng hoá với tặng cho, việc từ chối nhận di sản mà người được giám hộ là người thừa kế được gọi để hưởng.

1.1.2.3. Thay đổi người giám hộ

Các trường hợp thay đổi người giám hộ. Theo BLDS Điều 70 khoản 1, việc thay

đổi người giám hộ có thể được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Cá nhân là người giám hộ không còn có đủ các điều kiện quy định tại Điều 60 BLDS;
- Cá nhân là người giám hộ chết, bị Toà án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự;
- Người giám hộ đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;
- Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác có đủ điều kiện nhận làm giám hộ.

Người làm luật quên mất trường hợp người giám hộ vắng mặt mà đã có thông báo tìm kiếm của Toà án. Có thể thừa nhận việc thay đổi người giám hộ trong trường hợp này nhờ phương pháp áp dụng tương tự pháp luật.

Thể thức thay đổi người giám hộ. Việc thay đổi người giám hộ phải được thực hiện theo thứ tự do luật quy định: người giám hộ đương nhiên được thay thế bằng người giám hộ đương nhiên kế tiếp; việc cử người giám hộ chỉ được thực hiện một khi không có giám hộ đương nhiên…

Việc chuyển giao việc giám hộ của người giám hộ được cử được quy định tại Điều 71 BLDS: phải lập thành văn bản có ghi nhận tình trạng tài sản của người được giám hộ; phải được sự chứng kiến và công nhận của UBND nơi người giám hộ mới cư trú và của người giám sát việc giám hộ;...

1.1.2.4. Chấm dứt việc giám hộ.

Các trường hợp chấm dứt việc giám hộ. Việc giám hộ đối với người chưa thành niên chấm dứt trong các trường hợp được dự liệu tại Điều 72 BLDS, đặc biệt, khi người được giám hộ đã thành niên, chết, được nhận làm con nuôi hoặc khi cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền đại diện theo luật đối với con chưa thành niên của mình.

Hệ quả của việc chấm dứt. Trong thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ phải thanh toán tài sản với người được giám hộ hoặc với cha, mẹ của người này (Điều 73 khoản 1). Trong trường hợp người được giám hộ chết, thì trong thời hạn ba tháng kể từ thời điểm mở thừa kế, người giám hộ phải thanh toán tài sản cho những người thừa kế của người chết; nếu chưa tìm được người thừa kế, thì người giám hộ tiếp tục quản lý tài sản của người chết (như một người quản lý thực tế di sản) cho đến khi tài sản được giải quyết theo các quy định của pháp luật về thừa kế và thông báo cho UBND xã, phường, thị trấn nơi người giám hộ cư trú (cùng điều luật).

Việc thanh toán tài sản được thực hiện với sự giám sát của người cử người giám hộ (nếu có) và UNBD xã, phường, thị trấn nơi người giám hộ cư trú (cùng điều luật).

1.2. Đại diện theo pháp luật cho con chưa thành niên

1.2.1. Tổ chức việc đại diện

Đại diện đương nhiên. Trừ những trường hợp được luật dự kiến, con chưa thành niên đương nhiên được cha, mẹ đại diện trong các quan hệ với người thứ ba, nhất là trong việc xác lập và thực hiện các giao dịch mà con chưa thành niên không có quyền tự mình xác lập và thực hiện (Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 39).

Cơ chế đại diện. Việc đại diện theo pháp luật của cha, mẹ đối với con chưa thành niên được chi phối chủ yếu bởi các quy định trong BLDS (Điều 20, 21 và Chương VII - Đại diện) và trong Luật hôn nhân và gia đình năm năm 2000 (đặc biệt là các Điều 45 và 46). Nói chung, sự đại diện của cha, mẹ đối với con chưa thành niên cũng giống như sự đại diện của người giám hộ đối với người được giám hộ: việc đại diện mang tính chất toàn phần hay từng phần tuỳ theo con đã đủ hay chưa đủ 6 tuổi. Mặt khác, nếu con có đủ cha và mẹ nhưng một trong hai người không có năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Toà án hạn chế quyền của cha, mẹ, thì người còn lại là người có đầy đủ quyền đại diện cho con chưa thành niên.

Dẫu sao, nếu cha và mẹ cùng đại diện cho con, thì mọi giao dịch xác lập dưới danh nghĩa và vì lợi ích của con đều phải được sự đồng ý của cả cha và mẹ. Luật chưa dự liệu vai trò của Toà án trong trường hợp cha và mẹ không thống nhất ý kiến. Có vẻ như nếu cha, mẹ không thống nhất ý kiến, thì hoặc cha hoặc mẹ đại diện cho con trong các giao dịch thông thường; còn các giao dịch quan trọng sẽ rơi vào chỗ bế tắc.

Mặt khác, luật không ghi nhận vai trò giám sát của UBND địa phương đối với việc thực hiện quyền của cha, mẹ đại diện cho con chưa thành niên, như trong trường hợp giám hộ người chưa thành niên.

Con chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên chỉ có thể lập di chúc với sự đồng ý của cha, mẹ (BLDS Điều 647 khoản 2). Nhưng, con chưa thành niên đủ 15 tuổi có quyền tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý (Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 45 khoản 1). Nói chung, khi con chưa thành niên đủ 15 tuổi, thì vai trò đại diện của cha mẹ, cũng như vai trò của người giám hộ, mất dần tính chất bảo hộ và mang nhiều hơn tính chất hỗ trợ, hướng dẫn.

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện. Các quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ trong việc đại diện theo luật cho con chưa thành niên được quy định trong các văn bản luật chủ yếu là các quyền và nghĩa vụ về tài sản. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 46 khoản 1, trong trường hợp cha mẹ quản lý tài sản riêng của con, thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, có tính đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên.

Có thể tin rằng cũng như người giám hộ không có quyền tặng cho tài sản của người được

giám hộ, cha, mẹ không có quyền tặng cho tài sản của con chưa thành niên. Thế nhưng, cha, mẹ có quyền bán, cầm cố tài sản của con mà không cần xin phép UBND địa phương nơi cư trú như người giám hộ bán, cầm cố tài sản của người được giám hộ. Có thể mở rộng giải pháp này cho tất cả các trường hợp định đoạt có đền bù (có hoặc không có điều kiện) đối với tài sản của con chưa thành niên, như trao đổi, thế chấp bất động sản,... cũng như các trường hợp các giao dịch quan trọng có tính chất quản trị tài sản, như cho thuê, cho vay,... tài sản.
Trong trường hợp con chưa thành niên đủ 15 tuổi tự mình quản lý tài sản, thì có quyền tự mình định đoạt tài sản, dù vai trò đại diện của cha mẹ chưa chấm dứt (Luật hôn nhân và gia đình Điều 46 khoản 2); tuy nhiên, việc định đoạt các tài sản có giá trị lớn hoặc dùng tài sản để kinh doanh phải có sự đồng ý của cha mẹ (cùng điều luật).

1.2.2. Thực hiện quyền đại diện

1.2.2.1. Nguyên tắc

Thực hiện chung và trực tiếp. Dù không có quy định rõ ràng của luật viết, vẫn có thể khẳng định rằng trong khung cảnh của luật thực định Việt Nam cha mẹ có quyền ngang nhau trong việc đại diện cho con chưa thành niên và phải cùng nhau thực hiện quyền này.
Ngang quyền, cha mẹ, trên nguyên tắc, phải thống nhất ý chí trong hoạt động đại diện. Trong trường hợp ngược lại, thì, về mặt lý thuyết, việc đại diện sẽ sa vào chỗ bế tắc. Còn trên thực tế, người nào nắm quyền lực mạnh hơn sẽ có tiếng nói áp đảo. Thông thường, đó là người cha.

1.2.2.2. Các trường hợp đặc biệt

Trường hợp cha hoặc mẹ bị hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên. Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 43 khoản 1, trong trường hợp một trong hai người là cha mẹ bị Toà án hạn chế một số quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên, thì người kia thực hiện quyền trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con và đại diện theo pháp luật cho con. Không có văn bản nào chi phối việc thực hiện quyền cha mẹ trong trường hợp này; bởi vậy, có thể thừa nhận rằng người còn lại có toàn quyền của cha mẹ.
Trường hợp cha hoặc mẹ chết. Khi giải quyết vấn đề đại diện cho con chưa thành niên, luật không dự kiến tình huống cha hoặc mẹ chết. Tuy nhiên, như đã biết, việc đại diện cho con chưa thành niên chỉ được thực hiện theo một trong hai chế độ: đại diện theo pháp luật của cha mẹ hoặc giám hộ. Thế mà, luật chủ động dự kiến các trường hợp cần đặt người chưa thành niên dưới chế độ giám hộ; trong các trường hợp ấy không có tình huống cha hoặc mẹ của người chưa thành niên chết. Dùng phương pháp loại suy, ta xác định rằng khi cha hoặc mẹ chết, thì quyền đại diện cho con thuộc về người còn lại.
Trường hợp cha mẹ ly hôn. Trong trường hợp cha và mẹ ly hôn, thì con chưa thành niên sẽ được giao cho một trong hai người trông nom, nuôi dưỡng. Luật hôn nhân và gia đình, khi giải quyết vấn đề giao con chưa thành niên cho cha hoặc mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng, không đề cập đến việc đại diện cho con. Tuy nhiên, có thể tin rằng người đại diện rtoàn quyền của con phải là người trực tiếp nuôi con; người còn lại chỉ có quyền giám sát.

1.2.3. Chấm dứt việc đại diện

Việc đại diện theo luật của cha, mẹ đối với con chưa thành niên chấm dứt khi con thành niên hoặc chết. Nếu con không có năng lực hành vi dân sự, dù đã thành niên, thì việc đại diện theo luật cũng chấm dứt và được thay thế bằng chế độ giám hộ đương nhiên của cha, mẹ (BLDS Điều 62 khoản 3).
Luật không quy định việc thanh toán tài sản giữa cha mẹ và con chưa thành niên sau khi việc đại diện chấm dứt. Hẳn, mọi chuyện được giải quyết theo tục lệ.

2. Đại diện cho người đã thành niên

Có hai trường hợp trong đó, người đã thành niên phải được đại diện: người đã thành niên mất năng lực hành vi và người đã thành niên bị hạn chế năng lực hành vi.

2.1. Đại diện cho người đã thành niên mất năng lực hành vi

2.1.1. Điều kiện giám hộ

2.1.1.1. Đối với người được giám hộ

Mất năng lực hành vi. Theo BLDS Điều 58 khoản 2 điểm b và khoản 3, người mất năng lực hành vi dân sự phải có người giám hộ. Như vậy, khác với người làm luật năm 1995, các tác giả BLDS năm 2005 quy định việc giám hộ như là hệ quả của tình trạng mất năng lực hành vi, chứ không phải là một yếu tố của tình trạng đó[73].

Tình trạng mất năng lực hành vi, về phần mình, được định nghĩa tại BLDS Điều 22 khoản 1: "khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, thì theo yêu cầu của người có quyền và lợi ích liên quan, Toà án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định".

Để tình trạng mất năng lực hành vi được ghi nhận, điều cần thiết là đương sự ở trong tình trạng không thể nhận thức được hành vi của mình do bệnh tâm thần hoặc bệnh tật gì đó khác.

Bệnh tâm thần thì đã rõ. Còn các bệnh khác là một khái niệm rất rộng. Luật không xây dựng các tiêu chí nào khác, ngoài tiêu chí "không nhận thức, làm chủ được hành vi", như là hậu quả của bệnh. Trong hầu như tất cả trường hợp, đó là các bệnh đặc trưng bằng sự tác động tiêu cực vào sự phát triển và khả năng vận hành bình thường của não, khiến cho quá trình nhận thức không thể diễn ra suôn sẻ.

Tình trạng bệnh tật phải được cơ quan giám định có thẩm quyền xác nhận. Thực ra, chỉ riêng việc xác nhận tình trạng bệnh tật của đương sự chưa đủ để đặt đương sự dưới chế độ giám hộ. Cần có một người nào đó có quyền và lợi ích liên quan yêu cầu Toà án ra quyết định tuyên bố đương sự mất năng lực hành vi. Thông thường, đó là một người thân thuộc của người cần được giám hộ.

Theo Bộ luật tố tụng dân sự Điều 35 khoản 2 điểm a, Toà án có thẩm quyền xét xử là Toà án nơi cư trú của người mất năng lực hành vi. Bản án được tuyên, như đã nói, trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định. Về mặt lý thuyết, kết luận giám định không ràng buộc Toà án vào nghĩa vụ ra một bản án phù hợp với kết luận đó: nếu xét thấy kết luận không đáng tin cậy, Toà án có quyền yêu cầu giám định lại.

2.1.1.2. Đối với người giám hộ

Giám hộ đương nhiên. Một khi người đã thành niên mắc bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình bị Toà tuyên bố mất năng lực hành vi, thì những người sau đây, theo thứ tự, sẽ trở thành giám hộ đương nhiên của người đó (Điều 62): vợ hoặc chồng, con cả, con kế tiếp, cha, mẹ. Quan hệ giám hộ đương nhiên phát sinh một cách đương nhiên do hiệu lực của bản án đặt người được giám hộ vào tình trạng mất năng lực hành vi.

Giám hộ được cử. Trong trường hợp một người bị tuyên bố mất năng lực hành vi không có người giám hộ đương nhiên, thì UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ hoặc đề nghị một tổ chức đảm nhận việc giám hộ. Thông thường, người được cử làm giám hộ là một trong những người thân thuộc của người được giám hộ; còn tổ chức được yêu cầu giám hộ thường là một tổ chức có thiên hướng hoạt động xã hội.

2.1.1.3. Điều kiện thủ tục

Giống như trường hợp giám hộ đối với người chưa thành niên. Các tác giả Nghị định số 158-CP ngày 27/12/2005 không phân biệt giữa đăng ký giám hộ đối với người chưa thành niên và đăng ký giám hộ đối với người thành niên mất năng lực hành vi; bởi vậy, việc đăng ký giám hộ đới với loại người sau này được thực hiện theo cùng các thủ tục như đối với người

[73] Theo BLDS năm 1995 Điều 68 khoản 2 điểm b

chưa thành niên.

2.1.2. Cơ chế giám hộ

Tình trạng của người được giám hộ. Người bị tuyên bố không có năng lực hành vi không có quyền tự mình xác lập và thực hiện các giao dịch dân sự. Mọi giao dịch của người này đều do người giám hộ xác lập, thực hiện (Điều 22 khoản 2). Điều đó có nghĩa rằng các giao dịch do người được giám hộ tự mình xác lập và thực hiện sau ngày được đặt dưới sự giám hộ có thể bị tuyên bố vô hiệu (Điều 130 khoản 1).

Luật không có quy định rõ về giá trị của các giao dịch do người này xác lập trước ngày được giám hộ. Nói chung, giao dịch do người không có năng lực hành vi xác lập có thể bị tuyên bố vô hiệu theo yêu cầu của người giám hộ, không phân biệt giao dịch được xác lập trước hay sau ngày giám hộ; nhưng các giao dịch do người được giám hộ xác lập trước ngày bị tuyên bố mất năng lực hành vi chỉ có thể bị vô hiệu hoá trong trường hợp người được giám hộ không nhận thức được hành vi của mình lúc xác lập giao dịch.

Các di chúc do người được giám hộ lập trước ngày được đặt dưới chế độ giám hộ có thể bị tuyên bố vô hiệu, một khi có bằng chứng cho thấy người này không minh mẫn, sáng suốt lúc di chúc được lập (Điều 647 khoản 1 điểm a). Tuy nhiên, luật không trả lời câu hỏi liệu sau khi bị tuyên bố mất năng lực hành vi, người được giám hộ có hay không quyền lập di chúc. Trong logic của Điều 147 khoản 1, tình trạng mất năng lực hành vi tự nó không ảnh hưởng đến giá trị của di chúc: nếu tỉnh táo và tự nguyện, người mất năng lực hành vi vẫn có quyền lập di chúc, thậm chí không cần sự đồng ý của người giám hộ.

Người mất năng lực hành vi không thể kết hôn, dù có lúc tỉnh táo và mong muốn điều đó (Luật Hôn nhân và gia đình Điều 10 khoản 2). Thực ra, cho đến bây giờ, không ai hiểu tại sao người mất năng lực hành vi lại không thể kết hôn: nếu có một người nào đó chấp nhận kết hôn với người mất năng lực hành vi và bản thân người sau này, trong lúc tỉnh táo, cũng đồng ý, thì điều đó hoàn toàn tốt đẹp đối với người mất năng lực hành vi.

Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ. Người giám hộ cho người đã thành niên mất năng lực hành vi có các quyền và nghĩa vụ giống như người giám hộ cho người chưa thành niên dưới 15 tuổi, trừ nghĩa vụ giáo dục người được giám hộ. Ngoài ra, người giám hộ cho người đã thành niên còn có trách nhiệm chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ (Điều 67 khoản 1).

Chấm dứt việc giám hộ. Việc giám hộ cho người đã thành niên mất năng lực hành vi chấm dứt khi người được giám hộ chết hoặc khi có quyết định của Toà án huỷ bỏ quyết định tuyên bố đương sự bị mất năng lực hành vi. Hẳn quyết định của Toà án chỉ được ra trên cơ sở kết luận của cơ quan giám định có thẩm quyền. Người yêu cầu ra quyết định có thể là người giám hộ, đương sự hoặc bất kỳ người nào có quyền và lợi ích liên quan.

Sau khi việc giám hộ chấm dứt, người giám hộ tiến hành thanh toán tài sản giống như trong trường hợp giám hộ cho người chưa thành niên.

2.2. Đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

2.2.1. Điều kiện

Đối với người được đại diện. Theo BLDS Điều 23 khoản 1, thì người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự là người nghiện ma tuý hoặc nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình và bị Toà án ra quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan[74].

[74] Thực ra, một cách hợp lý, việc một người thành niên có hành vi phá tán tài sản một cách thường xuyên đủ để khiến người này được đặt trong tình trạng bị hạn chế năng lực hành vi. Việc người làm luật áp đặt điều kiện "nghiện ma tuý hoặc chất kích thích khác" làm cho diện những người phá tán tài sản có thể bị tuyên bố hạn chế năng lực hành vi bị thu hẹp lại. Rõ ràng sự thu hẹp đó không thể được coi là phù hợp với ý chí của người làm luật. Có lẽ cần áp dụng tương tự pháp luật cho các trường hợp phá tán tài sản do nghiện những thứ khác (ví dụ, nghiện cờ bạc), thậm chí không nghiện gì cả.

Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự nhất thiết phải là người đã thành niên: nếu người chưa thành niên đủ 15 tuổi, đang tự mình quản lý tài sản mà có hành vi phá tán, thì, một cách hợp lý, chỉ cần tăng cường chế độ giám hộ.

Đối với người đại diện. Người đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự nhất thiết phải có đủ điều kiện như một người giám hộ, dù luật không quy định rõ, bởi người này sẽ đảm nhận các chứ năng tương tự người giám hộ. Người này được chỉ định theo một quyết định của Toà án (Điều 23 khoản 2). Thông thường, nếu người bị hạn chế năng lực hành vi có vợ (chồng), thì người đại diện là vợ chồng; trong trường hợp người này không có vợ (chồng) thì người đại diện là một người thân thuộc.

Thủ tục. Cũng như tình trạng mất năng lực hành vi, tình trạng hạn chế năng lực hành vi không đương nhiên được thiết lập một khi có đủ các yếu tố khách quan. Cần có một vụ kiện trước Toà án và có một quyết định tư pháp. Theo Bộ luật TTDS Điều 35 khoản 2 điểm a, Toà án có thẩm quyền là Toà án nơi cư trú của người dự kiến bị đặt vào tình trạng bị hạn chế năng lực hành vi.

Là một quyết định tư pháp được tuyên theo đúng pháp luật về tố tụng dân sự, bản án đặt một người vào tình trạng bị hạn chế năng lực hành vi có thể bị kháng cáo, kháng nghị và được xét lại theo trình tự phúc thẩm, giám đốc thẩm,..

Đăng ký ? Luật hoàn toàn không có quy định về việc đăng ký việc hạn chế năng lực vi, như trường hợp đăng ký việc giám hộ. Người ta không hiểu bằng cách nào, tình trạng hạn chế năng lực hành vi của một người được công bố cho người thứ ba. Điều này có thể khiến cho tình trạng hạn chế năng lực hành vi của một người trở nên không minh bạch và là một bẫy rập đối với xã hội: người đại diện giấu mặt có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào để quấy rối bên giáo dịch với người bị hạn chế năng lực hành vi.

2.2.2. Cơ chế đại diện

Giám sát và cho phép. Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không hoàn toàn mất năng lực hành vi dân sự. Cũng như người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự có thể tự mình xác lập và thực hiện các giao dịch nhỏ nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, các giao dịch khác đều chỉ có thể được xác lập và thực hiện với sự đồng ý của người đại diện (Điều 23 khoản 2)[78].

Dẫu sao, có thể tin rằng khác với người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự có thể lập di chúc mà không cần có sự đồng ý của người đại diện: chỉ cần người bị hạn chế năng lực hành vi sáng suốt, minh mẫn, tự nguyện trong lúc lập di chúc, thì di chúc, một khi thoả mãn các điều kiện theo luật chung, sẽ có giá trị. Người bị hạn chế năng lực hành vi cũng có thể kết hôn mà không cần sự đồng ý của người đại diện.

Phạm vi đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự do Toà án quyết định (cùng điều luật). Kết hợp các quy định liên quan, ta kết luận rằng các giao dịch mà người bị hạn chế năng lực hành vi được phép xác lập, tự mình hoặc có sự đồng ý của người đại diện, bao gồm: các giao dịch nhỏ, các giao dịch mà đương sự không thể giao cho người khác thực hiện, dù không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, và các giao dịch mà người đại diện được phép thực hiện dưới danh nghĩa của đương sự trong phạm vi đại diện do Toà án xác định.

Không như người giám hộ, người đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không chịu sự giám sát của UBND địa phương nơi cư trú trong quá trình thực hiện việc đại diện. Người được đại diện, về phần mình, có nơi cư trú của mình chứ không được coi như có nơi cư trú tại nơi cư trú của người đại diện, như người giám hộ. Tất cả

---

78 Vậy nghĩa là chính người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xuất hiện trước người thứ ba và tự mình giao dịch, với điều kiện chứng minh được rằng mình được sự cho phép của người đại diện. Vấn đề là, không như việc giám hộ, việc đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi không hề được đăng ký ở bất kỳ nơi nào. Người thứ ba phải làm gì để phát hiện được một người bị hạn chế năng lực hành vi ?

những điều này có thể được lý giải bởi việc người bị hạn chế năng lực hành vi không mất khả năng nhận thức và không bị mất quyền năng tự mình xác lập giao dịch như người mất năng lực hành vi.

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện. Luật không có quy định riêng về quyền và nghĩa vụ của người đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Có lẽ người này có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ trong phạm vi đại diện do Toà án quyết định (Điều 23 khoản 2), được vận dụng trong điều kiện giao dịch nhân danh người bị hạn chế năng lực hành vi vẫn do người sau này xác lập. Song, người này không có trách nhiệm xác định tình trạng tài sản của người được đại diện. Một cách hợp lý, người đại diện cũng có thể được thay đổi, nhưng luật không có quy định về những trường hợp được phép thay đổi người đại diện và, do đó, không dự liệu các thủ tục về chuyển giao quyền đại diện. Việc đại diện chấm dứt trong trường hợp người được đại diện chết hoặc được khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Chế tài trong trường hợp giao dịch không hợp lệ. Cũng như trong trường hợp các giao dịch do người chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi xác lập mà không phù hợp với các quy định của pháp luật, giao dịch do người bị hạn chế năng lực hành vi thực hiện không đúng luật có thể bị tuyên bố vô hiệu theo yêu cầu của của người đại diện (Điều 130). Thực ra, điều luật được viết không rõ ràng lắm; tuy nhiên, có thể thừa nhận ý chí của người làm luật là như thế.

Thời hiệu khởi kiện là hai năm từ ngày giao dịch được xác lập (Điều 136 khoản 1).

MỤC 5 - Quyền nhân thân

1. Tổng quan

Quyền nhân thân trong luật dân sự. Theo BLDS năm 2005 Điều 34, quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người nghiên cứu luật có thể tự hỏi liệu khi xây dựng định nghĩa quyền nhân thân như trên, người làm luật có liên tưởng đến khái niệm quyền tài sản, cũng được ghi nhận trong BLDS tại Điều 181, và muốn có quyền nhân thân như một khái niệm đối lập với quyền tài sản. Theo Điều 181, quyền tài sản là quyền định giá được bằng tiền và chuyển giao được trong giao dịch dân sự kể cả quyền sở hữu trí tuệ. Nếu coi quyền tài sản là một khái niệm đối lập với quyền nhân thân, thì có thể thừa nhận rằng quyền tài sản, quyền nhân thân là các công cụ để phân loại các quyền dân sự của chủ thể quan hệ pháp luật: tất cả các quyền không phải quyền tài sản đều là quyền nhân thân và ngược lại.

Trong luật của các nước theo văn hoá pháp lý romano-germanique, khái niệm quyền tài sản được dùng để đối lập với khái niệm quyền phi tài sản. Trong các quyền phi tài sản có những quyền có tác dụng bảo vệ cá nhân về phương diện thể chất và tinh thần, gọi là các quyền nhân thân[75]. Với quan niệm đó, thì quyền nhân thân không phải là đối trọng của quyền tài sản; song, chắc chắn, quyền nhân thân, về bản chất, là những quyền không có giá trị tiền tệ.

Trong cuộc sống đương đại, dưới sự tác động của các phương tiện truyền thông mà tầm ảnh hưởng đối với đời sống xã hội ngày càng lớn rộng, một số quyền nhân thân có xu hướng được cân đo bằng tiền. Một trong những ví dụ điển hình là quyền đối với hình ảnh của các

---

[75] Quyền phi tài sản được xếp thành hai nhóm (xem: Cornu, *Droit civil-Introducxtion.Les personnes.Les biens*, Montchrestien, 1990, số 60 và kế tiếp): 1. một số quyền gia đình; 2. các quyền nhân thân. Trong các quyền gia đình thuộc nhóm quyền phi tài sản, có thể dẫn các quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ và chồng (yêu thương, chung thuỷ, chặm sóc nhau,…), quyền của cha mẹ đối với con, quyền nhận con, quyền nhận cha, mẹ….

Riêng nhóm quyền nhân thân không chỉ bao gồm các quyền có tác dụng bảo vệ cá nhân về phương diện thể chất và tinh thần, mà còn có cả các quyền nhân của người sáng tạo tác phẩm văn chương, khoa học, nghệ thuật, còn gọi là quyền nhân thân của tác giả.

nhân vật nổi tiếng. Xu hướng đó, đến lượt mình, đã kích thích sự phát triển trong luật học đương đại một học thuyết mới về tính thống nhất của quyền chủ thể: tất cả các quyền, suy cho cùng, đều ít nhiều gắn với nhân thân và đều có thể được đính giá. Tuy nhiên, không thể chối cãi rằng tính chất phi tài sản được coi là thuộc tính cơ bản của quyền nhân thân và việc một số quyền nhân thân định giá được bằng tiền trong một số trường hợp đặc thù chỉ là các ngoại lệ rát cá biệt.

Vả lại, trước khi một số quyền nhân thân đúng nghĩa có xu hướng trở thành các quyền có giá trị tiền tệ trong cuộc sống dân sự đương đại, thì luật học cũng đã ghi nhận một số quyền lưỡng tính, vừa có tính chất tài sản, vừa gắn với nhân thân. Ví dụ điển hình là quyền yêu cầu được cấp dưỡng. Người ta nói rằng những quyền như thế khiến cho ranh giới giữa quyền tài sản và quyền phi tài sản trở nên không rõ ràng.

Thực ra, khái niệm quyền tài sản được xây dựng trong luật Việt Nam theo một nghĩa rất hẹp. Nếu trong luật các nước, khái niệm quyền tài sản được sử dụng là công cụ phân loại tài sản, thì trong luật Việt Nam, quyền tài sản chỉ đơn thuần là một loại tài sản, hay đúng hơn là một loại động sản.

Quyền nhân thân là hệ quả của sự xác lập nhân thân pháp lý. Dù được định nghĩa như trong luật thực định Việt Nam hay trong luật phương Tây, quyền nhân thân được thừa nhận cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, địa vị, giai cấp, trình độ học vấn,… Một khi nhân thân pháp lý được xác lập, các quyền nhân thân cũng được xác lập đồng thời; một khi nhân thân pháp lý biến mất.

Có trường hợp một người bị bôi nhọ tên tuổi sau khi chết và người thừa kế kiện yêu cầu bảo vệ "danh dự, nhân phẩm của người đã chết". Tất nhiên, việc xúc phạm danh dự nhân phẩm của một người phải bị chế tài. Vấn đề là: một khi người bị xúc phạm đã chết, thì việc bảo vệ có đối tượng là gì ? Thực ra, nhân thân pháp lý của một người được xác lập khi người đó sinh ra, nhưng không hẳn mất đi khi người đó chết. Cuộc sống xã hội mà một người trải qua tạo ra những giá trị có thể không mất đi cùng với người đó.

2. Tính chất của quyền nhân thân

Không thể được chuyển giao. Quyền nhân thân, do bản chất, gắn liền với chủ thể của quyền đó: nó cần thiết cho việc xây dựng và hoàn thiện bộ mặt xã hội của chủ thể; được chuyển giao cho người khác, nó trở nên vô nghĩa. Vả lại, nếu thừa nhận tính chuyển giao được của các quyền nhân thân, thì phải hình dung khả năng một người mang nhân thân của nhiều người. Điều đó không hợp lý.

Khộng thể bị kê biên. Về mặt kỹ thuật, đây là hệ quả của tính chất không thể chuyển giao của quyền nhân thân: suy cho cùng, chẳng có lợi ích để kê biên một vật thuộc về một người, dù có giá trị tiền tệ, mà người ta không thể chuyển giao quyền sở hữu cho một nghười khác.

Không mất đi do thời hiệu. Quyền nhân thân luôn tồn tại ngay cả trong trường hợp không được sử dụng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, các kiện cáo liên quan đến việc xâm phạm quyền nhân thân chịu sự chi phối của luật chung về thời hiệu áp dụng đối với quyền khởi kiện.

3. Các quyền nhân thân cơ bản

3.1. Quyền đối với thân thể

Sự cần thiết của việc bảo vệ toàn vẹn thân thể. Thân thể vật lý là thể xác, hình hài của cá nhân. Phần lớn các quy định của pháp luật dân sự và, nói chung, của các ngành luật tư (thương mại, lao động,…) đều tập trung nói về vai trò của ý chí trong việc xác lập, thay đổi, chấm dứt các quan hệ pháp luật. Thế nhưng, ý chí không phải là yếu tố đầu tiên xuất hiện ở chủ thể, mà cũng không phải là yếu tố cơ sở. Người mới được sinh ra chưa thể có ý chí, nhưng đã được thừa nhận có năng lực pháp luật[76]; người không bày tỏ được ý chí của mình được pháp luật quan tâm điều chỉnh việc xử sự bằng một loạt các quy tắc đặc biệt. Suy cho cùng, tư

[76] Thậm chí người chưa sinh ra, nhưng đã thành thai ở thời điểm mở thừa kế cũng có năng lực pháp luật thừa kế vớI điều kiện sinh ra và còn sống (BLDS Điều 635)

cách chủ thể được thừa nhận một khi sự tồn tại vật chất của chủ thể được ghi nhận. Bởi vậy, người ta nói rằng thân thể vật lý là biểu hiện vật chất cần thiết cho sự tồn tại của cá nhân, là hiện thực cơ sở của cá nhân với tư cách là chủ thể quan hệ pháp luật[77].

3.1.1. Các quyền được bảo vệ

Bảo vệ chống sự xâm hại. Sự xâm hại thường đến từ người khác. Các ví dụ rất đa dạng: giết người, cố ý gây thương tích, hành hạ, ngược đãi,… Tuỳ mức độ nghiêm trọng của hành vi xâm hại, tác giả của hành có thể bị chế tài về mặt hành chính hoặc hình sự. Trách nhiệm dân sự cũng được quy kết trong trường hợp có những thiệt hại thực tế xảy ra đối với tính mạng, sức khoẻ của người bị xâm hại.

Nhưng sự xâm hại cũng có thể đến từ chính người có thân thể đó. Trên thực tế, người ta có thể hình dung các trường hợp tự huỷ hoại thân thể thậm chí tự huỷ diệt mạng sống hay còn gọi là tự sát. Luật Việt nam hiện hành không quy định trực tiếp cấm các hành vi cố ý tự xâm hại đối với thân thể hoặc tự huỷ diệt cuộc sống của mình[78]. Chỉ trong trường hợp hành vi đó là tác nhân gây rối loạn trật tự công cộng hoặc được thực hiện nhằm mục đích lẫn tránh một nghĩa vụ đối với Nhà nước, thì tuỳ theo đương sự có lỗi hay không có lỗi và nếu có lỗi thì tuỳ theo mức độ năng nhẹ, đương sự có thể bị chế tài hành chính hoặc hình sự do hành vi gây rối hoặc do lẫn tránh thực hiện nghĩa vụ

Bảo vệ chống sự lạm dụng. Lạm dụng cũng thường đến từ người thứ ba. Bóc lột sức lao động là một trong những ví dụ tiêu biểu về sự lạm dụng của người thứ ba đối với thân thể của một con người.

Lạm dụng tình dục là một ví dụ khác về lạm dụng thân thể con người bởi người thứ ba. Trong khung cảnh của luật thực định, hành vi lạm dụng tình dục có thể bị chế tài về mặt hình sự và dân sự một khi có đủ yếu tố cấu thành các tội hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô đối với trẻ em hoặc làm nhục người khác; trong các trường hợp khác, hành vi này chỉ bị lên án về mặt đạo đức.

Sự lạm dụng của bản thân. Sự lạm dụng thân thể gọi là của bản thân một khi các khả năng của thân thể bị chính người có thân thể đó khai thác một cách quá mức. Một trong những ví dụ điển hình về lạm dụng thân thể của chính bản thân là sự mại dâm. Trong luật Việt nam hiện hành, người mại dâm không bị chế tài hình sự do hành vi mại dâm, dù là mại dâm chuyên nghiệp[79], nhưng người này có thể bị xử lý hành chính về hành vi đó. Cần lưu ý rằng nếu việc lạm dụng khả năng sinh hoạt tình dục không kèm theo việc thu lợi ích vật chất để bị coi là mại dâm, thì đương sự thậm chí không

thể bị chế tài về mặt hành chính. Nói cách khác, sống sa đoạ, đồi truỵ tự nó chưa phải là hành vi vi phạm pháp luật mà chỉ mới là hành vi vi phạm đạo đức.

Một trường hợp khác của sự lạm dụng thân thể do chính người có thân thể thực hiện, nhưng tính chất lạm dụng không rõ ràng lắm, là trường hợp xác lập các hợp đồng nhằm thực hiện các công việc nguy hiểm đến tính mạng. Các ví dụ rất đa dạng trong thực tiễn: hợp đồng đóng thế vai diễn viên điện ảnh trong các tình huống nguy hiểm, hợp đồng . Gọi là lạm dụng, bởi các hoạt động này thường đòi hỏi việc huy động vượt quá mức bình thường các khả năng về thể chất của đương sự; bản thân các hoạt động ấy cũng không được coi là những hoạt động thích hợp với những người bình thường. Dẫu sao, trên nguyên tắc, các trường hợp

---

[77] Cornu, Droit civil-Introduction. Les personnes. Les biens, Montchrestien, 1990, số 479.

[78] Bởi vậy, người tự gây thương tích cho mình hoặc tự sát mà không thành công không bị chế tài chỉ vì có hành vi đó. Trái lại, người có hành vi xúi giục hoặc giúp người khác tự sát có thể bị chế tài về mặt hình sự (BLHS Điều 101), bởi các hành vi này tự chúng đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của luật về quyền con người: .

Ở các nước tiền tiến, nơi mà việc tự sát đang trở thành một vấn nạn, người làm luật đang xem xét việc đề ra các quy định ngăn cấm hành vi này và chế tài người vi phạm.

[79] Luật Việt Nam hiện hành chỉ chế tài về mặt hình sự đối với người có hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm hoặc mua dâm người chưa thành niên.

lạm dụng loại này không bị coi là trái pháp luật.

3.1.2. Thực hiện các tác nghiệp y học trên thân thể

Thực hiện các biện pháp điều trị bệnh mới. Theo BLDS 32 khoản 3, việc thực hiện phương pháp chữa bệnh mới trên cơ thể một người phải được sự đồng ý của người đó.

Trên thực tế, có trường hợp việc thực hiện các biện pháp điều trị bệnh mới còn có thể mang tính chất thực nghiệm y học. Thông thường, trước khi phổ biến đại trà việc áp dụng một loại thuộc mới trong việc điều trị một bệnh nào đó, người ta tiến hành áp dụng thử một thời gian trên cơ thể một số người tự nguyện và trước đó nữa, trên cơ thể động vật sống. Tất nhiên, việc điều trị thử trên cơ thể con người chỉ có thể được thực hiện với sự đồng ý của người đó; song, vấn đề không chỉ dừng lại ở chuyện người này đồng ý hay không đồng ý. Việc dùng người sống làm đối tượng cho các thí nghiệm y học cần phải được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của nhà chức trách nhằm ngăn chặn, xử lý việc mua bán thân thể con người. Về phần mình, người chấp nhận là đối tượng của biện pháp thực nghiệm có thể nhắm đến các lợi ích đa dạng. Đó trước hết có thể là lợi ích về sức khoẻ của bản thân: đương sự thực sự mắc bệnh, đã cố công theo đuổi nhiều loại liệu pháp, nhưng không thành công và nay trông đợi vào biện pháp thực nghiệm này như một cơ may cuối cùng. Đó cũng có thể là lợi ích thuần tuý khoa học: đương sự không thực sự mắc bệnh; nhưng tự nguyện để cho người khác dùng cơ thể của mình để thí nghiệm việc điều trị bệnh bằng các loại dược phẩm mới.

3.1.3. Bảo vệ chống việc định đoạt trái pháp luật

Định đoạt bao gồm định đoạt vật chất và định đoạt pháp lý.

3.1.3.1. Định đoạt pháp lý.

Trên nguyên tắc, thân thể con người là vật nằm ngoài lưu thông. Không chỉ toàn bộ thân thể, mà từng bộ phận của cơ thể cũng thu hút sự quan tâm của người làm luật.

Quyền hiến các bộ phận của cơ thể. Theo BLDS Điều 33, cá nhân có quyền hiến các bộ phận cơ thể của mình vì mục đích chữa bệnh cho người khác hoặc nghiên cứu khoa học. Bộ phận cơ thể trong điều luật phải được hiểu theo nghĩa rộng nhất, tức là không chỉ là các bộ phận ở thể rắn như tim, thận, gan,… mà còn có thể là các bộ phận ở thể lỏng như máu, tinh dịch,…

"Hiến" hàm nghĩa rằng việc chuyển giao các bộ phận cơ thể không được đánh đổi bằng các lợi ích vật chất. Thông thường, một người vẫn tiếp tục sống sau khi hiến một bộ phận nào đó, thì phải được hưởng các biện pháp bồi dưỡng thích hợp để khôi phục tình trạng sức khoẻ ban đầu. Nhưng sự đánh đổi chỉ dừng lại ở đó: đi xa hơn, thì sẽ có những vụ chuyển nhượng trái phép các bộ phận cơ thể người.

Quyền hiến xác, bộ phận cơ thể sau khi chết. Theo BLDS Điều 34, cá nhân có quyền hiến xác, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết vì mục đích chữa bệnh cho người khác hoặc nghiên cứu khoa học.

Cho đến nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về các điều kiện hình thức và nội dung của giao dịch loại này. Thông thường, việc hiến nhằm mục đích nghiên cứu khoa học được ghi nhận trên một mẫu khai do tổ chức nghiên cứu khoa học lập sẵn và cung cấp miễn phí cho người có ý định hiến. Giá trị pháp lý của tờ khai hiến theo mẫu này không rõ ràng. Điều chắc chắn, nếu người hiến lại quyết định huỷ bỏ việc hiến bằng một di chúc, thì việc huỷ bỏ sẽ có giá trị. Thực tiễn cho thấy rằng việc hiến xác chỉ được thực hiện một cách suôn sẻ khi không chỉ ngườihiến mà cả gia đình của người này cũng đồng thuận về việc hiến. Nếu gia đình phản đối, tổ chức nhận hiến xác thường chọn con đường rút lui: cho đến nay, chưa thấy có tranh chấp tư pháp về việc một người hiến xác trong trường hợp bản thân người này không rút lại lời hứa của mình cho đến ngày chết, nhưng gia đình của người này lại không đồng ý.

3.1.3.2. Định đoạt vật chất

Khái niệm. Gọi là định đoạt vật chất đối với thân thể hành vi của chính người mang thân

thể đó nhằm thủ tiêu sự tồn tại của toàn bộ hoặc một phần thân thể. Định đoạt toàn bộ hàm nghĩa rằng. gọi nôm na là tự sát; định đoạt một phần, còn được gọi là tự gây thương tích.

Nguyên tắc. Thực ra chẳng có nguyên tắc nào chi phối hành vi của cá nhân nhằm tự thủ tiêu cuộc sống hoặc huỷ hoại một phần thân thể của mình. Nguyên tắc tự do suy nghĩ, tự do hành động. Trong khi đó, nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ trật tự công cộng chỉ đòi hỏi cá nhân không gây tác động xấu đến cuộc sống, sinh hoạt bình thường của người khác bằng hành vi của mình.

Trường hợp đặc thù: quyền được chết của người bệnh nan y. Có những người mắc bệnh hiểm nghèo và nan y; khoa học hoặc trình độ tác nghiệp y khoa của người điều trị ở Việt Nam không cho phép đáp ứng yêu cầu chữa trị cho bệnh nhân. Vấn đề đặt ra trong trường hợp này là nếu bệnh nhân không muốn kéo dài cuộc sống đau khổ của mình, thì liệu họ có quyền buông xuôi để chết ?[80]. Luật hiện hành không trả lời thẳng câu hỏi này. Người có trách nhiệm điều trị có thể bị cáo buộc về mặt hình sự nếu

không điều trị bệnh nhân đến nơi đến chốn (BLHS Điều 102); tuy nhiên, việc quy trách nhiệm chỉ được thực hiện trong trường hợp bệnh nhân có thể được cứu chữa. Còn trong trường hợp chủ động giúp bệnh nhân được chết, người điều trị có thể phạm tội giúp người khác tự sát (BLHS Điều 101).

3.2. Quyền đối với sự toàn vẹn phẩm giá

Thiệt hại tinh thần. Theo BLDS Điều 37. danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. một người có thể bị xúc phạm dưới hình thức vu khống hoặc lăng nhục. Dù ở hình thức nào, việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín phải mang tính chất cố ý mới có thể bị chế tài: một câu nói sơ ý gây tổn thương chưa đủ để quy trách nhiệm về việc xúc phạm phẩm giá.

Trách nhiệm có thể được quy kết về mặt hình sự và cả về mặt dân sự. Theo BLDS năm 2005, Điều, người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín có quyền tự mình cải chính hoặc yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm phải chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai và yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại.

3.3. Quyền đối với bí mật của cuộc sống riêng tư

Khái niệm cuộc sống riêng tư. Có thể tạm định nghĩa cuộc sống riêng tư là tổng hợp các thông tin liên quan đến một cá nhân, được cá nhân đó nắm giữ và người nắm giữ có quyền chia sẻ hoặc không chia sẻ với người khác. Các thôpng tin ấy được gọi là các yếu tố của cuộc sống riêng tự. Cuộc sống riêng tự (còn được gọi là đời tư) của một người là những điều bí mật của người đò và việc bộc lộ các bí mật đó bởi một người khác mà không được sự đồng ý của người nắm giữ bí mật đó, là hành vi xâm phạm cuộc sống riêng tư.

Các yếu tố của cuộc sống riêng tự rất đa dạng. BLDS năm 2005 ghi nhận những yếu tố chủ yếu, bao gồm *thư tín, hình ảnh và tín ngưỡng, tôn giáo của một người*.

3.3.1. Thư tín

Định nghĩa. Theo nghĩa cổ điển, thư tín là một văn bản chứa đựng các thông tin mà một người (gọi là người gửi) muốn chuyển cho một (hoặc nhiều) người khác (gọi là người nhận). Theo nghĩa rộng nhất, thư tín là bất kỳ thông tin nào được ghi nhận dưới một hình thức vật chất nhất định.

Hình thức thư tín. Trong xã hội hiện đại, hình thức của thư tin rất đa dạng. Tuy nhiên, có thể ghi nhận bốn hình thức phổ biến nhất.

1. Thư viết trên giấy. Đây là loại thư tín cổ điển. Thông tin được ghi nhận trên giấy có thể bằng chữ viết thông thường hoặc bằng một hệ thống ký hiệu quy ước giữa chủ thể gửi thông tin và chủ thể nhận thông tin (gọi là mật mã trong ngôn ngữ thông dụng).

---

[80] Câu hỏi được đặt ra chủ yếu về phương diện lý thuyết. Đã có rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị bỏ rơi, không được cứu chữa tận tình, rồi chết: cả quyền được sống cũng còn đang vật lộn với thói vô trách nhiệm; vấn đề quyền được chết trở nên thừa

2. Thư ghi vào băng từ, đĩa từ. Thông tin có thể được chứa đựng trong băng, đĩa từ dưới dạng chữ viết, tiếng nói, hình ảnh hoặc cả ba.
3. Thư điện tử (email). Thư được soạn thảo trên máy vi tính và gửi từ một địa chỉ điện tử đến một địa chỉ điện tử khác, thông qua mạng internet.
4. Nhắn tin qua điện thoại. Đây là việc để lại lời nhắn trên hộp thư thoại hoặc hộp tin nhắn của một số điện thoại. Lời nhắn trên hộp thư thoại tồn tại dưới dạng lời nói (lời độc thoại) được ghi âm; lời nhắn trên hộp tin nhắn được ghi nhận dưới dạng chữ viết hoặc các ký hiệu viết khác. Nhắn tin qua điện thoại cũng được coi là một loại thư tín, do lời nhắn, sau khi được ghi nhận, tồn tại độc lập với ký ức của người nhắn tin.

Bí mật thư tín. là tình trạng không bộc lộ nội dung của thư tín cho người không phải là chủ thể nhận thông tin. Khái niệm bí mật thư tín chỉ được xây dựng cho trường hợp người gửi và người nhận đều là những chủ thể xác định: thư tín chỉ cần được giữ bí mật một khi được coi là một phần của cuộc sống riêng tư, tức là cuộc sống của một người được xác định. Bởi vậy, thư tín được gửi cho công chúng không cần được giữ bí mật.

Việc bảo vệ bí mật thư tín được người làm luật XHCN Việt Nam quan tâm từ rất sớm, thể hiện trong các quy định tại Luật số 103-SL/L.005 ngày 20/5/1957. Trong luật thực định, bí mật thư tín được bảo đảm bằng các biện pháp chế tài được ghi nhận trong luật dân sự và luật hình sự. Trong luật dân sự, việc chế tài đối với người xâm phạm bí mật thư tín được thực hiện theo chế độ chung về trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng; việc chế tài hình sự đối với người xâm phạm bí mật thư tín được ghi nhận tại Điều 125 Bộ luật hình sự.

3.3.2. Hình ảnh

Khái niệm. Hình ảnh là sự phản ánh gương mặt hoặc thân xác của con người trên một phương tiện vật chất. Hình ảnh của một người có thể được ghi nhận trong nhiều tình huống và ở nhiều góc độ và do đó, rất đa dạng. Có thể kể ra: hình ảnh chân dung, hình ảnh sinh hoạt, hình ảnh làm việc, hình ảnh kỷ niệm du lịch,…

Hình ảnh có hình thức thể hiện vật chất đa dạng. Trong quan niệm cổ điển, hình ảnh được ghi lại trên giấy; còn trong cuộc sống hiện tại, việc ghi nhận và lưu giữ hình ảnh có thể được thực hiện bằng các phương tiện điện tử.

Quyền đối với hình ảnh. Trước tiên, cần xác định rằng quyền đối với việc ghi nhận hình ảnh của một người không nhất thiết là quyền riêng biệt của chính người đó. Khi một người cho phép người khác chụp ảnh mình, thì người cho phép không chuyển giao quyền ghi nhận hình ảnh của mình, mà chính người chụp ảnh thực hiện quyền chụp ảnh của họ. Quyền chụp ảnh là một trường hợp đặc thù của quyền tự do hành động. Việc một người, khi chụp ảnh một người khác, phải xin phép người được chụp ảnh trong những trường hợp đặc thù, thể hiện giới hạn đối với quyền chụp ảnh của chính người đó.

Thực ra, người có hình ảnh cũng không được tự do sử dụng hình ảnh của mình. Ví dụ điển hình là việc sử dụng hình ảnh ghi nhận các sinh hoạt tình dục. Tất nhiên, luật không cấm (và không thể cấm) việc một người tự ghi hoặc nhờ người khác ghi các hình ảnh về những chuyện thầm kín của mình, trong đó có sinh hoạt tình dục. Thậm chí, luật cũng không thể cấm việc người có hình ảnh cho người khác xem những hình ảnh ấy. Thế nhưng, việc bộc lộ một cách có ý thức các hình ảnh loại này, nếu mang

đầy đủ tính chất của việc kích thích sự tò mò không lành mạnh của nhiều người khác, sẽ có thể bị coi là việc truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ[81].

---

[81] Theo BLHS Điều 253, người có hành vi làm ra nhằm phổ biến tranh, ảnh, phim có tính chất đối truỵ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ, một khi vật phạm pháp có số lượng lớn, hoặc việc phổ biến được thực hiện cho nhiều người, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

Thực ra, cụm từ văn hoá phẩm có vẻ không thích hợp lắm để chỉ các hình ảnh mang tính chất đồ vật riêng tư của một người. Nếu hình ảnh riêng tư được đưa lên mạng internet, thì hình ảnh chắc chắn sẽ trở thành văn hoá phẩm, bởi mạng internet do bản chất là một loại văn hoá phẩm.

Tiếng nói. Việc giao tiếp bằng lời nói có tác dụng chuyển những suy nghĩ của một người đến một hoặc nhiều người khác. Khác với thư tín, tiếng nói, một khi được phát đi, sẽ tan ra trong không khí chứ không được lưu lại và bảo tồn thông qua các phương tiện vật chất như giấy tờ, băng, đĩa,… Song, điều đó không có nghĩa rằng tiếng nói không phải là một đối tượng cần được bảo vệ trong khuôn khổ luật về các quyền nhân thân. Tiếng nói của một người là của riêng người đó: người này có quyền lưu giữ nó lại bằng cách ghi âm hoặc cho phép ghi âm. Việc người đối thoại ghi âm tiếng nói của người cùng đối thoại với mình không bị coi là bất hợp pháp; nhưng việc sử dụng, phổ biến lời nói đã được ghi âm mà không được sự đồng ý của người nói, có thể bị chế tài một khi việc đó gây thiệt hại cho người nói. Điều chắc chắn, việc ghi âm cuộc trao đổi lời nói giữa hai người do một người thứ ba thực hiện sẽ bị coi là bất hợp pháp, nếu ít nhất một trong hai người tham gia vào cuộc trao đổi ấy không đồng ý[82]. BLDS năm 2005 có ghi nhận điều cấm này, nhưng chỉ trong giả thiết cuộc trao đổi lời nói được thực hiện qua điện thoại.

3.3.3. Tín ngưỡng, tôn giáo

Khái niệm. Có thể tạm định nghĩa tín ngưỡng, tôn giáo là lòng tin của con người vào sự tồn tại và khả năng chi phối của thần linh hoặc thế lực siêu nhiên đối với nhận thức, hành động của con người trong cuộc sống (còn gọi là cuộc sống thế tục).

Quyền đối với tín ngưỡng, tôn giáo. Không nói về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân trong quan hệ với Nhà nước, mà chỉ nói về tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong quan hệ giữa các cá nhân. Mỗi người có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo của mình hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào. Luật cấm sự phân biệt đối xử giữa người và người do sự khác biệt về tín ngưỡng, tôn giáo.

Về mặt pháp lý, vợ (chồng) không thể áp đặt tôn giáo, tín ngưỡng của mình đối với chồng (vợ). Tuy nhiên, trên thực tế, các cặp nam nữ thường đạt được các thoả thuận về tín ngưỡng, tôn giáo chung trước khi tiến đến hôn nhân; và nếu không đạt được một thoả thuận như thế, thì dự án chung sống của họ cũng dừng lại. Trong thời kỳ hôn nhân, nếu vì một lý do nào đó mà vợ hoặc chồng thay đổi tôn giáo, tín ngưỡng, thì chồng hoặc vợ cũng được thuyết phục để thay đổi theo. Còn nếu việc thuyết phục không thành công và nếu do sự thay đổi đó mà giữa vợ và chồng phát sinh mâu thuẫn trầm trọng, thì họ sẽ chọn con đường ly hôn để mỗi người có thể được tự do với tín ngưỡng, tôn giáo của riêng mình.

Cha mẹ không thể áp đặt tín ngưỡng, tôn giáo của mình đối với con, dù trên thực tế, con thường theo đuổi tôn giáo, tín ngưỡng mà cha mẹ đã lựa chọn cho gia đình.

CHƯƠNG 2 - PHÁP NHÂN

Khái niệm. Cá nhân, trong xã hội có tổ chức, không thể sống và hoạt động một cách cô lập. Có những lý do khác nhau để cá nhân luôn gắn bó với các cá nhân khác trong quá trình tồn tại của mình. Trên cơ sở quan hệ thân thuộc và quan hệ hôn nhân, các cá nhân sống trong cùng một gia đình. Các quan hệ chính trị liên kết các cá nhân, các gia đình và đặt cơ sở cho sự tạo thành quyền lực công cộng - Nhà nước và chính quyền địa phương. Nhắm đến cùng một mục đích hoặc quan tâm đến cùng một quyền lợi, các cá nhân liên kết với nhau và tạo thành một nhóm người có tổ chức đồng thời tập hợp các nỗ lực cá nhân để thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ tổ chức đó, nhằm đạt đến mục đích chung hoặc bảo vệ quyền lợi chung.

Vấn đề là các quy tắc liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cá nhân không đủ để chi phối các quan hệ phát sinh từ sự hình thành các nhóm cá nhân có tổ chức: một mặt, nếu giữa lợi ích riêng và lợi ích chung có sự mâu thuẫn, thì cá nhân luôn có thiên hướng hy sinh lợi ích chung để bảo vệ lợi ích riêng; mặt khác, thời gian tồn tại của nhóm sẽ không dài thời gian tồn tại của cá nhân, trong khi người giao dịch với nhóm có thể còn sống sau khi tất cả các thành viên trong nhóm đều chết.

Để bảo vệ tốt lợi ích chung của nhóm cũng như lợi ích của người thứ ba có quan hệ với

[82] Trong ngôn ngữ thông dụng, việc ghi âm này được gọi là "nghe lén".

nhóm, cần công nhận sự tồn tại độc lập của nhóm so với cá nhân. Luật đáp ứng yêu cầu đó bằng cách thừa nhận cho nhóm có tư cách chủ thể của quan hệ pháp luật. Nhóm được coi như có nhân thân của riêng mình, phân biệt với nhân thân của từng thành viên. Được nhân cách hoá, nhóm có khả năng tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ, nghĩa là có năng lực hành vi, và có tài sản riêng bảo đảm cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó. Một con người trừu tượng, nhóm thực hiện các quyền và nghĩa vụ thông qua những con người cụ thể được bố trí vào các cơ quan của nhóm, gọi là các cơ quan quản trị, điều hành và kiểm soát hoạt động của nhóm. Luật gọi những nhóm như thế là những pháp nhân.
Ta lần lượt tìm hiểu lịch sử của chế định pháp nhân, tính chất pháp lý của pháp nhân, phân loại pháp nhân và chế độ pháp lý của pháp nhân trong luật thực định Việt Nam.

MỤC 1 - Lịch sử của chế định pháp nhân

Pháp nhân trong luật phương Tây. Trong luật La Mã, quan niệm về pháp nhân hình thành tương đối muộn. Thoạt tiên, tư cách pháp nhân chỉ được thừa nhận cho Nhà nước; sau đó, pháp nhân Nhà nước còn được gán cho một số định chế công pháp của Đế quốc La Mã: thành bang, khu tự quản, thuộc địa,...Vào thời kỳ cuối, luật thừa nhận có hai loại pháp nhân tư pháp: *universitates personarum, gồm những người có cùng các hoạt động nghề nghiệp; và universitates bonorum, để chỉ những nhóm người hoạt động trong các lĩnh* vực *từ thiện hoặc phúc lợi chung.* Pháp nhân tư pháp trong Luật La Mã chỉ được phép thành lập một khi có giấy phép của chính quyền. Vả lại, đó chỉ được coi như sự mở rộng diện những nhóm người được hưởng tư cách pháp nhân Nhà nước: chính là theo khuôn mẫu Nhà nước mà các pháp nhân tư pháp chiếm hữu tài sản chung của các thành viên, có ngân quỹ chung và được điều hành nhờ có vai trò của người quản lý. Cần lưu ý rằng chính quyền La Mã chỉ cấp giấy phép cho các nhóm người hoạt động không vụ lợi và những nhóm hoạt động có thu lợi nhuận mà có quan hệ với Nhà nước hoặc giữ một vai trò công cộng. Các hội hoạt động để thu lợi nhuận cho riêng mình, tương ứng với các công ty thương mại trong luật đương đại, nói chung, không có tư cách pháp nhân: đối với người La mã, các hội này được coi như những nhóm cá nhân hình thành từ các hợp đồng (gọi là hợp đồng lập hội), có tài sản mà họ đưa vào một dự án đầu tư chung để tìm kiếm các lợi ích vật chất.

Dưới chế độ phong kiến, các nhóm có mục đích không vụ lợi cũng chỉ được thành lập và hoạt động nếu có giấy phép của nhà vua và, một khi có giấy phép, nhóm đương nhiên được hưởng quy chế của pháp nhân. Các nhóm có mục đích thu lợi nhuận từ hoạt động của mình (các hội thương mại) không phải xin giấy phép, nhưng các nhóm này không có tư cách pháp nhân: tài sản của nhóm thuộc sở hữu chung của các thành viên; chỉ đối với các chủ nợ xác lập giao dịch với cả nhóm trong khuôn khổ thực hiện mục tiêu hoạt động của nhóm, thì các tài sản ấy coi như được sử dụng để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của nhóm. Một vài nhóm có tính chất của một công ty đối vốn, tỏ ra hữu ích đối với việc củng cố quyền lực và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, được thừa nhận có tư cách pháp nhân, thậm chí, được giao phó một phần quyền lực công cộng. Trường hợp Công ty Đông Ấn (một công ty khai thác thuộc địa lớn) là một ví dụ.
Luật phương Tây đương đại thừa nhận tư cách pháp nhân của các nhóm hình thành trong khuôn khổ pháp luật, áp dụng Điều 20 Tuyên ngôn về quyền con người của Liên hợp Quốc: tất cả mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội. Các nhóm hoạt động nhằm thu lợi nhuận được thành lập mà không cần giấy phép và có tư cách pháp nhân từ lúc việc thành lập được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.
Pháp nhân trong luật Việt Nam. Luật cổ Việt Nam không xây dựng khái niệm pháp nhân. Chỉ trong luật cận đại, pháp nhân mới bắt đầu được nhắc đến như một khái niệm vay mượn từ luật học phương Tây. Trong luật viết thời kỳ thuộc địa, pháp nhân được hiểu như một nhóm người được tập hợp lại để thực hiện một hay nhiều mục đích nhất định và được luật thừa nhận có khả năng đảm nhận tư cách chủ thể của các quyền và nghĩa vụ, bao gồm (BLDS Bắc

Điều 284 và 289; BLDS Trung Điều 392 và 293): *Nhà nước, Tỉnh, Thị tứ, Làng, Phường hoặc Phố, Thôn, Giáp* (nhóm hình thành từ nhiều gia đình gắn bó với nhau do có những lợi ích chung đặc biệt trong lĩnh vực thờ cúng), Xóm (nhóm hình thành từ những gia đình gắn bó với nhau do quan hệ láng giềng hoặc quan hệ phát sinh từ hoạt động nông nghiệp), các hiệp hội được cho phép thành lập và các công ty thương mại được thành lập đúng luật.
Cho đến cuối những năm 1980, luật Việt Nam hiện đại không có các quy định có hệ thống về pháp nhân, nhưng vẫn sử dụng thuật ngữ này trong các văn bản pháp luật. Tư cách pháp nhân được thừa nhận cho một số cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, cho các doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật đầu tư. Dấu hiệu đặc trưng của tư cách đó về mặt hành chính, được ghi nhận trong các văn bản pháp luật, bao gồm: *1. có con dấu riêng; 2. có tài khoản riêng.*
Học thuyết pháp lý về phần mình, đã dựa vào tập quán giao dịch để xây dựng một hệ thống các điều kiện mà một nhóm người cần hội đủ để có thể được thừa nhận là có tư cách pháp nhân: *1 - Được thành lập một cách hợp pháp; 2 - Có tên gọi riêng và có trụ sở riêng; 3 - Có tài sản riêng; 4 - Có khả năng tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ về tài sản và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.* Ta thấy ngay rằng luật chỉ thừa nhận tư cách pháp nhân của những tổ chức được cho phép thành lập.

Khi hướng dẫn thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989, Nghị định số 17- HĐBT ngày 16/1/1990, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn, ghi nhận các điều kiện cơ bản mà một nhóm hoạt động nhằm thu lợi nhuận phải có đủ, để được hưởng tư cách pháp nhân, như sau: 1 - Được thành lập một cách hợp pháp; 2- Có tài sản riêng và chịu trách nhiệm một cách độc lập bằng tài sản đó; 3- Có quyền quyết định một cách độc lập về hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình; 4- Có quyền tự mình tham gia các quan hệ pháp luật. Khái quát hoá quan niệm về pháp nhân được xây dựng như trên Pháp lệnh hợp đồng dân sự ngày 29/4/1991 thừa nhận rằng các dấu hiệu cơ bản của pháp nhân bao gồm (Điều 4 khoản 2): 1 - Có tài sản riêng và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; 2 - Tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập, có thể là nguyên đơn, bị đơn trước Toà án; 3 - Được thành lập hợp pháp và được pháp luật công nhận là một tổ chức độc lập.
BLDS năm 1995 chính thức thừa nhận pháp nhân như là một chủ thể của quan hệ pháp luật và định nghĩa pháp nhân như là một tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó, và nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập (BLDS 1995 Điều 94).
Kế thừa định nghĩa trên, BLDS 2005 định nghĩa pháp nhân như là một tổ chức được thành lập hợp pháp; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập (BLDS Điều 84).
Theo định nghĩa đó, luật thừa nhận tư cách pháp nhân của những tổ chức sau đây (Điều 100): cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; tổ chức kinh tế; tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội; tổ chức xã hội-nghề nghiệp; quỹ xã hội, quỹ từ thiện; các tổ chức khác có đủ các điều kiện ghi nhận tại định nghĩa nêu trên. Cũng như trong luật hiện đại phương Tây, luật thực định Việt Nam thừa nhận có những pháp nhân hình thành không phải từ việc kết nhóm của các nhân có cùng mục đích: Luật doanh nghiệp 2005 thừa nhận khá năng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân độc lập với tư cách pháp nhân của thành viên thành lập công ty.

MỤC 2 - Tính chất pháp lý của pháp nhân

Có hai quan niệm trái ngược trong luật phương Tây. Luật Việt Nam đang xây dựng một quan niệm dung hoà.
Quan niệm về tính hư cấu của pháp nhân. Vào thế kỷ thứ XIX, nhiều nhà luật học Pháp

và Đức cho rằng pháp nhân, suy cho cùng, chỉ là một hư cấu do người làm luật dựng nên nhằm tạo thuận lợi cho việc thiết lập các quan hệ giữa một nhóm người với người thứ ba. Lợi ích, mục đích của pháp nhân, suy cho cùng, là lợi ích, mục đích

chung của các cá nhân trong nhóm; và quyền sở hữu của pháp nhân đối với tài sản của nhóm chỉ hình một cách diễn đạt khác của quyền sở hữu chung của các thành viên trong nhóm đối với các tài sản đó. Tư cách pháp nhân của nhóm do người làm luật ban cho, như một ân huệ, một món quà tặng, và có thể bị người làm luật tước bỏ, nếu muốn. Về năng lực, pháp nhân chỉ được phép hưởng những quyền do pháp luật xác định: tình trạng không có năng lực của pháp nhân là giải pháp nguyên tắc, tình trạng có năng lực của pháp nhân là ngoại lệ của nguyên tắc.

Quan niệm về tính hiện thực của pháp nhân. Một số nhà luật học lại cho rằng pháp nhân có một thực tại xã hội học giống như cá nhân có một thực tại sinh học. Nhóm có ý chí của riêng mình, phân biệt với ý chí của các thành niên và chính ý chí đó là cơ sở của quan niệm về chủ thể của quan hệ pháp luật: cá nhân có ý chí, vậy cá nhân là chủ thể của quyền và nghĩa vụ; nhóm cũng có ý chí; vậy, nhóm cũng là chủ thể của quyền và nghĩa vụ, với tư cách là một pháp nhân.

Ôn hoà hơn, một vài người cho rằng pháp nhân chỉ là một hiện thực thuần tuý kỹ thuật. Tư cách chủ thể của quan hệ pháp luật tỏ ra cần thiết trong chừng mực nó tạo điều kiện cho thực thể pháp lý mang tư cách đó thực hiện các giao dịch nhằm đạt tới mục đích của mình. Chính là xuất phát từ tư tưởng chủ đạo đó mà người làm luật thừa nhận tư cách chủ thể của quan hệ pháp luật cho cá nhân. Bởi vậy, một khi các cá nhân kết nhóm để theo đuổi một mục đích nhất định, thì nhóm tự nhiên phải có tư cách pháp nhân, ít nhất trong điều kiện mục tiêu mà nhóm theo đuổi là chính đáng. Song, việc thừa nhận tư cách pháp nhân cho một nhóm chỉ được thực hiện một khi nhóm tỏ ra là một tập thể có tổ chức chứ không chỉ là một tập hợp đơn giản của các cá nhân. Sự tổ chức chặt chẽ của pháp nhân khiến cho hoạt động của nó, thông qua vai trò của các cơ quan của pháp nhân, mang dáng dấp của hoạt động của một thực thể sống có khả năng nhận thức, tự điều khiển, giống như hoạt động của một cá nhân có đầu đủ năng lực hành vi.

Quan niệm của luật thực định Việt Nam. Pháp nhân trong luật Việt Nam không phải là một hư cấu cũng không là một hiện thực. Trước hết, pháp nhân có một khối tài sản riêng, độc lập với các khối tài sản riêng của các thành viên; sở hữu của pháp nhân không phải là một hình thức đặc biệt của sở hữu chung[83]. BLDS có đề cập đến hình thức sở hữu chung hỗn hợp, hình thành từ việc góp vốn của các chủ sở hữu thuộc các

thành phần kinh tế khác nhau để sản xuất, kinh doanh, thu lợi nhuận, và coi đó như một loại sở hữu chung (Điều 218). Nhưng có thể tin rằng sở hữu hỗn hợp chỉ là sở hữu chung, trong trường hợp những người góp vốn không thành lập một pháp nhân đứng đầu khối tài sản liên quan: nếu một pháp nhân (ví dụ, một công ty trách nhiệm hữu hạn) được thành lập, thì tài sản gọi là thuộc sở hữu hỗn hợp, là tài sản riêng của pháp nhân chứ không phải là tài sản chung của các thành viên công ty.

Song, pháp nhân không thể tự động sinh ra từ việc kết nhóm của những người có cùng mục đích, cùng lợi ích: để có tư cách pháp nhân được luật thừa nhận, tổ chức phải được thành lập hợp pháp, nghĩa là theo đúng quy định của pháp luật (BLDS Điều 84 khoản 1); nếu pháp luật quy định tổ chức phải đăng ký hoạt động, thì tổ chức đó chỉ được hưởng tư cách pháp nhân từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký. Một khi có tư cách pháp nhân, tổ chức của các cá nhân là một định chế pháp lý, là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội đặc thù ràng buộc các thành viên của pháp nhân, đồng thời là tổng hoà các mối quan hệ xã hội ràng buộc pháp nhân với các chủ thể khác của quan hệ xã hội.

MỤC 3 - Phân loại pháp nhân

Pháp nhân công pháp và pháp nhân tư pháp. Tạm gọi là pháp nhân công pháp trong luật Việt Nam, các tổ chức nắm giữ quyền lực công cộng và thực hiện một trong các chức

[83] Thực ra, có một thời, người làm luật Việt Nam đã lẫn lộn sở hữu của pháp nhân với sở hữu chung, nhưng sự lẫn lộn này đã chấm dứt: Xem *Tài sản*, nxb Trẻ, 1999, số 30.

năng của Nhà nước hoặc đảm nhận một vai trò trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Đảng cộng sản, giữ vị trí trung tâm trong hệ thống chính trị, là một ví dụ về pháp nhân công pháp. Trong danh sách pháp nhân công pháp được ghi nhận trong luật viết hiện hành không có Nhà nước; song tư cách pháp nhân của Nhà nước được thừa nhận trong nhiều chế định, đặc biệt là trong pháp luật về tài sản và pháp luật thừa kế: Nhà nước là người thực hiện quyền sở hữu toàn dân về tài sản, là người tiếp nhận các di sản không người hưởng.

Nhà nước có các cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân. Các cơ quan Nhà nước được phân loại thành cơ quan Nhà nước trung ương và cơ quan Nhà nước của các địa phương. Các đơn vị hành chính thành lập theo lãnh thổ (tỉnh, thành phố, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn) không phải là pháp nhân[84], mà chính các cơ quan Nhà nước được thành lập trong khuôn khổ tổ chức bộ máy chính quyền địa phương là các pháp nhân. Bên cạnh Nhà nước có các tổ chức thành viên khác của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa: mặt trận tổ quốc, tổng liên đoàn lao động Việt Nam,...

Các pháp nhân công pháp quản lý tài sản của mình bằng các công cụ của hệ thống kế toán công. Pháp nhân công pháp có thể hình thành từ sự kết nhóm của các cá nhân (nói chung, các chủ thể của quan hệ pháp luật), như Đảng cộng sản, mặt trận tổ quốc, tổng liên đoàn lao động,..., nhưng cũng có thể do ý chí của Nhà nước, như các cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan dịch vụ công - trường học, bệnh viện...

Pháp nhân tư pháp không phải là pháp nhân công pháp. Tổ chức kinh tế là ví dụ điển hình về pháp nhân tư pháp. Tổ chức kinh tế có thể là doanh nghiệp Nhà nước, các hợp tác xã, các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,... Có một số tổ chức kinh tế, do Nhà nước thành lập, mang tính chất của pháp nhân hỗn hợp, vừa công pháp vừa tư pháp, như các doanh nghiệp Nhà nước độc quyền trong các lĩnh vực then chốt
của nền kinh tế quốc dân (bưu chính viễn thông, hàng không dân dụng, năng lượng,...)[85]. Các hội tự nguyện của những người có cùng nghề nghiệp, cùng sở thích, cùng lợi ích cá nhân chung (như hội những người nuôi tôm, hội câu cá, hội làm vườn,...) cũng là các pháp nhân tư pháp. Các pháp nhân tư pháp hoạt động sản xuất, kinh doanh và pháp nhân hỗn hợp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp.

Trong luật Việt Nam hiện hành doanh nghiệp Nhà nước trong các lĩnh vực mà Nhà nước không nắm độc quyền cũng mang các đặc điểm cơ bản của pháp nhân tư pháp. Tuy nhiên, các cán bộ điều hành chủ chốt của các doanh nghiệp này lại được hưởng quy chế đặc biệt như công chức biệt phái sang khu vực kinh tế.

Quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Khác với pháp nhân được thành lập từ sự kết nhóm của các chủ thể của quan hệ pháp luật hoặc do ý chí của Nhà nước, quỹ xã hội, quỹ từ thiện là một pháp nhân hình thành từ việc trích các tài sản, vốn thuộc một hình thức sở hữu nào đó, để tạo thành một khối tài sản phục vụ cho các hoạt động xã hội hoặc từ thiện. Quỹ xã hội, quỹ từ thiện không phải là một nhóm người mà là một tập hợp tài sản và chính từ sự cần thiết của việc đặt các tài sản thuộc tập hợp đó dưới một chế độ quản lý chặt chẽ để việc khai thác quỹ đó thực sự có hiệu quả mà luật thừa nhận tư cách pháp nhân của tổ chức con người quản lý quỹ đó.

Pháp nhân có thu lợi nhuận và pháp nhân không thu lợi nhuận. Thu lợi nhuận có thể được hiểu như là hoạt động đầu tư tài sản để tìm kiếm chênh lệch giá trị giữa đầu vào và đầu ra. Các pháp nhân công pháp và các quỹ xã hội, quỹ từ thiện là các pháp nhân không thu lợi nhuận. Pháp nhân tư pháp và pháp nhân hỗn hợp có thể nhắm đến mục đích thu lợi nhuận hoặc các mục đích khác. Một sô pháp nhân không thu lợi nhuận, trong khung cảnh của luật thực định, có thể tìm kiếm lợi ích vật chất thông qua việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bằng tài sản của mình.

---

[84] Trong luật của Pháp, các đơn vị hành chính cơ sở (*communes*) là những pháp nhân. Tư cách pháp nhân của cơ quan Nhà nước được thừa nhận cho hầu hết các đơn vị sự nghiệp (như trường học, bệnh viện,…) nhưng chỉ được thừa nhận cho một số cơ quan quản lý. Riêng các Bộ không phải là các pháp nhân.

[85] Theo xu thế hội nhập vào đời sống kinh tế khu vực và toàn cầu, Nhà nước dần dần từ bỏ vị thế độc quyền cả trong các lĩnh vực kinh tế then chốt. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Nhà nước trong các lĩnh vực này vẫn tiếp tục mang tính chất tổ chức công trong khu vực kinh tế.

MỤC 4 - Chế độ pháp lý của pháp nhân

1. Sự thành lập pháp nhân

Pháp nhân có thể được thành lập trong khuôn khổ xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện bộ máy Nhà nước hoặc theo ý chí của các chủ thể của quyền và nghĩa vụ được luật thừa nhận.

Thành lập pháp nhân trong khuôn khổ xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. Nhà nước và Đảng cộng sản là những pháp nhân trung tâm trong nhóm các pháp nhân loại này. Các tổ chức thành viên của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa khá đa dạng: mặt trận tổ quốc, tổng liên đoàn lao động, đoàn thanh niên cộng sản, hội liên hiệp phụ nữ, hội liên hiệp thanh niên, hội cựu chiến binh, các tổ chức thành viên khác của mặt trân tổ quốc,... Trong hầu hết trường hợp, các tổ chức này hình thành như là kết quả sự vận động mang tính quy luật của phong trào cách mạng.

Ở góc độ pháp lý, tư cách pháp nhân của các tổ chức này được thừa nhận một cách đương nhiên trong trường hợp tổ chức đã ra đời trước khi có Nhà nước XHCN và sự hiện hữu của tổ chức trong hệ thống chính trị được chính thức ghi nhận trong Hiến pháp. Ví dụ điển hình là việc thừa nhận tư cách pháp nhân của Đảng cộng sản, Đoàn thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Tổng công đoàn… Nếu tổ chức được thành lập sau khi có Nhà nước XHCN, thì thông thường, tư cách pháp nhân của tổ chức được thừa nhận trong văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập tổ chức đó. Ví dụ điển hình là việc thừa nhận tư cách pháp nhân của Hội cựu chiến binh.

Thành lập pháp nhân trong khuôn khổ xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước. Các cơ quan Nhà nước được thành lập theo trình tự, thủ tục do pháp luật (chủ yếu là luật Nhà nước) quy định. Một khi thủ tục thành lập hoàn tất, tư cách pháp nhân của cơ quan Nhà nước cũng phát sinh. Chính luật tạo ra các pháp nhân loại này; còn cơ quan ra quyết định thành lập chỉ là một trong những người thực hiện các thủ tục cần thiết cho sự ra đời của pháp nhân. Thậm chí có trường hợp pháp nhân được thành lập do hiệu lực trực tiếp của luật chứ không phải của một văn bản áp dụng pháp luật. Ví dụ điển hình là việc thành lập các cơ quan Hội đồng nhân dân, UBND các cấp.

Cơ quan Nhà nước được phân loại thành cơ quan quyền lực, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát và cơ quan quản lý. Trong các cơ quan quản lý còn có cơ quan quản lý thuần tuý (còn gọi là cơ quan hành chính) và cơ quan sự nghiệp (tức là cơ quan hoạt động có thu).

Thành lập pháp nhân theo ý chí của chủ thể của quyền và nghĩa vụ được luật thừa nhận. Các pháp nhân loại này có thể mang tính chất của pháp nhân tư pháp hoặc pháp nhân hỗn hợp hoặc quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Các pháp nhân này có thể sinh ra trên cơ sở hợp đồng giữa các chủ thể của quan hệ pháp luật (như trường hợp công ty nhiều thành viên) hoặc do hành vi pháp lý đơn phương (như trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, quỹ xã hội do một người lập). Việc thành lập pháp nhân loại này phải được sự cho phép hoặc công nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và, trong hầu hết các trường hợp, pháp nhân phải đăng ký hoạt động mới được hưởng tư cách đó trước người thứ ba.

Riêng về quỹ xã hội, quỹ từ thiện do một cá nhân thành lập. Sẽ không có vấn đề gì đặc biệt nếu quỹ được thành lập lúc cá nhân còn sống và đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để được hưởng tư cách pháp nhân. Nhưng, nếu cá nhân thành lập quỹ bằng di chúc, thì sao? Theo BLDS Điều 635 *"Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức, thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế"*. Quỹ xã hội, quỹ từ thiện lập bằng di chúc chỉ có thể tồn tại sau khi mở thừa kế, rõ hơn là sau khi hoàn tất các thủ tục xin phép thành lập....

2. Hoạt động của pháp nhân

2.1. Các cơ quan của pháp nhân

Pháp nhân, như đã biết, không phải là con người cụ thể. Để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong quan hệ với người thứ ba, pháp nhân được tổ chức thành các cơ quan tại

đó, các cá nhân được bố trí ở các cương vị khác nhau và xử sự nhân danh pháp nhân.

2.1.1. Pháp nhân công pháp

Nhà nước, các cơ quan Nhà nước và đơn vị vũ trang. Nhà nước được tổ chức thành các cơ quan. Tổ chức Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa không dựa vào học thuyết phân quyền. Tư tưởng chủ đạo trong việc tổ chức Nhà nước là: một mặt, toàn bộ quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; mặt khác, giữa các cơ quan Nhà nước có sự phân công để thực hiện các chức năng của Nhà nước.

Cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền chuyên môn, cơ quan kiểm sát và cơ quan xét xử, cũng như đơn vị vũ trang được tổ chức và điều hành theo chế độ thủ trưởng: người đứng đầu cơ quan là người duy nhất được thay mặt cơ quan để xác lập và thực hiện các giao dịch với người thứ ba.

Cơ quan quyền lực và quản lý Nhà nước có thẩm quyền chung được điều hành theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể. Trong quan hệ với các chủ thể khác của quan hệ pháp luật, các cơ quan này được đại diện bởi người đứng đầu gọi là Chủ tịch. Riêng Thủ tướng chính phủ và Chủ tịch nước là cơ quan đặc biệt: bản thân cơ quan Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ và cá nhân Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ hoàn toàn đồng nhất.

Tổ chức trong hệ thống chính trị. Các tổ chức trong hệ thống chính trị có các cơ quan được ghi nhận trong điều lệ hoạt động của mình. Đảng cộng sản có Bộ chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành trung ương,…; Mặt trận Tổ quốc có Uỷ ban trung ương;…

2.1.2. Pháp nhân tư pháp và pháp nhân hỗn hợp

Nguyên tắc phân công giữa các cơ quan. Để ngăn ngừa sự lạm quyền của một hoặc một nhóm cá nhân trong việc điều hành pháp nhân cũng như trong các hoạt động đối ngoại của pháp nhân, việc phân chia pháp nhân thành nhiều cơ quan tỏ ra cần thiết. Việc tổ chức các cơ quan của các pháp nhân tư pháp và pháp nhân hỗn hợp được thực hiện theo đúng điều lệ mà pháp nhân có quyền (và có nghĩa vụ) xây dựng. Điều lệ của pháp nhân phải có hình thức và nội dung phù hợp với các quy định của pháp luật áp dụng đối với từng loại pháp nhân. Điều lệ của pháp nhân, một khi được xây dựng và thông qua đúng luật, có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với tất cả thành viên của pháp nhân. Không chấp nhận điều lệ, thành viên chỉ có mỗi cách xử sự đúng luật là xin ra khỏi pháp nhân. Điều lệ hợp pháp của pháp nhân cũng có hiệu lực đối kháng với người thứ ba.

Một cách tổng quát, pháp nhân tư pháp và pháp nhân hỗn hợp có hai nhóm cơ quan chính: cơ quan quyết nghị và cơ quan chấp hành. Một số pháp nhân có quy mô tổ chức lớn còn có thêm cơ quan kiểm soát.

- Cơ quan quyết nghị của pháp nhân: là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của pháp nhân và có cả khả năng định đoạt số phận pháp lý của pháp nhân (sáp nhập, giải thể,..). Cơ quan này được tổ chức dưới hình thức đại hội thành viên.

- Cơ quan chấp hành của pháp nhân: là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định của cơ quan quyết nghị, đồng thời đảm nhận việc quản lý đối với các công việc hàng ngày của pháp nhân, kể cả việc đại diện cho pháp nhân trong quan hệ với người thứ ba. Cơ quan chấp hành có thể mang những tên gọi khác nhau: ban giám đốc, hội đồng quản trị, ban quản lý,... Bằng hoạt động của mình, cơ quan chấp hành ràng buộc trách nhiệm của pháp nhân đối với những giao dịch mà cơ quan chấp hành xác lập và thực hiện nhân danh pháp nhân và trong giới hạn quyền và nhiệm vụ được giao.

- Cơ quan kiểm soát: là cơ quan có trách nhiệm bảo đảm tính hợp pháp của các hoạt động của pháp nhân. Thông qua hoạt động kiểm soát, cơ quan này đánh giá chất lượng pháp lý của sự vận hành của pháp nhân cũng như của các giao dịch mà pháp nhân xác lập với người thứ ba.

2.2. Năng lực của pháp nhân

2.2.1. Năng lực pháp luật của pháp nhân

Tính đặc biệt của pháp nhân. Pháp nhân có năng lực pháp luật kể từ thời điểm tư cách pháp nhân phát sinh. Khác với năng lực pháp luật của cá nhân, năng lực pháp luật của pháp nhân do luật xác định về nội dung, phù hợp với đặc điểm của từng loại pháp nhân, thậm chí với từng pháp nhân. Chắc chắn, pháp nhân không thể có các quyền và nghĩa vụ đặc thù của cá nhân, như quyền kết hôn, quyền nhận cha, mẹ cho con, quyền nuôi con nuôi... Mỗi pháp

nhân có những mục đích xác định để theo đuổi và, do đó, có khả năng có những quyền và nghĩa vụ giới hạn bởi chính các mục đích đó. *Ví dụ: Sở tư pháp không có năng lực giao kết hợp đồng mua bán nông sản hàng hoá, do không có tư cách thương nhân; công ty trách nhiệm hữu hạn không có năng lực phát hành cổ phiếu;...*

Mục đích của các pháp nhân tư pháp và pháp nhân hỗn hợp được xác định trong điều lệ của pháp nhân. Bởi vậy, khi giao dịch với pháp nhân loại này, người thứ ba, muốn tránh khả năng giao dịch bị tuyên bố vô hiệu do không phù hợp với mục đích của pháp nhân đối tác, nên tham khảo điều lệ của pháp nhân trước khi quyết định nên hay không nên tiến hành giao kết. Cần lưu ý rằng người thứ ba luôn ở trong tình trạng buộc phải biết nội dung điều lệ của pháp nhân tư pháp, bởi trong mọi trường hợp, điều lệ này luôn được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nghĩa là được công bố cho tất cả mọi người.

Thụ hưởng tặng cho hoặc di tặng. Trong khung cảnh của luật thực định Việt Nam, vấn đề liệu pháp nhân có năng lực giao kết hợp đồng tặng cho với tư cách là người được tặng cho hoặc năng lực chấp nhận các di tặng chưa được giải quyết rõ ràng. Theo BLDS Điều 635, cơ quan, tổ chức có thể là người thừa kế theo di chúc, nhưng không chỉ rõ đó là loại cơ quan, tổ chức nào.

Có một quy tắc được chấp nhận trong học thuyết pháp lý theo đó, công dân được phép làm những gì pháp luật không cấm, trong khi cơ quan Nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Với quy tắc này, thì hẳn cơ quan hành chính Nhà nước không có quyền tiếp nhận các tặng cho hoặc di tặng. Thực tiễn, về phần mình, lại thừa nhận cho các cơ quan sự nghiệp (như trường học, viện nghiên cứu, bệnh viện,…) năng lực tiếp nhận các tặng cho và di tặng, nhưng tất nhiên, với điều kiện các tài sản được tặng cho hoặc di tặng phải được khai thác phù hợp với mục đích hoạt động của cơ quan đó.

Việc nhận các tài sản tặng cho hoặc di tặng của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị có vẻ được thực tiễn thừa nhận rộng rãi hơn: Đảng cộng sản, Mặt trận Tổ quốc có quyền tiếp nhận các tài sản do các tổ chức, cá nhân khác tặng hoặc hoặc do cá nhân để lại theo di chúc.

Các pháp nhân tư pháp và pháp nhân hỗn hợp được hưởng các tặng cho và di tặng như những cá nhân.

2.2.2. Năng lực hành vi của pháp nhân.

Pháp nhân không có năng lực hành vi thực. Suy cho cùng, khái niệm năng lực hành vi của pháp nhân không thể được xây dựng như một khái niệm ứng dụng được. Pháp nhân, dù được nhân cách hoá, không phải là con người cụ thể và do đó, không thể tự mình xử sự. Ngay cả các cơ quan của pháp nhân cũng chỉ vận hành thông qua vai trò của những cá nhân cụ thể đảm nhận các chức vụ cụ thể. Suy cho cùng, pháp nhân luôn phải được đại diện, từ khi được thành lập cho đến khi chấm dứt, trong tất cả các hoạt động của mình. Năng lực hành vi của pháp nhân thực ra là năng lực hành vi mà pháp nhân vay mượn của những con người mà pháp nhân hoá thân vào.

2.3. Tài sản của pháp nhân

Pháp nhân công pháp. Trong luật hiện hành, tài sản gọi là thuộc về pháp nhân công pháp thực ra của Nhà nước. Các pháp nhân công pháp chỉ có quyền sử dụng các tài sản được giao cho mình phù hợp với mục đích hoạt động của mình. Pháp nhân công pháp không có tài sản có riêng, do đó, không thể có tài sản nợ riêng: các nghĩa vụ tài sản do pháp nhân công pháp xác lập được Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện.

Pháp nhân hỗn hợp. Các doanh nghiệp Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế trọng yếu được Nhà nước giao một số tài sản để khai thác. Các tài sản này thuộc về Nhà nước; còn doanh nghiệp Nhà nước có quyền quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp Nhà nước (BLDS Điều 203). Doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế trọng yếu cũng có tài sản nợ riêng; nhưng việc xác định khối tài sản bảo đảm cho việc thực hiện các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp có vẻ không đơn giản trong luật thực định: các doanh nghiệp này thường được các định chế tài chính công hỗ trợ mỗi khi cần vượt qua khó khăn.

Pháp nhân tư pháp. Pháp nhân tư pháp có khối tài sản riêng, bao gồm các tài sản có riêng và các tài sản nợ riêng. Pháp nhân chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài sản của mình bằng các tài sản có của mình. Quy tắc này, thực ra, chỉ được áp dụng nghiêm ngặt đối với các pháp nhân tư pháp. Tài sản của pháp nhân công pháp và pháp nhân hỗn hợp không thể bị kê biên và bán để thực hiện các nghĩa vụ của pháp nhân. Theo BLDS Điều 101 khoản 2, cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang chịu trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình bằng kinh phí được cấp từ ngân sách Nhà nước. Còn các pháp nhân hỗn hợp, nếu gặp khó khăn, thường được Nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nghĩa vụ tài sản của mình.

Trong trường hợp pháp nhân được thành lập từ sự kết nhóm của nhiều chủ thể của quan hệ pháp luật, thì khối tài sản của pháp nhân độc lập với khối tài sản của mỗi thành viên: các chủ nợ của thành viên không có quyền yêu cầu kê biên và bán tài sản của pháp nhân để thực hiện nghĩa vụ riêng của thành viên; ngược lại các chủ nợ của pháp nhân không có quyền yêu cầu kê biên và bán tài sản của thành viên để thực hiện các nghĩa vụ của pháp nhân[86].

Trong quan hệ giữa pháp nhân và thành viên của pháp nhân, các tài sản của pháp nhân không phải thuộc sở hữu chung của các thành viên: pháp nhân có tài sản của mình; còn thành viên có một phần hùn và chính phần hùn đó là tài sản thuộc quyền sở hữu của thành viên[87].

Doanh nghiệp Nhà nước không độc quyền. Tính chất pháp lý của các quyền của doanh nghiệp Nhà nước không độc quyền đối với tài sản đầu tư vào doanh nghiệp chưa được xác định rõ trong khung cảnh của luật thực định Việt Nam. Tài sản đầu tư vào doanh nghiệp Nhà nước vẫn thuộc về Nhà nước, nhưng doanh nghiệp có các quyền sử dụng các tài sản ấy và thậm chí có quyền định đoạt đối với một số tài sản trong quá trình hoạt động của mình. Doanh nghiệp Nhà nước cũng có tài sản nợ riêng như bất kỳ pháp nhân tư pháp nào và các tài sản nợ ấy được bảo đảm thanh toán bằng các tài sản có được đầu tư vào doanh nghiệp cũng như bằng các tài sản mà doanh nghiệp tao ra trong quá trình hoạt động của mình. Các chủ nợ của doanh nghiệp Nhà nước, trên nguyên tắc, có quyền yêu cầu kê biên các tài sản thuộc quyền sử dụng và định đoạt của doanh nghiệp Nhà nước để thu hồi nợ, nhưng không có quyền kê biên các tài sản khác của Nhà nước.

2.4. Nhân thân của pháp nhân

Tên của pháp nhân. Pháp nhân phải có tên gọi riêng và phải sử dụng tên gọi của mình trong các giao dịch. Tên gọi của pháp nhân trong luật Việt Nam phải bằng tiếng Việt, thể hiện rõ loại hình tổ chức của pháp nhân và phân biệt với các pháp nhân khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động (BLDS Điều 87 khoản 1), *ví dụ: công ty cổ phần Bảo Việt, Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu,...* Pháp nhân có thể sử dụng tên gọi tắt hoặc tên gọi bằng tiếng nước ngoài trong các hoạt động trao đổi thông tin hoặc trong quan hệ giao tế.

Tên gọi của pháp nhân hoạt động thương mại (tên thương mại) là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Tên thương mại cò giá trị tài sản, có thể được chuyển nhượng và được bảo hộ theo quy định của pháp luật. Bởi vậy, việc lựa chọn tên gọi của pháp nhân thương mại không tự do như việc đặt tên cho một cá nhân.

Tên gọi của pháp nhân công pháp do pháp luật quy định.

Trụ sở của pháp nhân. Pháp nhân có trụ sở tại nơi đặt cơ quan điều hành của mình (cơ quan chấp hành đối với pháp nhân tư pháp và pháp nhân hỗn hợp) (BLDS Điều 90), dù có thể toàn bộ hoặc một phần lớn hoạt động của pháp nhân được thực hiện ở nơi khác. Trụ sở của pháp nhân, trong chừng mực nào đó, mang ý nghĩa đối với pháp nhận (và đối với người giao dịch với pháp nhân) như nơi cư trú của cá nhân: nếu pháp nhân là bị đơn trong một vụ tranh chấp liên quan đến động sản, thì Toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, trên

---

[86] Đó là giải pháp nguyên tắc. Một cách ngoại lệ, các chủ nợ của một thành viên công ty hợp danh có quyền yêu cầu kê biên và bán tài sản của thành viên để thu hồi nợ.

[87] Trong luật của Pháp, phần hùn của thành viên là căn cứ xác lập môt quyền tương tự như quyền chủ nợ đối với pháp nhân, một thứ quyền chủ nợ đặc biệt, cho phép thành viên được hưởng một phần lợi nhuận của pháp nhân và nhận một phần tài sản khi thanh lý pháp nhân.

nguyên tắc, là Toà án nơi có trụ sở của pháp nhân... Pháp nhân có thể chọn nơi khác làm địa chỉ liên lạc (Điều 90).

Quốc tịch của pháp nhân. Cũng như cá nhân, pháp nhân có quốc tịch riêng. Tất cả các pháp nhân công pháp được thành lập trong khuôn khổ xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị và bộ máy Nhà nước Việt Nam, cũng như pháp nhân hỗn hợp, đều là pháp nhân Việt Nam. Các pháp nhân tư pháp có trụ sở tại Việt Nam, trên nguyên tắc cũng là pháp nhân Việt Nam.

Danh dự, uy tín của pháp nhân. Là một chủ thể của quan hệ xã hội, pháp nhân có danh dự, uy tín của riêng mình, độc lập với uy tín, danh dự của cá nhân thành viên[88]. Uy tín, danh dự của pháp nhân hình thành trong quá trình hoạt động của pháp nhân nhằm vươn tới mục đích của mình và được củng cố bằng hiệu quả hoạt động của pháp nhân.

2.5. Quyền kiện cáo

Bảo vệ lợi ích riêng. Pháp nhân có quyền kiện để yêu cầu bảo vệ lợi ích của riêng mình, trong lĩnh vực tài sản (đòi nợ hội phí, đòi lại tài sản bị chiếm đoạt trái pháp luật, đòi bồi thường thiệt hại vật chất,…) hoặc phi tài sản (đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần). Quyền kiện cáo để yêu cầu bảo vệ lợi ích riêng được thừa nhận cho tất cả các pháp nhân, không phân biệt pháp nhân công pháp hay pháp nhân tư pháp.

Bảo vệ lợi ích chung. Pháp nhân cũng có thể kiện cáo để yêu cầu bảo vệ lợi ích chung. Thông thường, quyền kiện cáo đòi bảo vệ lợi ích chung được luật chính thức thừa nhận cho một số pháp nhân là tổ chức xã hội hoặc một cơ quan Nhà nước đảm trách một hoặc nhiều mặt công tác xã hội. Ví dụ, Uỷ ban chăm sóc và bảo vệ trẻ em co thể kiện yêu cầu cấm bán thuốc lá cho trẻ em. Có trường hợp lợi ích chung được viện dẫn trong quá trình tìm kiếm biện pháp bảo vệ lợi ích riêng của một người nào đó; ví dụ, Hội liên hiệp phụ nữ kiện yêu cầu huỷ hôn nhân trái pháp luật do người đàn ông đã có vợ (Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 15), qua đó, bảo vệ chế độ hôn nhân một vợ một chồng.

3. Chấm dứt pháp nhân

Các trường hợp chấm dứt pháp nhân. Theo BLDS Điều 99 khoản 1, pháp nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- Hợp nhất, sáp nhập, chia, giải thể pháp nhân theo quy định tại các điều 94, 95, 96 và 98 của Bộ luật dân sự.
- Bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

Ta có hai lưu ý:

- *Lưu ý thứ nhất*: dù luật không quy định, pháp nhân cũng chấm dứt trong trường hợp mục đích của pháp nhân đã đạt được, ngay nếu như thời hạn hoạt động của pháp nhân chưa hết; ví dụ: công ty được thành lập nhằm mục đích khai thác khoáng sản tại một khu vực có ranh giới được xác định rõ và nguồn khoáng sản đã cạn kiệt.
- *Lưu ý thứ hai*: pháp nhân chỉ chấm dứt kể từ ngày kết thúc việc thanh toán tài sản theo quy định của pháp luật và (hoặc) theo điều lệ (nếu có).

Thanh toán tài sản của pháp nhân. Pháp nhân không có người thừa kế như cá nhân. Khi pháp nhân chấm dứt, tài sản của pháp nhân được chuyển giao cho các chủ thể khác của quan hệ pháp luật tuỳ theo tính chất, đặc điểm của từng loại pháp nhân.

- Các tài sản còn lại của pháp nhân công pháp và pháp nhân hỗn hợp được giao cho Nhà nước. Cần lưu ý rằng giải pháp này được áp dụng cả đối với các pháp nhân hình thành từ việc kết nhóm các cá nhân để xây dựng tổ chức thành viên của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa: một khi tổ chức hoàn thành vai trò lịch sử của mình và chấm dứt, tài sản còn lại của tổ chức không được chia cho các thành viên, mà trở thành tài sản thuộc sở hữu

[88] Bởi vậy, trên nguyên tắc, việc xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân người đại diện của pháp nhân không thể coi là việc xúc phạm danh dự, uy tín của pháp nhân.

toàn dân và do Nhà nước quản lý.

- Các tài sản còn lại của tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân được giao lại cho người đầu tư vốn vào tổ chức kinh tế. Tài sản của doanh nghiệp Nhà nước được Nhà nước thu hồi; tài sản của các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được phân chia giữa các thành viên theo điều lệ hoặc, nếu điều lệ không có quy định, theo tỷ lệ vốn góp của các thành viên.
- Các tài sản còn lại của các tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không được phân chia cho các thành viên mà phải được giải quyết theo quy định của pháp luật (BLDS Điều 104 khoản 3). Các tài sản còn lại của quỹ xã hội, quỹ từ thiện cũng được giải quyết theo quy định của pháp luật chứ không được giao lại cho các thành viên sáng lập hoặc cho người thừa kế của họ (Điều 105 khoản 4).

CHƯƠNG 3 - Hộ Gia đình. Tổ hợp tác

Nhóm không có tư cách pháp nhân - Nhóm không có tư cách pháp nhân trong luật phương Tây không phải là một thực thể pháp lý và không có khả năng đảm nhận tư cách chủ thể của quyền và nghĩa vụ. Luật Việt Nam cũng chấp nhận giải pháp này, nhưng coi đó là giải pháp nguyên tắc. Một cách ngoại lệ, và phù hợp với đặc điểm và trình độ của nền kinh tế Việt Nam, luật Việt Nam thừa nhận có hai loại chủ thể của quan hệ pháp luật không có tư cách pháp nhân mà cũng không phải là cá nhân: hộ gia đình và tổ hợp tác.

MỤC 1 - Hộ gia đình

Khái niệm. Theo BLDS Điều 106, hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trong trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định, là chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự thuộc các lĩnh vực này.

Sự thành lập hộ gia đình. Hộ gia đình luôn bắt đầu bằng hai người kết hợp với nhau do quan hệ hôn nhân và khối tài sản chung của hộ gia đình luôn có các yếu tố thứ nhất là các tài sản chung của vợ và chồng. Các thành viên khác của hộ gia đình xuất xứ từ ba nguồn: 1 - Tự nhiên, tức là do được cha và mẹ - hai thành viên đầu tiên - sinh ra, sau đó tham gia vào hoạt động kinh tế chung của hộ, khi có đủ khả năng lao động; trong các hộ gia đình tồn tại lâu năm còn có các thành viên có xuất xứ tự nhiên do được một thành viên không phải là người sáng lập ra hộ gia đình sinh ra, sau đó tham gia vào hoạt động kinh tế chung của hộ; 2 - Nuôi con nuôi, tức là được thành viên của hộ nhận làm con nuôi, sau đó tham gia vào hoạt động kinh tế của hộ; 3 - Hôn nhân, một người ngoài hộ kết hôn với một thành viên trong hộ và sau đó, cùng với cả hộ thực hiện hoạt động kinh tế chung. Ta thấy rằng thành viên của hộ gia đình trước hết phải là thành viên của gia đình; nhưng không phải thành viên nào của gia đình cũng là thành viên của hộ gia đình: chỉ gọi là thành viên của hộ gia đình, những thành viên nào của gia đình tham gia vào hoạt động kinh tế chung của hộ. *Hộ gia đình đương nhiên có tư cách chủ thể của quan hệ pháp luật mà không cần xúc tiến một thủ tục pháp lý nào.*

Chế độ pháp lý của hộ gia đình. Hộ gia đình được đại diện bởi chủ hộ. Thông thường chủ hộ gia đình là người đứng đầu gia đình theo tập quán - cha, mẹ, ông, bà. Có trường hợp cha, mẹ, ông, bà đều mất hoặc không còn tham gia vào hoạt động kinh tế chung của hộ, thì chủ hộ có thể là con trưởng hoặc con thứ đã thành niên, tuỳ theo kết quả dàn xếp trong nội bộ gia đình. Nếu cha, mẹ, ông, bà không còn đứng đầu hộ gia đình mà giữa những người có liên quan không có được sự dàn xếp cần thiết, thì hộ gia đình sẽ được chia nhỏ thành các hộ gia đình mới.

Chủ hộ gia đình được giao các quyền hạn rộng rãi trong việc xác lập và thực hiện các giao dịch dưới danh nghĩa của hộ, kể cả các giao dịch có tác dụng định đoạt tài sản. Chủ hộ có thể uỷ quyền cho thành viên khác đã thành niên làm đại diện cho hộ trong quan hệ dân sự (BLDS Điều 107 khoản 1).

Hộ gia đình có năng lực pháp luật phù hợp với mục đích tồn tại của nó: để hoạt động kinh tế chung trong quan hệ sử dụng đất, trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, ... Nói chung, theo tập quán, hộ gia đình có năng lực có quyền và nghĩa vụ gần giống như cá nhân, trừ các quyền và nghĩa vụ gắn liền với con người - quyền kết hôn, quyền nhận cha, mẹ cho con,

quyền lập di chúc,... Hộ gia đình có thể là nguyên đơn hoặc bị đơn trước Toà án.
Hộ gia đình có một khối tài sản, gọi là khối tài sản chung của hộ. Thông thường, khối tài sản có của hộ gồm các tài sản chuyên dùng để hoạt động kinh tế chung. BLDS Điều 108 quy định : Tài sản chung của hộ gia đình gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộ gia đình, tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung, được thừa kế chung và các tài sản khác mà các thành viên thoả thuận là tài sản chung của hộ. Song, khác với khối tài sản của pháp nhân hoặc của cá nhân, các tài sản nợ của hộ gia đình được bảo đảm không chỉ bằng các tài sản có chung của hộ mà còn cả bằng các tài sản có thuộc khối tài sản riêng của thành viên của hộ (Điều 110 khoản 2). Các chủ nợ riêng của thành viên không có quyền yêu cầu kê biên tài sản chung của hộ; nhưng nếu mỗi thành viên đều có nghĩa vụ đối với một chủ nợ, thì chủ nợ này lại có quyền đó.

MỤC 2 - Tổ hợp tác

Khái niệm. Tổ hợp tác là sự kết nhóm của từ 3 cá nhân trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi ích và cùng chịu trách nhiệm (BLDS Điều 111 khoản 1 và Điều 112). Trên thực tế, tổ hợp tác hình thành từ sự thoả thuận giữa những người có cùng nghề nghiệp nông nghiệp hoặc thủ công nghiệp, nhằm tập hợp các nỗ lực của cá nhân, tạo thành nỗ lực chung để thực hiện các hoạt động nghề nghiệp đó với hiệu quả cao hơn so với trường hợp cá nhân hoạt động riêng lẻ. Có thể coi tổ hợp tác như là một nhân vật pháp lý nằm giữa pháp nhân và nhóm thực tế trong lĩnh vực kinh tế.
Thành lập tổ hợp tác. Hợp đồng thành lập tổ hợp tác phải lập thành văn bản có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn (Điều 111 khoản 1). Luật không nói rõ tại UBND địa phương nào mà tổ hợp tác phải yêu cầu chứng thực hợp đồng. Có lẽ, thẩm quyền chứng thực thuộc về UBND địa phương nơi cư trú của tổ trưởng, ngay nếu như tổ trưởng cư trú ở một nơi, trong khi tổ tiến hành các hoạt động hoặc phần lớn hoạt động ở một nơi khác: nơi cư trú của tổ trưởng và của các tổ viên phải được ghi nhận trong hợp đồng thành lập tổ hợp tác, như là một trong những nội dung chủ yếu của hợp đồng; còn nơi hoạt động của tổ hợp tác không nhất thiết được ghi nhận trong hợp đồng đó. Ngoài nơi cư trú của các thành viên, hợp đồng thành lập tổ hợp tác còn phải có các chi tiết về mục đích, thời hạn của hợp đồng hợp tác; họ tên của các thành viên; mức đóng góp tài sản (nếu có); phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức giữa các tổ viên; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ trưởng, của các tổ viên; điều kiện nhận tổ viên mới và ra khỏi tổ hợp tác; điều kiện chấm dứt tổ hợp tác và các thoả thuận khác (Điều 111 khoản 2). Số lượng tổ viên tối thiểu mà tổ hợp tác phải có là 3 người. Tổ viên thường là những người có cùng nghề nghiệp, nhưng không nhất thiết có quan hệ thân thuộc.
Chế độ pháp lý của tổ hợp tác. Tổ hợp tác được đại diện bởi tổ trưởng, do các tổ viên cử ra (Điều 113). Thể thức cử tổ trưởng hẳn phải được quy định trong hợp đồng thành lập tổ. Tổ trưởng có thể uỷ quyền cho tổ viên thực hiện một số công việc nhất định cần thiết cho tổ (cùng điều luật). Tổ trưởng tổ hợp tác không có những quyền hạn rộng rãi trong việc đại diện như chủ hộ gia đình: các giao dịch do tổ trưởng xác lập nhân danh tổ phải đượüc sự đồng ý của đa số tổ viên (cùng điều luật), nhắc lại rằng "đa số tổ viên" chứ không phải "đa số tổ viên dự họp"; riêng việc định đoạt các tài sản là tư liệu sản xuất của tổ phải được sự đồng ý của tất cả tổ viên (Điều 114 khoản 3).
Tổ hợp tác có năng lực pháp luật giới hạn trong phạm vi mục đích hoạt động của tổ, như năng lực pháp luật giới hạn của pháp nhân.Tổ hợp tác có một khối tài sản. Cũng như tài sản của hộ gia đình, tài sản của tổ hợp tác là tài sản chuyên dùng. Và cũng như khối tài sản nợ của hộ gia đình, tài sản nợ của tổ hợp tác được bảo đảm không chỉ bằng tài sản có của tổ hợp tác mà còn cả bằng tài sản có của các tổ viên (Điều 117 khoản 2).
Chấm dứt tổ hợp tác và thanh toán tài sản - Tổ hợp tác chấm dứt trong những trường hợp được dự liệu tại BLDS Điều 120 khoản 1, bao gồm: a) Hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác; b) Mục đích của việc hợp tác đã đạt được; c) Các tổ viên thoả thuận chấm dứt tổ hợp tác. Việc chấm dứt tổ hợp tác phải được báo cáo với UBND xã, phường, thị trấn nơi đã

chứng thực hợp đồng hợp tác (cùng điều luật). Tổ hợp tác cũng có thể chấm dứt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong những trường hợp do pháp luật quy định (Điều 120 khoản 2).
Tài sản còn lại của tổ hợp tác, sau khi thanh toán các khoản nợ, được phân chia cho các tổ viên theo tỷ lệ tương ứng với phần đóng góp của mỗi người, trừ trường hợp có thoả thuận khác (Điều 120 khoản 3).

BÀI 3 - TÀI SẢN

Nhập đề - GIỚI THIỆU CHUNG PHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN

Khái niệm tài sản - Thuật ngữ "tài sản" *(biens - property)* có thể được hiểu theo hai cách:

- *Thứ nhất*: về phương diện pháp lý, *tài sản là của cải* được con người sử dụng. "Của cải" là một khái niệm luôn luôn biến đổi và hoàn thiện cùng với sự phát triển của quan niệm về giá trị vật chất. Ở xã hội La Mã cổ xưa, nhắc đến tài sản người ta liên tưởng ngay đến những của cải trong gia đình như ruộng đất, nhà cửa, gia súc...Còn trong xã hội hiện đại ngày nay, ngoài của cải trong gia đình, chúng ta còn có một số loại tài sản đặc biệt, như năng lượng mặt trời, thủy năng, sóng vô tuyến, phần mềm máy tính...
- *Thứ hai:* trong ngôn ngữ thông dụng hằng ngày, *tài sản là một vật* cụ thể mà có thể nhận biết bằng các giác quan và được con người sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Dù được hiểu theo các nào, tài sản cũng có hai loại, tài sản hữu hình hoặc tài sản vô hình. Hay nói khác đi, các tài sản đều hữu hình hoặc đều có thể hữu hình hóa.
Bởi lẽ, một quyền gắn với tài sản - gọi là tài sản vô
hình - có thể trở thành tài sản hữu hình khi quyền đó được thực hiện bằng việc sử dụng nó làm một vật thay thế trong một giao dịch, hoặc khi quyền đó được định giá bằng tiền hay được chuyển nhượng có đền bù... Và dù vô hình hay hữu hình, của cải hay vật chỉ có thể là tài sản nếu chúng được sở hữu, nghĩa là thuộc về một người nào đó hay chính xác hơn là thuộc về một chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự.

Khái niệm sản nghiệp

Sản nghiệp (theo tiếng Latinh là *patrimonium)*, với tư cách là phạm trù kỹ thuật của khoa học luật được hiểu là một tổng thể các quan hệ pháp luật về tài sản, ***là tập hợp các tài sản có và tài sản nợ của một chủ thể*** chứ không chỉ đơn thuần là một bộ sưu tập đồ vật. Bất kỳ yếu tố nào của tài sản nợ cũng được bảo đảm bằng toàn bộ tài sản có và ngược lại bất kỳ yếu tố nào của tài sản có cũng có thể được dùng để thanh toán toàn bộ tài sản nợ.
Tài sản có thuộc sản nghiệp là tập hợp tất cả những tài sản thuộc về chủ sở hữu, hay đúng hơn đó là tập hợp tất cả những quyền tài sản có cùng một chủ thể. Tuy nhiên, các quyền tài sản chỉ được xem là các yếu tố của một sản nghiệp khi các quyền đó có thể được định giá bằng tiền. Do đó, các quyền không định giá được bằng tiền được gọi là các quyền không có tính chất tài sản hay là quyền nhân thân (Ví dụ như quyền đối với tên họ; quyền được tôn trọng danh dự, nhân phẩm; quyền bầu cử; quyền khiếu nại, tố cáo...).
Các quyền tài sản tạo thành một tập hợp - sản nghiệp - và tập hợp này tồn tại độc lập với các quyền tài sản đó. Tài sản có thể được mua bán, sử dụng, hao mòn, thậm chí biến mất nhưng sản nghiệp vẫn được duy trì. Do đó, một chủ nợ không có bảo đảm chỉ có quyền yêu cầu kê biên và bán đấu giá bất kỳ tài sản nào của người mắc nợ ở thời điểm kê biên mà sẽ không có quyền này đối với những tài sản đã chuyển nhượng trước khi nợ đến hạn đòi. Mặt khác, cần chú ý rằng *sản nghiệp không chỉ là tài sản hiện có mà còn bao gồm cả những tài sản sẽ có* của chủ sở hữu.
Tài sản nợ thuộc về sản nghiệp là tất cả những nghĩa vụ tài sản của một người. Hay nói một cách đơn giản hơn đó là những gì còn lại của khối tài sản sau khi đã trừ đi các giá trị của các nghĩa vụ tài sản. Trong kinh tế học, có khái niệm *tài sản có ròng (actif net)* của sản nghiệp. Khi tài sản có ròng có giá trị dương, ta nói sản nghiệp có khả năng thanh toán; và ngược lại, nếu đó là một giá trị âm, đồng nghĩa với việc sản nghiệp không có khả năng thanh toán

những nghĩa vụ có liên quan. Mặc dù vậy, dù có khả năng thanh toán hay không, sản nghiệp luôn luôn tồn tại.

1. Lý thuyết về sản nghiệp trong luật học phương Tây

Trong luật học phương Tây tồn tại hai quan niệm khác nhau về *"sản nghiệp"*: quan niệm chủ thể và quan niệm khách thể.

1.1. Quan niệm chủ thể

Đại diện tiêu biểu nhất của quan niệm này là luật học Pháp. Tuy nhiên, luật tục của Pháp không thừa nhận khái niệm "sản nghiệp". Các tài sản trong luật tục cổ được chia thành nhiều nhóm tùy theo mục đích tồn tại, tính chất vật lý của tài sản hoặc tùy vào căn cứ xác lập quyền sở hữu tài sản (như tài sản quý tộc, tài sản tiện dân, tài sản riêng, tài sản chung, động sản, bất động sản...) Mỗi loại tài sản chịu sự chi phối của một chế độ pháp lý riêng biệt.[89]
Đến đầu thế kỷ XIX, lý thuyết sản nghiệp được xây dựng bởi hai nhà khoa học Aubry và Rau. Mặc dù vẫn còn gây nhiều tranh cãi tại thời điểm đó song lý thuyết này đã được sửa đổi, hoàn thiện theo thời gian và trở thành một học thuyết khá tiến bộ bàn về sản nghiệp. Tư tưởng chủ đạo của học thuyết này là *"sản nghiệp luôn gắn liền với con người"*. Như ta đã biết, sản nghiệp luôn tồn tại ngay cả khi *tài sản có ròng* thuộc về sản nghiệp là một giá trị âm. Về nguyên tắc, mỗi chủ thể sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về tài sản bằng bất cứ tài sản nào mà mình là chủ sở hữu đối với chủ nợ. Tất cả tài sản thuộc sở hữu của người mắc nợ tạo thành một khối thống nhất và có giá trị bảo đảm cho việc thanh toán nợ của người đó. Chính vì thế, có thể nói rằng *bất kỳ một người nào cũng có một và chỉ một sản nghiệp.* Từ nhận xét này, chúng ta có thể rút ra hai hệ quả. *Thứ nhất*, sản nghiệp không thể chuyển nhượng khi người có sản nghiệp còn sống mà chỉ có thể chuyển nhượng các yếu tố cụ thể của sản nghiệp như nhà cửa, xe, hoa lợi, lợi tức... Khi người có sản nghiệp chết thì toàn bộ sản nghiệp sẽ được chuyển giao cho những người thừa kế của họ. *Thứ hai*, sản nghiệp không thể phân chia. Một thương nhân khi đứng trước các chủ nợ của mình, dù là chủ nợ dân sự hay chủ nợ thương mại, đều chỉ có một khối tài sản duy nhất và họ có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ của mình bằng khối tài sản đó. Mặt khác, *mọi sản nghiệp đều thuộc về một người,* là một cá nhân hoặc là một pháp nhân. Không thể có trường hợp một sản nghiệp không có chủ sở hữu.

1.2. Quan niệm khách thể

Quan niệm khách thể có nguồn gốc từ luật học Đức và tiếp tục hoàn thiện trong hệ thống pháp luật Đức nói riêng cũng như cả hệ thống luật Anh Mỹ nói chung. Trái ngược với quan niệm chủ thể, tư tưởng chủ đạo của quan niệm khách thể cho rằng *"sản nghiệp tồn tại độc lập với con người"*. Điều này chính là sự khái quát hóa quan niệm về tài sản từ quan niệm về chế độ pháp lý của đất đai mà hệ thống Common Law cổ xưa xây dựng dựa trên nguyên tắc bảo vệ lợi ích của vương quyền. Theo đó, sản nghiệp không gắn liền với một con người cụ thể mà gắn liền với một mục đích nhất định. Như vậy, *một người có thể có nhiều sản nghiệp và ngược lại, một sản nghiệp có thể gắn liền với lợi ích của nhiều người*. Tuy nhiên, quan niệm này thống nhất với quan niệm chủ thể ở việc khẳng định sản nghiệp là thực thể độc lập với các yếu tố cấu thành nên nó, các yếu tố này có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến sự tồn tại của tập hợp.

2. Sự phát triển của pháp luật về tài sản trong luật Việt Nam

2.1. Trong luật cổ và tục lệ

Luật cổ và tục lệ Việt Nam không biết đến sản nghiệp như là một tập hợp các tài sản có và tài sản nợ thuộc về một người hoặc tồn tại vì một mục đích nào đó. Vào thời kỳ đó, các tài sản đều thuộc về gia đình. Các quyền đối với tài sản của gia đình do người chủ gia đình thực hiện. Các nghĩa vụ về tài sản cũng do chủ gia đình xác lập một cách trực tiếp thông qua các thành viên của gia đình.

---

[89] *Introduction historique au droit des bien,* Presse Univeritaire de France, Droit fondamamental, 1989, số 85

Thời nhà Lê, *"gia đình"* được hiểu là tập hợp những người có quan hệ thân thuộc về trực hệ hay quan hệ hôn nhân. Tài sản thuộc về tất cả thành viên trong gia đình nhưng việc quản lý tài sản do ông, bà, cha, mẹ, nói chung là người đứng đầu của gia đình quản lý. Khi ông, bà, cha, mẹ chết thì tài sản được giao lại cho con cháu. Khi còn sống, ông bà, cha mẹ cũng có thể phân chia một phần hoặc toàn bộ tài sản cho con cháu, nhưng có quyền lấy lại tài sản đã chia bất cứ lúc nào khi họ vẫn còn sống. Các khoản nợ của gia đình được thanh toán trước hết bằng các động sản; các bất động sản chỉ được dùng để thanh toán khi không còn động sản. Đây là điểm tương đồng của luật cổ Việt Nam với tục lệ một số vùng của miền Bắc nước Pháp và luật *Germanique* của nước Đức cổ xưa.

Thời nhà Nguyễn, *"gia đình"* được hiểu là tập hợp những người xung quanh người gia trưởng, gắn bó với người này do quan hệ thân thuộc về trực hệ, hôn nhân hoặc quan hệ nuôi dưỡng. Tài sản thuộc về tất cả các thành viên gia đình nhưng việc thực hiện quyền sở hữu thuộc về người gia trưởng. Khi người gia trưởng chết, người vợ góa cùng với các con và trưởng tộc bên nhà chồng thực hiện việc quản lý tài sản. Khi cả cha mẹ đều đã chết thì các con, đứng đầu là người con trai trưởng, cùng nhau quản lý tài sản của gia đình cho đến khi được trưởng tộc bên nội cho phép tiến hành phân chia tài sản. Khi còn sống, cha mẹ có quyền phân chia tài sản cho các con và khi họ vẫn còn sống vẫn có quyền lấy lại tài sản đó bất cứ lúc nào. Như vậy, những tục lệ này được tiếp tục duy trì từ thời nhà Lê cho đến sau này.

2.2. Luật cận đại

Thời kỳ nước ta còn là thuộc địa của Pháp, các nhà nghiên cứu luật học và thực hành luật đã nỗ lực xây dựng hệ thống pháp luật về tài sản ở Việt Nam trên cơ sở lý thuyết sản nghiệp của luật học Pháp. Tuy nhiên, do hạn chế về đặc điểm của trình độ phát triển kinh tế xã hội thời kỳ đó (sở hữu tư nhân mang tính chất cá nhân vẫn chưa thay thế được sở hữu gia đình đã trở nên phổ biến) nên việc vận dụng lý thuyết sản nghiệp của luật học Pháp thành lý thuyết sản nghiệp của luật Việt Nam có nhiều cải biên cho phù hợp. Theo đó, *mỗi gia đình chỉ có một sản nghiệp; bất kỳ sản nghiệp nào cũng thuộc về một gia đình; mỗi yếu tố của tài sản có thuộc về sản nghiệp gia đình đều được dùng để thanh toán toàn bộ tài sản nợ của gia đình và mỗi yếu tố của tài sản nợ thuộc sản nghiệp gia đình đều được bào đảm thanh toán bằng toàn bộ tài sản có của gia đình.*

Sắc lệnh ngày 21/7/1925 thiết lập chế độ điền thổ mới theo khuôn mẫu *Alsace- Lorraine* về đăng ký đất đai của Pháp. Chế độ điền thổ này thừa nhận rằng có những bất động sản thuộc sở hữu tư nhân mang tính chất cá nhân mà không phải thuộc sở hữu gia đình. Như vậy, một cá nhân có tài sản riêng sẽ phải tự mình chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ tài sản do mình xác lập. Chế độ điền sản mới đã góp phần định hình cho lý thuyết về sản nghiệp cá nhân ở Việt Nam.

Trong luật cổ và tục lệ, di sản thờ cúng là một phần của khối tài sản gia đình, đặt ngoài lưu thông để phục vụ cho các mục đích tín ngưỡng. Trong luật cận đại, di sản thờ cúng là khối tài sản không có chủ sở hữu theo luật chung đặt dưới sự quản lý của tất cả những người có liên quan đến việc thờ cúng tổ tiên. Bên cạnh di sản thờ cúng, gia đình còn có một khối sản nghiệp khác. Hai khối sản nghiệp này hoàn toàn độc lập với nhau, trong đó di sản thờ cúng là một sản nghiệp đặc biệt vì không có tài sản nợ.

2.3. Luật hiện đại

Ngay từ những ngày đầu giành được độc lập, Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã chú trọng thiết lập các chế độ pháp lý của nhà nước dân chủ nhân dân. Quyền sở hữu tư nhân được thừa nhận ngay trong các văn bản pháp luật đầu tiên của nhà nước ta, trong đó ghi nhận quyền sở hữu về tài sản của cá nhân nói chung cũng như quyền để lại di sản thừa kế nói riêng. Mặc dù vậy, luật học thời kỳ này chưa xây dựng khái niệm sản nghiệp. Từ năm 1986, với chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, việc tích lũy của cải của tư nhân được khuyến khích. Chính điều này đã góp phần tạo điều kiện cho các giao dịch

về tài sản được xác lập đa dạng và phong phú hơn, là cơ sở để xây dựng lý thuyết về sản nghiệp của luật học Việt Nam trên cơ sở vận dụng có chọn lọc những thành tựu của các hệ thống luật tiên tiến và kế thừa có sáng tạo tinh thần luật học cổ điển của nước nhà.

Chưa có một văn bản nào của luật viết hiện hành ghi nhận những quy tắc cơ bản của sản nghiệp tư, song, thông qua một số văn bản pháp luật hiện hành chúng ta có thể rút ra được một số tư tưởng chủ đạo của nhà làm luật về vấn đề này. Trước hết, có thể ghi nhận rằng: *sản nghiệp là tập hợp tài sản có và tài sản nợ của một chủ thể. Sản nghiệp phải thuộc về một chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự (cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác).* Riêng đối với di sản thờ cúng, luật viết vẫn ghi nhận đó là khối tài sản không có chủ sở hữu theo luật chung và chịu sự quản lý của tất cả những người có liên quan đến việc thờ cúng. Đây là một loại sản nghiệp đặc biệt, trong đó các yếu tố tạo thành quyền sở hữu được phân chia giữa người quản lý di sản thờ cúng với những người thừa kế. Hay nói cách khác, đó là một *"sản nghiệp uỷ thác"* mà việc quản lý chịu sự giám sát của những người thừa kế. *Một chủ thể có thể có một sản nghiệp thường và một hay nhiều sản nghiệp đặc biệt.* Các thành viên của hộ gia đình chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài sản của hộ gia đình bằng tài sản riêng của mình khi tài sản của hộ không đủ để thanh toán các nghĩa vụ đó. Như vậy, *sản nghiệp cá nhân đóng vai trò hỗ trợ cho sản nghiệp của hộ gia đình trong việc thanh toán các tài sản nợ khi tài sản của hộ gia đình không có khả năng thanh toán.* Nhưng ngược lại*, tài sản của hộ gia đình không được dùng để thanh toán các khoản nợ cá nhân.* Đây chính là sự kế thừa quan niệm truyền thống về khối tài sản gia đình trong luật cổ và tục lệ cũng như quan niệm sản nghiệp gia đình của luật cận đại.

CHƯƠNG 1 - TÀI SẢN

Theo Điều 163 BLDS, *"Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản."*.

a) ***Vật*** được đưa vào giao lưu dân sự đáp ứng đầy đủ ba yêu cầu:
- Vật phải là một bộ phận của thế giới vật chất.
- Vật phải đem lại lợi ích cho con người.
- Vật phảI có thể chiếm giữ được.

b) ***Tiền,*** theo kinh tế học, là giá trị đại diện cho giá trị thực của hàng hóa và là phương tiện lưu thông trong đời sống của con người. Về mặt chính trị, đó còn là đại diện cho chủ quyền của một quốc gia, đòi hỏi người có tiền (là chủ sở hữu) không thể có toàn quyền định đoạt loại tài sản đặc biệt này mà phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt của Nhà nước. Do đó, tiền có một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

c) ***Giấy tờ có giá*** bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, công trái, séc, giấy ủy nhiệm chi, sổ tiết kiệm...

d) ***Các quyền về tài sản.*** Đó là những quyền gắn liền với một tài sản hoặc khi thực hiện quyền đó, chủ sở hữu sẽ có được một tài sản. Các quyền tài sản là các quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao được trong giao dịch dân sự, chẳng hạn như quyền đòi nợ, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp,...

Tài sản có thể được phân loại theo nhiều cách. Hệ thống luật Latinh chia tài sản thành động sản và bất động sản; tài sản hữu hình và tài sản vô hình; vật tiêu hao và vật không tiêu hao; vật cùng loại và vật đặc định; vốn và lợi tức; vật được sở hữu và vật không được sở hữu; tài sản công và tài sản tư. Theo luật Anh Mỹ, chia thành quyền sở hữu đối vật và quyền sở hữu đối nhân; đất đai và các loại tài sản khác (bao gồm tiền, động sản hữu hình mà không phải tiền, động sản vô hình...).

BLDS Việt Nam hiện hành xây dựng khái niệm động sản và bất động sản (Điều 174), hoa lợi và lợi tức (Điều 175); vật chính, vật phụ (Điều 176); vật chia được và vật không chia dược (Điều 177); vật tiêu hao và vật không tiêu hao (Điều 178); vật cùng loại và vật đặc định

(Điều 179)... Điều này cho thấy luật dân sự Việt Nam có xu hướng định hình cách thức phân loại tương tự như hệ thống luật Latinh. Mặt khác, trong cấu trúc của bộ luật, tại chương "Các loại tài sản", cách thức phân loại tài sản thành động sản và bất động sản được nêu ra trước tiên. BLDS của Cộng Hòa Pháp, tại Điều 518 không định nghĩa tài sản là gì mà chỉ nói rằng tài sản bao gồm động sản và bất động sản. Những điều luật tiếp theo quy định về bất động sản (Chương I, từ Điều 517 đến Điều 526), động sản (Chương II, từ Điều 527 đến Điều 536) và tài sản trong mối quan hệ với người chiếm hữu nó (Chương III, từ Điều 537 đến Điều 543). Do đó, có thể hiểu rằng đây là cách thức phân loại chính, chủ yếu nhất trong các cách thức phân loại tài sản. Các cách thức phân loại từ Điều 175 đến Điều 179 BLDS hiện hành là cách thức phân loại thứ cấp. Riêng các loại tài sản vô hình và quyền sử dụng đất có vị trí độc lập trong BLDS cần được tách thành nhóm tài sản độc lập và sẽ được phân tích riêng biệt.

MỤC 1 - Động sản và Bất động sản[90]

1. Tiêu chí phân biệt

Trước BLDS 1995, không có một văn bản pháp luật của Nhà nước ta quy định về động sản và bất động sản. Bộ Dân luật Bắc kỳ 1972 của chế độ Sài Gòn cũ có phân chia về động sản và bất động sản. Theo đó, *bất động sản được phân chia theo tính chất, mục đích, và mục đích sử dụng; động sản được chia thành động sản theo tính chất và động sản do pháp luật quy định*[91]

Kế thừa định nghĩa về bất động sản và động sản của BLDS 1995, Điều 174 BLDS hiện hành quy định:

1. Bất động sản là các tài sản bao gồm:

a) Đất đai;

b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó;

c) Các tài sản khác gắn liền với đất đai;

d) Các tài sản khác do pháp luật quy định.

2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.

Qua nội dung điều luật, ta thấy Điều 174 BLDS liệt kê các tài sản mà luật gọi là các bất động sản, sau đó quy định rằng những loại tài sản không là bất động sản đều là động sản. Như vậy, bất kỳ một tài sản nào cũng chỉ có thể hoặc là bất động sản, hoặc là động sản. Luật viết thiết lập và giới hạn danh mục các tài sản là bất động sản; còn danh mục các tài sản là động sản được bỏ ngỏ bằng một quy phạm mở, danh mục này sẽ được bổ sung ngay trong thực tiễn áp dụng pháp luật. Đây là kỹ thuật lập pháp thông dụng trong BLDS của nhiều nước trên Thế giới, nhất là khi phân loại tài sản thành động sản và bất động sản.

1.1. Vật

Đứng đầu vị trí trong danh mục các tài sản được gọi là bất động sản là đất đai cũng vì lẽ khi xác định một vật là động sản hay bất động sản, trước hết và chủ yếu ta dựa vào mối quan hệ của vật đó với đất đai. Đất đai là bất động sản là điều không cần tranh cãi nữa. Khi đó, những vật sinh ra từ đất (như cây cối, mùa màng, khoáng sản...); những vật gắn liền với đất do hoạt động có ý thức của con người và không thể tách rời đất mà không hư hỏng (như nhà cửa, công trình xây dựng,...) đều là bất động sản. Những vật không cố định vị trí trên đất (như bàn, ghế, xe máy, tàu thuyền...); những vật không do đất sinh ra (như súc vật, chim muông, thú rừng...); những vật đã tách rời khỏi đất (như mùa màng đã thu hoạch, khoáng sản đã khai thác...) đều được xem là động sản.

1.2. Quyền

[90] Động sản: meubles (tiếng Pháp) - movables (tiếng Anh); Bất động sản: immeubles (tiếng Pháp) - immovables (tiếng Anh)

[91] Điều 450 Dân luật Bắc kỳ và Điều 461 Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật

Theo Điều 181 BLDS, "*Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ".* Rõ ràng, trước hết quyền tài sản là một tài sản và có thể là quyền đối vật (*droit réel)* hay các quyền đối nhân (*droit personnel)*. Mặt khác, một quyền dân sự được coi là quyền tài sản khi hội đủ hai yếu tố sau: *thứ nhất*, quyền đó phải trị giá được bằng tiền; *thứ hai*, quyền đó chuyển giao được trong giao lưu dân sự. Tính chất động sản hay bất động sản của quyền được xác định dựa vào đặc điểm vật chất của đối tượng mang quyền, trừ trường

hợp pháp luật có quy định khác.[92] Như vậy, quyền sở hữu nhà là một bất động sản; quyền sở hữu xe máy là động sản; quyền thế chấp quyền sử dụng đất là bất động sản nhưng quyền thế chấp tàu biển là một động sản; quyền cầm cố là động sản; quyền hưởng hoa lợi là một động sản nếu tài sản sinh lợi là một động sản và quyền đó sẽ là bất động sản nếu tài sản sinh lợi là một bất động sản...

Quyền đối nhân của một người thường tương ứng với nghĩa vụ tài sản của một người khác. Nghĩa vụ ấy thuộc một trong hai nhóm: nghĩa vụ làm hay không làm một việc và nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu tài sản. Luật học Pháp quan niệm rằng: nghĩa vụ làm hay không làm một việc luôn mang tính chất là động sản và thông thường nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu cũng mang tính chất là động sản, trừ trường hợp tài sản chuyển quyền sở hữu là một bất động sản thì nghĩa vụ đó mang tính chất là một bất động sản. Luật dân sự Việt Nam chưa giải quyết vấn đề tính chất của các nghĩa vụ tài sản, song quan niệm tương ứng của luật học Pháp có thể được nghiên cứu, áp dụng ở Việt Nam bởi nó hoàn toàn phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự Việt Nam nói riêng cũng như pháp luật dân sự nói chung.

Riêng đối với các quyền vô hình (như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, các yếu tố vô hình của sản nghiệp thương mại...), do không gắn liền với đất đai hoặc mặc dù thông qua các tài sản gắn liền với đất đai, vẫn không được luật viết thừa nhận đó là bất động sản. Tất cả các quyền vô hình đều là động sản do áp dụng khoản 2 Điều 174 BLDS.

1.3. Trường hợp đặc biệt

- Có một số trường hợp, tài sản, ban đầu là một bất động sản nhưng lại có xu hướng trở thành động sản và ngược lại, có những tài sản là động sản nhưng chỉ phát huy công dụng khi nó được cố định ở một vị trí thích hợp như là một bất động sản. Cũng có trường hợp tài sản không có xu hướng thay đổi tính chất nhưng sau một sự kiện hay trong một hoàn cảnh đặc biệt lại được thay thế bằng một tài sản có tính chất khác và chịu chi phối bởi một chế độ pháp lý hoàn toàn khác. Trong thực tế, có những trường hợp cụ thể sau:

1.3.1. Bất động sản trở thành động sản do đặc điểm công dụng tương lai.

Theo khoản 1, Điều 174 BLDS hoa lợi tự nhiên chưa thu hoạch là bất động sản. Giá trị vật chất của hoa lợi tự nhiên không thể tranh cãi khi hoa lợi tự nhiên được thu hoạch (nghĩa là tách rời khỏi đất), được tiêu dùng, được tặng cho, hoặc được chuyển nhượng có đền bù (nói chung là được đưa vào lưu thông). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hoa lợi tự nhiên vẫn có giá trị vật chất nếu được chuyển nhượng khi chưa thu hoạch.

Khi đó, dù vẫn còn gắn liền với đất, hoa lợi tự nhiên được định giá và chuyển giao như một tài sản độc lập đã tách rời khỏi đất (như là một động sản).[93] Như vậy, ta nói hoa lợi tự nhiên chưa thu hoạch - đối tượng của quan hệ mua bán - là một *bất động sản được động sản hóa*.

---

[92] thông thường được áp dụng trong các trường hợp đối tượng của quyền không phải là các vật cụ thể mà là các tài sản vô hình.

[93] Đây là một trường hợp rất phổ biến trong đời sống người nông dân Việt Nam. Sau, hoặc ngay cả khi đang trong thời gian vun trồng, chăm sóc cây trái, mùa màng..., các thương lái đã vào tận nhà vườn để xem xét, đánh giá chất lượng và tiến hành ngã giá mua theo một số lượng nhất định (chẳng hạn như 10 cây, 20 cây, 5 mẫu, 10 mẫu hoặc cả vườn...). Việc thu hoạch thông thường do người mua thực hiện. Và trên thực tế việc mua bán này được giao kết và thực hiện như là đối với một động sản chứ không phải là một bất động sản.

Ta hoàn toàn có thể mở rộng việc áp dụng quy chế động sản cho hoa lợi tự nhiên trong tất cả các giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu (có đền bù hay không có đền bù), ngay cả việc chuyển nhượng quyền sở hữu có điều kiện (trong các giao kết bảo đảm thực hiện nghĩa vụ).

1.3.2. Bất động sản trở thành động sản do công dụng

Có những tài sản, nếu xét theo đặc điểm vật lý thì đó là những động sản, nhưng trên thực tế, tài sản đó lại gắn chặt vào một bất động sản như là một yếu tố cần thiết cho việc khai thác bất động sản và sẽ tự động đi theo bất động sản đó trong trường hợp bất động sản được chuyển dịch (với tư cách là một vật phụ của bất động sản). Ta gọi đó là những *động sản được bất động sản hóa* do công dụng hiện tại. Việc bất động sản hoá các động sản như vậy phải hội đủ hai điều kiện: *thứ nhất*, cả hai đối tượng của sự chuyển hóa đều phải thuộc về một chủ sở hữu; *thứ hai*, bất động sản do công dụng phải mang đầy đủ tính chất là một vật phụ của bất động sản đó (nghĩa là phải trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng theo tính năng của vật chính)[94]. Việc xác định này có ảnh hưởng đến việc xác định chế độ pháp lý của một số giao dịch trong thực tế, như: chuyển nhượng tài sản có vật chính, vật phụ; quan hệ về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ... Tuy nhiên, việc xác định tài sản nào đó là một bất động sản do công dụng chỉ có ý nghĩa trong những quan hệ đặc thù mà không làm mất đi tính chất động sản mà nó có được một cách tự nhiên[95].

1.3.3. Tài sản thay thế

Trong một giao kết bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (cụ thể là quan hệ thế chấp), đối tượng của hợp đồng là một tài sản đã được mua bảo hiểm. Trong thời gian hợp đồng thế chấp có hiệu lực, do nguyên nhân khách quan, tài sản thế chấp bị hủy hoại. Theo nội dung của hợp đồng bảo hiểm, chủ sở hữu sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường bằng một khoản tiền theo thỏa thuận đã giao kết giữa hai bên. Lúc này, số tiền bảo hiểm tiếp tục là đối tượng của hợp đồng thế chấp (vì hợp đồng vẫn còn hiệu lực). Điều này trái với quy định của luật: trừ tàu biển, đối tượng của hợp đồng thế chấp phải là một bất động sản. Vấn đề này được lý giải ra sao?

Chế độ tài sản thay thế như trong trường hợp trên chỉ là một biện pháp do luật dự liệu nhằm bảo vệ của các chủ thể tham gia một số giao dịch đặc thù. Khi mối quan hệ đó chấm dứt, tài sản thay thế chịu sự chi phối trở lại của các quy định thông thường phù hợp với tính chất tự nhiên của nó. [96]

2. Ý nghĩa của sự phân biệt

Việc phân biệt tài sản thành động sản và bất động sản có ý nghĩa về ba phương diện sau:

2.1. Là căn cứ để xác định thời hiệu xác lập quyền sở hữu

Theo Điều 247 BLDS, các trường hợp *"chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, công khai, liên tục trong thời hạn 10 năm đối với động sản và 30 năm đối với bất động sản thì người chiếm giữ tài sản đó sẽ trở thành chủ sở hữu của tài sản đó"*, trừ trường hợp liên quan đến tài sản thuộc sở hữu toàn dân.

2.2. Là căn cứ để xác lập thẩm quyền của TAND trong việc giải quyết các tranh chấp về tài sản.

Theo Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2004: các tranh chấp về bất động sản sẽ do TAND nơi có bất động sản giải quyết; còn các tranh chấp về động sản sẽ do TAND nơi bị đơn cư trú

---

94 Điều 176, khoản 2 BLDS

95 Chẳng hạn, khi tài sản đó bị mất cắp, bị cướp...thì vẫn xem đó là một vụ phạm pháp hình sự chú không thể viện dẫn rằng do đó là một bất động sản nên không thể trộm cắp hay bị cướp được.

96 Đối với trường hợp trên, nếu người thế chấp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã giao kết trong hợp đồng thế chấp, thì việc thế chấp chấm dứt và số tiền bảo hiểm trở thành động sản như theo định nghĩa của luật viết cũng như đặc điểm tự nhiên của nó.

hoặc làm việc giải quyết.

MỤC 2 - Phân loại thứ cấp

1. Tài sản gốc và hoa lợi, lợi tức

Căn cứ vào nguồn gốc sinh ra của tài sản, ta có cách phân loại tài sản thành hoa lợi, lợi tức. Điều 175 BLDS quy định: *" Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại. Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản."*. Nói một cách tổng quát, hoa lợi, lợi tức là những vật có giá trị tiền tệ do tài sản sinh ra. Ta gọi tài sản sinh ra hoa lợi, lợi tức là *tài sản gốc*. Cần lưu ý rằng, việc phân định tài sản gốc và hoa lợi, lợi tức trong nhiều trường hợp không thể rạch ròi được bởi có một số trường hợp hoa lợi, lợi tức được tiêu dùng, biến mất hoặc được tích lũy để trở thành tài sản đầu tư (tài sản gốc mới) và tiếp tục sinh lợi. Hoặc có nhiều trường hợp tài sản gốc là tài sản không thể sinh lợi, như vật dụng cá nhân, kỷ vật gia đình...Như vậy, tài sản gốc được hiểu như tài sản để bảo tồn và sản xuất ra những lợi ích vật chất một cách đều đặn, phục vụ cho chủ sở hữu hoặc người có quyền thụ hưởng lợi ích vật chất từ tài sản.

Chỉ được gọi là hoa lợi, lợi tức những tài sản sinh ra từ tài sản gốc mà không làm giảm sút chất liệu của tài sản gốc (ở mức có thể nhận thấy được). Trong trường hợp để thu được một lợi ích vật chất từ tài sản gốc mà không thể tái tạo bằng cách khai thác khả năng sinh lợi của tài sản gốc hoặc chỉ có thể tái tạo bằng cách lặp lại một chu kỳ đầu tư nhằm khôi phục chất liệu của tài sản gốc, thì lợi ích vật chất thu được đó chính là *sản phẩm* mà không phải là hoa lợi, lợi tức. ở góc độ pháp luật về tài sản, sản phẩm là một hình thức tồn tại của tài sản gốc, hay đúng hơn là sự thay đổi hình thức tồn tại của tài sản gốc. Một tài sản có thể là hoa lợi trong quan hệ này và là sản phẩm trong một quan hệ khác.

Việc phân loại tài sản theo cách thức này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nghĩa vụ của người khai thác tài sản mà không phải là chủ sở hữu (theo quy định tại Điều 606 BLDS) hoặc trong các trường hợp phân chia tài sản cụ thể. Về phương diện quản lý sản nghiệp, sự phân biệt này có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư: nếu tài sản thu được là hoa lợi, lợi tức thì nhà đầu tư được tự do trong việc thụ hưởng và tiêu dùng; nếu tài sản thu được là một sản phẩm, thì nhà đầu tư nên tái đầu tư để khôi phục khả năng sinh lợi của tài sản gốc. Đó chính là lợi ích thực tiễn của sự phân biệt.

2. Vật chính và vật phụ

Căn cứ vào tính chất, chức năng của tài sản, có thể chia tài sản thành vật chính và vật phụ.

Theo Điều 176 BLDS,

" - Vật chính là vật độc lập, có thể khai thác công dụng theo tính năng.

- Vật phụ là vật trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng của vật chính, là một bộ phận của vật chính, nhưng có thể tách rời khỏi vật chính."

Từ nội dung điều luật, chúng ta có thể rút ra một số nhận xét sau:

- Vật chính có thể nhận biết với đầy đủ đặc điểm về cấu tạo, tính năng mà không cần vật phụ. Chẳng hạn như: bàn, ghế, quần, áo...
- Vật phụ là vật trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng của vật chính, mà thông thường làm tăng giá trị cho vật chính nhưng không hẳn là yếu tố không thể thiếu được của vật chính. Ví dụ: kính lọc của màn hình máy vi tính, lớïp hóa chất chống trầy, chống tia cực tím của tròng mắt kính.
- Vật phụ sẽ đảm nhận tư cách "phụ" khi được gắn với vật chính về mặt vật chất.
- Vật phụ, khi tách khỏi vật chính, có thể trở thành một tài sản độc lập và có công dụng đặc thù nhưng cũng có thể không hữu dụng cho chủ sở hữu.

Điều 176 BLDS quy định: *" Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật chính thì phải chuyển*

giao cả vật phụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.". Ta có giải pháp truyền thống của luật Latinh: *" vật phụ cùng số phận của vật chính"*. Như vậy,

- Khi vật chính được mua bán, tặng cho, trao đổi, di tặng, góp vốn vào công ty thì vật phụ cũng mặc nhiên đi theo, nếu không có thỏa thuận khác.
- Trong trường hợp một vật được gắn với một vật khác như là vật phụ của vật đó, thì vật mới được tạo thành thuộc về chủ sở hữu của vật chính. (Điều 236 BLDS)

3. Vật tiêu hao và vật không tiêu hao

Cách thức phân loại này được xây dựng **căn cứ vào mức độ hao mòn khi sử dụng của tài sản.**

Theo Điều 178 BLDS:

- *Vật tiêu hao là vật khi đã qua sử dụng một lần thì mất đi hoặc không giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu.*
- *Vật không tiêu hao là vật khi đã qua sử dụng nhiều lần mà cơ bản vẫn giữ được tính chất, hình dáng, tính năng sử dụng như ban đầu.*

Chúng ta có thể lấy rất nhiều ví dụ cho hai loại tài sản này. Thức ăn, nguyên nhiên liệu là vật tiêu hao. Quần áo, xe máy, TV, ...là những vật không tiêu hao. Tiền là vật tiêu hao không phải do sử dụng mà do được dùng để thanh toán trong lưu thông. Những bất động sản là vật không tiêu hao...

Vật tiêu hao có thể biến mất hoàn toàn về mặt vật chất sau lần sử dụng đầu tiên; cũng có những vật tiêu hao không hoàn toàn biến mất nhưng không còn mang tính chất, hình dáng và tính năng ban đầu sau một lần sử dụng mà lại mang tính chất, hình dáng, tính năng của một vật khác. Chẳng hạn như băng cassette, đĩa CD,... Và có những vật, khi qua một lần sử dụng không mất đi về mặt vật chất và qua nhiều lần sử dụng vẫn giữ được tính chất, hình dáng, tính năng ban đầu nhưng lại giảm giá trị rất nhanh và sẽ được thay thế sau một thời gian ngắn. Ta gọi đó là *vật tiêu dùng* - loại vật trung gian giữa vật tiêu hao và vật không tiêu hao. Ví dụ như tập, vở, bút viết, quần áo, đồ gia dụng... Danh sách sản phẩm tiêu dùng được bổ sung theo sự phát triển của xã hội và sự rút ngắn của chu kỳ đổi mới công nghệ. Tất cả các tài sản tiêu dùng đều là động sản.

BLDS chỉ nêu ra lợi ích của việc xác định tài sản nào đó là vật tiêu hao hay không tiêu hao tại Điều 178, khoản 1 BLDS như sau:*" Vật tiêu hao không thể là đối tượng của hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng cho mượn".* Nghĩa là các tài sản có thể cho thuê, cho mượn không thể là những vật tiêu hao. Thật vậy, đối với tài sản tiêu hao, sử dụng đồng nghĩa với định đoạt và chuyển quyền sử dụng bao hàm cả việc chuyển quyền sở hữu. Tài sản tiêu hao không thể cho thuê, cho mượn nhưng lại có thể cho "mượn" để tiêu dùng hay định đoạt. Loại giao dịch này luật viết hiện hành gọi tên là *hợp đồng vay tài sản* (Điều 471 BLDS). Khi đó, người vay nhận tài sản, sau một thời gian (sử dụng tự do), phải trả lại cho người cho vay vật cùng loại có giá trị tương đương với vật đã vay trước đó. Loại giao dịch này khá phổ biến trong cuộc sống (như vay tiền, vay gạo...) cũng như trong giao dịch kinh doanh (vay hàng, vay vật tư...).

4. Vật đặc định và vật cùng loại

Theo Điều 179 BLDS:

- *"Vật cùng loại là những vật có cùng hình dáng, tính chất, tính năng sử dụng và xác định được bằng những đơn vị đo lường.*
- *Vật đặc định là vật phân biệt được với các vật khác bằng những đặc điểm riêng về ký hiệu, hình dáng, màu sắc, chất liệu, đặc tính, vị trí."*

Luật viết quy định thêm rằng:*" Vật cùng loại có cùng chất lượng có thể thay thế cho nhau".* Khái niệm vật cùng loại chỉ là một khái niệm mang tính tương đối. Vật cùng loại có thể trở thành đặc định trong quá trình thực hiện một giao dịch nhưng lại trở thành cùng loại khi là đối tượng của một giao giao dịch khác.

Trong thực tế cuộc sống, việc mua bán những sản phẩm nông nghiệp là vật cùng loại thường được tiến hành như sau: bên mua và bên bán thảo luận, ngã giá, đi đến sự thống nhất ý chí về giá của món hàng; người mua sẽ tiến hành *"đặc định hóa"* bằng cách lựa chọn, cân, đong, đo, đếm...(có thể được sự chỉ dẫn và giám sát của người bán); cuối cùng hai bên tiến hành thanh toán tiền và giao, nhận hàng. Cũng có khi người bán đã tiến hành *"đặc định hóa có điều kiện"* mặt hàng của mình bằng cách cân, đong, đo, đếm và đóng gói sẵn (một chục trái, 100 gram, nửa ký...). Khi đó, nếu đồng ý với giá cả mà người bán đưa ra, người mua hoàn toàn tự do lựa chọn túi, bao, gói...mà mình thích. Lúc này, tính chất đặc định của vật cùng loại được thể hiện rõ ràng nhất.

Cũng có trường hợp *" làm cho cùng loại"* những tài sản hoàn toàn khác nhau về tính chất vật lý, giá cả... bằng cách xác lập cơ chế giao dịch đồng nhất cho tất cả tài sản trong một giao dịch nào đó. Trong dân gian, việc mua bán này được gọi là *"bán sa cạ"* (miền Nam), hay *"mua mão"* (miền Trung) và ở nhiều nơi đó chính là loại hình kinh doanh *"cửa hàng 10.000*

đồng" đã xuất hiện ở TP.HCM hay các *"shop 5 USD"*, *"shop 10 USD"* ở các nước phương Tây. Về phía người mua trong các trường hợp này, đã tiến hành *"đặc định hóa"* đối tượng mua bán bằng việc lựa chọn giữa các vật cùng giá được người bán chào hàng. Và một khi việc lựa chọn đã thực hiện xong thì nghĩa vụ giao hàng, lấy tiền của người bán và nghĩa vụ nhận hàng, trả tiền của người mua được thực hiện cùng một lúc ngay tại thời điểm đó.

Việc phân định theo cách thức phân loại này là cơ sở cho việc miễn trừ nghĩa vụ trong trường hợp hai người có nghĩa vụ về tài sản cùng loại với nhau. Theo khoản 1, Điều 380 BLDS trong trường hợp này, khi đến hạn, hai người không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau và nghĩa vụ được xem là chấm dứt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Luật viết gọi đó là sự *"bù trừ nghĩa vụ"*. Ngoài ra, đây còn là cơ sở xác định và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến việc chuyển giao tài sản trong một số giao dịch bởi theo Điều 179, khoản 2, một vật nếu là vật đặc định, khi được chuyển giao thì phải giao đúng vật đó, còn vật cùng loại chỉ cần chuyển giao đủ và đúng loại. Trong luật dân sự Pháp, cách thức phân loại này còn có ý nghĩa trong việc xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu của các giao dịch. Việc xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu theo luật Việt Nam, khác với luật Pháp, tùy thuộc vào quy định của pháp luật có bắt buộc đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó hay không chứ không dựa vào tính chất đặc định hay cùng loại của tài sản có liên quan. Do đó, tính chất đặc định hay cùng loại của tài sản không là tiêu chí xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu theo quy định của BLDS hiện hành.

5. Vật sở hữu được và vật không sở hữu được.

Không phải vật nào cũng là tài sản theo ý nghĩa pháp lý, bởi lẽ có những vật thuộc về sở hữu của cộng đồng (hay còn gọi là của chung) và cũng có những vật vô chủ.

- ***Của chung*** (tiếng Latinh là *res communes*) là những gì thuộc về mọi người. Sở hữu cá nhân đối với của chung là một điều không có ý nghĩa. Của chung theo quan niệm Latinh bao gồm: không khí, nước biển, ánh sáng, nước chảy tự nhiên, năng lượng mặt trời... Theo sự gia tăng dân số trên Trái đất và sự hoàn thiện của các khái niệm về dân tộc và chủ quyền quốc gia, danh mục của chung ngày càng thu hẹp lại.
- ***Vật vô chủ*** (tiếng Latinh là *res derelictae*), theo khoản 1, Điều 239 BLDS *"là vật mà chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu đối với vật đó"*. Trong luật Việt Nam và cả trong Luật dân sự của nhiều nước (Pháp, Nhật Bản...) vật vô chủ không thể là một bất động sản. Luật dân sự Việt Nam hiện hành quy định rằng các vật vô chủ, nếu là động sản, thì thuộc về người phát hiện; còn nếu là bất động sản thì thuộc về Nhà nước (Điều 239, khoản 1). Quy định này cũng được thừa nhận trong luật Pháp (Điều 713). Do đó, có thể nói rằng chỉ có khái niệm động sản vô chủ trong khoa học luật dân sự.

MỤC 3 - Các tài sản vô hình

Ngay trong luật học cổ La Mã cũng đã thừa nhận quan niệm về những giá trị tài sản không biểu hiện bằng vật thể, chẳng hạn như các quyền của chủ nợ đối với con nợ (như quyền đòi nợ, quyền gán nợ, xoá nợ...). Trong xã hội hiện đại, khi nói đến giá trị tài sản phi vật thể, ta liên tưởng đến ba nhóm tài sản lớn và tiêu biểu: *quyền sở hữu công nghiệp; quyền sở hữu văn chương nghệ thuật, khoa học và phần hùn trong công ty có tư cách pháp nhân*. Ngoài ra, còn có *các yếu tố vô hình của sản nghiệp thương mại như mạng lưới tiêu thụ hàng hóa, thương hiệu, biển hiệu...* Luật học Latinh gọi đó là những tài sản vô hình tuyệt đối.

1. Các đặc điểm của tài sản vô hình

1.1. Là kết quả của lao động sáng tạo

Không phải là vật chất nhưng có quan hệ với vật chất - Tài sản vô hình, đúng như tên gọi của nó, không được nhận biết bằng giác quan của con người mà muốn nhận biết được, phải thông qua những ý niệm về mối quan hệ giữa người có quyền khai thác lợi ích của tài sản và người thứ ba. Quyền tác giả đối với một bài hát có đối tượng không phải là bài hát đó; hay một tên gọi xuất xứ không phải là đối tượng của quyền đối với tên gọi, xuất xứ

của sản phẩm, hàng hóa đó. Bài hát, tên gọi xuất xứ,... chính là hình thức biểu hiện cụ thể bằng vật chất của kết quả lao động sáng tạo và chính kết quả này mới là đối tượng của các quyền trên.

1.2. Không phải là quyền chủ nợ cũng không gắn liền với vật thể.

Quyền sở hữu đối với tài sản vô hình không có đối tượng là một nghĩa vụ tài sản do người khác thực hiện. Tác giả sẽ được hưởng nhuận bút khi tác phẩm của mình được sử dụng (xuất bản, biểu diễn...); tác giả của một sáng chế sẽ được trả thù lao khi sáng chế của mình được đưa vào ứng dụng trong đời sống hoặc trong sản xuất, kinh doanh.

Quyền đối với tài sản vô hình không có đối tượng là một vật hữu hình. Bởi lẽ tác phẩm, suy cho cùng là ý niệm về một công trình trí tuệ; bài hát, công trình nghiên cứu... chỉ là cách ghi nhận, cách thể hiện ý niệm đó trong không gian và thời gian.

1.3. Nội dung quyền sở hữu đối với tài sản vô hình với quyền sở hữu theo luật chung Không thể đồng nhất

Luật viết Việt Nam chính thức sử dụng thuật ngữ *"quyền sở hữu"* để chỉ mối quan hệ giữa tài sản vô hình và người có quyền khai thác lợi ích từ tài sản mà không phải thông qua hợp đồng sử dụng tài sản với người khác. Dẫu sao, quyền sở hữu đối với tài sản vô hình không thể tương đồng với quyền sở hữu theo luật chung. Chắc chắn, tài sản vô hình không thể chiếm hữu được, nghĩa là không thể nằm trong phạm vi kiểm soát vật chất của con người như những loại tài sản khác (bàn ghế, tập vở, bút viết...). Trong trường hợp quyền sở hữu đối với tài sản vô hình bị xâm hại thì chủ sở hữu có quyền khởi kiện hay khiếu nại trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích của mình chứ không thể kiện đòi lại tài sản.

Quyền sở hữu có thời hạn - Quyền sở hữu tài sản vô hình thường có thời hạn. Các quyền tài sản của tác giả tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh được bảo hộ 50 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Các quyền tài sản của tác giả tác phẩm không thuộc loại hình trên được bảo hộ trong suốt cuộc đời của tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết (Luật sở hữu trí tuệ 2005 Điều 27 khoản 2). Độc quyền sáng chế hết hiệu lực sau 20 năm kể từ ngày nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ; sau 10 năm đối với độc quyền giải pháp hữu ích; sau 15 năm đối với độc quyền kiểu dáng công nghiệp (Luật sở hữu trí tuệ 2005 Điều 93).

Quyền sở hữu đối với tài sản vô hình và người thứ ba - Nội dung vật chất của các quyền sở hữu đối với tài sản vô hình chỉ có thể xây dựng với sự tham gia của người thứ ba, có thể là khán thính giả, người tiêu dùng...gọi chung là khách hàng. Tài sản hữu hình, trái lại, tồn tại tồn tại tự nó và có thể trở thành đối tượng của một quyền sở hữu hoàn chỉnh bằng việc xác lập mối quan hệ giữa tài sản với chủ sở hữu mà không cần sự tham gia của người thứ ba.

2. Các hình thức tồn tại của tài sản vô hình

Tài sản vô hình rất đa dạng và phong phú cả trong cuộc sống lẫn khía cạnh pháp lý. Nội dung nghiên cứu phần này đề cập đến ba nhóm tài sản vô hình được luật viết điều chỉnh tương đối chặt chẽ và đầy đủ nhất. Đó là *quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu đối với tác phẩm văn chương, nghệ thuật, khoa học* và *quyền sở hữu các yếu tố vô hình thuộc về sản nghiệp thương mại*[97]

2.1. Quyền sở hữu tác phẩm văn chương, nghệ thuật, khoa học

2.1.1. Tác phẩm

Sự liệt kê không định nghĩa - Luật sở hữu trí tuệ 2005 Điều 4 khoản 7 định nghĩa *« Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào »*. Không kể chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu (là sản phẩm đặc biệt), tác phẩm được bảo hộ có thể chia làm ba nhóm:

- Nhóm thứ nhất: *tác phẩm văn chương* - bao gồm các sáng tác văn chương viết không phân biệt hình thức, thể loại, lĩnh vực, đề tài... (như tiểu thuyết, truyện vừa, truyện ngắn, bút ký, ký sự, tùy bút, hồi ký, thơ ca, kịch bản, phóng tác, cải biên,...).
- Nhóm thứ hai: *tác phẩm nghệ thuật* - bao gồm các công trình nghệ thuật như tác phẩm sân khấu, điện ảnh, video, âm nhạc, kiến trúc, hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc...
- Nhóm thứ ba: *công trình nghệ thuật* - bao gồm các kết quả sáng tạo có tính khoa học, như công trình nghiên cứu, khảo sát, phân tích chuyên môn, bình luận, bài phát biểu,

[97] Xem các quy định về quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu tác phẩm văn chương, nghệ thuật, khoa học, quyền sở hữu các yếu tố vô hình thuộc sản nghiệp thương mại trong Bộ luật dân sự 2005, Luật sở hữu trí tuệ 2005 và Luật Thương mại 2005.

bài giảng, họa đồ, bản vẽ,... trừ những kết quả sáng tạo được bảo hộ dưới hình thức là sáng chế. Như vậy, tác phẩm được hiểu là kết quả lao động sáng tạo của tác giả được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định và trở nên độc đáo chính nhờ hình thức thể hiện đó. Quyền tác giả được xác định từ thời điểm hình thức thể hiện của tác phẩm được nhận biết, không phân biệt tác phẩm đã được công bố hay chưa công bố hoặc đã đăng ký bảo hộ hay chưa đăng ký bảo hộ.

2.1.2. Tác phẩm của nhiều tác giả, tác phẩm của tập thể, tác phẩm vô danh

- *Tác phẩm của nhiều tác giả* là kết quả lao động của nhiều người (gọi là đồng tác giả) để tạo ra một sản phẩm chung. Ở góc độ tài sản, tác phẩm chung của nhiều người thuộc sở hữu chung của những người đó (gọi là các đồng sở hữu).
- *Tác phẩm của tập thể* cũng là kết quả lao động sáng tạo của nhiều người, nhưng mỗi người thực hiện công việc của mình trong khuôn khổ một kế hoạch, một dự án chung do một người (cá nhân hoặc pháp nhân) chịu trách nhiệm và chính người này có đầy đủ các quyền của một tác giả.
- *Tác phẩm vô danh* là kết quả sáng tạo của một người không rõ lai lịch. Trong thời hạn bảo hộ, người được phép công bố tác phẩm, tạm thời thực hiện quyền của tác giả đối với tác phẩm đó.

2.1.3. Quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm

2.1.3.1. Quyền nhân thân

Theo khoản 1, Điều 738 BLDS: *"Quyền nhân thân thuộc quyền tác giả bao gồm: quyền đặt tên cho tác phẩm; quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố, phổ biến tác phẩm; quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc tác phẩm."*

Các quyền nhân thân sau đây của tác giả đối với tác phẩm tồn tại vĩnh viễn hay được bảo hộ vô thời hạn: *quyền đặt tên cho tác phẩm; quyền đứng tên thật hoặc bút*

danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho phép người khác sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc tác phẩm (Luật sở hữu trí tuệ 2005 Điều 27 khoản 1).

Các quyền nhân thân sau đây của tác giả tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh được bảo hộ 50 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên ; của tác giả tác phẩm không thuộc loại hình trên được bảo hộ trong suốt cuộc đời của tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết và có thể được chuyển nhượng, chuyển giao cho người thừa kế trong thời gian bảo hộ: *quyền công bố tác phẩm hoặc cho người khác công bố tác phẩm* (Luật sở hữu trí tuệ 2005 Điều 27 khoản 2 và Điều 45 khoản 2).

2.1.3.2. Quyền tài sản

Theo Điều 738 khoản 2 *« Quyền tài sản thuộc quyền tác giả bao gồm:quyền sao chép tác phẩm ; cho phép tạo tác phẩm phái sinh ; phân phối, nhập khẩu bản gốc và bản sao tác phẩm ; truyền đạt tác phẩm đến công chúng; cho thuê bản gốc hoặc bản sao chương trình máy tính ».* Những quyền này có thể được chuyển nhượng, được chuyển giao cho người thừa kế nhưng sẽ đương nhiên mất hiệu lực khi hết năm mươi năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, sân khấu mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh ; khi hết 50 năm sau ngày tác giả chết đối với các tác phẩm không thuộc loại hình nêu trên (Luật sở hữu trí tuệ 2005 Điều 27 khoản 2 và Điều 45 khoản 1).

2.2. Quyền sở hữu công nghiệp

Sở hữu công nghiệp - là một khái niệm luôn thay đổi theo thời gian và không gian. Điều 1 Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ghi nhận khái niệm *"sở hữu công nghiệp"* theo hai nghĩa. *Theo nghĩa rộng*, sở hữu công nghiệp bao gồm các sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, công nghiệp khai thác và tất cả sản phẩm công nghiệp và sản phẩm tự nhiên là kết quả của hoạt động sáng tạo của con người. *Hiểu theo nghĩa hẹp*, sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, tên gọi xuất xứ hàng hóa và chống cạnh tranh không lành mạnh. Không như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp chỉ có thể xác lập bằng việc đăng ký văn bằng bảo hộ.

2.2.1. Sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên (Luật sở hữu trí tuệ Điều 4 khoản 12).

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức độc quyền sáng chế nếu đáp ứng được các điều kiện sau : có tính mới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp. Nếu sáng chế không đáp ứng được điều kiện về trình độ sáng tạo nhưng đáp ứng được hai điều kiện còn lại thì được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường (Luật sở hữu trí tuệ Điều 58).

2.2.2. Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này (Luật sở hữu trí tuệ Điều 4 khoản 13). Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây : có tính mới, có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp (Luật sở hữu trí tuệ Điều 63). Thông thường một kiểu dáng mới phải tỏ ra độc đáo so với kiểu dáng của các sản phẩm cùng loại khác mà chính sự độc đáo đó được dùng để phân biệt kiểu dáng này với tất cả kiểu dáng khác.

2.2.3. Nhãn hiệu

Là dấu hiệu nhận dạng sản phẩm thương mại - *Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa,dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau* [98](Luật sở hữu trí tuệ Điều 4 khoản 16)

Có thể nói rằng nhãn hiệu có mục đích kép. Một mặt, nó bảo vệ người có quyền khai thác chống lại sự cạnh tranh của những người khác kinh doanh trong cùng một lĩnh vực; mặt khác nó đảm bảo cho người tiêu dùng về nguồn gốc cũng như chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ mà mình quan tâm.
Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây : là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc ; có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác (Luật sở hữu trí tuệ Điều 72).

2.2.4. Chỉ dẫn địa lý

Là quyền sở hữu công nghiệp tập thể, không thể chuyển nhượng – Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể (Luật sở hữu trí tuệ Điều 4 khoản 22).

Ví dụ: bưởi năm roi Biên Hòa, kẹo dừa Bến Tre, gạo thơm chợ Đào...

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây : sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý ; sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định (Luật sở hữu trí tuệ Điều 79).
Cùng một chỉ dẫn địa lý, nhiều người ở cùng một địa phương có thể cùng được bảo hộ dù rằng những người này cùng sản xuất một mặt hàng. Do đó, có thể nói rằng, *quyền sử dụng* chỉ dẫn địa lý l*à một quyền tập thể*. Tuy nhiên, *quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý là một quyền không thể chuyển nhượng được* bởi lẽ một người ở một vùng khác tuy cũng sản xuất mặt hàng đó nhưng không thể sử dụng chỉ dẫn địa lý không thuộc về không gian địa lý của nơi mình sản xuất cho dù có sử dụng nguyên liệu, công thức, kỹ thuật của vùng xuất xứ gốc.

2.3. Các yếu tố vô hình của sản nghiệp thương mại

2.3.1. Mạng lưới tiêu thụ hàng hóa và cung ứng dịch vụ

Một tài sản vô hình có giá trị mong manh - Có thể tạm hình dung, mạng lưới tiêu thụ hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, với tư cách là một tài sản vô hình, chính là kết quả của những nỗ lực phát huy tài năng và sự khéo léo của thương nhân nhằm thu hút khách hàng để tiêu thụ hàng hóa mà mình sản xuất. Sự phát triển của mạng lưới tiêu thụ hàng hóa hay cung ứng dịch vụ lệ thuộc rất nhiều vào yếu tố khách quan (tình hình kinh tế xã hội của quốc gia và khu vực; thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng, thời điểm kinh doanh, tốc độ đô thị hoá, điều kiện tự nhiên, môi trường...) cũng như yếu tố chủ quan (sự nhạy bén của chính sách maketing, uy tín của thương hiệu, ý chí của bạn hàng...). Nói chung mạng lưới tiêu thụ hàng

[98] Luật sở hữu trí tuệ còn đưa ra các khái niệm về nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết và nhãn hiệu nổi tiếng.

hóa hay cung ứng dịch vụ có giá trị rất mong manh.

2.3.2. Tên thương mại

Yếu tố đầu tiên về lai lịch thương nhân đã trở thành tài sản – Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh (Luật sở hữu trí tuệ Điều 4 khoản 21).

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó và chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh (Luật sở hữu trí tuệ Điều 76).

Như vậy, tên thương mại là danh hiệu dùng trong giao dịch của thương nhân, tên thương mại là một sản nghiệp thương mại và có thể chuyển nhượng[99]. Ở các nước có nền kinh tế thương mại phát triển, có một số tên thương mại được định giá rất cao. Ví dụ như Sony, Honda, Microsoft ...

2.3.3. Biển hiệu

Dấu hiệu nhận dạng thương nhân đã trở thành tài sản - Biển hiệu là dấu hiệu gắn liền với cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm giúp phân biệt cơ sở này với cơ sở khác. Cũng như tên thương mại, biển hiệu chỉ có thể là đối tượng của quyền sở hữu được pháp luật bảo vệ khi thương nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Pháp luật Việt Nam hiện hành chỉ mới dự liệu các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu biển hiệu trong tập quán và trong các quy phạm địa phương trong khi nhu cầu này trên thực tế của dân cư là rất lớn, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế trị trường cũng như chính sách chống cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh đã được ghi nhận trong một số văn bản pháp quy khác của Nhà nước ta.

MỤC 4 - Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là một tài sản đặc biệt - Luật hiện hành khẳng định quyền sử dụng đất là một tài sản. Theo luật Đất đai 2003 và BLDS 2005, quyền sử dụng đất là một tài sản có thể chuyển giao cũng như tham gia thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật.

Điều 108 BLDS 2005 ghi nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình là tài sản chung của hộ. Bằng nguyên tắc áp dụng pháp luật chúng ta có thể rút ra những quy tắc khác như : quyền sử dụng đất hợp pháp của cá nhân là tài sản của cá nhân, quyền sử dụng đất hợp pháp của hợp tác xã là tài sản của hợp tác xã. Song, đây là một tài sản có những đặc điểm riêng không như bất cứ loại tài sản nào được ghi nhận trong luật thực định Việt Nam.

Sự đa dạng của chế độ pháp lý áp dụng đối với quyền sử dụng đất - Luật Đất đai 2003 phân chia quyền sử dụng đất thành ba nhóm:

- Nhóm được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Nhóm được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
- Nhóm được Nhà nước cho thuê đất, có hai loại:
  + Đất thuê trả tiền hàng năm,
  + Đất thuê trả tiền nhiều năm.

Mỗi nhóm quyền được sự điều chỉnh của một chế độ pháp lý đặc thù về quy chế chuyển nhượng, chuyển giao cho người thừa kế, cho thuê, cho mượn...Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu những quy định chung nhất về vấn đề này, còn những vấn đề cụ thể hơn như chế độ pháp lý của từng loại đất, từng nhóm chủ thể sử dụng đất, hay việc chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất sẽ được nghiên cứu kỹ trong những chuyên đề khác như Luật Đất đai, Thừa kế quyền sử dụng đất ...

1. Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất

[99] Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó (Luật sở hữu trí tuệ Điều 139 khoản 3).

Điều 33 Luật đất đai 2003 quy định Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 70 của Luật đất đai;
2. Tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối;
3. Đơn vị vũ trang nhân dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối hoặc sản xuất kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;
4. Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo các dự án của Nhà nước;
5. Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối;
6. Người sử dụng đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp quy định tại Điều 88 của Luật đất đai; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất giao thông, thuỷ lợi; đất xây dựng các công trình văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng và các công trình công cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;
7. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 99 của Luật đất đai.

-Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác; chuyển nhượng quyền sử dụng đất (trừ trường hợp chuyển nhượng có điều kiện theo quy định của Chính phủ); cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thuê quyền sử dụng đất; để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật; tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế hoặc cá nhân để vay vốn sản xuất, kinh doanh; góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh (Điều 113 Luật đất đai 2003).

-Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng các công trình không bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước được quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất. Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục giao đất không thu tiền sử dụng đất theo mục đích đã được xác định (Điều 109 Luật đất đai 2003).

-Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất; không được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất (Điều 117 khoản 2 Luật đất đai 2003) .

2. Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Điều 34 Luật đất đai 2003 quy định Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;
2. Tổ chức kinh tế được giao đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê;
3. Tổ chức kinh tế được giao đất sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;
4. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh;

5. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;
6. Tổ chức kinh tế được giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
7. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất để thực hiện các dự án đầu tư.

-Hộ gia đình, cá nhân đượcNhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất có các quyền tương tự như quyền của hộ gia đình, cá nhân đượcNhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (Điều 109 Luật đất đai 2003).

-Quyền của tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất được phân biệt thành hai trường hợp:

+Trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được xây dựng gắn liền với đất; cho thuê quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được xây dựng gắn liền với đất; tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vốn theo quy định của pháp luật; góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật (Điều 110 khoản 2 Luật đất đai 2003).

+Trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì có các quyền tương tự tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (Điều 110 khoản 3 Luật đất đai 2003).

-Người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đầu tư tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam giao đất có thu tiền sử dụng đất có các quyền tương tự như quyền của tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước được nêu ở trên (Điều 119 khoản 1 Luật đất đai 2003).

3. Quyền sử dụng đất thuê

Luật Đất đai 2003 phân biệt hai loại hợp đồng thuê đất: hợp đồng thuê trả tiền hàng năm và hợp đồng thuê trả tiền nhiều năm.

3.1. Hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm

Điều 35 khoản 1 Luật đất đai 2003 quy định Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm trong các trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối;

b) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao trước ngày 01 tháng 01 năm 1999 mà thời hạn sử dụng đất đã hết theo quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật đất đai;

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 đến trước ngày Luật đất đai 2003 có hiệu lực thi hành, trừ diện tích đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất;

d) Hộ gia đình, cá nhân thuê đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

đ) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

e) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

g) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc.

-Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền bán, để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua, người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định; thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế hoặc cá nhân để vay vốn sản xuất, kinh doanh; góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh (Điều 114 khoản 1Luật đất đai 2003)[100]

-Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền và nghĩa vụ sau đây: thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; bán tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định; cho thuê lại đất đã được xây dựng xong kết

cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế[101]. (Điều 111 khoản 1Luật đất đai 2003)

-Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; trường hợp người mua tài sản là tổ chức, cá nhân thì được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; trường hợp người mua tài sản là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu tiền thuê đất hàng năm. Người được giao đất, thuê đất tiếp tục sử dụng theo đúng mục đích đã được xác định trong thời hạn còn lại; cho thuê nhà ở trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (Điều 119 khoản 2 Luật đất đai 2003).

-Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc có quyền sở hữu công trình do mình xây dựng trên đất thuê trong thời hạn thuê đất và được hưởng các quyền theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; được hưởng các quyền khác ghi trong hợp đồng thuê đất (Điều 118 Luật đất đai 2003).

---

[100] Khác với các văn bản luật đất đai trước đây, Luật đất đai 2003 không quy định trường hợp hộ gia đình, cá nhân trong nước được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhiều năm. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trước ngày Luật đất đai 2003 có hiệu lực thi hành mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 113 của Luật đất đai 2003 trong thời hạn đã trả tiền thuê đất; trường hợp có nhu cầu chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất trừ đi tiền thuê đất đã trả và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 113 của Luật đất đai 2003 (Điều 114 khoản 2 Luật đất đai 2003).

[101] Khác với các văn bản luật đất đai trước đây, Luật đất đai 2003 không quy định trường hợp tổ chức kinh tế trong nước được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhiều năm.Trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trước ngày Luật đất đai 2003 có hiệu lực thi hành mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 110 của Luật đất đai 2003 trong thời hạn đã trả tiền thuê đất; trường hợp có nhu cầu chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất trừ đi tiền thuê đất đã trả và có các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 110 của Luật đất đai 2003 (Điều 111 khoản 1 điểm đ Luật đất đai 2003) .

Như vậy, quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm không phải là tài sản được phép giao dịch một cách độc lập, mà chỉ là một yếu tố không thể tách rời của tài sản gắn liền với đất.

3.2. Hợp đồng thuê đất trả tiền nhiều năm

Điều 35 khoản 2 Luật đất đai 2003 quy định Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

a) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê;

b) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc.

Như vậy, hợp đồng thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê chỉ dành cho các các chủ thể có yếu tố nước ngoài.

-Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất; thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam trong thời hạn thuê đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh trong thời hạn thuê đất; trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở thì có quyền bán hoặc cho thuê nhà ở theo quy định của Chính phủ; người mua nhà ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai (Điều 119 khoản 3 Luật đất đai 2003).

-Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc có quyền theo Điều 118 Luật đất đai 2003 đã nêu trên.

Quyền sử dụng đất thuê trả tiền nhiều năm chỉ là một tài sản độc lập tương đối. Nghĩa là, nếu không có tài sản gắn liền trên đất thì quyền sử dụng đất đó có thể được thế chấp, chuyển nhượng...(nghĩa là được giao dịch một cách độc lập); nhưng nếu có tài sản gắn liền với đất thì khi tham gia một giao dịch nào đó, quyền sử dụng đất phải đi cùng tài sản đó.

CHƯƠNG 2 - QUYỀN SỞ HỮU

Dẫn nhập - Trong bất cứ một chế độ xã hội nào cũng tồn tại những cách thức nhất định về việc chiếm hữu, làm chủ của cải vật chất của con người. Mối quan hệ giữa người với người trong quá trình chiếm hữu của cải vật chất đó làm phát sinh các quan hệ sở hữu. Các quan hệ sở hữu này tồn tại một cách khách quan cùng với sự phát triển của xã hội. Khi Nhà nước và pháp luật ra đời, địa vị của giai cấp thống trị trong việc phân phối của cải vật chất trong xã hội được ghi nhận bằng những quyền năng hạn chế mà Nhà nước trao cho người đang chiếm giữ của cải vật chất đó. Lúc này, các quan hệ sở hữu đã được điều chỉnh bằng pháp luật và hình thành nên quyền sở hữu của các chủ thể có tài sản.

Với tư cách là một chế định pháp luật, quyền sở hữu có từ khi xuất hiện Nhà nước và chỉ mất đi khi xã hội không còn sự phân chia giai cấp và không còn sự tồn tại của Nhà nước.

Khái niệm quyền sở hữu - được hiểu theo hai nghĩa:

- *Theo nghĩa khách quan*, quyền sở hữu là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình chiếm hữu, sử dụng, định đoạt các tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng trong xã hội. Hay nói khác đi, quyền sở hữu chính là pháp luật về sở hữu.
- *Theo nghĩa chủ quan*, quyền sở hữu là khả năng được phép xử sự của chủ sở hữu trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của mình. Những quyền năng này cũng chính là nội dung của quyền sở hữu mà chủ sở hữu có được đối với tài sản. BLDS Việt Nam hiện hành tuy không định nghĩa trực tiếp như vậy nhưng có quy định rằng: *"quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật."*.

Tính chất của các quyền của chủ sở hữu - Các quyền của chủ sở hữu có tính độc nhất, chỉ có thể bị giới hạn do quy định của pháp luật và tồn tại lâu dài.

MỤC 1 - Nội dung pháp lý của quyền sở hữu

1. Quyền sử dụng

Dùng và thu hoa lợi, lợi tức - Điều 192 BLDS quy định: *"quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản."*. Như vậy, với tư cách là một trong những nội dung của quyền sở hữu, quyền sử dụng bao gồm quyền khai thác công dụng của tài sản và quyền thu nhận hoa lợi, lợi tức từ tài sản. "Khai thác công dụng" nghĩa là chủ sở hữu tự mình thụ hưởng các lợi ích vật chất từ một tài sản không sinh lợi hoặc không được khai thác về phương diện kinh tế. "Thu nhận hoa lợi, lợi tức từ tài sản" được hiểu là việc chủ sở hữu được thụ hưởng những kết quả từ khai thác sự sinh lợi của tài sản mà vẫn bảo tồn chất liệu của tài sản. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, hai quyền này không nhất thiết phải tồn tại song song trên cùng một tài sản.

Chủ sở hữu có quyền quyết định phương thức sử dụng tài sản (dùng hay không dùng tài sản) cũng như cách thức thu hoa lợi, lợi tức (trực tiếp khai thác hoa lợi, tự nhiên của tài sản, hoặc để cho người khác khai thác thông qua một hợp đồng cho thuê, cho mượn). Tài sản có thể được sử dụng hoặc được khai thác trực tiếp bằng chính chủ sở hữu hoặc bởi một người khác không phải là chủ sở hữu (khi được chủ sở hữu chuyển giao quyền sử dụng hoặc do pháp luật quy định)

Hạn chế quyền sử dụng - Điều 193 BLDS quy định: *"Chủ sở hữu có quyền khai thác công dụng của tài sản, hưởng hoa lợi lợi tức từ tài sản theo ý chí của mình nhưng không được gây thiệt hại và làm ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác."*. Đây là nguyên tắc chung mà luật viết đã dự liệu để hạn chế quyền sử dụng chủ động, ngăn ngừa sự lạm dụng. Ngoài ra, pháp luật còn có những quy định hạn chế quyền sử dụng thụ động trong một số trường hợp đặc thù khác đã được thừa nhận trên thực tế.

2. Quyền định đoạt.

Định đoạt vật chất và định đoạt pháp lý - Theo Điều 195 BLDS *"Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó."*. Ngoài ra, chủ sở hữu còn có thể định đoạt tài sản bằng cách chấm dứt sự tồn tại vật chất của tài sản. Như vậy, chủ sở hữu có quyền quyết định số phận của tài sản về phương diện vật chất (tiêu dùng, thiêu hủy, chuyển hóa thành một hình thức tồn tại khác...), hoặc về phương diện pháp lý (chuyển nhượng, tặng cho, trao đổi, góp vốn kinh doanh...). Cũng như quyền sử dụng, quyền định đoạt của chủ sở hữu có thể do chính chủ sở hữu hoặc do một người khác thực hiện Mọi trường hợp định đoạt tài sản ngoài khuôn khổ giới hạn của quyền tự định đoạt của chủ sở hữu cũng như định đoạt tài sản thuộc sở hữu của người khác đều bị xem là những giao dịch vô hiệu. Cũng có trường hợp, tài sản được chuyển quyền sở hữu không phải do hiệu lực của việc thực hiện quyền tự định đoạt của chủ sở hữu, mà do pháp luật quy định (như trong các trường hợp trưng mua, trưng dụng vì mục đích an ninh quốc phòng, giải tỏa có đền bù để thực hiện quy hoạch đô thị...).

Hạn chế quyền định đoạt - Quyền định đoạt có thể bị hạn chế trong những trường hợp có sự xung đột giữa lợi ích của chủ sở hữu với lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc quyền và lợi ích của người khác mà việc bảo vệ những quyền lợi này hoàn toàn cần thiết và hợp lý. Luật viết quy định nhiều cách thức hạn chế quyền định đoạt khác nhau, như:

- Quyền định đoạt số phận pháp lý của một tài sản bị Nhà nước cấm hoặc hạn chế một cách trực tiếp bằng các quy định của pháp luật. Ví dụ, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác (khoản 3, Điều 81 Luật doanh nghiệp 2005).
- Quyền định đoạt số phận pháp lý của tài sản được Nhà nước hạn chế và kiểm soát một cách gián tiếp thông qua vai trò của một tổ chức hay một cá nhân.

3. Quyền chiếm hữu

Khái niệm - Theo Điều 182 BLDS: *"Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ, quản lý tài sản"*. Việc nắm giữ và quản lý ở đây bao hàm cả việc thực hiện quyền sử dụng (dùng và khai thác) hoặc quyền không sử dụng tài sản (cất giữ).

Trong bối cảnh hiện tại, luật viết hiện hành ghi nhận sự khác nhau về chế độ pháp lý của người chiếm hữu với tư cách là chủ sở hữu và người chiếm hữu tài sản của người khác trong quá trình thực hiện quyền chiếm hữu của mình đối với tài sản. Chúng ta lần lượt nghiên cứu sự khác nhau của hai chế độ pháp lý này:

3.1. Chiếm hữu của chủ sở hữu

3.1.1. Các yếu tố của quyền chiếm hữu của chủ sở hữu

Quyền chiếm hữu của chủ sở hữu được hình thành từ hai yếu tố:

Yếu tố khách quan *(corpus)* - đặc trưng bằng việc thực hiện các quyền thuộc nội dung của quyền sở hữu, thể hiện thành các giao dịch mang tính chất vật chất có tác động đến tài sản chẳng hạn như cất giữ đồ trang sức, cư trú trong nhà, canh tác trên đất, cho thuê tài sản.... Luật Việt Nam hiện hành xếp các giao dịch này thành hai nhóm:

- *Các giao dịch nắm giữ:* là các giao dịch mà thông qua đó, chủ sở hữu giữ vật trong phạm vi kiểm soát vật chất của mình. Vật không nhất thiết phải nằm trong tay chủ sở hữu theo nghĩa đen mà chỉ cần vật được đặt dưới quyền năng kiểm soát vật chất tiềm tàng của chủ sở hữu.
- *Các giao dịch quản lý:* là các giao dịch mà thông qua đó chủ sở hữu có thể kiểm soát được sự tồn tại của tài sản (về phương diện vật chất hay về giá trị) cũng như kiểm soát cả việc sử dụng, khai thác tài sản. Kiểm kê, định giá, bảo quản, tiêu dùng, cư trú, canh tác, ... là những giao dịch quản lý.

Trước đây, Điều 189 BLDS 1995 định nghĩa *"quyền chiếm hữu là quyền của chủ sở hữu tự mình nắm giữ, quản lý tài sản thuộc sở hữu của mình"*. Hiện nay định nghĩa này đã được sửa đổi *"Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ, quản lý tài sản"*. Như vậy, có thể thừa nhận sự tồn tại của các khái niệm "*chiếm hữu thông qua vai trò của người khác"* hay *"chiếm hữu dưới danh nghĩa người khác"*. Luật cũng quy định thời gian chiếm hữu của người khác sẽ được tính như một phần thời gian chiếm hữu của chủ sở hữu khi xem xét về tình trạng chiếm hữu liên tục (Điều 190 BLDS).

Nói một cách tổng quát rằng: trong trường hợp tự mình nắm giữ, quản lý tài sản thì chủ sở hữu có quyền chiếm hữu theo nghĩa đầy đủ; còn trong trường hợp tài sản được giao cho người khác chiếm hữu, thì chủ sở hữu chỉ được coi là người chiếm hữu khi cần tính thời gian chiếm hữu liên tục chứ không phải là trường hợp người chiếm hữu theo nghĩa vật chất. Ta gọi chiếm hữu theo nghĩa đầy đủ là *chiếm hữu vật chất và pháp lý* còn chiếm hữu theo ý nghĩa của Điều 190 là *chiếm hữu pháp lý.*

Yếu tố chủ quan *(animus)* - đặc trưng bằng thái độ tâm lý của chủ sở hữu trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến tài sản được chiếm hữu, thể hiện bằng cung cách cư xử mang tính chất quyền lực đối với tài sản (có quyền sở hữu đối với tài

sản mà không phải báo cáo với bất kỳ ai về những vấn đề liên quan đến tài sản và không buộc phải giao tài sản co bất kỳ người nào. Tuy nhiên không phải bất cứ người nào có thái độ tâm lý như vậy cũng là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản.Bởi lẽ, thái độ tâm lý đó hoàn toàn khác với sự ngay tình.

Yếu tố chủ quan được cấu thành từ hai yếu tố: ý chí và dự định. *Ý chí* phải được bày tỏ bởi một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. *Dự định* chính là những xử sự của người chiếm hữu nhằm khẳng định quyền sở hữu của mình đối với tài sản đó.

3.1.2. Xác lập quyền chiếm hữu của chủ sở hữu

Hội đủ corpus và animus - Quyền chiếm hữu vật chất và pháp lý được xác lập khi hội đủ hai yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan. Riêng yếu tố chủ quan không những phải có mà còn phải được pháp luật thừa nhận. Nếu yếu tố chủ quan tuy có nhưng không được pháp luật thừa nhận thì người chiếm hữu sẽ ở trong tình trạng chiếm hữu thực tế mà không không có quyền chiếm hữu. Luật viết gọi đó là tình trạng chiếm hữu không có căn cứ pháp luật và không ngay tình.

Quyền chiếm hữu của người quản lý tài sản - Yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan không nhất thiết phải hội đủ vào bản thân chủ sở hữu bởi có trường hợp các yếu tố này xuất hiện ở người không phải là chủ sở hữu và cũng không xem mình là chủ sở hữu, đó là người quản lý tài sản. Vai trò của người quản lý tài sản được đặt trong nhiều trường hợp: chủ sở hữu là người chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng không có khả năng nhận thức được hành vi của mình; chu sở hữu vắng mặt hoặc mất tích; chủ sở hữu chết; được chỉ định làm người quản lý di sản thừa kế... Khi đó, người quản lý tài sản thực hiện các tác động vật chất lên tài sản mà mình quản lý, thể hiện thái độ tâm lý của chủ sở hữu trong quá trình thực hiện những giao dịch đó. Tuy nhiên, chỉ có *corpus* của người quản lý còn animus được người quản lý thể hiện không hoàn hảo, bởi tài sản - đối tượng của việc chiếm hữu - thuộc sở hữu của người khác.

3.1.3. Mất quyền chiếm hữu của chủ sở hữu

Chỉ mất corpus - Việc chủ sở hữu không tự mình nắm giữ, quản lý tài sản nhưng vẫn duy trì thái độ xử sự của của chủ sở hữu đối với tài sản chỉ khiến cho chủ sở hữu mất quyền chiếm hữu vật chất chứ không mất quyền chiếm hữu pháp lý. Chính vì lẽ đó, chủ sở hữu vẫn được coi là người chiếm hữu liên tục đối với tài sản dù không tự mình nắm giữ tài sản. Mất *corpus* có thể xảy ra một cách tự nguyện (trong các trường hợp chủ sở hữu giao kết hợp đồng cho thuê, cho mượn, ủy quyền quản lý và sử dụng tài sản...), cũng có thể xảy ra một cách không tự nguyện (có hai loại: có *animus* với sự ngay tình và có *animus* với sự không ngay tình).

Chỉ mất animus - Trong các trường hợp chủ sở hữu đã bán tài sản của mình co người khác và đã làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho người mua; nhưng do điều kiện khách quan mà người mua chưa thể tự mình nắm giữ và quản lý tài sản mà yêu cầu người bán tiếp tục quản lý tài sản trong một thời gian nhất định. Khi đó, người bán

vẫn có quyền chiếm hữu vật chất nhưng không có quyền chiếm hữu về mặt pháp lý, bởi tài sản vào lúc này thuộc quyền sở hữu của người khác.

3.1.4. Chiếm hữu không hoàn hảo[102]

Dẫn nhập - Điều 247, khoản 1 BLDS quy định: *" người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản, thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm chiếm hữu..."*. Từ nội dung điều luật, ta có thể rút ra một nguyên tắc rằng quyền sở hữu theo thời hiệu sẽ không được xác lập nếu thiếu bất cứ một trong những yếu tố nào đã được quy định tại Điều 247 BLDS. Vấn đề đặt ra ở đây là như thế nào là chiếm hữu không liên tục, chiếm hữu gián đoạn, chiếm hữu không công khai, hoặc những trường hợp khác không thể xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu theo Điều 247 BLDS.

Chiếm hữu không liên tục - Theo Điều 190 BLDS, *"việc chiếm hữu tài sản được thực hiện trong một khoảng thời gian mà không có tranh chấp về tài sản đó là chiếm hữu liên tục, kể cả khi tài sản được giao cho người khác chiếm hữu"*. Như vậy, để có sự chiếm hữu liên tục với tư cách chủ sở hữu cần có đầy đủ các điều kiện sau:

- Có sự liên tục của *corpus* và *animus*.
- Không có sự tranh chấp của người thứ ba về tài sản.

Những trường hợp chiếm hữu không đáp ứng đầy đủ những điều kiện này sẽ được xem là sự chiếm hữu không liên tục.

Chiếm hữu không công khai - Theo Điều 191 BLDS, *"việc chiếm hữu được coi là công khai khi thực hiện một cách minh bạch, không giấu giếm; tài sản đang chiếm hữu được sử dụng theo tính năng, công dụng và được người chiếm hữu bảo quản, giữ gìn như tài sản của chính mình"*. Yếu tố cơ bản và quan trọng nhất của khái niệm chiếm hữu công khai chính là sự công khai của *corpus,* nghĩa là người chiếm hữu thực hiện các tác động vật chất đối với tài sản một cách minh bạch, không giấu giếm. Và ngược lại, sự chiếm hữu trở nên không công khai một khi các giao dịch tạo thành *corpus* được thực hiện không minh bạch hoặc giấu giếm nhằm ngăn chặn sự truy tìm tài sản của người có quyền kiện đòi lại tài sản. Khi đó, sự chiếm hữu công khai với tất cả mọi người, trừ người có quyền kiện đòi lại tài sản vẫn là sự chiếm hữu công khai theo ý nghĩa pháp lý. Do đó, có thể nói rằng sự chiếm hữu công khai theo ý nghĩa pháp lý chỉ là một khái niệm tương đối.

Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình -Theo Điều 189 BLDS: *"Người chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình là người chiếm hữu mà không biết và không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật."*

3.1.5. Hiệu lực của quyền chiếm hữu của chủ sở hữu

Bảo vệ quyền chiếm hữu - Quyền chiếm hữu của chủ sở hữu được bảo vệ trong khuôn khổ những quy định chung về bảo vệ quyền sở hữu được ghi nhận tại các Điều từ 255 đến 261 BLDS. Theo đó, người chiếm hữu là chủ sở hữu đích thực đối với tài sản có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền chiếm hữu phải trả lại tài sản, chấm dứt hành vi cản trở việc thực hiện quyền sở hữu, quyền chiếm hữu trái pháp luật, và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Luật viết hiện hành ghi nhận trường hợp một người xác lập quyền chiếm hữu của chủ sở

[102] còn gọi là chiếm hữu có tì vết (vice)

hữu đối với một tài sản nhưng không phải là chủ sở hữu đích thực của tài sản đó. Trường hợp này, trên thực tế có thể phân thành hai nhóm:

Chiếm hữu ngay tình - Người chiếm hữu trong trường hợp này có thể xác lập quyền sở hữu đối với tài sản chiếm hữu do thời hiệu và có quyền đối với một phần hoa lợi, lợi tức từ tài sản trong trường hợp phải trao trả tài sản cho chủ sở hữu đích thực[103].

Chiếm hữu không ngay tình - Luật không thừa nhận quyền chiếm hữu của người chiếm hữu không ngay tình trong trường hợp này và cũng không thừa nhận tình trạng chiếm hữu không ngay tình. (khoản 1, Điều 601 BLDS)

3.2. Chiếm hữu tài sản của người khác

Tình trạng chiếm hữu chỉ có *corpus* - Một khi việc chiếm hữu không có yếu tố chủ quan *(animus)* mà chỉ có yếu tố khách quan *(corpus)* thì người chiếm hữu đang ở trong tình trạng chiếm hữu tài sản của người khác. Điều 183 BLDS ghi nhận những trường hợp chiếm hữu hợp pháp của người khác, bao gồm: người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản, người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua các giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật, người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm phù hợp với các điều kiện do pháp luật quy định, người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với các điều kiện do pháp luật quy định và một số trường hợp khác do pháp luật quy định. Tất cả những người này đều có quyền xác lập những giao dịch mang tính chất vật chất tác độûng lên tài sản với tư cách của một người có quyền đối với tài sản của người khác chứ không phải đối với tài sản mà mình là chủ sở hữu.

Hiệu lực của việc chiếm hữu tài sản của người khác - Người chiếm hữu tài sản của người khác luôn có nghĩa vụ giao trả tài sản cho chủ sở hữu. Nghĩa vụ hoàn trả phải được thực hiện tại một thời điểm nào đó tùy theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Điều này xuất phát từ nguyên tắc *người chiếm hữu tài sản của người khác không thể xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu.* Người chiếm hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ trong trường hợp quyền chiếm hữu của mình bị xâm phạm theo các quy định tại các Điều từ 255 đến Điều 261 BLDS. Tuy nhiên, việc chiếm hữu tài sản của người khác chỉ được bảo vệ trong trường hợp bị xâm hại với điều kiện người chiếm hữu chứng minh được tính hợp pháp của tình trạng chiếm hữu đó của mình. Cũng cần lưu ý rằng các biện pháp bảo vệ quyền chiếm hữu tài sản của người khác không thể được áp dụng trong trường hợp có tranh chấp giữa các bên tham gia mối quan hệ kết ước làm phát sinh việc chiếm hữu đó.

MỤC 2 - Căn cứ xác lập quyền sở hữu

Theo BLDS Điều 170, "*Quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản trong các trường hợp sau đây: do lao động, do hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp; được chuyển giao quyền sở hữu theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thu hoa lợi, lợi tức; tạo thành vật mới do sáp nhập, trộn lẫn, chế biến; được thừa kế tài sản; chiếm hữu trong các trường hợp do pháp luật quy định đối với vật vô chủ, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, gia súc gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên; chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai phù hợp với thời hiệu quy định tại khoản 1 Điều 247 BLDS; và các trường hợp khác do pháp luật quy định*".

Như vậy, các căn cứ xác lập quyền sở hữu dự liệu tại Điều 170 BLDS được xếp thành hai nhóm:

- *Nhóm quyền sở hữu được chuyển giao*: có nhiều phân nhóm nhỏ:

[103] Theo Điều 601, khoản 2 BLDS: người chiếm hữu tài sản mà không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, thì phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức thu được từ thời điểm người đó biết hoặc phải biết việc chiếm hữu đó là không có căn cứ pháp luật. Nghĩa là, không phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức đã thu được một cách ngay tình

+ *Theo nguồn gốc của việc chuyển giao*, quyền sở hữu được xác lập có thể do luật định (như thừa kế theo pháp luật, quốc hữu hóa); bằng con đường tư pháp (như thanh toán doanh nghiệp trong tình trạng phá sản, buộc bồi thường thiệt hại, tịch thu sung công quỹ) hoặc hành chính (như xử phạt hành chính, giao quyền sử dụng đất); do ý chí của chủ sở hữu bằng giao dịch một bên (di chúc) hoặc bằng hợp đồng (bán, tặng cho, trao đổi).

+ *Theo phạm vi đối tượng chuyển giao*, ta có chuyển giao tổng quát (như để lại di sản thừa kế, sáp nhập các doanh nghiệp) hoặc chuyển giao đặc định (như bán, tặng cho, di tặng).

+ *Theo động cơ vật chất của việc chuyển giao*, ta có chuyển giao có đền bù (như bán, trao đổi, giao quyền sử dụng đất có thu tiền) hoặc không có đền bù (tặng cho, thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

 Nhóm quyền sở hữu được xác lập trực tiếp: do lao động sáng tạo, do chiếm giữ, sáp nhập, chiếm hữu tài sản,...mà quyền sở hữu được hình thành và thừa nhận.

Trong phần này, nội dung nghiên cứu chỉ giới hạn trong nhóm quyền sở hữu được xác lập theo phương thức trực tiếp và những vấn đề có liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu theo phương thức đó.

1. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu

Thời hiệu - Theo Điều 154 BLDS: *"Thời hiệu là thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự, được miễn trừ nghĩa vụ dân sự hoặc mất quyền khởi kiện vụ án dân sự, quyền yêu cầu giải quyết việc dân sự."*

Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu - được ghi nhận tại Điều 247 BLDS như sau: *"Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn mười năm đối với động sản, ba mươi năm*

đối với bất động sản, thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu" trừ trường hợp *"chiếm hữu tài sản thuộc sở hữu nhà nước, không có căn cứ pháp luật thì dù ngay tình, liên tục, công khai, dù thời gian chiếm hữu là bao lâu"* thì người chiếm hữu tài sản đó cũng không thể trở thành chủ sở hữu hợp pháp được. Tuy nhiên, rõ ràng luật viết đã không quy định rõ cách tính thời hiệu trong việc xác lập quyền sở hữu theo căn cứ này. Về mặt lý luận, có thể lý giải vấn đề này theo nhiều cách:

□□ *Cách thứ nhất, không có sự kết nối việc chiếm hữu* - Thời hạn mười năm hoặc ba mươi năm nói trên được tính từ ngày người xác lập quyền sở hữu do thời hiệu thực sự chiếm hữu tài sản một cách ngay tình. Nếu người này chuyển nhượng tài sản cho người khác lúc còn sống hoặc di tặng tài sản mà chưa kịp xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu, thì thời hiệu được tính lại từ đầu cho người chiếm hữu mới.

□□ *Cách thứ hai, có kết nối việc chiếm hữu với điều kiện tất cả những người chiếm hữu liên tiếp đều ngay tình* - Thời hạn mười năm hoặc ba mươi năm nói trên được tính từ ngày chiếm hữu của người chiếm hữu ngay tình đầu tiên. Những người nối tiếp nhau nhận tài sản sau này (qua một giao dịch dân sự) được cộng thêm thời gian chiếm hữu của người chiếm hữu trước vào thời gian chiếm hữu của mình trong việc tính thời hiệu, với điều kiện tất cả đều là người chiếm hữu ngay tình. Nếu trong chuỗi người chiếm hữu nối tiếp nhau có một người không ngay tình, thì thời hiệu lại được tính lại từ đầu kể từ ngày chiếm hữu của người chiếm hữu ngay tình đầu tiên sau người chiếm hữu không ngay tình đó. Riêng người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc sẽ kế tục sự ngay tình hoặc không ngay tình của người chết.

□□ *Cách thứ ba, có kết nối việc chiếm hữu nhưng quyền sở hữu do thời hiệu chỉ được xác lập cho người chiếm hữu ngay tình* - Thời hạn mười năm hoặc ba mươi năm nói trên được tính từ ngày chiếm hữu của người chiếm hữu đầu tiên, bất kể ngay tình hay không ngay tình. Nhưng, cần chú ý rằng chỉ có người chiếm hữu ngay tình mới có thể xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu. Người thừa kế của một người chiếm hữu ngay tình cũng xác lập được quyền sở hữu theo thời hiệu, dù bản thân có thể không ngay tình.

□□ *Cách thứ tư, có kết nối việc chiếm hữu tính từ người chiếm hữu ngay tình đầu tiên* - Thời hạn mười năm hoặc ba mươi năm nói trên được tính kể từ ngày chiếm hữu của người chiếm hữu ngay tình đầu tiên; những người chiếm hữu nối tiếp được cộng thêm thời gian chiếm hữu của người chiếm hữu trước vào thời gian chiếm hữu của mình để tính thời hiệu và người chiếm hữu vào năm thứ mười một hoặc năm thứ ba mươi mốt sẽ có quyền xác lập quyền sở hữu do thời hiệu. Kể từ người chiếm hữu kế tiếp sau người người chiếm hữu ngay tình đầu tiên, vấn đề ngay tình hay không ngay tình không được đặt ra nữa.

Gián đoạn thời hiệu - Theo BLDS Điều 158 khoản 2, thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự bị gián đoạn khi có một trong các sự kiện sau đây: a) Có sự giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đối với quyền và nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu; b) Quyền, nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu mà bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan tranh chấp. Qua nội dung điều luật này, chúng ta có thể rút ra một số nhận xét sau:

- *Thứ nhất*: thời hiệu xác lập quyền sở hữu không bị gián đoạn trong trường hợp tài sản bị mất hoặc bị đánh cắp. Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm truy tầm và thu hồi tài sản bị mất hoặc bị đánh cắp. Trong trường hợp tài sản được thu hồi, thì người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình lại tiếp tục chiếm hữu và thời gian tài sản bị mất vẫn được tính trong thời gian chiếm hữu liên tục của người này.
- *Thứ hai*: việc giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nếu có tác dụng buộc người chiếm hữu hoàn trả tài sản cho chủ sở hữu đích thực, thì không những chỉ làm gián đoạn thời hiệu mà còn loại trừ khả năng bắt đầu một thời hiệu mới Trái lại, nếu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thừa nhận quyền sở hữu của người chiếm hữu (do nhầm lẫn), thì thời hiệu vẫn liên tục.
- *Thứ ba:* việc tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, như đã nói, tự nó không ảnh hưởng đến sự chiếm hữu liên tục. Tranh chấp cũng không hẳn làm gián đoạn thời hiệu xác lập quyền sở hữu, trừ trường hợp người tranh chấp là chủ sở hữu đích thực của tài sản. Ta nói rằng tranh chấp có tác dụng làm gián đoạn thời hiệu với điều kiện treo. Giả sử người tranh chấp được thừa nhận là chủ sở hữu tài sản, thì thời hiệu xác lập quyền sở hữu cho người chiếm hữu bị gián đoạn từ ngày có tranh chấp và cũng không thể bắt đầu lại, dù người bị tranh chấp có tiếp tục chiếm hữu tài sản. Nhưng đó phải là tranh chấp chính thức, nghĩa là được đưa ra xem xét tại một cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: sự tranh cãi thuần tuý dân gian không thể làm gián đoạn thời hiệu, ngay cả với điều kiện treo.

Hoãn tính thời hiệu - Thời hiệu xác lập quyền sở hữu cho người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình tương ứng với thời hiệu khởi kiện đòi lại tài sản của chủ sở hữu đích thực. Theo BLDS Điều 161 thì không được tính vào thời hiệu khởi kiện khoảng thời gian mà trong đó xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

1. Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền hoặc nghĩa vụ dân sự của mình;

2. Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
3. Chưa có người đại diện khác thay thế hoặc vì lý do chính đáng khác mà không thể tiếp tục đại diện được trong trường hợp người đại diện của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chết.

Trong trường hợp thời hiệu được hoãn tính, thì sau khi sự kiện làm dừng thời hiệu chấm dứt, thời hiệu sẽ được tính tiếp bằng cách cộng khoảng thời gian tính vào thời hiệu trước khi xảy ra sự kiện vào khoảng thời gian bắt đầu từ lúc sự kiện chấm dứt. Trong khung cảnh của luật thực định Việt Nam, hiệu lực của việc xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu phát sinh một cách đương nhiên. Người trước đây là chủ sở hữu tài sản sẽ bị bác đơn kiện đòi lại tài sản, một khi có đủ bằng chứng cho thấy bị đơn của vụ kiện đáp ứng đầy đủ các điều kiện để xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu.Tuy nhiên, một cách hợp lý, người chiếm hữu cũng có thể từ chối việc xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu.

2. Xác lập quyền sở hữu theo các phương thức trực tiếp khác

Các phương thức trực tiếp xác lập quyền sỏ hữu đối với tài sản hữu hình được thừa nhận tại Điều 170 BLDS bao gồm: sáp nhập, trộn lẫn, chế biến; chiếm hữu đối với vật vô chủ, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, gia súc gia cầm bị thất lạc; vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên (gọi chung là chiếm hữu theo Điều 170 BLDS).

2.1. Sáp nhập, trộn lẫn, chế biến

2.1.1. Chế biến

Đối tượng của việc chế biến phải là động sản. Việc chế biến có thể được chủ sở hữu tự mình thực hiện hoặc giao cho người khác thực hiện thông qua một hợp đồng gia công và chủ sở hữu nguyên vật liệu trở thành chủ sở hữu tài sản mới tạo thành (BLDS Điều 238 khoản 1). Cũng có trường hợp vật được chế biến bởi một người không phải là chủ sở hữu đối với vật đó mà cũng không được chủ sở hữu yêu cầu làm việc đó; người chế biến có thể ngay tình hoặc không ngay tình, khi chiếm hữu tài sản gốc.

Luật hiện hành quy định rằng nếu người chế biến ngay tình thì trở thành chủ sở hữu của của tài sản mới, nhưng phải thanh toán giá trị nguyên vật liệu, bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu nguyên vật liệu đó (BLDS Điều 238 khoản 2). Trong trường hợp người chế biến không ngay tình, thì chủ sở hữu có quyền yêu cầu giao vật mới; nếu có nhiều chủ sở hữu nguyên vật liệu, thì những người này là đồng chủ sở hữu theo phần đối với vật mới được tạo thành, tương ứng với giá trị nguyên vật liệu của mỗi người. Chủ sở hữu không ngay tình đối với nguyên vật liệu bị chế biến có quyền yêu cầu người chế biến bồi thường thiệt hại (Điều 238 khoản 3). Như vậy:

- *Thứ nhất*, luật không dự liệu việc thanh toán công sức lao động mà người chế biến không ngay tình bỏ ra để để chế biến sản phẩm. Người chế biến không ngay tình không những không có quyền sở hữu đối với tài sản mới mà còn không được trả công chế biến và phải bồi thường thiệt hại, nếu chủ sở hữu nguyên vật liệu có yêu cầu.
- *Thứ hai*, nếu việc chế biến được thực hiện một phần bằng nguyên vật liệu của người chế biến không ngay tình, thì người này cũng trở thành một trong các đồng chủ sở hữu theo phần đối với tài sản mới, áp dụng Điều 238 khoản 3 nêu trên. Tất nhiên, người này vẫn phải bồi thường thiệt hại, nếu chủ sở hữu phần nguyên vật liệu bị chế biến không ngay tình có yêu cầu.

2.1.2. Sáp nhập và trộn lẫn

Đặt vấn đề - Sáp nhập, trong luật hiện hành, *là việc gắn một vật vào một vật khác tạo thành một vật mới có thể chia được hoặc không chia được* (BLDS Điều 236 khoản 1) ; còn *trộn lẫn là việc pha trộn các vật với nhau tạo thành một vật mới* (Điều 237 khoản 1). Vật được sáp nhập có thể là một động sản hoặc một bất động sản, vật được trộn lẫn chỉ có thể là một động sản.

2.1.2.1. Sáp nhập bất động sản

Nguyên tắc: quyền sử dụng đất luôn là vật chính - Các bất động sản hữu hình nếu không là đất, thì đều là những tài sản gắn liền với đất và đều là những vật phục vụ cho việc khai thác công dụng của đất. Với đặc điểm đó, các tài sản gắn liền với đất phải được coi là vật phụ so với đất. Đất, hay nói đúng hơn là quyền sử dụng đất luôn là vật chính.

Sáp nhập bất động sản có thể xảy ra tự nhiên, như trong trường hợp di chuyển tự nhiên của vật nuôi dưới nước nhưng có khi sự sáp nhập là rõ ràng về mặt tự nhiên nhưng lại không được coi là sáp nhập về mặt pháp lý trong luật Việt Nam (ví dụ như sự bồi đắp của phù sa...). Sự sáp nhập cũng có thể xảy ra một cách nhân tạo.

Theo BLDS Điều 236 khoản 3, "Khi một người sáp nhập tài sản là động sản của người khác vào tài sản là bất động sản của mình, mặc dù đã biết hoặc phải biết tài sản đó không phải là của mình và cũng không được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập thì chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập có quyền yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại". Vậy, các tài sản gắn liền với đất do sự sáp nhập thuộc quyền sở hữu của người có quyền sử dụng đất. Giải pháp này còn được luật chính thức thừa nhận cho trường hợp đặc thù của việc sáp nhập các vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên (BLDS Điều 244). Tuy nhiên, chủ sở hữu tài sản bị sáp nhập có quyền yêu cầu người sáp nhập tài sản thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại.

2.1.2.2. Sáp nhập và trộn lẫn động sản

Các quy tắc chung - Nếu các tài sản được sáp nhập hoặc trộn lẫn thuộc về cùng một chủ sở hữu, thì chính người này là chủ sở hữu tài sản mới được tạo thành từ việc sáp nhập hoặc trộn lẫn. Nếu tài sản được sáp nhập hoặc trộn lẫn thuộc hai chủ sở hữu khác nhau, thì cả hai trở thành những người có quyền sở hữu chung theo phần đối với tài sản mới (BLDS Điều 236 khoản 1, Điều 237 khoản 1).

Nếu trường hợp việc sáp nhập hoặc trộn lẫn được thực hiện với sự không ngay tình thì người có tài sản bị sáp nhập hoặc bị trộn lẫn có thể lựa chọn một trong hai giải pháp như ta đã biết (BLDS Điều 236 khoản 2, Điều 237 khoản 2) hoặc nhận tài sản mới và thanh toán cho người sáp nhập hoặc trộn lẫn giá trị phần tài sản của người đó; hoặc không nhận tài sản mới và yêu cầu người sáp nhập, trộn lẫn thanh toán giá trị phần tài sản của mình và bồi thường thiệt hại.

2.2. Chiếm hữu theo khoản 6 Điều 170 BLDS

Vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, gia súc, gia cầm bị thất lạc.

2.2.1. Vật bị đánh rơi, bị bỏ quên

"Người nhặt hoặc phát hiện được vật do người khác đánh rơi hoặc bỏ quên mà biết rõ địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên, thì phải thông báo hoặc trả lại vật cho người đó." (BLDS Điều 239 khoản 2, Điều 241 khoản 1). Trường hợp không biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên, BLDS quy định rằng *"người nhặt hoặc phát hiện phải thông báo cho UBND xã, phường, thị trấn hoặc Công an cơ sở nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau một năm kể từ ngày thông báo công khai về vật nhặt được, phát hiện được mà không xác định được ai là chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận, nếu vật có giá trị đến mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì vật đó thuộc sở hữu của người nhặt được, phát hiện được"* (Điều 239 khoản 2 đoạn 4, Điều 241 khoản 2); *"nếu vật có giá trị lớn hơn mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, thì sau khi trừ chi phí bảo quản người nhặt được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối thiểu và 50% giá trị của phần vượt quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước"* (Điều 241 khoản 2 BLDS). *"Trong trường hợp vật bị đánh rơi, bị bỏ quên là cổ vật, là di tích lịch sử, văn hóa mà sau một năm, kể từ ngày thông báo công khai, không xác định được ai là chủ sở hữu hoặc không có người đến nhận, thì vật đó thuộc Nhà nước và người nhặt được, phát hiện được vật đó được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật"* (Điều 241 khoản 3).

2.2.2. Gia súc, gia cầm bị thất lạc

Việc xác lập quyền sở hữu đối với gia súc, gia cầm bị thất lạc được dự liệu tại các Điều 242 và 243 BLDS. Nếu bắt được gia súc bị thất lạc, thì người bắt được phải thông báo cho UBND xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại (Điều 242). Người bắt được gia súc bị thất lạc, sau khi hết thời hạn sáu tháng kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì sẽ được xác lập quyền sở hữu đối với gia súc bị thất lạc đó Nếu gia súc bắt được là gia súc thả rông theo tập quán, thì thời hạn này là một năm (Điều 242); còn đối với gia cầm thất lạc, thời hạn này là một tháng kể từ ngày thông báo công khai (Điều 243).

Nếu có người đến nhận gia súc trong thời hạn luật định và, trong thời gian chờ đợi, gia súc sinh con, thì người bắt được gia súc được hưởng một nửa số gia súc sinh ra (Điều 242). Trong cùng một giả thuyết, người bắt được gia cầm được hưởng trọn hoa lợi do gia cầm sinh ra (Điều 243). Cần lưu ý rằng hoa lợi nói ở đây là hoa lợi phát sinh trong suốt thời gian người bắt được gia súc, gia cầm bị thất lạc chiếm hữu tài sản cho đến ngày cuối của thời hạn được luật ấn định để chủ sở hữu thực hiện quyền nhận lại tài sản, không phải từ ngày thông báo công khai cho đến hết thời hạn luật định. Ngoài ra, cần lưu ý rằng hoa lợi của gia súc sinh sản nhiều kỳ sẽ được phân chia theo lứa chứ không theo số đầu gia súc thực tế.

Qua nội dung đã phân tích ở trên, ta có thể rút ra một số nhận người xét sau:

Thứ nhất, trong khoảng thời gian giữa thời điểm nhặt, phát hiện vật bị đánh rơi, bị bỏ quên hoặc thời điểm bắt được gia súc, gia cầm bị thất lạc và thời điểm giao trả lại cho chủ sở hữu hoặc giao nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, người nhặt, phát hiện hoặc bắt được có quyền chiếm hữu tài sản đó. Để có quyền chiếm hữu tài sản, người nhặt, phát hiện hoặc bắt được phải thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tự mình thông báo công khai. Quyền chiếm hữu được xác lập kể từ ngày nhặt, phát hiện, bắt được chứ không phải từ ngày thông báo. Nếu không thông báo, người nhặt, phát hiện hoặc bắt được sẽ ở trong tình trạng chiếm hữu không có căn cứ pháp luật và không ngay tình đối với tài sản. Dù có thông báo hay không, người nhặt, phát hiện hoặc bắt được không thể xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu đối với vật bằng cách chỉ dựa vào tình trạng chiếm hữu liên tục và công khai.

Thứ hai, luật không định thời hạn thông báo công khai kể từ ngày vật được nhặt, phát hiện, bắt được hoặc được giao nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Luật cũng không xác định hình thức thông báo công khai (công bố trên báo đài, đài trung ương, đài địa

phương,...) vấn đề này được giải quyết tùy theo tập quán sinh hoạt của từng vùng cũng như mức độ hiện đại của các phương tiện thông tin mà dân cư trong vùng đang sử dụng hoặc hưởng thụ.

Thứ ba, luật không xác định từ thời điểm nào quyền sở hữu được xác lập cho người nhặt, phát hiện vật bị đánh rơi, bỏ quên hoặc bắt được gia cầm, gia súc thất lạc. Ta có thể suy luận hai cách thức xác định thời điểm xác lập quyền sở hữu trong trường hợp này như sau: quyền sở hữu được xác lập từ thời điểm hết hạn để người đánh rơi, bỏ quên, làm thất lạc nhận lại tài sản; hoặc quyền sở hữu được xác lập từ thời điểm nhặt, phát hiện vật, bắt được gia cầm, gia súc đó. Rõ ràng, việc xác lập quyền sở hữu theo cách thứ nhất tỏ ra hợp lý hơn về lý luận cũng như thực tiễn và cũng phù hợp với tinh thần của giải pháp cho vấn đề xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu ghi nhận tại khoản 1 Điều 247 BLDS.

Việc chuyển nhượng vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc - được giải quyết như sau:

- *Giả thuyết thứ nhất: người nhặt được vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, bắt được gia súc, gia cầm bị thất lạc đã có thông báo công khai và việc chuyển nhượng được thực hiện trong thời gian chờ đợi* - Người được chuyển nhượng không thể được coi như ngay tình khi tham gia vào việc chuyển nhượng, bởi đã có thông báo công khai: việc thông báo có tác dụng đặt tất cả mọi người vào tình trạng buộc phải biết việc chiếm hữu gia, súc, gia cầm bị thất lạc. Nhưng, một cách hợp lý, người này phải được hưởng thời gian chiếm hữu liên tục của người chuyển nhượng và chỉ cần chờ đến khi hết thời hạn luật định, kể từ ngày thông báo công khai, để xác lập quyền sở hữu của mình đối với gia súc, gia cầm bị thất lạc và được chuyển nhượng. Giả sử, trong thời gian chờ đợi, chủ sở hữu gia súc, gia cầm bị thất lạc đến nhận lại tài sản, thì người được chuyển nhượng cũng có quyền yêu cầu hoàn trả chi phí nuôi giữ và các chi phí khác, cũng như được quyền sở hữu đối với hoa lợi như thể tài sản còn nằm trong tay người chuyển nhượng. Ta nói rằng việc chuyển nhượng có tác dụng chuyển các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản chuyển nhượng cho người được chuyển nhượng. Nếu tài sản được chuyển nhượng trong điều kiện đã có thông báo công khai, thì người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng hưởng hoa lợi phát sinh trong thời gian chiếm hữu của mình, theo các quy định tại các Điều 242 và 243 BLDS.
- *Giả thuyết thứ hai: người bắt được gia súc, gia cầm không thông báo công khai*. Không thông báo, người chuyển nhượng ở trong tình trạng chiếm hữu không ngay tình. người được chuyển nhượng có thể biết mà cũng có thể không biết điều đó. Nếu người được chuyển nhượng biết mà vẫn chấp nhận mua, trao đổi,... thì người này tiếp tục chiếm hữu không ngay tình và không bao giờ có thể xác lập được quyền sở hữu đối với tài sản.

Nếu người được chuyển nhượng không biết và không thể biết việc chiếm hữu không ngay tình của người chuyển nhượng, thì sau khi chuyển nhượng, người được chuyển nhượng sẽ trở thành người chiếm hữu ngay tình. Trong trường hợp này, quyền sở hữu đối với tài sản có thể được xác lập theo thời hiệu, được quy định tại khoản 1 Điều 255 BLDS. Nếu tài sản được chuyển nhượng trong điều kiện người chuyển nhượng không thông báo công khai, thì, khi chủ sở hữu của gia súc, gia cầm bị thất lạc xuất hiện, việc giải quyết số phận của hoa lợi được xác định tuỳ theo người được chuyển nhượng ngay tình hoặc không ngay tình: nếu ngay tình, người này không phải hoàn trả hoa lợi đã thu được cho đến ngày chấm dứt sự ngay tình; trong trường hợp không ngay tình, người này phải hoàn trả toàn bộ hoa lợi sinh ra từ khi bắt đầu chiếm hữu.

2.2.3. Vật bị chôn giấu

Theo BLDS Điều 240, "*Vật bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy mà không có hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu, thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với vật đó được xác định như sau:*

1. Vật được tìm thấy là cổ vật, là di tích lịch sử, văn hóa, thì thuộc Nhà nước, người tìm thấy vật đó được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Vật được tìm thấy không phải là di tích lịch sử, văn hoá, mà có giá trị đến mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu vật tìm thấy có giá trị lớn hơn mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc Nhà nước.

2.3. Chiếm hữu theo khoản 7 Điều 170 BLDS

2.3.1. Chiếm hữu với tư cách chủ sở hữu

Có đủ corpus và animus - Để xác lập được quyền sở hữu theo thời hiệu, người chiếm hữu tài sản phải chiếm hữu theo cung cách của một người có quyền sở hữu đối với tài sản đó, nghĩa là có đủ corpus và animus. Việc chiếm hữu phải liên tục và công khai.

2.3.2. Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình

Người tự mình chiếm đoạt tài sản của người khác không bao giờ là người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình theo nghĩa của khoản 1 Điều 247 BLDS bởi người này biết rõ hoặc buộc phải biết tài sản không thuộc sở hữu của mình, nhưng vẫn xử sự như là chủ sở hữu; không có sự ngay tình cần thiết, người này mãi mãi là người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật cũng không ngay tình và không bao giờ có quyền sở hữu đối với tài sản. Tuy nhiên, nếu người chiếm đoạt chuyển nhượng tài sản cho người khác và người được chuyển nhượng không biết và không thể biết việc chiếm đoạt, thì người được chuyển nhượng sau này lại trở thành người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình.

Luật Việt Nam hiện hành còn đang trong giai đoạn hoàn thiện khái niệm *"người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình"*. Có thể xác định được rằng người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình đối với tài sản phải hội đủ các điều kiện sau đây:

- *Thứ nhất*, phải là người nhận được tài sản từ tay một người xử sự theo cung cách của một chủ sở hữu và giao tài sản một cách tự nguyện, nghĩa là nhận được tài sản do một vụ chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng tài sản có thể được giao kết và thực hiện có đền bù (bán, trao đổi..) hoặc không có đền bù (tặng, cho, di tặng...).
- *Thứ hai*, phải ngay tình, nghĩa là *"không biết hoặc không thể biết việc chiếm hữu tài sản đó là không có căn cứ pháp luật"* (BLDS Điều 189 đoạn 2).

Luật viết cũng ghi nhận một số trường hợp đặc biệt:

Quyền sở hữu nhà nước không mất đi theo thời hiệu - Theo khoản 2 Điều 247 BLDS, người chiếm hữu tài sản thuộc sở hữu nhà nước không có căn cứ pháp luật, thì dù ngay tình, liên tục, công khai, dù thời gian chiếm hữu là bao lâu cũng không thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản đó.

3. Trường hợp người chuyển nhượng không có quyền sở hữu tài sản do giao dịch chuyển nhượng vô hiệu:

+***Tài sản có đăng ký quyền sở hữu*** - Theo khoản 2 Điều 138 BLDS *"Trong trường hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị huỷ, sửa."* Trong luật Việt Nam hiện hành, đối với tài sản thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu, thì việc chuyển nhượng chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở xuất trình các bằng chứng về việc đăng ký quyền sở hữu đó. Vậy, một người chấp nhận giao kết việc chuyển nhượng đối với một tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, trong điều kiện người chuyển nhượng không xuất trình được bằng chứng về việc đăng ký đó, thì không thể được coi là ngay tình khi chiếm hữu tài sản và không thể xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu bằng cách viện dẫn khoản 1 Điều 247 BLDS. Trong hầu hết các trường hợp chuyển nhượng đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu (mua bán, tặng cho, trao đổi,...), thì quyền sở hữu được chuyển cho người được chuyển nhượng ở thời điểm đăng ký. Như vậy, đối với các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, thì để được coi là người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, người chiếm hữu tài sản trước hết phải hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu tại cơ quan có thẩm quyền; tình trạng chiếm hữu được dùng làm cơ sở để xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu được coi như bắt đầu từ ngày đăng ký chứ không phải từ ngày tiếp nhận tài sản.

+***Tài sản là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu-***Ta có giả thiết như sau: một người được nhận một tài sản do một giao dịch dân sự. Ít lâu sau, người này chuyển nhượng tài sản cho người khác. Thời gian sau nữa, giao dịch dân sự có tác dụng chuyển giao tài sản cho người chuyển nhượng bị tuyên bố vô hiệu. Trong trường hợp này, luật nói rằng, nếu người được chuyển nhượng sau ngay tình, thì giao dịch được xác lập sau vẫn có hiệu lực, mặc dù giao dịch trước vô hiệu (BLDS Điều 138 khoản 1). Nếu giao dịch có tác dụng chuyển quyền sở hữu tài sản, thì người được chuyển nhượng sau là chủ sở hữu của tài sản do sự công nhận của luật mà không cần đợi đến mười năm hoặc ba mươi năm để xác lập

quyền sở hữu theo thời hiệu như người chiếm hữu ngay tình trong các trường hợp khác. Tuy nhiên, giải pháp này chắc chắn chỉ được áp dụng cho các vụ chuyển nhượng theo nghĩa đích thực. Nó không thể được áp dụng cho các trường hợp chuyển giao tài sản bằng con đường thừa kế bởi người thừa kế chỉ có quyền và nghĩa vụ của người để lại di sản chứ không xác lập quyền của riêng mình lên tài sản được người đó chuyển giao.

MỤC 3 - Bằng chứng về quyền sở hữu

Dẫn nhập - Vấn đề bằng chứng về quyền sở hữu không chỉ được đặt ra mỗi khi có tranh chấp. Trong trường hợp tài sản phải đăng ký quyền sở hữu và việc đăng ký được thực hiện lần đầu, thì người yêu cầu đăng ký phải chứng minh quyền sở hữu của mình đối với tài sản liên quan, trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Một khi các bằng chứng về quyền sở hữu được thiết lập đầy đủ, người đăng ký lần đầu được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản và giấy chứng nhận này trở thành bằng chứng thay thế cho các bằng chứng khác về quyền sở hữu trong thực tiễn các giao dịch. Nhưng nói chung, về quyền sở hữu hoặc quyền yêu cầu chuyển quyền sở hữu đối với tài sản phải đăng ký, cơ quan đăng ký tiếp nhận và thẩm định các loại bằng chứng trong khuôn khổ luật chung. Trong thực tiễn giao dịch có xu hướng chấp nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu như là bằng chứng tốt nhất (thậm chí duy nhất) về quyền sở hữu đối với tài sản phải đăng ký. Mỗi khi chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp các tài sản loại này, người chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp chỉ cần xuất trình giấy chứng nhận có liên quan thì việc thẩm tra tư cách chủ sở hữu coi như được thực hiện xong. Khi kiện đòi lại tài sản, người có giấy chứng nhận quyền sở hữu có thể xuất trình giấy này để chứng minh quyền sở hữu của mình đối với tài sản tranh chấp và người bị kiện, muốn giữ lại tài sản, trước hết phải thiết lập được bằng chứng phủ nhận giá trị của giấy đó. Trái lại, trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu mà người có giấy chứng nhận quyền sở hữu là bị đơn, thì giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ có tác dụng như một lá chắn, một giấy chứng nhận quyền được miễn chứng minh. Khi đó, giấy chứng nhận, suy cho cùng, chỉ là hình thức xác nhận một quyền được giả định là đã tồn tại trước đó hoặc xác nhận việc chuyển giao quyền đó.

Có những hệ thống luật (như Anh, Đức) quan niệm rằng các quyền đối với bất động sản không chỉ có giá trị đối với tất cả mọi người mà còn có tầm quan trọng lớn lao đối với nền kinh tế. Bởi vậy, các quyền này chỉ có thể xác lập nhờ có sự can thiệp của quyền lực công cộng, đặc biệt là thông qua thủ tục đăng ký. Một khi được đăng ký, quyền sở hữu tài sản được chứng minh bằng các giấy tờ xác nhận việc đăng ký và sự chứng minh đó không thể bị phủ nhận, trừ một vài trường hợp đặc biệt. Các tư tưởng của giải pháp này cũng được ảnh hưởng trong tâm lý của một bộ phận lớn dân cư ở Việt Nam (người dân luôn coi trọng việc hoàn tất thủ tục trước bạ sang tên và việc cấp *"giấy hồng", "sổ đỏ"*[104] có tác dụng thiết lập sự an toàn đối với quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của người được chuyển nhượng, người thừa kế,...). Và gần như, cả người làm luật và người áp dụng pháp luật ở Việt Nam đều muốn dựa vào định chế đăng ký bất động sản để giải quyết các tranh chấp liên quan đến loại tài sản này. Song cho đến nay các điều kiện khách quan của giải pháp, nhất là các điều kiện về chất lượng hoạt động của hệ thống kiểm soát lưu thông dân sự vẫn chưa hội đủ. Bởi vậy, luật Việt Nam vẫn chưa bao giờ chính thức thừa nhận giá trị chứng cứ không thể tranh cãi của giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu bất động sản.

Tuy nhiên, những nội dung vừa trình bày ở trên là đối với quyền sở hữu đối với các tài sản phải đăng ký. Còn quyền sở hữu các tài sản không đăng ký trong luật Việt Nam được chứng minh bằng bất kỳ phương tiện nào, bất kỳ nguồn chứng cứ nào được pháp luật thừa nhận: chiếm hữu vật chất, hoá đơn, chứng từ thanh toán, người làm chứng,... Việc thẩm định chứng cứ hoàn toàn không đơn giản. Nhưng dẫu sao, mỗi khi có tranh chấp, thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, ra quyết định ai là người được công nhận có quyền sở hữu tài sản. Cơ quan giải quyết tranh chấp không thể bác yêu cầu của cả hai bên để tài sản

[104] "Giấy hồng": giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; "sổ đỏ": giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

tranh chấp ở trong tình trạng không xác định được chủ sở hữu, cũng không thể tuyên bố cả hai đều có quyền sở hữu đối với một tài sản tranh chấp. Tuy nhiên, có thể nói rằng *khi giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu, cơ quan chức năng chỉ tìm cách xác định sự tồn tại của quyền trên cơ sở những bằng chứng thuyết phục nhất trong những bằng chứng chống lại nhau.*

1. Trách nhiệm của các bên tranh chấp về quyền sở hữu trong việc cung cấp chứng cứ

Luật Việt Nam chưa có các quy định mang tính nguyên tắc về trách nhiệm của các bên trong một vụ tranh chấp về quyền sở hữu tài sản trong việc cung cấp chứng cứ. Nói riêng về quyền tác giả, luật quyết định rằng *"Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại"* (Luật sở hữu trí tuệ 2005 Điều 49 khoản 3). Giải pháp này được thừa nhận mà không phân biệt người đăng ký bảo hộ là nguyên đơn hay bị đơn trong vụ việc tranh chấp. Thực tiễn áp dụng pháp luật cũng có xu hướng thiết lập sự suy đoán có lợi cho người đã đăng ký quyền sở hữu, mỗi khi có tranh chấp, dù luật hầu như không có quy định nào tương tự như Điều 49 khoản 3 nêu trên áp dụng cho các trường hợp tài sản phải đăng ký quyền sở hữu không phải là tác phẩm. Song, chúng ta có một nguyên tắc chung nhất được thừa nhận trên thực tế. Đó là: *một khi có tranh chấp về quyền sở hữu đối với một tài sản phải đăng ký, thì trách nhiệm chứng minh thuộc về bên tranh chấp không đăng ký.* Người có giấy chứng nhận quyền sở hữu có thể là nguyên đơn, nhưng cũng có thể là bị đơn trong vụ tranh chấp, có thể là người đang chiếm hữu vật chất và pháp lý đối với tài sản, nhưng cũng có thể đang ở trong tình trạng bị người khác chiếm đoạt tài sản. Trong trường hợp tài sản tranh chấp thuộc loại tài sản vô hình, thì thông thường, người có giấy chứng nhận là nạn nhân của một vụ vi phạm độc quyền khai thác và chủ động kiện cáo để yêu cầu bảo vệ quyền lợi của mình. Mặt khác, cũng như người có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, người chiếm hữu một tài sản không thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu chỉ có ưu thế tương đối. Nếu người tranh chấp chứng minh được rằng sự chiếm hữu của người bị tranh chấp không hoàn hảo (không liên tục, không công khai, hoặc mập mờ), thì cả hai bên tranh chấp sẽ trở nên bình đẳng trong việc chứng minh. Còn trong trường hợp tài sản tranh chấp không thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu, người đứng nguyên đơn trong vụ tranh chấp về một tài sản phải đăng ký quyền sở hữu nhưng chưa được đăng ký thường cũng là người đòi lại tài sản, còn bị đơn là người chiếm hữu. Tất cả các bên đều phải cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu của mình đối với tài sản tranh chấp và người có bằng chứng thuyết phục nhất sẽ được công nhận là chủ sở hữu.

1.1. Đối tượng chứng minh

Đối tượng chứng minh trong các tranh chấp về quyền sở hữu lẽ đương nhiên là quyền sở hữu. Người khởi kiện tranh chấp phải chứng minh rằng chính mình, chứ không phải người bị tranh chấp, mới là chủ sở hữu của tài sản.

Song, đối tượng chứng minh trong một vụ kiện về quyền thừa kế không phải là quyền sở hữu hay quyền yêu cầu chuyển quyền sở hữu mà là quyền hưởng di sản.

1.2. Phương tiện chứng minh

Luật Việt Nam không có các quy định riêng về việc thiết lập và thẩm định chứng cứ trong trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu tài sản. Người tranh chấp có thể sử dụng bất kỳ phương tiện chứng minh nào được pháp luật thừa nhận. Phương tiện chứng minh thông dụng nhất là giấy tờ. Đôi khi người tranh chấp còn viện dẫn sự chiếm hữu; nhưng trong luật hiện hành, sự chiếm hữu chỉ có giá trị chứng minh trong một vài trường hợp rất đặc biệt. Sự chiếm hữu chỉ được luật viết chính thức coi là phương tiện chứng minh quyền sở hữu, trong trường hợp việc chiếm hữu thoả mãn các điều kiện dự liệu cho việc xác lập quyền sở hữu đối với vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, hoặc cho việc xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu quy định tại khoản 1 Điều 247 BLDS. Việc chiếm hữu trong các trường hợp xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu rút ngắn được thừa nhận nhờ việc xuất trình bằng chứng về thông báo công khai (ghi nhận ngày nhặt, phát hiện, bắt được tài sản, thì việc chiếm hữu có thể coi như bắt đầu từ ngày đó). Trong các trường hợp khác, bằng chứng về sự chiếm hữu

có thể được cung cấp từ bất kỳ nguồn nào được thừa nhận trong luật chung có chứa đựng các dữ kiện cho thấy đương sự có thực hiện các giao dịch vật chất tác động lên tài sản theo cung cách của một người có quyền sở hữu tài sản: hoá đơn thanh toán tiền sửa chữa tài sản; hợp đồng gửi giữ, hợp đồng cầm cố, cho mượn tài sản; lời khai của người làm chứng;...

MỤC 4 - Các hình thức sở hữu

Đặt vấn đề - Theo chương XIII BLDS, quyền sở hữu tồn tại dưới các hình thức sau đây: sở hữu nhà nước; sở hữu tập thể; sở hữu tư nhân; sở hữu chung; sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội; sở hữu của tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Chúng ta có thể chia các hình thức sở hữu này thành hai nhóm: sở hữu có một chủ sở hữu và sở hữu có nhiều chủ sở hữu.

1. CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU CÓ MỘT CHỦ THỂ

Bao gồm sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện (gọi chung là pháp nhân không hoạt động sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận).

1.1. Sở hữu nhà nước

1.1.1. Chủ thể của sở hữu nhà nước

BLDS Điều 201 quy định "Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước". Điều luật còn quy định thêm rằng Chính phủ thống nhất quản lý và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước.

1.1.2. Tài sản thuộc sỏ hữu nhà nước

Có tài sản thuộc sở hữu nhà nước một cách tuyệt đối, nghĩa là không bao giờ có thể được chuyển nhượng để trở thành tài sản thuộc sỏ hữu của các chủ thể khác và có những tài sản thuộc sở hữu nhà nước nhưng có thể được chuyển nhượng để trở thành đối tượng của những hình thức sở hữu khác. Ta tạm gọi các tài sản thuộc nhóm thứ nhất là tài sản công của nhà nước; các tài sản thuộc nhóm thứ hai là tài sản tư của nhà nước.

- *Tài sản công của nhà nước*: tất cả các tài sản công của nhà nước đều có chung một đặc điểm: chỉ có thể được sử dụng vì lợi ích công cộng. Tài sản không thể được dùng vào việc nào khác ngoài việc phục vụ cho tất cả mọi người. Đó là: đất đai, rừng, núi, sông hồ, nguồn nước, công trình giao thông công cộng thủy, bộ, đường sắt, đường không, công trình quốc phòng, cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở cung ứng dịch vụ công cộng (Điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc, nước..), các di tích lịch sử, văn hóa thuộc khối tài sản quốc gia..
- *Tài sản tư của nhà nước*: bao gồm tất cả những gì trong khối tài sản quốc gia mà không phải là tài sản công của nhà nước. Thuộc nhóm này hầu hết là những tài sản được giao cho các cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để sử dụng: nhà làm việc, nhà xưởng, trang thiết bị, máy móc chuyên dùng, tiền vốn...

1.1.3. Sử dụng tài sản thuộc sở hữu nhà nước

Các tài sản thuộc sở hữu nhà nước phải được sử dụng có hiệu quả và phù hợp với lợi ích của toàn xã hội. Việc sử dụng tài sản thuộc sỏ hữu nhà nước rất đa dạng. Một số tài sản được dành cho tất cả mọi người để sử dụng chung một cách trực tiếp: sông, hồ lưu thông tự do, đường bộ... bất kỳ ai cũng có quyền sử dụng các tài sản này với điều kiện tôn trọng các quy tắc hành chính và quyền sử dụng của người khác. Có những tài sản được giao cho cơ quan cung ứng dịch vụ công cộng để khai thác nhằm phục vụ cho tất cả mọi người: đường sắt được cơ quan quản lý đường sắt sử dụng để chuyên chở hành khách, hàng hóa; mạng lưới điện quốc gia được giao cho tổng công ty điện lực để cung ứng điện cho nhân dân. Những tài sản giao cho doanh nghiệp Nhà nước khai thác nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và làm gia tăng tích lũy thuộc sở hữu nhà nước. Cũng có tài sản được

giao cho các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (bảo tàng, bảo tồn, thư viện...) để phục vụ cho các sinh hoạt tinh thần hoặc đáp ứng nhu cầu tích lũy kiến thức, vui chơi giải trí của người dân.

1.1.4. Quản lý Nhà nước đối với tài sản thuộc sở hữu nhà nước

Tài sản thuộc sở hữu nhà nước được đặt dưới sự quản lý thống nhất của Chính phủ. Tài sản thuộc sở hữu nhà nước được giao cho các cơ quan Nhà nước, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp để sử dụng. Nhà nước thực hiện quyền kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng tài sản đó (BLDS Điều 204 khoản 1, Điều 205 khoản 1).

Đối với các tài sản thuộc sở hữu nhà nước được đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước, thì Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (BLDS Điều 203 khoản 1).

1.1.5. Bảo vệ sở hữu nhà nước

Các tài sản công thuộc sở hữu nhà nước không thể được chuyển nhượng và không thể bị kê biên. Có một số tài sản tư thuộc sở hữu nhà nước có thể được chuyển nhượng dưới sự kiểm soát và giám sát của cơ quan tài chính nhưng trên nguyên tắc không thể bị kê biên. Và trong bất kỳ trường hợp nào, tài sản thuộc sở hữu nhà nước không thể là đối tượng của quyền sở hữu được xác lập theo thời hiệu (BLDS Điều 247 khoản 2).

1.2. Sở hữu tập thể.

Nhóm chủ thể của sở hữu tập thể bao gồm các hợp tác xã và các tổ chức kinh tế tập thể có tư cách pháp nhân. Các tài sản thuộc sở hữu tập thể được hình thành từ nguồn đóng góp của các thành viên, thu nhập hợp pháp do sản xuất, kinh doanh, được Nhà nước hỗ trợ hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật (BLDS Điều 208 và 209).

"Việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản thuộc sở hữu tập thể phải tuân theo pháp luật, phù hợp với điều lệ của tập thể đó, bảo đảm sự phát triển ổn định của sở hữu tập thể" (BLDS Điều 210 khoản 1). Sở hữu tập thể đặt cơ sở cho việc tương trợ giữa những người lao động trong lao động sản xuất, kinh doanh. Bởi vậy, *"tài sản thuộc sở hữu tập thể được giao cho các thành viên khai thác công dụng bằng sức lao động của mình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế chung và lợi ích, nhu cầu của các thành viên"* (Điều 210 khoản 2).*"Thành viên của tập thể có quyền được ưu tiên mua, thuê, thuê khoán tài sản thuộc sở hữu tập thể "* (Điều 210 khoản 3).

1.3. Sở hữu của các pháp nhân không hoạt động sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận

1.3.1. Tài sản

Tài sản thuộc sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội - là những tài sản được hình thành từ nguồn đóng góp của các thành viên, các tặng cho chung cũng như từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật (BLDS Điều 228). Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội có thể được Nhà nước chuyển giao quyền sở hữu đối với một số tài sản cần thiết cho hoạt động của tổ chức đó (Điều 228 khoản 1)

Tài sản thuộc sở hữu của các tổ chức chính trị- xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp là tài sản được hình thành từ nguồn đóng góp của các thành viên, tài sản được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với những quy định của pháp luật và phù hợp với mục đích hoạt đông của tổ chức đó được quy định trong điều lệ.(Điều 231 BLDS).

1.3.2. Thực hiện quyền sở hữu

Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị- xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của mình theo quy định của pháp luật và phù hợp với mục đích hoạt động của tổ chức đó được quy định trong điều lệ (BLDS Điều 229 và 232).

2. SỞ HỮU CHUNG

2.1. Sở hữu chung hỗn hợp

Thông thường, chủ thể của sở hữu hỗn hợp là một pháp nhân được thành lập theo ý chí của các thành viên góp vốn để sản xuất, kinh doanh thu lợi nhuận. Cũng có trường hợp các thành viên góp vốn tạo một ngân quỹ chung nhằm thực hiện một hoặc một loạt các hoạt động sản xuất, kinh doanh mà không thành lập một pháp nhân độc lập để quản lý ngân quỹ đó. Các thành viên góp vốn vẫn là chủ thể đầy đủ của quyền sở hữu hỗn hợp và chịu trách nhiệm trước người thứ ba không chỉ bằng tài sản thuộc sở hữu hỗn hợp mà còn cả bằng tài sản riêng của mình một cách vô hạn. Sở hữu hỗn hợp trong trường hợp này là một hình thức sở hữu chung theo phần đặc biệt, tồn tại nhằm phục vụ cho việc đạt tới một mục đích kinh tế chung nào đó của các chủ thể của quyền sở hữu chung.

"Các tài sản thuộc sở hữu hỗn hợp được hình thành từ vốn góp của các thành viên, lợi nhuận hợp pháp do sản xuất, kinh doanh hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật" (BLDS Điều 218 khoản 2).*"Việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản thuộc sở hữu hỗn hợp phải tuân theo các quy định về sở hữu chung và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc góp vốn, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, điều hành, trách nhiệm về tài sản và phân chia lợi nhuận"* (BLDS Điều 218 khoản 3).

2.2. Sở hữu của hộ gia đình, tổ hợp tác

2.2.1. Chủ thể

Hộ gia đình, tổ hợp tác không phải là những pháp nhân. Suy cho cùng hộ gia đình, tổ hợp tác chỉ là những khái niệm của luật về nhân thân, dùng để chỉ một nhóm người gắn bó với nhau do quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc quan hệ bè bạn, thầy trò và lao động trong cùng một ngành, nghề, một lĩnh vực hoặc cùng có quyền sử dụng đối với đất được giao trong tình trạng không phân chia. (Điều 106, Điều 111 BLDS)

2.2.1.1. Thành viên của hộ gia đình

Hộ gia đình theo Điều 106 BLDS tức là một đơn vị kinh tế, chứ không phải là tập hợp những người được ghi tên trong sổ hộ khẩu. Tất cả các thành viên hộ gia đình đều là thành viên của gia đình; nhưng không phải thành viên nào của gia đình cũng là thành viên của hộ gia đình. Có trường hợp thành viên của gia đình chưa thành niên và chưa tham gia lao động cùng với các thành viên khác trong hoạt động kinh tế chung của hộ gia đình. Những người này vẫn là chủ thể của các quyền của một thành viên đối

với các tài sản của hộ gia đình[105], nhưng với điều kiện phải tham gia lao động cùng với các

[105] Ở đây, "các tài sản của hộ gia đình" được hiểu như một tập hợp tài sản có và tài sản nợ, một sản nghiệp, chứ

thành viên khác một khi có khả năng và có điều kiện để lao động. Cũng có những trường hợp thành viên của gia đình đã thành niên, nhưng hoạt động trong một lĩnh vực kinh tế, nghề nghiệp khác với lĩnh vực kinh tế, nghề nghiệp của hộ gia đình. Những người này cũng trở thành người có quyền của một thành viên đối với các tài sản thuộc hộ gia đình, một khi trở về tham gia vào hoạt động kinh tế chung của hộ. Các điều kiện
nêu trên được gọi là những *"điều kiện treo"*[106] để một người có quyền của một thành viên đối với khối tài sản thuộc hộ gia đình. Ta có thể chia thành viên của hộ gia đình thành hai nhóm:

- *Thành viên đầy đủ*: là thành viên của gia đình và đang tham gia vào hoạt động kinh tế chung của hộ;
- *Thành viên có điều kiện*: là thành viên của gia đình nhưng chưa tham gia vào hoạt động kinh tế chung của hộ.

2.2.1.2. Thành viên của tổ hợp tác

Khác với hộ gia đình, tổ hợp tác xây dựng lực lượng thành viên của mình thông qua quan hệ hợp đồng chứ không phải quan hệ gia đình. Ta có hai loại thành viên tổ hợp tác: thành viên tham gia sáng lập và thành viên được nhận vào.

2.2.2. Tài sản

2.2.2.1. Tài sản có của hộ gia đình, tổ hợp tác

Tài sản của hộ gia đình - gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộ gia đình, tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung, được thừa kế chung và các tài sản khác mà các thành viên thoả thuận là tài sản chung của hộ (BLDS Điều 108). Các tài sản này đều có chung một đặc điểm: đó là phương tiện thực hiện hoạt động kinh tế chung của hộ.

Tài sản của tổ hợp tác - là *"tài sản do các tổ viên đóng góp, cùng tạo lập hoặc được tặng cho chung"* (BLDS Điều 114 khoản 1).

2.2.2.2. Tài sản nợ của hộ gia đình, tổ hợp tác

Nợ chung của hộ gia đình - là những khoản nợ thỏa mãn hai điều kiện: 1 - Chủ thể xác lập nghĩa vụ là chủ hộ gia đình hoặc là người được chủ hộ uỷ quyền hợp lệ; 2 - Nghĩa vụ phải được xác lập trong khuôn khổ hoạt động kinh tế chung của hộ gia đình và vì lợi ích chung của hộ.

Nợ chung của tổ hợp tác - là những khoản nợ thỏa mãn ba điều kiện: 1 - Chủ thể xác lập nghĩa vụ phải là tổ trưởng hoặc người được tổ trưởng uỷ quyền hợp lệ; 2 - Nghĩa vụ phải được xác lập phù hợp với mục đích hoạt động của tổ hợp tác; 3 - Việc xác lập nghĩa vụ phải được sự chấp thuận của đa số tổ viên[107]; nếu nghĩa vụ được xác lập do hiệu lực của một giao dịch định đoạt có đối tượng là tư liệu sản xuất của tổ, thì phải có sự chấp thuận của tất cả các tổ viên.

Các chủ nợ chung của hộ gia đình (tổ hợp tác) có quyền yêu cầu kê biên và bán tài sản của hộ gia đình (tổ hợp tác) để thu hồi nợ (BLDS Điều 110 khoản 2, Điều 117 khoản 2). Trong trường hợp tài sản chung không đủ để thanh toán nợ, thì các thành viên của hộ gia đình trả nợ của hộ bằng tài sản riêng theo nguyên tắc liên đới (BLDS Điều 110 khoản 2); các thành viên của tổ hợp tác trả nợ bằng tài sản riêng theo nguyên tắc liên đới theo phần tương ứng với phần đóng góp bằng tài sản của mình (Điều 117 khoản 2).

---

không phải là các yếu tố cụ thể của tập hợp đó.

[106] condition suspensive

[107] Vậy trước khi giao kết nghĩa vụ với người đại diện tổ hợp tác, người cùng giao kết phải yêu cầu người đại diện xuất trình bằng chứng về sự chấp thuận này (biên bản họp, nghị quyết đại hội tổ viên,...). Cần nhấn mạnh rằng người đại diện phải có được sự chấp thuận của đa số tổ viên tổ hợp tác chứ không phải của đa số tổ viên dự họp.

Nợ riêng của thành viên hộ gia đình (tổ hợp tác) - Các nghĩa vụ do người đại diện hợp pháp của hộ gia đình (tổ hợp tác) xác lập, một cách trực tiếp hoặc thông qua người được uỷ quyền, mà không có đủ các điều kiện trên đây, là nợ riêng của người đó. Cũng như vậy, một khi nghĩa vụ do một thành viên hộ gia đình (tổ viên tổ hợp tác) xác lập ngoài khuôn khổ hợp đồng uỷ quyền giao kết với chủ hộ (tổ trưởng tổ hợp tác) nhằm thực hiện các chức năng của hộ gia đình (hay vì mục đích hoạt động của tổ hợp tác) cũng được xem là nợ riêng của thành viên đó. Chủ nợ riêng của thành viên không có quyền yêu cầu kê biên và bán tài sản chung của hộ gia đình (tổ hợp tác), cũng không có quyền yêu cầu phân chia tài sản chung của hộ gia đình (tổ hợp tác) để nhận tiền thanh toán theo khoản 2 Điều 224 BLDS. Đặc biệt, chủ nợ của thành viên tổ hợp tác cũng không có quyền yêu cầu kê biên phần quyền sở hữu của tổ viên trong tài sản chung, bởi phần quyền này chỉ tồn tại ở thời điểm thanh toán phần tài sản của tổ viên đóng góp vào tổ.

Quyền của thành viên hộ gia đình (tổ hợp tác) - Luật không có quy định về quyền của các *thành viên hộ gia đình* đối với tài sản chung của hộ. Nói chung, thành viên hộ gia đình tham gia vào đời sống pháp lý của hộ theo các quy tắc được thiết lập trong tục lệ chứ không phải trong luật. Chắc chắn, thành viên không có quyền chuyển nhượng các tài sản thuộc sở hữu của hộ gia đình thông qua các giao dịch xác lập nhân danh cá nhân mình. Thành viên có quyền hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản, có quyền giám sát công việc của chủ hộ và có quyền có ý kiến trong các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh tế chung của hộ, trong việc xác lập các giao dịch quan trọng liên quan đến tài sản của hộ. Tuy nhiên, các quyền này được thực hiện trên cơ sở tôn trọng các chuẩn mực đạo đức và trong khuôn khổ tôn ti trật tự gia đình và ngược lại trách nhiệm vật chất của thành viên đối với hộ gia đình được quy kết và thực hiện chủ yếu bằng con đường dàn xếp nội bộ chứ không phải bằng con đường tư pháp. *Tổ viên tổ hợp tác* được hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ hoạt động của tổ hợp tác theo thoả thuận và được tham gia quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động của tổ, cũng như được thực hiện việc kiểm tra hoạt động của tổ (BLDS Điều 116). Trong trường hợp gây thiệt hại do lỗi của mình, tổ viên có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (Điều 115 khoản 2). Tổ viên tổ hợp tác không có quyền chuyển nhượng các tài sản mình đã đóng góp vào tổ, cũng như phần tài sản của mình (phần đóng góp của tổ viên) trong khối tài sản chung.

2.3. Sở hữu chung của cộng đồng

Theo định nghĩa của luật viết hiện hành, *"Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, làng, bản, cộng đồng tôn giáo và các cộng đồng dân cư đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thoả mãn lợi ích chung hợp pháp của cả cộng đồng."* (BLDS Điều 220 khoản 1)

Chủ thể của sở hữu cộng đồng - có thể là một pháp nhân, nhưng thông thường chỉ là những nhóm thực tế (*groupement de fait*) hình thành từ việc liên kết những người có quan hệ huyết thống, có chung một tín ngưỡng dân gian hoặc cư trú trên cùng một địa bàn và có sự quan tâm chung đối với cùng một hoặc nhiều vấn đề tâm linh, lịch sử, văn hoá,..., thậm chí những vấn đề của đời sống vật chất hàng ngày.

Tài sản thuộc sở hữu cộng đồng - thường là bất động sản.

Thực hiện quyền sở hữu - Theo BLDS Điều 220 khoản 2, các thành viên của cộng đồng cùng quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung theo thoả thuận hoặc theo tập quán, vì lợi ích của cộng đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. Việc quản lý tài sản cộng đồng được giao cho một thành viên do cộng đồng chỉ định phù hợp với tập quán và với các quy ước được mặc nhiên chấp nhận trong cộng đồng. Người quản lý thực hiện công việc của mình dưới sự giám sát của cộng đồng và hầu như không thể bị thay thế cho đến khi chết, trừ trường hợp có sai sót nghiêm trọng trong việc quản lý gây thiệt hại cho cộng đồng.

Về mặt lý thuyết tài sản thuộc sở hữu cộng đồng có thể được chuyển nhượng; có thể dùng

làm vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và, do đó, có thể bị kê biên. Tuy nhiên, cho đến nay, việc kê biên tài sản thuộc sở hữu chung của cộng đồng còn chưa được ghi nhận trong thực tiễn áp dụng pháp luật.

2.4. Sở hữu chung của vợ chồng[108]

Chủ thể của sở hữu chung của vợ chồng lẽ dĩ nhiên là vợ và chồng trong một quan hệ hôn nhân hợp pháp.

Tài sản - Khối tài sản chung của vợ và chồng được hình thành từ các tài sản do vợ hoặc chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, các tài sản mà vợ, chồng được thừa kế chung và những tài sản mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung(Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, Điều 27).

Thực hiện quyền sở hữu - Vợ, chồng có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung (BLDS Điều 219 khoản 2). Việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch dân sự liên quan đến tài sản có giá trị lớn là nguồn sống duy nhất của gia đình, việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh phải được vợ chồng bàn bạc, thỏa thuận (Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Điều 28). Vợ, chồng có thể uỷ quyền cho nhau để thực hiện các quyền của chủ sở hữu đối với tài sản chung (BLDS Điều 219 khoản 3).

2.5. Sở hữu nhà chung cư

Dẫn nhập - Vào thời kỳ chiến tranh cũng như trong những năm đầu thống nhất đất nước, ở miền Bắc, chung cư được biết đến với tên gọi "khu tập thể" là nơi cư trú của những người làm việc cùng một cơ quan hoặc ít ra có cùng nghề nghiệp. Dưới cơ chế bao cấp, việc sử dụng nhà ở tập thể hoàn toàn không mất tiền.trong cơ chế mới, các khu tập thể vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng người cư trú phải trả tiền như những người thuê nhà ở. Các chung cư theo nghĩa đích thực xuất hiện đầu tiên ở các đô thị miền Nam trong thời kỳ chiến tranh. Đó coi như là giải pháp tối ưu cho các bài toán về nhà ở cho các tầng lớp người lao động có thu nhập cố định và tương đối thấp. Cho đến năm 1975, loại hình sở hữu này tồn tại một cách tự phát, luật viết không có quy định đối với nó. Cùng với việc xác lập và hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường, khu tập thể được chuyển dần thành khu nhà ở tư nhân thông qua chính sách hoá giá. Bên cạnh đó, các tổ chức kinh tế trong nước và tổ chức kinh tế thành lập theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được Nhà nước cho thuê đất để kinh doanh địa ốc, cũng tiến hành xây dựng các chung cư mới rồi phân thành các căn hộ và bán rộng rãi cho tư nhân. Tại các đô thị lớn (như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) đã xuất hiện các chung cư cao cấp gồm những căn hộ được trang bị tiện nghi nội thất hiện đại, được bán cho những người có điều kiện và nhu cầu mua.

Luật nhà ở 2005 Điều 70 khoản 1 quy định nhà chung cư có phần sở hữu riêng của từng hộ gia đình, cá nhân và phần sở hữu chung của tất cả các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà chung cư. Như vậy, người có quyền sở hữu đối với nhà chung cư ở trong một tình trạng pháp lý rất đặc biệt: có quyền sở hữu tư nhân theo đúng nghĩa của luật chung đối với căn hộ của mình, nhưng chỉ có quyền sử dụng chung cùng với tất cả những người khác trong chung cư, đối với mái nhà, cầu thang, sân chơi, nơi để xe,... Các quy tắc liên quan đến quyền sở hữu chung theo phần không đủ để điều chỉnh các quan hệ sở hữu đối với loại tài sản này (sở hữu chung theo phần luôn có thể chấm dứt do hiệu lực của việc phân chia tài sản chung; trong khi các phần chung của chung cư được duy trì bắt buộc chừng nào chung cư còn tồn tại). Các quy tắc của sở hữu tư nhân theo nghĩa thông thường - sở hữu của một người - cũng không thể được coi là cơ sở pháp lý duy nhất của hình thức sở hữu này (một bất động sản tư nhân biệt lập tồn tại tự thân; trong khi một tầng lầu hoặc một phần của tầng lầu tạo thành căn hộ không thể tồn tại như một tài sản mà không có các phần chung của chung cư).

2.5.1. Cấu tạo của căn hộ chung cư

[108] Nội dung này sẽ được nghiên cứu trong phần "Chế độ tài sản của vợ chồng" của chương trình Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam

Căn hộ chung cư thường được ghi nhận theo nghĩa hẹp, tức là gồm tất cả những gì tồn tại bên trong bốn bức tường chung phân ranh căn hộ với các căn hộ lân cận hoặc với hành lang, không gian bên ngoài: vách bảo hộ tường chung, phần che trần, lót sàn nhà, vách ngăn phòng nội bộ, công trình phụ riêng của căn hộ, ban công... Ta gọi tất cả những yếu tố này là các phần riêng của căn hộ chung cư[109]. Ngoài ra, chủ sở hữu còn có quyền đối với các phần được dùng để phục vụ cho tất cả mọi người thuộc cùng một chung cư. Các phần này - tạm gọi là phần chung - rất đa dạng, bao gồm quyền sử dụng đất, sân, vườn chung, lối đi chung, mái nhà chung, cầu thang, thang máy, hành lang, nơi đổ rác, nơi để xe, mạng điện chung, đường ống nước chung, cống rãnh, antenne chung, nhà kho chung,... [110]Theo BLDS Điều 225 khoản 1, các phần chung trong chung cư thuộc sở hữu chung của tất cả chủ sở hữu các căn hộ trong nhà đó và không thể phân chia, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có sự thỏa thuận của tất cả các chủ sở hữu. Có thể nói, các phần chung trong chung cư thuộc sở hữu chung theo phần không thể phân chia.

2.5.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu chung

Các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu một căn hộ chung cư đối với phần chung được quy định khá đơn giản trong luật viết.

2.5.2.1. Quyền của chủ sở hữu chung

2.5.2.1.1. Quyền chiếm hữu và sử dụng

Trên nguyên tắc, chủ sở hữu căn hộ chung cư có quyền chiếm hữu và sử dụng căn hộ riêng của mình (theo nghĩa hẹp) như một chủ thể đầy đủ của quyền sở hữu tư nhân: ở, bảo quản, cho thuê,... Tuy nhiên, do đặc điểm tài sản, chủ sở hữu không thể làm tất cả mọi việc theo ý mình trong một số trường hợp nhất định. Có trường hợp kết cấu của các căn hộ trong cùng một chung cư không giống nhau để phục vụ cho những mục đích khác nhau. Khi đó, mỗi chủ sở hữu căn hộ sử dụng tài sản theo cung cách phù hợp với các đặc điểm của tài sản: căn hộ này chỉ có thể được dùng để ở; trong khi căn hộ khác chỉ có thể được dùng làm văn phòng giao dịch thương mại. Nhiều chung cư còn đặt ra các quy định nội bộ về hạn chế gây tiếng ồn trong những giờ nhất định, về sử dụng các thiết bị chung, về xử lý chất thải sinh hoạt,... Chủ sở hữu có quyền sửa chữa, cải tạo, nâng cấp căn hộ của mình trong chừng mực kết cấu chung của chung cư cho phép và nhất là không được gây thiệt hại cho các chủ sở hữu khác trong chung cư.

2.5.2.1.2. Quyền định đoạt

Chủ sở hữu căn hộ chung cư có quyền thế chấp, chuyển nhượng căn hộ theo ý mình và có quyền để lại căn hộ của mình cho người thừa kế. "Căn hộ" ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, tức là bao gồm phần riêng và các quyền đối với phần chung. Người được chuyển nhượng, người thừa kế, đến lượt mình, lại có quyền sở hữu đối với phần riêng và có các quyền của một chủ sở hữu căn hộ chung cư đối với các phần chung.

2.5.2.2. Nghĩa vụ của các chủ sở hữu chung

Khái niệm - Nghĩa vụ của chủ sở hữu chung là phần đóng góp vật chất mà chủ sở hữu một căn hộ chung cư có trách nhiệm thực hiện nhằm bảo quản, sửa chữa, nâng cấp hoặc thay thế

---

[109] Luật nhà ở 2005 Điều 70 khoản 2 quy định phần sở hữu riêng trong nhà chung cư bao gồm : phần diện tích bên trong căn hộ, bao gồm cả diện tích ban công, lôgia gắn liền với căn hộ đó ; phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng theo quy định pháp luật ; hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ, phần diện tích thuộc sở hữu riêng.

[110] Luật nhà ở 2005 Điều 70 khoản 3 quy định phần sở hữu chung trong nhà chung cư bao gồm : phần diện tích nhà còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng (quy định tại khoản 2 của cùng điều luật) ; không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà chung cư, gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, nơi để xe, hệ thống cấp điện, nước, ga, thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hỏa và các phần khác không thuộc sở hữu riêng của căn hộ nào ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng được kết nối với nhà chung cư đó.

các phần chung của chung cư. Có thể phân nghĩa vụ của chủ sở hữu chung thành hai nhóm: 1 - Các nghĩa vụ liên quan đến các dịch vụ hạ tầng: điện, nước, thang máy,... 2 - Các nghĩa vụ liên quan đến việc bảo quản, sửa chữa, quản trị các phần chung: sửa chữa cầu thang, hàng lang, đường cống; tu bổ mái nhà chung;...

Thực hiện nghĩa vụ - Theo Điều 225 khoản 2 BLDS, các chủ sở hữu căn hộ chung cư có nghĩa vụ ngang nhau trong việc quản lý và sử dụng phần diện tích và thiết bị chung. Hiếm có trường hợp chủ sở hữu chung cư vi phạm nhóm nghĩa vụ thứ hai bởi thông thường, trước khi tiến hành các công trình liên quan đến chung cư, cơ quan quản lý chung cư huy động sự đóng góp của các chủ sở hữu chung theo mức thoả thuận và chỉ khi nào các đóng góp đã được thực hiện hoặc được bảo đảm thực hiện đầy đủ, thì việc sửa chữa mới được bắt đầu. Riêng đối với các nghĩa vụ thuộc nhóm thứ nhất, việc thanh toán thường được thực hiện hàng tháng; nợ tồn đọng - nếu có thông thường không lớn và không làm phát sinh kiện cáo trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tính chất của quyền của chủ sở hữu chung - Ta đã nói rằng quyền sở hữu đối với nhà chung cư không phải là một trường hợp cá biệt của sở hữu chung hay của sở hữu riêng. Đó cũng không phải là quyền sở hữu kép gồm có sở hữu riêng đối với phần riêng và sở hữu chung đối với các phần chung. Nói cách khác, không phải quyền sở hữu đối với nhà chung cư mang tính chất kép, mà đúng ra bản thân chung cư, với tư cách là một tài sản, là một thực thể kép: một mặt: chung cư là một khối tài sản thống nhất; mặt khác, chung cư là một tập hợp có tổ chức hình thành từ các căn hộ. Quyền sở hữu đối với khối chung cư thống nhất do tập thể các chủ sở hữu căn hộ chung cư thực

hiện thông qua vai trò của Ban quản trị nhà chung cư[111]; còn đối với căn hộ chung cư (hiểu theo nghĩa rộng), thì cá nhân chủ sở hữu là người duy nhất có tư cách để thực hiện các quyền của chủ sở hữu.

2.6. Sở hữu chung theo phần

Khái niệm - Theo BLDS Điều 216 khoản 1, sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung. Các nguyên nhân làm hình thành sở hữu chung theo phần khá đa dạng như hai người cùng mua một tài sản; một người bán hoặc tặng cho một người khác một phần quyền sở hữu tài sản của mình; nhiều người cùng thừa kế một di sản; một công ty đã giải thể và tài sản công ty đang chờ được phân chia giữa các thành viên;... Ở nước ta, sở hữu chung theo phần đối với di sản chưa chia là hình thức sở hữu chung rất phổ biến, có ý nghĩa rất lớn về kinh tế và đạo đức.

2.6.1. Thành phần cấu tạo của khối tài sản thuộc sở hữu chung theo phần

Khối tài sản thuộc sở hữu chung theo phần bao gồm tài sản có chung và tài sản nợ chung của tất cả các chủ sở hữu chung.

2.6.1.1. Tài sản có

Khối tài sản có thuộc sở hữu chung theo phần không bất biến, cũng không khép kín. Thế nhưng không giống như khối tài sản chung của vợ, chồng (gia tăng nhờ các tài sản do vợ hoặc chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân), khối sở hữu chung theo phần không thể sáp nhập các tài sản mà một chủ sở hữu chung tạo ra trong thời kỳ tồn tại của sở hữu chung; mà đó là tài sản riêng của người này. Vấn đề được đặt ra ở đây là khi tài sản thuộc sở hữu chung được chuyển nhượng hoặc có hoa lợi, lợi tức phát sinh thì giá trị chuyển nhượng cũng như phần hoa lợi, lợi tức đó sẽ được xác định chủ sở hữu như thế nào.

2.6.1.1.1. Chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu chung

Vấn đề sẽ không có gì bàn cãi khi số tiền thu được từ việc chuyển nhượng được chia cho các chủ sở hữu, khi đó sở hữu chung theo phần sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, nếu số tiền này không

[111] Ban quản trị nhà chung cư là người đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu và những người sử dụng trong quá trình sử dụng nhà chung cư (Xem Luật nhà ở 2005 Điều 71 và 72).

được chia cho các chủ sở hữu chung mà dùng để mua một tài sản khác thì vấn đề trở nên phức tạp hơn. Ta có thể đặt giả thiết thành nhiều trường hợp:

□□ Trường hợp thứ nhất: ***việc mua tài sản được thực hiện bởi tất cả các chủ sở hữu chung hoặc bởi một chủ sở hữu chung hành động với tư cách người được uỷ quyền của cộng đồng các chủ sở hữu chung theo phần*** - Rõ ràng tài sản mua được trong trường hợp này sẽ là của chung. Vấn đề đặt ra là tài sản đó là đối tượng của một quan hệ sở hữu chung theo phần độc lập hay chỉ thế chỗ cho số tiền chuyển nhượng trong tập hợp các tài sản vốn đã thuộc sở hữu chung theo phần của những người chuyển nhượng ? Vấn đề này có thể được lý giải theo hai cách:

- *Cách thứ nhất* - Ta thừa nhận rằng các chủ sở hữu chung theo phần đã tiến hành phân chia số tiền chuyển nhượng tài sản, ngay sau đó góp lại phần của mỗi người để mua tài sản mới. Vậy, tài sản mua được là đối tượng của một quan hệ sở hữu chung theo phần mới được xác lập. Nếu khối sở hữu chung theo phần trước đây vẫn còn tài sản, thì khối sở hữu chung theo phần mới được xác lập tồn tại độc lập với khối sở hữu chung theo phần sẵn có.
- *Cách thứ hai* - Ta nói rằng các chủ sở hữu chung theo phần không phân chia số tiền chuyển nhượng tài sản, mà đã nhất trí dùng số tiền đó để mua một tài sản khác. Vậy, nên xem việc mua tài sản là hình thức thay thế một tài sản chung này bằng một tài sản chung khác; không có sự thành lập một khối sở hữu chung mới, mà trước sau chỉ có một khối sở hữu chung với thành phần cấu tạo có thay đổi.

□□ Trường hợp thứ hai: ***việc mua tài sản chỉ được thực hiện bởi một chủ sở hữu chung mà không có uỷ quyền của những người đồng sở hữu chung khác*** - Nếu những người có quyền sở hữu chung đồng ý để cho người mua giao kết và thực hiện việc mua tài sản, thì tài sản mua, đối với cộng đồng các chủ sở hữu chung theo phần, là tài sản chung; cũng như vậy, một khi những người có quyền sở hữu chung theo phần không đồng ý, nhưng không phản đối, và người mua tự coi mình như người được uỷ quyền mặc nhiên (hoặc người thực hiện công việc mà không có uỷ quyền) của cộng đồng các chủ sở hữu chung theo phần, để mua tài sản.

□□ Trường hợp thứ ba: **tài sản mua thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu -** Ý nghĩa của việc đăng ký quyền sở hữu tài sản chưa được xác định rõ trong luật thực định Việt Nam, tuy nhiên có thể ghi nhận xu hướng rõ nét của luật (và cả của thực tiễn) luôn coi việc đăng ký như là phương tiện thiết lập các bằng chứng không thể tranh cãi về quyền sở hữu đối với tài sản liên quan. Trước khi luật chính thức thừa nhận rằng người đăng ký quyền sở hữu tài sản là người duy nhất có quyền sở hữu đối với tài sản đó, trong khung cảnh hiện tại của thực tiễn áp dụng pháp luật, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu và thuộc sở hữu chung theo phần vẫn còn có thể được đăng ký theo tên người đại diện.
□□ Trường hợp thứ tư: **mua bán hàng hoá thuộc sản nghiệp thương mại** - Hàng hoá thuộc sản nghiệp thương mại được mua và bán theo chế độ riêng được xây dựng trong khuôn khổ pháp luật thương mại.

2.6.1.1.2. Hoa lợi, lợi tức của tài sản chung –

Theo BLDS Điều 222 khoản 1, mỗi chủ sở hữu chung theo phần hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Ta có thể hiểu điều luật đó theo một trong hai nghĩa. *Một là,* hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung tạo thành một khối tài sản thuộc sở hữu chung theo phần, độc lập với khối sở hữu chung theo phần gồm có các tài sản gốc, và sẽ được chia cho các chủ sở hữu chung theo phần theo đúng các tỷ lệ phần quyền sở hữu của mỗi người trong khối tài sản gốc chung. *Hai là,* hoa lợi, lợi tức sẽ được chia ngay sau khi thu hoạch cho các chủ sở hữu chung theo phần theo tỷ lệ phần quyền của mỗi người trong khối tài sản chung. Dù hiểu điều luật vừa dẫn theo nghĩa nào, thì rõ ràng hoa lợi, lợi tức chưa thu hoạch vẫn là một phần không tách rời của tài sản gốc và, do đó, là một bộ phận của khối sở hữu chung theo phần. Nếu toàn bộ khối tài sản thuộc sở hữu chung theo phần được đem chia trong lúc hoa lợi, lợi tức chưa được thu hoạch, thì phần hoa lợi, lợi tức ấy nằm trong khối tài sản chia. Quy tắc này có ý nghĩa rất quan trọng về lý luận cũng như thực tiễn.
Trên nguyên tắc, các chủ sở hữu theo phần cùng nhau quản lý và sử dụng tài sản chung. Tuy nhiên, pháp luật không cấm các chủ sở hữu chung đạt được một thoả thuận về việc phân chia quyền sử dụng đối với tài sản chung. Người sử dụng và khai thác một tài sản chung có thể hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản mà không phải chia sẻ quyền thụ hưởng đó với các chủ sở hữu chung khác, nhưng phải có sự thoả thuận rành mạch giữa các chủ sở hữu chung về việc đó. Mặc dù luật viết chưa có điều luật nào chính thức thừa nhận về khoản thù lao của người chủ sở hữu chung quản lý tài sản chung nhưng chúng ta có thể rút ra được nhận xét này gián tiếp qua việc phân tích quy nạp một số điều luật có liên quan. Như vậy, nếu có thu hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung do mình quản lý, thì người người chủ sở hữu chung đang quản lý tài sản chung chỉ phải trả cho khối sở hữu chung (hoặc cho những người cùng có quyền sở hữu chung khác) phần hoa lợi, lợi tức sau khi trừ đi khoản thù lao mà mình được hưởng.
Chắc chắn rằng, các chủ sở hữu chung theo phần phải được hưởng hoặc phải cùng nhau gánh chịu hệ quả của sự gia tăng hoặc giảm sút giá trị của tài sản chung do nguyên nhân khách quan. Nếu do nguyên nhân chủ quan, thì có thể xảy ra nhiều trường hợp. Nếu do lỗi của mình mà tài sản chung bị giảm sút giá trị, thì chủ sở hữu chung có lỗi phải chịu trách nhiệm dân sự theo luật chung. Nếu sự gia tăng giá trị của tài sản là do hệ quả của việc chủ

sở hữu chung thực hiện hành vi sáp nhập một vật phụû, thì tài sản mới tiếp tục thuộc về cộng đồng các chủ sở hữu chung theo phần (BLDS Điều 236 khoản 1) nhưng nếu tài sản đem sáp nhập không thể được xác định đó là vật chính hay vật phụ và việc sáp nhập có sự đồng ý của cộng đồng các chủ sở hữu chung, thì tài sản mới vẫn thuộc sở hữu chung theo phần, song tỷ lệ phần quyền của mỗi chủ sở hữu chung sẽ thay đổi.

2.6.1.2. Tài sản nợ

Nợ riêng của chủ sở hữu chung - Theo BLDS Điều 224 khoản 2, trong trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán khi người đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung để nhận tiền thanh toán và được tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Chủ nợ riêng của một chủ sở hữu chung, trong quá trình tiến hành thủ tục cưỡng chế người mắc nợ thực hiện nghĩa vụ trả nợ không có quyền yêu cầu kê biên tài sản mà người mắc nợ có quyền sở hữu chung cùng với người khác. Trong điều kiện người mắc nợ không còn tài sản riêng, chủ nợ muốn được trả nợ bằng tài sản chung của người mắc nợ chỉ có thể chọn một trong hai cách: yêu cầu phân chia tài sản chung hoặc yêu cầu bán phần quyền sở hữu của người mắc nợ trong tài sản chung.

Nợ chung của chủ sở hữu chung - Các chủ nợ chung của tất cả các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu kê biên và bán tài sản chung để thu hồi nợ mà không cần yêu cầu phân chia tài sản chung. Nợ chung của chủ sở hữu chung là nợ ràng buộc tất cả các chủ sở hữu chung, có tính chất liên đới hoặc không liên đới gắn liền với việc quản lý, khai thác tài sản hoặc từ các nguồn gốc khác.

2.6.2. Quản lý tài sản thuộc sở hữu chung theo phần

Như đã nói ở trên, sở hữu chung theo phần đối với di sản chưa chia là hình thức sở hữu chung rất phổ biến trong thực tiễn đời sống ở nước ta. Việc quản lý di sản thuộc sở hữu chung cần phải tuân thủ một số nguyên tắc do luật định cũng như tôn trọng nội dung thỏa thuận của các chủ sở hữu chung của di sản đó.

2.6.2.1. Các nguyên tắc do luật định

Nguyên tắc nhất trí - Theo BLDS Điều 221, các chủ sở hữu chung cùng quản lý tài sản chung theo nguyên tắc nhất trí, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Tuy nhiên, nguyên tắc này sẽ bị loại bỏ trong một số trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích cộng đồng, lợi ích chung của các chủ sở hữu (chẳng hạn như: kiện đòi chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối với việc thực hiện quyền sở hữu, quyền chiếm hữu hợp pháp; bán tài sản dễ hư hỏng; sửa chữa tài sản theo định kỳ; khắc phục sự cố...). Các chủ sở hữu chung không nhất thiết tự mình quản lý tài sản chung. Họ có thể uỷ quyền cho một chủ sở hữu chung (thậm chí một người thứ ba) để quản lý và sử dụng tài sản hoặc để xác lập một giao dịch nào đó liên quan đến tài sản.

Nguyên tắc sử dụng chung - Sử dụng chung một tài sản không thể được hiểu theo nghĩa đen mà có thể hình dung như sau: một chủ sở hữu chung sử dụng tài sản thuộc sở hữu chung và một chủ sở hữu chung khác cũng sử dụng tài sản chung đó. Cả hai người này đều không có độc quyền hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung do mình sử dụng và khai thác. Hoa lợi, lợi tức đó, sau khi trừ giá trị công sức lao động của người sử dụng sẽ thuộc về tất cả các chủ sở hữu chung và trong trường hợp không được tích luỹ, thì hoa lợi, lợi tức đó được phân bổ cho các chủ sở hữu theo tỷ lệ phần quyền của mỗi người trong khối tài sản chung.

Nguyên tắc tự do hợp tan - Theo BLDS Điều 224 khoản 1, trong trường hợp sở hữu chung có thể phân chia, thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung. Điều luật được áp dụng chung cho sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất. Sở hữu chung theo phần, trên nguyên tắc, có thể phân chia. Tuy nhiên, ta cũng có một số trường hợp sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia như sở hữu của cộng đồng, sở hữu của hộ gia đình... Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung theo phần không thể phân chia về mặt vật chất, thì việc phân chia vẫn có thể được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng về giá trị. Nếu các chủ sở hữu chung theo phần có thoả thuận về việc duy trì sở hữu chung trong một thời gian hoặc nếu việc phân chia tài sản chung bị cấm thực hiện trong một thời gian theo ý chí của người chuyển giao tài sản cho các chủ sở hữu chung, thì sở hữu chung có thể phân chia sau khi hết thời hạn đó.

2.6.2.2. Quản lý tài sản chung theo thỏa thuận

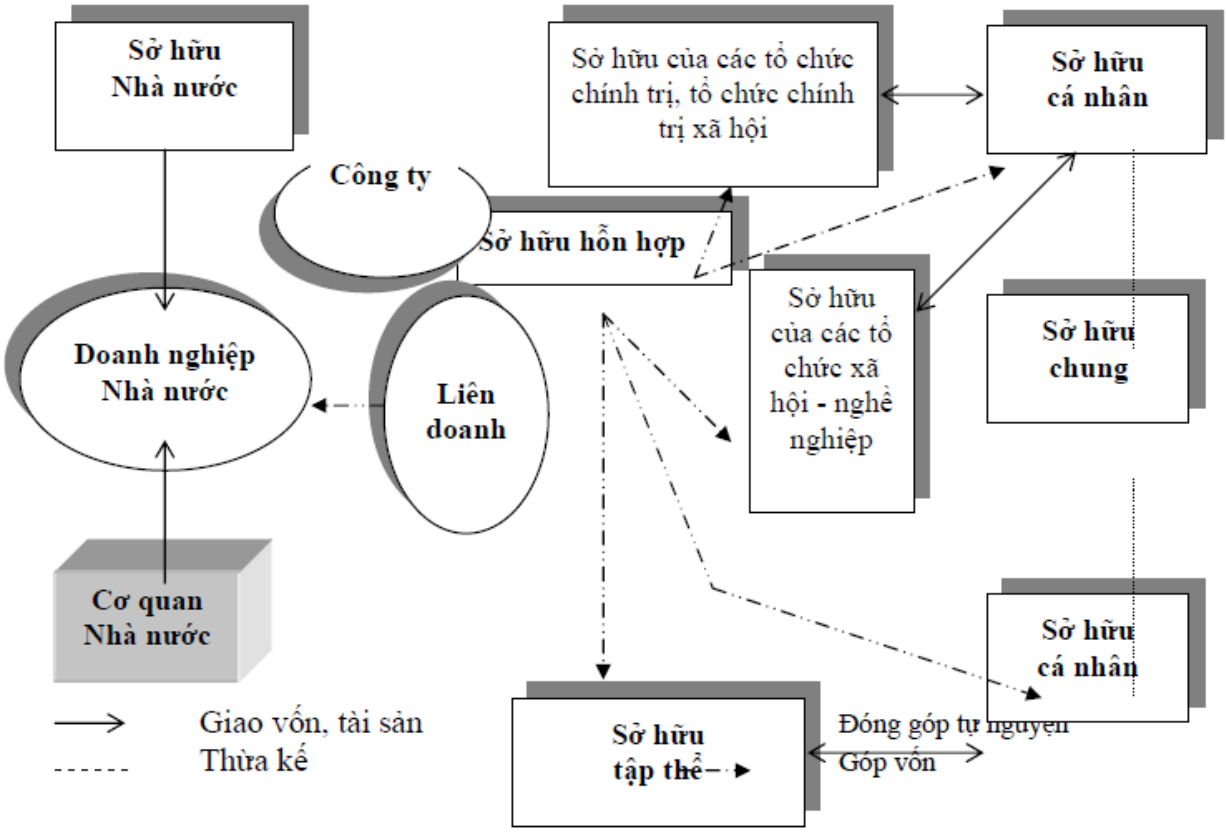
Theo BLDS Điều 681 khoản 2, mọi thoả thuận của những người thừa kế đều phải lập thành văn bản. Như vậy, sự thoả thuận giữa những người có quyền sở hữu chung theo phần về việc quản lý một khối di sản chưa chia phải được lập thành văn bản. Các chủ sở hữu chung có thể thoả thuận về việc loại bỏ nguyên tắc nhất trí trong việc quản lý tài sản chung. Các chủ sở hữu chung cũng có thể thoả thuận về việc cử một hoặc nhiều người đứng ra quản lý khối tài sản chung. Quyền hạn của người quản lý có thể được pháp luật xác định một phần, như trong trường hợp quản lý chính thức di sản chưa chia, nhưng thông thường do cộng đồng các chủ sở hữu chung ấn định. Người quản lý được hưởng quy chế của người được uỷ quyền, đặc biệt là được hưởng thù lao do công việc quản lý của mình.

2.6.2.3. Quyền của chủ sở hữu chung đối với phần tài sản của mình

Định đoạt - Theo BLDS Điều 223 khoản 1, mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Một cách tổng quát, chủ sở hữu chung có quyền chuyển giao phần quyền sở hữu của mình trong tài sản chung cho người khác, có hoặc không có đền bù. Việc chuyển giao có thể có đối tượng là một phần hoặc toàn bộ phần quyền sở hữu đó. Nếu chủ sở hữu chung bán phần quyền của mình trong tài sản chung, thì các chủ sở hữu chung khác có quyền ưu tiên mua.

Là một tài sản theo nghĩa đầy đủ, phần quyền sở hữu trong một hoặc một khối tài sản chung có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ như bao nhiêu tài sản khác.

Phù hợp với tính đa dạng về sở hữu của nền kinh tế thị trường, BLDS đã đưa ra sự phân loại các loại hình sở hữu và những quy định phù hợp với tính chất đặc thù của mỗi loại sở hữu. Các quy định của BLDS về các hình thức sở hữu và cơ sở xác lập chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sở hữu trong các doanh nghiệp liên doanh, công ty, kể cả công ty đối nhân hay công ty đối vốn. Sự vận động của các hình thức sở hữu theo BLDS đáp ứng sự đòi hỏi của nền kinh tế thị trường có thể được mô hình hóa theo sơ đồ sau:



MỤC 5 - Các hạn chế đối với việc thực hiện quyền sở hữu

Dẫn nhập - Chủ sở hữu được tự do khai thác và được độc quyền khai thác tài sản của mình. Quy tắc này thực ra chỉ được áp dụng trọn vẹn đối với một số động sản. Nói riêng lĩnh vực bất động sản, chính việc áp dụng quy tắc vừa nêu lại dẫn đến việc hạn chế áp dụng nó: mỗi người được tự do khai thác bất động sản của mình và mỗi người phải tôn trọng việc tự do khai thác bất động sản của người khác. Bất động sản và sự lân cận (láng giềng) là những khái niệm gắn liền với nhau. Quyền khai thác bất động sản luôn được đặt ra cho những người láng giềng như trong việc thoát nước sinh hoạt, nước mưa; lối đi chung; mở cửa sổ trông sang nhà bên; đục tường nhà chung để đặt kết cấu xây dựng; để cành cây, rễ cây phát triển sang phần đất giáp ranh;... Quyền tự do khai thác bất động sản, ở góc độ tư pháp, được định nghĩa thông qua việc xác định các quyền và

nghĩa vụ của chủ sở hữu trong quan hệ láng giềng.Thế nhưng, lân cận hay láng giềng, với tư cách là những thuật ngữ của pháp luật về tài sản, được ghi nhận trước hết như những thuật ngữ gắn liền với những ý niệm về sự giới hạn hay nói khác đi đó chính là những ranh giới bất động sản vẫn thường gặp trong thực tế đời sống của người dân, nhất là người Việt nam.

1. RANH GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

1.1. Cọc mốc

Chủ sở hữu bất động sản có quyền dựng cọc mốc để xác định ranh giới bất động sản của mình trước người thứ ba, nhất là trước chủ sở hữu bất động sản liền kề. Tuy nhiên, chủ sở hữu bất động sản liền kề chỉ được dựng cột mốc trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình nếu việc dựng cột mốc là ý kiến của một bên (BLDS Điều 266 khoản 1). Trong trường hợp này, cọc mốc thuộc quyền sở hữu riêng của người dựng. Nếu cọc mốc do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý, thì mốc giới ngăn cách đó là của chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thoả thuận khác (Điều 266 khoản 1 đoạn 2). Những người sử dụng đất liền kề cũng có thể thoả thuận với nhau về việc dựng cọc mốc trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản (Điều 266 khoản 1 đoạn 1) và cả về chi phí dựng cọc mốc đó; trong trường hợp này, cọc mốc thuộc sở hữu chung của những người đó (cùng điều luật).

1.2. Hàng rào, hào, rãnh, kênh, mương, bờ bao

Hàng rào, hào, rãnh, kênh, mương, bờ bao không chỉ có tác dụng xác định ranh giới bất động sản, bao bọc bất động sản, mà còn là hình thức phân lập bất động sản, nhằm khẳng định nguyên tắc mỗi người có quyền sở hữu. Đối với tài sản của mình phân biệt với các bất động sản thuộc về những người khác nằm ngoài phạm vi hàng rào, hào, rãnh, kênh, mương, bờ bao đó. Quyền dựng hàng rào, bờ bao hoặc đào hào, rãnh, kênh, mương là một quyền năng không tuyệt đối: *một mặt*, người xây dựng phải tôn trọng những giới hạn do pháp luật quy định về quy hoạch đô thị, thẩm mỹ chung ... và các quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề của người láng giềng, nhất là quyền sử dụng lối đi qua, quyền có tầm nhìn, quyền cấp, thoát nước, tưới nước, tiêu nước; *mặt khác*, người xây dựng không được phép lạm dụng quyền xây dựng của mình, gây thiệt hại cho người khác. Hàng rào, hào, rãnh, kênh mương, bờ bao có thể thuộc quyền sở hữu riêng của một người, nhưng cũng có thể là của chung của các chủ sở hữu bất động sản liền kề. Các tài sản này chịu sự chi phối của cùng một chế độ pháp lý áp dụng đối với vách tường ngăn cách các bất động sản.

1.3. Vách tường ngăn cách các bất động sản

Vách tường ngăn cách các bất động sản, một khi thuộc sở hữu riêng của một người, sẽ do người đó bảo quản bằng chi phí của riêng mình; người sử dụng nhờ vách tường của người khác không phải trả các chi phí đó. Đổi lại, người có vách tường riêng có trọn quyền sở hữu đối với vách tường đó, trong chừng mực tôn trọng các quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và quyền sử dụng hạn chế của người láng giềng đối với bất động sản liền kề.

1.3.1. Xác lập quyền sở hữu chung

- ***Theo thoả thuận*** - Thông thường các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thoả thuận về việc xây dựng vách tường chung bằng chi phí do các bên đóng góp. Cũng có trường hợp vách tường do một bên xây dựng, sau đó lại được chuyển nhượng một phần cho bên lận cận khi bên này xây dựng nhà của mình hoặc một bên sử dụng nhờ vách tường của bên kia trong một thời gian rồi được bên kia chuyển nhượng một phần quyền đối với vách tường đó...
- ***Theo khoản 1 Điều 266 BLDS*** - Khi chủ sở hữu bất động sản liền kề xây dựng một vách tường ngăn cách bất động sản của mình với bất động sản lân cận bằng chi phí của mình, trên ranh giới giữa hai bất động sản và đã được chủ sở hữu bất động sản lân cận đồng ý thì vách tường được xây dựng trong trường hợp này thuộc sở hữu chung của hai bên. Tất nhiên, hai bên có thể thoả thuận về việc cùng bỏ tiền để xây dựng vách tường; nhưng nếu không có thoả thuận gì đặc biệt, thì chủ sở hữu bất động sản lân cận đương nhiên có quyền sở hữu chung đối với vách tường ngăn, dù có thể đã không góp chi phí xây dựng vách ngăn đó.
- ***Theo thời hiệu*** - Theo BLDS Điều 247 khoản 1, người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn ba mươi năm đối với bất động sản, thì trở thành chủ sở hữu của bất động sản đó kể từ ngày chiếm hữu. Điều luật này cũng được áp dụng để xác lập quyền sở hữu chung đối với vách tường ngăn cách hai bất động sản lân cận.

1.3.2. Tính chất pháp lý của quyền sở hữu chung

Sở hữu chung theo phần không thể phân chia - Đây không phải là một quyền sở hữu riêng kép (nếu hiểu rằng mỗi chủ sở hữu bất động sản liền kề đều có quyền sở hữu trọn vẹn đối với một nửa vách quay mặt về phía nhà của mình). Đây cũng không phải là quyền sở hữu chung theo phần thông thường (bởi sở hữu chung theo phần thông thường luôn có thể chấm dứt do hiệu lực của việc phân chia tài sản chung). Cuối cùng, đây không phải là sở hữu chung hợp nhất, bởi: *một là*, phần quyền (tương ứng với phần nghĩa vụ) của mỗi chủ sở hữu chung có thể được xác định về số lượng; *hai là*, mỗi chủ sở hữu chung có thể chuyển nhượng phần quyền sở hữu của mình đối với vách tường chung (như khi bán nhà) mà không cần có sự ưng thuận của chủ sở hữu chung còn lại. Có thể nhận thấy những nét tương đồng rất cơ bản giữa quyền sở hữu vách tường chung và quyền sở hữu các phần chung trong nhà chung cư. Ta gọi đây là *sở hữu chung theo phần không thể phân chia.*

1.3.3. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu chung

Quyền sử dụng - Luật viết hiện hành không có quy định chi tiết về quyền sử dụng của chủ sở hữu chung đối với vách tường chung, ngoài quy định về việc cấm trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu bất động sản liền kề (BLDS Điều 266 khoản 2). Thông thường, theo tập quán, chủ sở hữu chung có quyền sử dụng riêng đối với mặt vách tường chung phía bên mình, với điều kiện việc sử dụng không ảnh hưởng một cách không bình thường đến chất liệu và tuổi thọ của tài sản chung.

Nghĩa vụ bảo quản, sửa chữa, xây dựng lại - Chủ sở hữu chung có nghĩa vụ bảo quản, sửa chữa, xây dựng lại vách tường chung tương ứng với phần quyền của mình. Đây là nghĩa vụ gắn liền với quyền sở hữu chung về tài sản; bởi vậy, nếu quyền sở hữu đối với bất động sản liền kề được chuyển cho người khác, thì chủ sở hữu mới tiếp nhận các nghĩa vụ này một cách đương nhiên. Và trong trường hợp nếu một bên đã thực hiện trọn công việc bằng chi phí của mình, thì có quyền yêu cầu bên kia hoàn lại cho mình phần đóng góp của họ, như một chủ nợ không có bảo đảm.

1.4. Xây dựng, trồng cây, mở lỗ thông khí, khe sáng và tầm nhìn

1.4.1. Xây dựng

Theo BLDS Điều 267 khoản 1, khi xây dựng công trình, chủ sở hữu công trình phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây dựng vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản liền kề và chung quanh. Đây là các quy phạm mang tính nguyên tắc.

Khi có nguy cơ xảy ra sự cố đối với công trình xây dựng, ảnh hưởng đến bất động sản liền kề và xung quanh, thì chủ sở hữu công trình phải cho ngừng ngay việc xây dựng, sửa chữa hoặc dỡ bỏ theo yêu cầu của chủ sở hữu các bất động sản liền kề và xung quanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; nếu gây thiệt hại, thì phải bồi thường (BLDS Điều 267 khoản 2). Khi xây dựng công trình vệ sinh, kho chứa hoá chất độc hại và các công trình khác mà việc sử dụng có khả năng gây ô nhiễm môi trường, chủ sở hữu phải xây cách mốc giới một khoảng cách và ở vị trí hợp lý, phải bảo đảm vệ sinh, an toàn và không làm ảnh hưởng đến chủ sở hữu liền kề và xung quanh (BLDS Điều 267 khoản 3). Khi đào giếng, đào ao hoặc xây dựng các công trình xây dựng liền kề, chủ sở hữu công trình phải thi công cách mốc giới một khoảng cách do pháp luật về xây dựng quy định (Điều 268); trong trường hợp công trình có nguy cơ đe doạ sự an toàn của bất động sản liền kề và xung quanh, thì chủ công trình phải thực hiện ngay các biện pháp khắc phục; nếu gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh thì phải bồi thường (Điều 268).

1.4.2. Trồng cây

Theo BLDS Điều 265 khoản 2 đoạn 2, người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Trong trường hợp việc dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn không đúng luật, hoặc khi cây cối, công trình xây dựng có nguy cơ sập đổ, luật viết luôn xác định rằng nghĩa vụ sửa chữa, dỡ bỏ, phá dỡ công trình xây dựng không đúng luật hoặc có nguy cơ sập đổ, cũng như nghĩa vụ chặt bỏ cây cối trong những hoàn cảnh tương tự, là nghĩa vụ của chủ sở hữu (BLDS Điều 266 khoản 1 đoạn 2; Điều 272 đoạn 1).

1.4.3. Lỗ thông khí, khe sáng

Lỗ thông khí là khoảng trống trên vách tường để thông thoáng phần bên trong vật kiến trúc. Khe sáng là khoảng trống trên vách tường để ánh sáng tự nhiên đi vào bên trong vật kiến trúc dụng thông thoáng. Luật hiện hành có quy định liên quan đến lỗ thông khí tại BLDS Điều 266 khoản 2, nhưng chưa có quy định về khe sáng. Có thể dựa vào nguyên tắc áp dụng tương tự pháp luật để đặt các khe sáng dưới cùng một chế độ pháp lý như đối với lỗ thông khí.

1.4.4. Tầm nhìn

Tầm nhìn là một khái niệm được xây dựng nhằm đặt cơ sở cho các quy tắc liên quan đến quyền của chủ sở hữu một bất động sản được nhìn ra bên ngoài, đặc biệt là được nhìn sang bất động sản của người láng giềng. Các phương tiện thông dụng ở Việt Nam bao gồm cửa sổ và balcon.

Luật hiện hành có một số quy định về việc trổ cửa sổ: chủ sở hữu bất động sản không được trổ cửa sổ trên vách tường chung, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý (BLDS Điều 266 khoản 2 đoạn đầu); chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và lối đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng (Điều 271 khoản 1); mái che trên cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5m trở lên (Điều 271 khoản 2). Trong khung cảnh của luật thực định, các cửa sổ chỉ cần được trổ theo đúng các quy định về xây dựng và nhất là bảo đảm được yêu cầu sử dụng an toàn. Luật không dự liệu một giới hạn nào đối với quyền khai thác tầm nhìn từ cửa sổ của chủ sở hữu bất động sản và ngược lại, cũng không đòi hỏi chủ sở hữu bất động sản liền kề phải tôn trọng quyền này bằng cách tránh thực hiện các công trình xây dựng có tác dụng che chắn hoặc hạn chế tầm nhìn đó. Luật chưa có quy định liên quan đến các balcon.

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LÁNG GIỀNG

Dẫn nhập - Có một số trường hợp do địa thế tự nhiên của một bất động sản mà chủ sở hữu phải chịu những bất tiện, phiền phức do việc chủ sở hữu bất động sản liền kề phải nhờ đến bất động sản của chủ sở hữu để thực hiện quyền sở hữu của họ đối với bất động sản liền kề. Cũng có khi luật chủ động áp đặt cho chủ sở hữu nghĩa vụ cho phép người láng giềng được sử dụng bất động sản của chủ sở hữu để thực hiện quyền sở hữu đối với bất động sản của người láng giềng. Các quyền và nghĩa vụ láng giềng, dù phát sinh do địa thế tự nhiên của bất động sản, do quy định của pháp luật hoặc do sự tác động của con người, đều là những quyền và nghĩa vụ gắn liền với bất động sản mà đương sự có quyền sở hữu chứ không phải với quyền nhân thân của đương sự

2.1. Các quyền và nghĩa vụ láng giềng phát sinh do địa thế tự nhiên của bất động sản hoặc do quy định của luật

2.1.1. Quyền, nghĩa vụ của láng giềng trong việc thoát nước mưa và nước thải

Theo BLDS Điều 269, chủ sở hữu nhà phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho nước mưa từ mái nhà của mình không được chảy xuống bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề. Điều 270 BLDS quy định chủ sở hữu nhà phải làm cống ngầm hoặc rãnh thoát nước để đưa nước thải ra nơi quy định, sao cho nước thải không chảy tràn sang bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề, ra đường công cộng hoặc nơi công cộng làm ô nhiễm môi trường.

2.1.2. Sử dụng hạn chế bất động sản liền kề

Sẽ không có vấn đề gì đặc biệt khi bất động sản tiếp xúc với đường công cộng, thiết bị công cộng (chủ sở hữu có thể đặt ngay ở đó một cổng ra vào, thiết bị kết nối và dùng cổng, thiết bị này làm cửa ngõ giao tiếp với cộng đồng). Thế nhưng, trong trường hợp bên kia ranh giới của một bất động sản tư nhân chỉ có các bất động sản tư nhân khác (hoặc các bất động sản thuộc sở hữu nhà nước). Luật gọi đó là *bất động sản bị vây bọc* (BLDS Điều 275). Luật viết khẳng định ngay rằng bất động sản trong trường hợp này vẫn phải được thông thương với cộng đồng và trong điều kiện bất động sản không liên hệ trực tiếp với hệ thống giao thông công cộng, thiết bị công cộng, việc thông thương của chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc vẫn được bảo đảm bằng quyền được sử dụng hạn chế lối đi qua bất động sản khác (có đền bù hoặc không có đền bù tùy theo thỏa thuận).

Trong quan hệ láng giềng cổ điển, ta có lối đi qua bất động sản liền kề theo nghĩa hẹp: đó là một con đường được vạch ra trên bất động sản liền kề, dùng cho người và súc vật đi lại. Theo nghĩa rộng lối đi qua bất động sản liền kề được hình dung như tất cả các loại hình thông thương cần thiết cho việc khai thác công dụng của bất động sản bị vây bọc như: lối đi; cấp, thoát nước; cấp khí ga; đường dây tải điện; thông tin liên lạc; các nhu cầu thông thương cần thiết khác...(BLDS Điều 273) Ta gọi chung các quyền khai thác các loại hình thông thương

này là *quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề.*

2.1.2.1. Điều kiện xác lập quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề do luật định

- *Bất động sản phải bị vây bọc* - Nghĩa là bất động sản đó không có lối đi ra đường công cộng, không có điểm trên ranh giới của bất động sản tiếp xúc trực tiếp được với các thiết bị công cộng hoặc có nhưng không sử dụng được. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp này nhưng chủ sở hữu đã được quyền về lối đi qua, quyền sử dụng nhờ thiết bị theo thoả thuận với một chủ sở hữu bất động sản liền kề[112] thì khi đó bất động sản không thể bị coi là bị vây bọc để xác lập quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề theo luật cho chủ sở hữu[113]. Ngoài ra, cũng không thể xác lập quyền sử dụng bất động sản trong một số trường hợp chỉ là *sự vây bọc giả tạo hoặc vây bọc không hoàn hảo*[114].

2.1.2.2. Thực hiện quyền quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề do luật định

2.1.2.2.1. Lựa chọn bất động sản để xây dựng lối thông thương theo thoả thuận hoặc bằng con đường tư pháp

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề của chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc tồn tại một cách đương nhiên do hiệu lực của luật. Tuy nhiên, để thực hiện được quyền này, chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc phải đạt được một thoả thuận với một chủ sở hữu bất động sản liền kề. Đó không phải là thoả thuận để tạo ra quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề mà là thoả thuận về các thể thức thực hiện một quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề đã sẵn có (được luật thừa nhận). Luật quy định rằng lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi (BLDS Điều 275 khoản 1 đoạn 2). Một khi chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý cho chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc xây dựng lối đi chung trên bất động sản của mình, thì các đương sự còn cần phải thoả thuận tiếp về vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi chung (BLDS Điều 275 khoản 2), và nhất là về mức đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề có lối đi chung đó. Nếu không đạt được sự thoả thuận cần thiết, thì chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc có quyền khởi kiện trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có được quyết định phân xử hợp lý (BLDS Điều 275 khoản 2).[115]

2.1.2.2.2. Trường hợp bất động sản bị vây bọc do hệ quả của sự phân chia

Có trường hợp bất động sản vốn không bị vây bọc, nhưng sau khi phân chia (do hiệu lực của một vụ mua bán từng phần, trao đổi, phân chia tài sản thuộc sở hữu chung theo phần,...), thì lại có một bất động sản hoàn chỉnh mới hình thành ở trong tình trạng bị vây bọc. Luật quy định rằng lối đi qua trong trường hợp này phải được xây dựng trên các phần bất động sản khác thuộc khối bất động sản bị phân chia (BLDS Điều 275 khoản 3).

2.1.3. Chấm dứt quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề do luật định

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề sẽ chấm dứt, một khi điều kiện tồn tại của nó không còn được thoả mãn. Điều 279 BLDS liệt kê hai trường hợp chấm dứt quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề, không phân biệt quyền sử dụng hạn chế được xác lập theo thoả thuận hay theo quy định của pháp luật: *1 - Bất động sản liền kề với bất động sản của chủ sở hữu đang thực hiện quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề đó nhập làm một; 2 - Chủ sở*

---

[112] do một giao dịch một bên hoặc đã sử dụng lối đi qua, thiết bị của một bất động sản liền kề trong khuôn khổ một hệ thống phục vụ được thiết lập từ lâu và đã dẫn đến việc xác lập quyền và nghĩa vụ láng giềng theo thời hiệu).

[113] Trong trường hợp quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề đã được xác lập cho chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất thì người được chuyển giao nhà, quyền sử dụng đất cũng được hưởng quyền đó (BLDS Điều 274 khoản 2).

[114] Xem Nghiên cứu về tài sản trong Luật Dân sự Việt Nam - TS Nguyễn Ngọc Điện trang 360

[115] Cần lưu ý rằng trong khung cảnh của luật thực định Việt Nam, việc mở lối đi qua có thể được thực hiện cả trên bất động sản thuộc sở hữu nhà nước

hữu nhà, người sử dụng đất không còn nhu cầu sử dụng hạn chế bất động sản liền kề. .

2.2. Quyền và nghĩa vụ láng giềng phát sinh do sự tác động của con người

Đặt vấn đề - Luật chỉ chủ động dự liệu các quyền và nghĩa vụ láng giềng trong những trường hợp cần thiết khi dung hoà giữa các lợi ích đối lập, nhằm duy trì trật tự xã hội. Trong quá trình khai thác công dụng của một bất động sản, chủ sở hữu có thể có nhu cầu riêng về việc thiết lập một hệ thống phục vụ trên một bất động sản thuộc về một người khác. Chẳng hạn như khi bất động sản không bị vây bọc, nhưng nếu mở được lối đi qua bất động sản liền kề, chủ sở hữu sẽ có được con đường đi ra đường công cộng ngắn hơn nhiều so với con đường đi qua điểm tiếp xúc trực tiếp giữa bất động sản của mình và đường công cộng; hoặc trường hợp chủ sở hữu có hai bất động sản bị chia cắt bởi một bất động sản thứ ba thuộc về người khác và nếu mở được một lối đi qua bất động sản nằm giữa, thì chủ sở hữu sẽ có thể đi lại giữa hai bất động sản của mình bằng con đường ngắn nhất mà không phải đi lòng vòng qua các đường công cộng;... Các lối đi qua trong những trường hợp vừa nêu không thể được thiết lập do hiệu lực của luật, mà chỉ có thể là kết quả của các giao dịch, tức là kết quả của sự tác động của con người.

2.2.1. Các điều kiện và căn cứ xác lập quyền và nghĩa vụ láng giềng phát sinh do sự tác động của con người.

2.2.1.1. Điều kiện liên quan đến bất động sản

- *Phải là bất động sản hữu hình và tự nhiên* - Cụ thể là đất và nhà. Có thể khẳng định rằng không có các quyền và nghĩa vụ láng giềng với các bất động sản vô hình hoặc bất động sản do công dụng.

- *Hai bất động sản thuộc về hai chủ sở hữu khác nhau* - Nếu hai bất động sản thuộc về một người và để khai thác công dụng của một bất động sản, chủ sở hữu sử dụng bất động sản còn lại, thì việc sử dụng đó được coi như một phương thức quản lý tài sản của chính chủ sở hữu. Nếu hai bất động sản thuộc về một người, nhưng một được chủ sở hữu trực tiếp chiếm hữu còn bất động sản còn lại được cho thuê và người thuê được chủ sở hữu cho phép sử dụng hạn chế bất động sản của người cho thuê để khai thác công dụng của bất động sản thuê, thì việc sử dụng hạn chế đó được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng cho thuê chứ không phải dựa trên chế định quyền và nghĩa vụ láng giềng đang nghiên cứu. Nếu hai bất động sản được chiếm hữu bởi hai người thuê, thì mối quan hệ láng giềng giữa hai người thuê là mối quan hệ thuần tuý nhân thân, không gắn liền với tài sản thuê và nhất là không chuyển giao được cho người thuê tiếp theo (hoặc khi hết thời hạn thuê và tài sản thuê được trả lại cho chủ sở hữu.

2.2.1.2. Căn cứ xác lập

2.2.1.2.1. Do thỏa thuận

Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thoả thuận về việc một chủ sở hữu được quyền sử dụng hạn chế bất động sản của một chủ sở hữu khác để bảo đảm các nhu cầu của mình về lối đi; cấp thoát nước; đường dây tải điện, điện thoại, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác (BLDS Điều 273 và 274). Các chủ sở hữu bất động sản liền kề cũng có thể đạt tới những thoả thuận nhằm làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ láng giềng khác không được liệt kê trong luật viết như không xây nhà vượt quá một độ cao cho phép; không được gây tiếng ồn, xả khói... Thoả thuận này có thể được lập thành văn bản, các bằng chứng liên quan được thiết lập trong khuôn khổ luật chung về chứng cứ.

2.2.1.2.2. Di chúc

Trong một số trường hợp, chủ sở hữu bất động sản có thể lập di chúc ghi nhận việc cho phép chủ sở hữu bất động sản liền kề sử dụng hạn chế bất động sản của mình và xác lập các nghĩa vụ láng giềng nào đó gắn liền với bất động sản của mình vì lợi ích của chủ sở hữu bất động sản liền kề. Thông thường trên thực tế trường hợp này xảy ra khi láng giềng có quan hệ thân thuộc, họ hàng.

2.2.1.2.3. Tách rời các bất động sản thuộc về cùng một chủ sở hữu

Khi hai bất động sản liền kề thuộc về cùng một chủ sở hữu, trong đó một bất động sản được lắp đặt các thiết bị dùng để khai thác công dụng của bất động sản còn lại và nếu chủ sở hữu tách một bất động sản bán cho người khác, thì các quyền và nghĩa vụ láng giềng sẽ phát sinh (người mua bất động sản sẽ được hưởng quyền hoặc sẽ phải có nghĩa vụ đối với chủ sở hữu bất động sản liền kề trong mối quan hệ giữa hai bất động sản). Một cách tổng quát, nếu vì lý do nào đó mà hai bất động sản nói trong giả thuyết được tách ra thành các bất động sản độc lập thuộc về các chủ sở hữu khác nhau, thì quyền và nghĩa vụ láng giềng sẽ được xác lập (những quyền và nghĩa vụ tương ứng sẽ tồn tại gắn liền với các bất động sản liên quan và sẽ được chuyển giao khi quyền sở hữu bất động sản được chuyển giao).

2.2.1.2.4. Thời hiệu

Với tính chất là các quyền đối vật, các quyền và nghĩa vụ láng giềng có thể được chiếm hữu và có thể được xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu. Nghĩa là, được coi như các quyền bất động sản, quyền và nghĩa vụ láng giềng được xác lập cho người chiếm hữu ngay tình, liên tục, công khai trong thời gian từ ba mươi năm trở lên. Đây là giải pháp mang tính nguyên tắc và trước mắt chỉ mới được ghi nhận về mặt lý thuyết. Để áp dụng được giải pháp này, cần có thêm các quy tắc chi tiết đặt cơ sở cho việc xác định tình trạng chiếm hữu, đặc biệt các các quy tắc phân biệt giữa việc chiếm hữu thực sự của chủ sở hữu bất động sản dẫn đến việc áp dụng thời hiệu hưởng quyền, với tình trạng sử dụng mặc nhiên được chủ sở hữu bất động sản liền kề chấp nhận nhưng không thể đặt cơ sở cho việc áp dụng thời hiệu hưởng quyền...

2.2.2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ láng giềng phát sinh do sự tác động của con người

2.2.2.1. Điều kiện thực hiện

Các điều kiện của việc thực hiện quyền và nghĩa vụ láng giềng được xác định tuỳ theo đặc điểm của quyền và nghĩa vụ đó. Chẳng hạn như quyền về lối đi chung (theo nghĩa hẹp) đòi hỏi lối đi chung này phải ở vị trí hợp lý với chiều rộng, chiều dài, chiều cao, cấu tạo thích hợp của bất động sản; quyền thoát nước thải được thực hiện trên cơ sở có đường cống, rãnh dẫn nước có quy cách phù hợp với yêu cầu của các bên và được đặt ở vị trí thích hợp;...Nói chung, các điều kiện vật chất cần thiết cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ láng giềng phải được xác định một cách chặt chẽ và chính xác để tránh những tranh chấp đáng tiếc có thể phát sinh.

Quyền và nghĩa vụ láng giềng phát sinh từ sự tác động của con người phải được thực hiện trong những điều kiện vật chất ổn định. Không giống như chủ sở hữu bất động sản bị vây

bọc, chủ sở hữu bất động sản có quyền về lối đi qua bất động sản liền kề do sự tác động của con người không đương nhiên có quyền sửa đổi lối đi qua cho phù hợp với công dụng của bất động sản của mình. Bởi vậy, mỗi khi muốn sửa đổi vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi qua, người có quyền về lối đi qua do sự tác động của con người nhất thiết phải đạt được sự thoả thuận với chủ sở hữu bất động sản liền kề. Trong trường hợp việc thực hiện quyền và nghĩa vụ láng giềng không được tôn trọng thì người có quyền có thể yêu cầu được bảo vệ trong khuôn khổ pháp luật bảo vệ quyền sở hữu, nếu có thiệt hại xảy ra thì có thể yêu cầu được bồi thường.

2.2.3. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ láng giềng phát sinh do sự tác động của con người

Cũng như đối với quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề do luật định, luật hiện hành (BLDS Điều 279) chỉ dự liệu việc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề phát sinh từ sự tác động của con người trong hai trường hợp: *1 - Bất động sản phục vụ và bất động sản được phục vụ hoà nhập thành một; 2- Chủ sở hữu bất động sản được phục vụ không còn nhu cầu sử dụng hạn chế bất động sản liền kề.* Ta có thể mở rộng phạm vi điều chỉnh của điều luật đã dẫn đến tất cả các quyền và nghĩa vụ láng giềng phát sinh từ sự tác động của con người bằng nguyên tắc áp dụng tương tự pháp luật.

2.2.3.1. Trường hợp bất động sản phục vụ và bất động sản được phục vụ hoà nhập thành một

Như ta đã biết điều kiện cơ bản của sự hình thành quan hệ láng giềng về mặt pháp lý là có hai bất động sản độc lập thuộc về hai chủ sở hữu khác nhau. Một khi bất động sản phục vụ và bất động sản được phục vụ thuộc về một chủ sở hữu duy nhất, thì hệ thống phục vụ bị thu hút vào hệ thống quản lý nội bộ của một sản nghiệp và các quyền và nghĩa vụ láng giềng, không còn đối tượng sẽ không có căn cứ để được duy trì.

2.2.3.2. Trường hợp chủ sở hữu bất động sản được phục vụ từ chối quyền sử dụng hệ thống phục vụ

Người thụ hưởng hệ thống phục vụ bày tỏ ý chí một cách hữu hiệu và rõ ràng về việc không có nhu cầu sử dụng hệ thống đó nữa. Sự từ chối có thể được ghi nhận bằng miệng hoặc bằng văn bản và nói chung có thể được chứng minh bằng bất kỳ phương tiện nào được thừa nhận trong luật chung về chứng cứ.

2.2.3.3. Trường hợp chủ sở hữu bất động sản được phục vụ không còn sử dụng hệ thống phục vụ

Khi chủ sở hữu bất động sản được phục vụ thực hiện một việc nào đó nhằm loại bỏ công dụng của hệ thống phục vụ, ví dụ: dựng vách chắn ngang lối đi qua, lấp đất vào rãnh thoát nước,...hoặc trong trường hợp chủ sở hữu bất động sản được phục vụ dù không thực hiện hành vi nào có tác dụng loại bỏ công dụng đó nhưng không thực sự tiếp tục khai thác công dụng của hệ thống phục vụ, ví dụ: người có quyền về lối đi qua bất động sản liền kề mở một lối đi qua mới trên một bất động sản liền kề khác và sử dụng lối đi qua mới mà không quan tâm đến lối đi qua cũ nữa... thì quyền và nghĩa vụ láng giềng sẽ chấm dứt.

2.2.3.4. Trường hợp bất động sản phục vụ được Nhà nước mua lại và trở thành tài sản công –

Nếu bất động sản phục vụ được Nhà nước mua lại nhằm phục vụ cho lợi ích công cộng và lợi ích đó không dung hoà được với các lợi ích gắn liền với hệ thống phục vụ mà chủ sở hữu bất động sản lân cận đang thụ hưởng, thì hoàn toàn hợp lý khi hệ thống phục vụ đó phải bị huỷ bỏ.

2.2.4. Trách nhiệm dân sự do vi phạm quyền và nghĩa vụ láng giềng

Tại các Điều 276 và 278 BLDS, ta thấy có các quy định buộc chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc theo nghĩa kinh tế phải bồi thường cho chủ sở hữu bất động sản phục vụ, trong

trường hợp gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản phục vụ. Tại Điều 261 BLDS cũng chính thức thừa nhận việc bảo vệ quyền của người chiếm hữu quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề. Bằng phương pháp diễn dịch quy nạp, ta rút ra được từ các điều luật ấy một nguyên tắc chi phối việc thực hiện quyền sở hữu bất động sản trong quan hệ láng giềng: *trách nhiệm dân sự của người có quyền sở hữu có thể được quy kết, một khi việc thực hiện quyền sở hữu đó dẫn đến thiệt hại cho người láng giềng và những người lân cận*. Chắc chắn, những thiệt hại dẫn đến trách nhiệm của chủ sở hữu bất động sản phải là những thiệt hại không bình thường, không ở mức chấp nhận được đối với một chủ sở hữu bất động sản lân cận trong trường hợp điển hình. Thiệt hại có thể được gây ra do lỗi cố ý hoặc vô ý. Người có quyền và lợi ích bị xâm hại gánh chịu thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngăn chặn và buộc chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật của chủ sở hữu bất động sản liền kề, có quyền khởi kiện chủ sở hữu bất động sản liền kề để yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và bồi thường thiệt hại đã xảy ra theo thủ tục tố tụng có liên quan.

MỤC 6 - Quyền sở hữu bề mặt

Khái niệm - Quyền sở hữu bề mặt, trong khung cảnh của luật thực định Việt Nam, là quyền sở hữu của một người không có quyền sử dụng đất đối với các tài sản gắn liền với đất đó. Quyền sử dụng đất trong định nghĩa này được hiểu như một tài sản (nghĩa là có thể chuyển nhượng được); nó có thể thuộc về một người khác (ví dụ: người cho thuê quyền sử dụng đất ở, đất chuyên dùng) hoặc không tồn tại (như trong trường hợp người có quyền sở hữu đối với các tài sản gắn liền với đất chỉ là người được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm). Sự phát triển của chế định quyền sở hữu bề mặt trong luật hiện đại Việt Nam gắn liền với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai.

1. Xác lập quyền sở hữu bề mặt

Quyền sở hữu bề mặt có thể được xác lập theo pháp luật đất đai hoặc theo pháp luật dân sự.

1.1. Xác lập quyền sở hữu bề mặt theo pháp luật đất đai trong các trường hợp cụ thể như:

1.1.1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê hàng năm-

Về nguyên tắc người thuê chỉ có quyền sở hữu bề mặt.

-Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền sở hữu và định đoạt đối với các tài sản gắn liền với đất thuê (Điều 114 khoản 1 Luật đất đai 2003) nhưng lại không có quyền sử dụng đất có giá trị tài sản. Người được chuyển giao quyền sở hữu tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định. Có thể nói, quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm có tính chất tương tự như một quyền không có tính chất tài sản và gắn liền với nhân thân người có quyền. Nói cách khác, họ chỉ có quyền sở hữu bề mặt đối với các tài sản gắn liền với đất thuê.

- Tương tự, tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm về nguyên tắc chỉ có quyền sở hữu bề mặt đối với các tài sản gắn liền với đất thuê (Điều 111 khoản 1Luật đất đai 2003). Người mua tài sản gắn với đất được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định. Một cách ngoại lệ, tổ chức kinh tế được quyền cho thuê lại đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

-Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm chỉ có quyền sở hữu bề mặt đối với các tài sản gắn liền với đất thuê và có quyền định đoạt các tài sản ấy (Điều 119 khoản 2 Luật đất đai 2003). Trường hợp người mua tài sản gắn với đất là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc thu tiền thuê đất hàng năm theo đúng mục đích đã được xác định trong thời hạn còn lại

-Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm cũng chỉ có quyền sở hữu bề mặt đối với công trình do mình xây dựng trên đất thuê trong thời hạn thuê đất (Điều 118 Luật đất đai 2003).

1.1.2. Trường hợp thuê đất trả tiền nhiều năm của tổ chức ngoại giao nước ngoài

Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất trả tiền nhiều năm cũng chỉ có quyền sở hữu bề mặt đối với công trình do mình xây dựng trên đất thuê trong thời hạn thuê đất theo Điều 118 Luật đất đai 2003 đã nêu trên.

1.1.3. Trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

Quyền sử dụng đất của các tổ chức này không thể chuyển giao và không có giá trị tài sản. Nếu các tổ chức kinh tế này được Nhà nước giao đất để xây dựng không bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì được quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất. Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục giao đất không thu tiền sử dụng đất theo mục đích đã được xác định (Điều 109, Điều 110 khoản 3 Luật đất đai 2003). Như vậy, tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cũng chỉ có quyền sở hữu bề mặt đối với các công trình gắn liền với đất.

1.2. Xác lập quyền sở hữu bề mặt theo pháp luật dân sự trong một số trường hợp sau:

1.2.1. Tách quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất thành hai bất động sản độc lập

Có nhiều rất phổ biến trong thực tiễn giao dịch, chẳng hạn người có quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tặng quyền sử dụng đất cho một người và quyền sở hữu nhà cho một người khác; *hoặc* người có quyền sở hữu nhà nhiều tầng và quyền sử dụng đất tặng cho hoặc bán một hoặc nhiều tầng lầu cho người khác và giữ lại cho mình quyền sở hữu tầng trệt cùng với quyền sử dụng đất; *hoặc* người có quyền sử dụng đất tặng cho hoặc chuyển nhượng các cây lâu năm gắn liền với đất cho người khác và giữ lại quyền sử dụng đất; *hoặc* người có quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp quyền sở hữu nhà, sau đó, quyền sử dụng đất được bán cho người khác để thanh toán nghĩa vụ được bảo đảm; *hoặc* người sử dụng đất chuyển nhượng quyền sở hữu nhà (hay tài sản khác), nhưng không chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nhà (hay tài sản khác) đó; ... Trong những trường hợp này quyền sở hữu bề mặt được xác lập.

1.2.2. Cho thuê quyền sử dụng đất ở, đất chuyên dùng

Quyền sử dụng đất ở, đất chuyên dùng được cho thuê, vào thời điểm giao kết hợp đồng, là quyền sử dụng đối với đất chưa được xây dựng, nghĩa là chưa có tài sản gắn liền trên đất đó. Chính người thuê sẽ xây dựng trên đất có quyền sử dụng được cho thuê các công trình cần thiết cho việc khai thác công dụng của đất phục vụ lợi ích của mình. Nếu ta xem quyền sử dụng đất là vật chính, thì theo các quy tắc về sáp nhập tài sản, các công trình xây dựng trên đất thuộc quyền sở hữu của người cho thuê và người này có trách nhiệm thanh toán cho người thuê phần giá trị của các công trình đó (BLDS Điều 236 khoản 1). Giải pháp này không thể tranh cãi khi hợp đồng cho thuê hết hạn, bởi khi đó, người cho thuê tiếp tục là người sử dụng đất và do vậy, có quyền sở hữu đối với những tài sản được sáp nhập vào quyền sử dụng đất theo luật; người thuê không còn mối quan hệ pháp lý nào đối với đất đó.

Có thể phân tích hợp đồng thuê quyền sử dụng đất ở, đất chuyên dùng thành hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất để xây dựng. Khi đó, người sử dụng đất có quyền xây dựng trên đất đó, và do hiệu lực của hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất, họ chuyển nhượng có thời hạn (bằng với thời hạn thuê) quyền xây dựng trên đất cho người thuê. Như vậy, với tư cách là người tạo ra một cách hợp pháp tài sản được xây dựng, người thuê phải có quyền sở hữu đối với các tài sản đóï -quyền sở hữu có thời hạn chấm dứt cùng một lúc với hợp đồng cho thuê. Ta nói: hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ở, đất chuyên dùng có tác dụng làm phát sinh quyền sở hữu bề mặt của người thuê

1.3. Xác lập quyền sở hữu bề mặt bằng các phương thức được thừa nhận trong luật chung

Trong trường hợp này, quyền sở hữu bề mặt đã tồn tại và một người nào đó trở thành chủ thể của quyền sở hữu đó do được chủ sở hữu trước chuyển giao (bán, tặng cho,...) hoặc do các phương thức trực tiếp (xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu).

2. Chế độ pháp lý của quyền sở hữu bề mặt

2.1. Tài sản thuộc sở hữu bề mặt

Tài sản thuộc sở hữu bề mặt có thể là những vật hiện hữu (như nhà, công trình xây dựng khác, cây lâu năm), nhưng cũng có thể được phi vật chất hoá thành các quyền tài sản (quyền xây dựng, quyền trồng cây).

Nếu chỉ có đối tượng là các vật hiện hữu, thì khi vật không còn nữa (nhà bị đổ, cây chết,...), quyền sở hữu bề mặt sẽ chấm dứt. Trong trường hợp vật hiện hữu là cây, chắn chắn chủ sở hữu có quyền sở hữu đối với tất cả những kết quả phát triển tự nhiên của cây, kể cả đối với các cây con được cây mẹ sản sinh ra... ; tuy nhiên không được trồng thêm cây mới trên diện tích đất đó.

2.2. Quyền sở hữu theo luật chung

Người có quyền sở hữu bề mặt là chủ sở hữu theo nghĩa đầy đủ đối với các tài sản đối tượng của quyền sở hữu đó. Người này có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản, nghĩa là có quyền cư trú, cho thuê, thay đổi cấu trúc, phá dỡ tài sản, có quyền thế chấp tài sản, có quyền bán, trao đổi, tặng cho tài sản, để tài sản cho người thừa kế,...trừ trường hợp có thoả thuận khác với người có quyền sử dụng đất. Nếu đối tượng của quyền sở hữu bề mặt là quyền xây dựng, quyền trồng cây, thì chủ sở hữu còn có quyền mở rộng hoặc thu hẹp công trình, tăng hoặc giảm số lượng cây trồng, xây dựng công trình hay trồng các loại cây mới.

Cũng như quyền sở hữu theo luật chung, quyền sở hữu bề mặt có tính ổn định và lâu dài, trừ trường hợp các bên liên quan đạt được thoả thuận giới hạn sự tồn tại của quyền sở hữu bề mặt trong thời gian (như đối với quyền sở hữu bề mặt phát sinh từ hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ở, đất chuyên dùng).

2.3. Quyền sử dụng hạn chế đối với đất

Khi sở hữu các tài sản gắn liền với đất, người có quyền sở hữu bề mặt, muốn thực hiện quyền sở hữu của mình, nhất thiết phải xác lập được quyền sử dụng đối với đất có các tài sản đó. Khi đó, quan hệ giữa người có quyền sở hữu bề mặt và người sử dụng đất giống như quan hệ giữa hai chủ sở hữu bất động sản liền kề. Trong chừng mực nào đó, có thể tin rằng bất động sản đối tượng của quyền sở hữu bề mặt luôn là bất động sản bị vây bọc mà nếu như không có quyền sử dụng đất, người có quyền sở hữu bề mặt sẽ không bao giờ có thể tiếp xúc với đường công cộng, thiết bị công cộng mà không sử dụng đến đất đai thuộc quyền sử dụng của người khác.

2.4. Đăng ký quyền sở hữu

Nếu các tài sản gắn liền với đất thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu, thì quyền sở hữu bề mặt xác lập đối với các tài sản đó cũng phải được đăng ký. Trong trường hợp tài sản gắn liền với đất không thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu bề mặt cũng không được đăng ký. Thực ra, quyền sở hữu bề mặt không đăng ký và, nói chung, bất động sản không đăng ký quyền sở hữu, không phải là một chế định cần được hoàn thiện, mà chỉ là một hiện tượng phát sinh từ tình trạng chưa hoàn thiện của pháp luật về tài sản.

Tài liệu tham khảo

BONNECASE, *L'école de l'Exégèse en droit civil,* Paris, 1924.

CAPITANT và DE LA MORANDIÈRE, *Traité élémentaire de droit civil*, Dalloz, 1957, t.1.

CORNU, *Droit civil - Introduction. Les personnes. Les biens*, Montchrestien, 1990.

ĐINH VĂN QUẾ, Bình luận án, nxb TPHCM, 1998.

GÉNY, *Méthode d'interprétation et sources en droit positif,* LGDJ, 1932.

GHESTIN và GOUBEAUX, *Traité de droit civil - Introduction générale*, LGDJ, 1990.

GRIDEL, *La dissertation, le cas pratique et la consultation en droit privé*, Dalloz, 1996.

MAZEAUD và CHABAS, *Le□ons de droit civil,* Montchrestien, 1986, t1, q.1.

NHÀ PHÁP LUẬT VIỆT - PHÁP, *Bộ luật dân sự của nước Cộng Hòa Pháp,* nxb Chính trị quốc gia 19998.

NGUYỄN NGỌC ĐIỆN, *Một số suy nghĩ về thừa kế trong luật dân sự Việt Nam*, nxb Trẻ, TPHCM, 1999.

NGUYỄN NGỌC ĐIỆN, *Một số suy nghĩ về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong luật dân sự Việt Nam*, nxb Trẻ, TPHCM, 1999.

NGUYỄN NGỌC ĐIỆN, *Nghiên cứu về tài sản trong luật dân sự Việt nam,* nxb Trẻ, TPHCM, 2000.

NGUYỄN NGỌC ĐIỆN, *Bình luận khoa học Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Tập I - Gia đình,* nxb Trẻ, 2002.

NGUYỄN THẾ GIAI, *Luật hôn nhân và gia đình, trả lời 120 câu hỏi*, nxb Pháp lý, 1991.

NGUYỄN VĂN THÔNG, *Hỏi đáp về Luật hôn nhân và gia đình,* nxb Tổng hợp

Đồng Nai, 2001.

SOURIOUX và LERAT, *L'analyse de texte*, Dalloz, 1997.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI, *Giáo trình Luật dân sự Việt Nam*, nxb Công an nhân dân, 2000.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI, *Giáo trình Luật hình sự Việt Nam*, nxb

VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ BỘ TƯ PHÁP, *Bình luận khoa học Bộ luật dân sự (tập 1, 3)* -nxb Chính trị quốc gia 2001.

VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ BỘ TƯ PHÁP, *Bình luận khoa học Bộ luật dân sự Nhật Bản* -nxb Chính trị quốc gia 1995.